

스터디파이터 2차 보상법규 개별법 기본서

2026년 개정판

감정평가사
2차 합격을
위한
필수 기본서

제1판

01
PART

공용수용

제1장 공용수용

제1절	공용수용	1
제2절	공공적 사용수용 (사적 공용수용, 사용수용)	6

제2장 공익사업, 당사자, 목적물

제1절	수용적격사업으로서 공익사업	9
제2절	당사자	11
제3절	목적물	15

제3장 공익사업의 준비

제1절	의의와 법적 성격	24
제2절	타인 점유토지에의 출입	24
제3절	장해물의 제거 등	27
제4절	권리구제	28

제4장 사업인정 전 협의취득

제1절	토지조서·물건조서의 작성(제14조)	31
제2절	보상계획의 공고 및 열람(제15조)	32
제3절	보상액의 산정(제68조)	33
제4절	사업인정 전 협의	34

제5장 사업인정

제1절	사업인정	37
제2절	사업인정 의제제도	43
제3절	사업인정의 실효와 사업의 완료	44

제6장 사업인정 후 협의 및 협의성립확인

제1절	토지조서 및 물건조서의 작성(제14조)	47
제2절	사업인정 후 협의(제26조)	51
제3절	협의성립확인	57

제7장 재결

제1절	재결신청청구권	61
제2절	재결신청	65
제3절	수용재결	66
제4절	재결의 실효	70
제5절	화해	72

제8장 약식절차

75

제9장 공용수용의 효과

제1절	공용수용의 일반적 효과	79
제2절	보상금 지급 또는 공탁	81
제3절	수용목적물의 인도·이전 의무 및 그 의무이행 확보수단	86
제4절	위험부담의 이전	89
제5절	담보물권자의 물상대위	91
제6절	환매권	92

제10장 권리구제(재결의 불복)

제1절	개설	103
제2절	이의신청(토지보상법 제83조)	104
제3절	행정소송(토지보상법 제85조)	106

제11장 토지수용위원회와 보상협의회

제1절	토지수용위원회	115
제2절	보상협의회	117

02

PART

손실보상**제1장 손실보상 일반론**

제1절	손실보상 개요	117
제2절	헌법 제23조 제3항의 해석	119
제3절	손실보상의 요건	123
제4절	손실보상의 원칙	128
제5절	채권보상	131
제6절	대토보상	133

제2장 토지보상법상 손실보상 기준

제1절	정당보상	135
제2절	토지의 보상평가기준	137
제3절	공시지가기준 보상	139
제4절	그 밖의 요인 보정	143
제5절	개발이익배제	144

제3장 손실보상의 내용

제1절	재산권 보상	149
제2절	생활보상	150

제4장 손실보상액의 산정과 평가각론

제1절	공법상 제한받는 토지 평가	153
제2절	무허가건물 등의 부지와 불법형질변경된 토지의 평가	155
제3절	미지급용지의 평가	157
제4절	도로부지의 평가	159
제5절	잔여지에 대한 보상평가	162
제6절	건축물 등 물건에 대한 보상평가	166
제7절	영업손실보상	169
제8절	이주대책	173
제9절	간접손실보상	181
제10절	주거이전비	188
제11절	건축물의 잔여부분에 대한 보상평가	191
제12절	개간비의 보상과 평가	192
제13절	토지에 대한 소유권 외의 권리에 대한 보상	193
제14절	사용하는 토지에 대한 보상평가	194
제15절	농업손실보상	195

03

PART

기타 개별법

제1장 부동산 가격공시에 관한 법률

제1절	표준지공시지가	199
제2절	개별공시지가	207
제3절	토지가격비준표	217
제4절	부동산가격공시위원회	220
제5절	타인토지출입	221
제6절	주택가격공시제도	223

제2장 감정평가법

제1절	감정평가사의 법적지위	229
제2절	감정평가사의 자격등록 및 갱신등록	234
제3절	감정평가법인등	236
제4절	징계 및 징계위원회	239
제5절	감정평가	246
제6절	기타(과징금, 과태료, 한국감정평가협회)	249

제3장 도정법

제1절	정비사업의 기초	253
제2절	조합설립인가	254
제3절	사업시행계획인가	258
제4절	관리처분계획인가	260
제5절	매도청구 및 수용재결	263
제6절	분양신청 통지 및 이전고시 관련 판례	266

PART 01

공용수용

Chapter 01 공용수용

Chapter 02 공익사업, 당사자, 목적물

Chapter 03 공익사업의 준비

Chapter 04 사업인정 전 협의취득

Chapter 05 사업인정

Chapter 06 사업인정 후 협의 및 협의성립확인

Chapter 07 재결

Chapter 08 약식절차

Chapter 09 공용수용의 효과

Chapter 10 권리구제(재결의 불복)

Chapter 11 토지수용위원회와 보상협의회

제1절

공용수용

01 공용수용과 공용수용제도

공용수용(公用收用)이란 특정한 공익사업을 위해 사업주체가 국가권력으로 타인의 재산권을 강제적으로 취득하는 것을 말한다. 사인의 재산권은 사유재산제 아래서 존중되어야 하나, 사업의 원활한 실시를 확보하고, 공공이익의 증진을 도모하기 위해 사인의 토지소유권 등 권리를 강제적으로 취득하게 하는 법적 수단이 필요하다. 공용수용제도는 공익사업을 위해 권리자의 의사에 관계없이 토지소유권 등을 강제적으로 취득하는 길을 열어두기 위해 마련된 제도이다.

02 근거

1) 이론적 근거

- ① 〈사유재산불가침 원칙에 대한 특례〉 현대국가의 사유재산제도 아래에서 소유권은 절대권이라 하더라도 소유권 행사는 사회의 안녕질서를 위해 필연적으로 사회적 제약을 받게 된다.
- ② 〈공공복리를 위한 국가권력의 발동〉 현대복지국가는 단순한 경찰 목적의 임무 외에 공공복리 증진을 중요한 임무로 하고 있다.

2) 헌법적 근거

공용수용은 재산권에 대한 중대한 침해이므로 헌법에 근거를 두고 있다. 헌법은 “공공필요에 의한 재산권의 수용·사용 또는 제한 및 그에 대한 보상은 법률로써 하되, 정당한 보상을 지급하여야 한다(헌법 제23조 제3항).”고 규정함으로써, 재산권의 수용을 인정하고 있다.

3) 실정법적 근거

- ① 공용수용의 일반법은 헌법을 구체화한 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」(이하 명칭 사용에는 “토지보상법”으로 하고, 관련 법규정은 조항으로만 표기함)이다. 토지보상법은 공용수용의 목적물을 비롯하여 공익사업, 공용수용의 절차와 효과 등에 관한 일반규정, 손실보상의 기준과 보상액 산정에 관한 구체적 규정을 두고 있다.
- ② 많은 개별 법률은 공익사업의 시행을 위하여 토지보상법에서 정하는 토지·물건 또는 권리를 수용 또는 사용할 수 있다고 규정하고, 수용 또는 사용에 관하여는 개별 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 토지보상법을 준용하도록 하고 있다.
- ③ 개별 법률은 사업인정에 관한 특례, 재결신청기간에 관한 특례, 관할 토지수용위원회에 관한 특례, 환매에 관한 특례, 사적 공용수용에 관한 특례 등을 두고 있다.

03 특징

1) 목적의 특징

공용수용의 목적은 특정 공익사업을 원활하게 수행하여 **공익 증진을 도모**하는 데 있다. 수용에 의해 재산을 취득할 때 해당 재산은 직접 공공이익의 증진에 이바지하여야 한다.

2) 수단의 특징

공용수용의 법적 수단은 **강제적 취득**이다. 공익사업에 제공하기 위해 민사계약에 의해 임의로 재산권을 조달하는 경우 등은 공용수용과 구별된다.

3) 목적물의 특징

공용수용의 목적물은 **특정한 재산권**이다. 공용수용 대상 가운데 가장 일반적인 것은 토지소유권이며, 그 밖에 토지에 관한 소유권 이외의 권리, 토지와 함께 공익사업을 위하여 필요한 입목(立木), 건물, 그 밖에 토지에 정착된 물건 및 이에 관한 소유권 외의 권리, 광업권·어업권 또는 물의 사용에 관한 권리, 토지에 속한 흙·돌·모래 또는 자갈에 관한 권리가 있다(제3조).

4) 효과의 특징

공용수용의 효과는 재산권을 취득·소멸시키는 물건변동이다. 일반적으로 공용수용에 의한 토지 등의 취득은 국가 권력에 의한 권리의 **원시취득**이다. 원시취득으로 해석하는 실질적 논거는 수용이 공익사업을 시행하는 자에게 완전히 토지 기타 물건을 취득시켜 아무런 장애 없이 사업을 실시할 수 있도록 하는 것을 목적으로 하고 있음에서 찾을 수 있다. 임의매수가 승계취득이라는 점에서 공용수용과 구별된다.

5) 손실보상의 전제

공용수용은 손실보상을 전제한다. 수용으로 인해 권리를 상실하는 자에 대하여 부담의 공평을 위해 **정당한 보상**이 지불되어야 한다(헌법 제23조 제3항).

04 요건

1) 공용수용의 당사자

공용수용의 당사자는 공용수용 법률관계의 당사자로서, 수용권 주체인 **수용권자**와 수용목적물에 대한 권리를 가진 **피수용자**이다.

2) 공용수용의 내용상 요건

헌법 제23조 제3항에 따라 공용수용의 요건을 살펴볼 수 있다. 즉 공공필요가 있을 것, 재산권에 대한 공권적 침해 일 것, 재산권 침해의 법적 근거가 있을 것, 특별한 희생이 발생할 것, 보상규정이 존재할 것이 그 요건이 된다.

3) 공용수용의 절차상 요건

공용수용에 따른 토지의 취득 및 보상에 관한 일반법적 지위에 있는 토지보상법은 사업인정 전 협의(제16조), 사업인정(제20조), 토지조서 및 물건조서의 작성(제14조), 협의(제26조), 수용재결(제34조)로 이어지는 일련의 공용수용의 절차를 규정하고 있다.

05 공용수용의 유형

- ① 본래수용이란 공익사업을 위해 목적물을 직접 수용하는 일반수용을 말한다.
- ② 확장수용은 공익사업의 필요에 의한 것이라기보다 **피수용자에 대한 권리구제의 보충적 필요**에 의해 인정되는 제도라는 점에서 본래수용과 차이가 있다.
- ③ 확장수용에는 완전수용(제72조), 잔여지 등의 매수 및 수용청구(제74조), 이전수용(제75조 제1항)이 있다.

06 공용수용과 공공필요

1) 공공필요의 의미

공공필요란 **대표적 불확정개념**으로, 확실적인 개념정립이 불가능하나, 공익을 위해 공익사업을 실현시키거나, 국가안전보장·질서유지 등의 **공익 목적을 달성하기 위해 재산권의 수용·사용·제한이 불가피한 경우**를 말한다. 공익과 사익의 개념은 고정적인 것으로 볼 것은 아니며, 공익은 역사적으로 **가변적인 것**이므로 그 내용도 시대에 따라 달라지는 것으로 볼 수 있다.

심화

공공필요

헌법 제23조 제3항에서 규정하고 있는 ‘공공필요’는 “국민의 재산권을 그 의사에 반하여 강제적으로라도 취득해야 할 공익적 필요성”으로서, ‘공공필요’의 개념은 ‘공익성’과 ‘필요성’이라는 요소로 구성되어 있는바, ‘공익성’의 정도를 판단함에 있어서는 공용수용을 허용하고 있는 개별법의 입법목적, 사업내용, 사업이 입법목적에 이바지 하는 정도는 물론, 특히 그 사업이 대중을 상대로 하는 영업인 경우에는 그 사업 시설에 대한 대중의 이용·접근가능성도 아울러 고려하여야 한다. 그리고 ‘필요성’이 인정되기 위해서는 **공용수용을 통하여 달성하려는 공익과 그로 인하여 재산권을 침해당하는 사인의 이익 사이의 형량에서 사인의 재산권침해를 정당화할 정도의 공익의 우월성이 인정되어야 하며**, 사업시행자가 사인인 경우에는 그 사업 시행으로 획득할 수 있는 공익이 현저히 해태되지 않도록 보장하는 제도적 규율도 갖추어져 있어야 한다(헌법재판소 2014. 10. 30. 선고 2011헌바129,172).

2) 수용과 공공필요의 관계

(1) 헌법 제23조 제3항의 공공필요

헌법 제23조 제3항은 “공공필요에 의한 재산권의 수용·사용 또는 제한 및 그에 대한 보상은 법률로써 하되, 정당한 보상을 지급하여야 한다.”라고 규정한다. 재산권에 대한 공권적 침해는 공공필요가 있을 때만 행해질 수 있으므로, 공공필요는 공용침해의 **실질적 허용요건**이자 **본질적 제약요소**이다.

(2) 토지보상법 제4조 및 별표, 제4조의2 수용적격사업

토지보상법은 공공필요가 있는 사업을 수용적격사업으로 규정하고 있다(제4조 및 별표, 제4조의2). 사업의 공공성을 확보하기 위해 사업인정 발령 시 실질적 공공필요가 있는지 판단한다. 개별법률은 공공필요를 확보하기 위해 수용적격사업과 사업인정 의제에 관하여 규정하고 있는 것이 일반적이다.

(3) 공공필요의 판단기준

공공필요는 공용침해를 통하여 얻어지는 공익과 재산권자의 재산권 보유이익 간에 이익형량을 통해서 그 여부가 결정되고, 재산권 침해가 정당화할 만한 공익의 존재가 비교형량의 결과로 입증되어야 하며 그 입증책임은 사업시행자에게 있다(대법 2005. 11. 10. 선고 2003두7507). 공공필요는 재산권에 대한 공권적 침해의 구체적 사안에 따라 결정될 성질의 것이며, 공공필요는 사업인정 시에 비례의 원칙을 적용하여 판단한다.

(4) 수용에 있어 공공필요의 확대 경향

최근 민간의 이윤, 동기까지 포함하는 시설의 설치 등을 목적으로 하는 사업에 대하여도 점차 공공필요를 인정하기에 이르고 있어 '공공의 이익'이란 개념은 확대현상을 보이고 있다. 토지보상법은 제4조 제5호에서 국가, 지방자치단체, 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관, 「지방공기업법」에 따른 지방공기업 또는 국가나 지방자치단체가 지정한 자가 임대나 양도의 목적으로 시행하는 주택 건설 또는 택지 및 산업단지 조성에 관한 사업을 규정하고 있다.

07 최근 공용수용제도의 동향

1) 공익사업의 확대와 공익성 검증 강화

토지보상법 제4조와 제4조 제8호 해당 사업인 별표 규정을 살펴보면, 다른 법률에 따라 토지 등을 수용 또는 사용할 수 있는 수많은 사업이 포함된다. 이는 개별법률 역시 다양한 사업에 대하여 수용권을 부여하는 경향을 보이고 있는 것으로서, 공공필요를 널리 인정하여 공익사업의 범위를 확대하는 현상을 반영하고 있는 것이다.

아울러, 토지보상법은 입법단계 시 공익성에 관한 중앙토지수용위원회의 심의제도를 도입하고(제4조의3), 사업인정 시 중앙토지수용위원회의 협의 절차를 강화하는 등 공익성 검증을 강화하였다.

2) 공적 사용수용의 확대

공공적 사용수용이란 공공필요를 위해, 사적 주체가 손실보상을 전제로, 사인의 특정한 재산권을 강제적으로 취득하는 것을 말한다. 공공목적의 토지취득은 종래 공적 주체에게 한정되는 것으로 이해되어 왔으나, 공공적 사용수용은 공익상 필요, 공익사업의 증대, 민간 활력의 도입, 공행정의 민간화 등에 의해 그 필요성이 인정되고 있으며, 최근 민자유치사업 등에서 확대 현상을 보이고 있다. 토지보상법은 사업주체를 구분하지 않고 공익사업을 시행하는 자에게 수용권을 부여하여 공공적 사용수용을 인정하고 있다. 한편 개별법률은 택지개발촉진법, 도시개발법, 기업도시개발특별법 등에서 공공적 사용수용을 인정하고 있다.

3) 보상금에서 개발이익의 배제

공용수용은 재산권의 본질적 내용의 침해에 해당되기 때문에 당연히 정당보상이 수반되어야 한다. 그렇지만 정당보상이 결코 해당 공익사업으로 인한 지가상승분인 개발이익까지 포함된 것으로 볼 수는 없다. 개발이익은 불로소득으로 사회에 환수되어야 하므로 공용수용에 따른 보상에서 개발이익을 배제하는 제도적 장치가 일반화되고 있다.

4) 정당보상과 생활보상의 확대

(1) 정당보상의 확대

손실보상은 공용침해로 인해 특정한 재산권자가 입은 특별한 희생을 전보하는 제도로서, 공익과 사익을 조정하고 피해자를 구제하기 위한 제도이다. 헌법 제23조 제3항은 정당한 보상을 하여야 함을 규정하고, 그에 따른 토지보상법은 **부대적 손실보상**과 **생활보상** 등의 규정을 두고 있다.

(2) 생활보상의 확대

손실보상은 종래 대물보상을 중심으로 인정되어 왔으나, 오늘날 대물보상의 문제를 해결하고 피수용자 보호를 위해 생활보상이 확대되고 있다. 보상목적은 수용이 없었던 것과 같은 재산 상태를 만드는 것만으로는 불충분하고, **수용이 없었던 것과 마찬가지로의 생활상태를 회복**시키는 데 있다. 이주대책과 간접손실보상은 생활보상을 대표하는 제도로서 널리 활용되고 있다. 최근 피수용자의 생활회복을 위해 생활보상이 확대되고, 그 유형도 다양화되어 가는 현상을 보이고 있다.

CASE

1. 사기업인 A회사의 비료공장건설사업에 대한 사업인정의 적법 여부 및 위법하다고 인정되는 경우의 권익구제방법을 논술하시오.(10점) [10회 1번]
2. 사적(私的) 공용수용의 의의 및 요건에 대하여 설명하시오.(20점) [19회 3번]

01 제도의 배경

공공목적의 토지취득은 공적 주체에게 한정되는 것으로 이해되어 왔으나, 날로 공익사업이 증대함에 따라 공적 주체만으로는 이를 감당할 수 없게 되었다. 도시화의 진전과 산업의 발전에 따라 사회기반시설의 설치를 비롯하여 택지 등의 개발에 **민간 활력의 도입**이 절실히 요구되고 있다. 이러한 문제를 해결하기 위해서는 사적 주체에게도 공적 주체와 마찬가지로 수용권이 적극적으로 부여할 필요가 있다. 토지보상법은 이 한계를 극복하기 위해 사적 주체에게도 수용권을 인정하고 있다.

02 의의·취지 및 요건

공공적 사용수용(사적 공용수용, 사용수용)이란 **특정한 공익사업을 위하여 사적 주체가 타인의 특정 재산권을 법률의 힘에 의해 보상을 조건으로 강제적으로 취득하는 것이다**. 민간활력의 도입, 사업의 확대 등에 취지가 있다. 공공적 사용수용은 다음과 같은 개념 요소를 내용으로 한다.

- ① 공공적 사용수용은 공익사업의 목적에만 인정된다.
- ② 사적 주체로서 국가권력에 의해 수용권을 부여받는다.
- ③ 대상은 특정한 재산권이다.
- ④ 법률에 근거하여 타인의 재산권을 강제적으로 취득한다. 강제적 취득이란 권리자의 의사에 상관없이 일방적으로 재산권을 취득하는 것을 말한다.
- ⑤ 공공적 사용수용은 공용수용과 마찬가지로 재산권자에게 특별한 희생을 발생시키므로, 정당한 보상을 지급하여야 한다.

03 인정여부

독일에서는 일반 사기업도 공익을 위해 수용이 허용된다고 보는 것이 일반적이다. 독일법상의 사기업의 유형으로는 생존배려형 사기업과 경제적 사기업이 있다. 생존배려형 사기업은 공공재화 등의 공익사업을 수행하는 경우의 국민의 생존을 배려하는 급부행정작용을 수행하는 사기업이고, 경제적 사기업은 공공성보다는 이윤추구를 우선적 목적으로 하는 사기업이다. 생존배려형 사기업의 공익사업은 국가적 과제이므로 사기업에게 수용권한을 부여하는 것은 당연하다. 그러나 경제적 사기업에 대해서는 엄격한 요건 아래에서 허용해야 한다는 주장이 있으나, 오늘날 경제적 사기업은 경제구조 개선·고용 증진·지역 발전 등이라는 공익이 합리적으로 요구될 때 공익사업을 수행하므로, 경제적 사기업의 재산권 침해는 공익적 요청에 의한 것이라면 정당화될 수 있다고 봄이 일반적 입장이다. **《대법원》**은 어떤 사업이 공익사업인가의 여부는 그 사업자체의 성질에 의하여 정할 것이고, 사업주체의 여하에 의하여 정할 것이 아니라고 판시한 바 있다[대법 70누81]. **《헌법재판소》**도 관광진흥법 위헌소원사건에서 재산권의 수용의 주체를 한정하지 않고 있는바 합헌 판결을 하였다[헌재 2011헌바250].

04 사용수용과 공공필요

1) 대상사업과 공공필요

수용권이 부여되려면 공공필요를 근거로 사업인정을 받아야 한다. 일반적으로는 기업의 법형식이나 사업시행자의 동기가 문제되지 않고, 객관적으로 공익사업을 시행하여 공익이 실현될 수 있는지 여부에 따라 공공필요는 인정된다. 토지보상법 제4조 및 별표, 제4조의2는 공익사업을 규정하고 있으며, 개별법률은 사업인정 의제조항을 두고 있다. **헌법재판소**는 민간기업에게 산업단지에 필요한 토지 등을 수용할 수 있도록 한 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 조항이 위헌이 아니라고 하였고, 토지 등 소유자가 도시환경정비사업을 시행할 수 있는 토지수용 규정인 「도시 및 주거환경정비법」 규정도 피수용자의 재산권을 과도하게 침해하지 않는다고 하였다.

2) 공공필요의 판단기준인 비례의 원칙

공공적 사용수용의 공익사업이 모두 공공성을 바탕으로 한다고 보기 어려운 경우도 있다. 어떠한 공익사업이 공공필요가 있는지 여부는 판단하기 쉽지 않기 때문에, **비례의 원칙에 의하여 엄격한 이익형량이 필요하다**.

05 계속적 공익실현의 보장책

1) 보장책 마련의 필요성

공공적 사용수용의 사적 주체는 이윤추구의 목적도 함께 가지고 있으므로 언제든지 사업을 중도에 포기할 가능성이 있어 보장책이 필요하다.

2) 보장의 수단

(1) 토지보상법상 환매권 및 사업인정의 실효

- ① **환매권(제91조)**은 토지보상법상 공익사업의 계속성을 담보하기 위한 가장 일반적인 수단이다. 그러나 환매권은 행정주체의 개입 없이 환매권자에 의해서만 행사된다는 점에서 공익성 계속적 보장책으로서 미흡하다는 지적이 있다.
- ② **사업인정의 실효(제23조), 사업의 폐지 및 변경(제24조)제도**는 수용법관계의 조속한 확정을 바라는 피수용자를 보호하고 간접적으로 공익사업의 계속을 보장한다.

(2) 입법적 통제 및 사법적 통제

- ① **입법적 통제**
「사회기반시설에 대한 민간투자법」에서는 사업시행자에 대한 감독명령과 처분, 위반시 벌칙 등을 규정하고 있다. 그러나 민간자본유치 촉진에 역점을 둔 까닭에 공익사업의 계속성 담보에 대한 배려가 미흡하다. 구체적 보장책 수단으로 입법론이 요구된다.
- ② **사법적 통제**
공익사업의 계속성 보장책이 헌법 제23조 제3항의 공공필요의 요건을 충족하지 못할 경우에는 위헌·위법한 재산권의 침해라 할 것이어서 행정쟁송의 제기, 위헌법률심판, 헌법소원 등의 방법으로 사법적 통제가 가능하다.

3) 문제점

개별법에는 공익의 계속적 실현을 위한 여러 보장수단이 규정되어 있으나 추상적이고 제한적이어서 실효성 확보수단으로는 미흡하므로 법규명령, 자치법규 등 개괄적인 규정의 마련이 검토되어야 할 것이다.

제1절 수용적격사업으로서 공익사업

01 의미

수용적격사업이란 수용주체가 수용할 수 있는 적격을 갖는 공익사업을 말한다. 입법자는 해당 사업이 객관적으로 보아 충분히 공공필요를 지녔다고 판단될 때 수용적격을 승인하여 이에 관한 입법을 하고, 사업인정의 처분청은 이를 근거로 해당 공익사업이 과연 수용적격사업에 해당하는가를 다시 판단하여 사업인정을 하게 된다.

02 토지보상법 제4조, 별표, 제4조의2의 설정방법

입법시 수용적격방법을 정하는 방법에는 개별입법주의, 제한열거주의, 포괄주의로 구분할 수 있다.

- ① <개별입법주의>는 개개 사업이 토지를 수용할 만한 공공성을 지니는가를 입법자가 개별적으로 심사하여 입법하는 것이다.
- ② <제한열거주의>는 법률상 수용대상사업의 범위를 한정하고, 그 범위 내에서 사업의 수용적격성 유무를 행정청에게 판단하게 하는 것이다.
- ③ <포괄주의>는 수용 대상사업의 범위를 법률로 한정하지 않고 포괄적으로 행정청에게 맡겨 구체적 사업에 대해 수용여부를 판단하게 하는 것이다.
- ④ <검토> 토지보상법은 공익사업의 종류를 규정하고(제4조 및 별표), 토지 등을 사용하거나 수용할 수 있는 사업은 제4조 또는 별표에 규정된 법률에 따르지 않고는 정할 수 없으며, 별표는 이 법 외의 다른 법률로 개정할 수 없다고 하여(제4조의2) 제한열거주의를 채택하고 있다.

03 내용

토지보상법에 따라 토지 등을 취득하거나 사용할 수 있는 사업은 다음 어느 하나에 해당하는 사업이어야 한다(제4조 및 별표). 공익사업이란 토지보상법 제4조 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업을 말한다(제2조 제2호).

- ① 국방·군사에 관한 사업
- ② 관계 법률에 따라 허가·인가·승인·지정 등을 받아 공익을 목적으로 시행하는 철도·도로·공항·항만·주차장·공영차고지·화물터미널·궤도(軌道)·하천·제방·댐·운하·수도·하수도·하수종말처리·폐수처리·사방(砂防)·방풍(防風)·방화(防火)·방조(防潮)·방수(防水)·저수지·용수로·배수로·석유비축·송유·폐기물처리·전기·전기통신·방송·가스 및 기상 관측에 관한 사업
- ③ 국가나 지방자치단체가 설치하는 청사·공장·연구소·시험소·보건시설·문화시설·공원·수목원·광장·운동장·시장·묘지·화장장·도축장 또는 그 밖의 공공용 시설에 관한 사업

- ④ 관계 법률에 따라 허가·인가·승인·지정 등을 받아 공익을 목적으로 시행하는 학교·도서관·박물관 및 미술관 건립에 관한 사업
- ⑤ 국가, 지방자치단체, 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관, 「지방공기업법」에 따른 지방공기업 또는 국가나 지방자치단체가 지정한 자가 임대나 양도의 목적으로 시행하는 주택 건설 또는 택지 및 산업단지 조성에 관한 사업
- ⑥ 제1호부터 제5호까지의 사업을 시행하기 위하여 필요한 도로, 교량, 전선로, 재료 적치장 또는 그 밖의 부속시설에 관한 사업
- ⑦ 제1호부터 제5호까지의 사업을 시행하기 위하여 필요한 주택, 공장 등의 이주단지 조성에 관한 사업
- ⑧ 그 밖에 별표에 규정된 법률에 따라 토지 등을 수용하거나 사용할 수 있는 사업

04 공익사업 신설 등에 대한 개선요구 등

1) 토지보상법 제4조의2

수용(또는 사용)할 수 있는 사업은 제4조 또는 별표에 규정된 법률에 따르지 않고는 정할 수 없고(제1항), 별표는 토지보상법 외의 다른 법률로 개정할 수 없다(제2항). 국토교통부장관은 사업인정이 의제되는 공익사업의 공공성, 수용의 필요성 등을 5년마다 재검토하여 폐지, 변경 또는 유지 등을 위한 조치를 하여야 한다(제3항).

2) 토지보상법 제4조의3

중앙토지수용위원회는 사업인정이 의제되는 공익사업의 신설, 변경 및 폐지 등에 관하여 개선요구 등을 할 수 있고, 중앙토지수용위원회의 개선요구 등을 받은 관계 행정기관은 정당한 사유가 없으면 이를 반영하여야 한다. 또한, 중앙토지수용위원회는 개선요구 등을 위하여 관계 기관 소속 직원 또는 관계 전문가 등에게 의견진술이나 자료제출을 요구할 수 있다. 이는 공익사업의 공공성을 높이는 데 그 취지가 있고, 위 개정은 중앙토지수용위원회의 권한이 확대되고 적극적인 지위를 명시한 것으로 평가할 수 있다.

01 의미

토지수용의 당사자는 수용권의 주체인 수용자와 수용목적물인 재산권의 주체인 피수용자가 된다.

02 사업시행자와 수용권의 주체

1) 사업시행자의 의미

사업시행자란 **공익사업을 수행하는 자**를 말한다(제2조 제3호). 사업시행자는 국가·지방자치단체·법인 또는 사인에 관계없이 특정한 공익사업의 시행자를 말한다. 여기에서 공익사업이란 토지보상법 제4조 각 호 규정에 따른 사업을 말한다. 따라서 사업시행자는 수용적격사업에 관한 법률상 권한을 갖는 자이다.

2) 국가 이외의 자가 수용권자인 경우 수용권의 주체 논의

(1) 문제점

국가가 사업시행자인 경우는 논란이 없으나, 국가 이외의 공공단체나 사인(공무수탁사인)이 사업시행자인 경우 수용권의 주체가 누구인지 견해가 대립한다.

(2) 학설

- ① <국가수용권설> 수용권이란 **수용의 효과를 야기할 수 있는 능력**이므로 수용권자는 국가라고 한다.
사업시행자는 수용권의 발동을 국가에게 청구하는 권리를 갖는데 지나지 않는다고 한다.
- ② <사업시행자수용권설> 수용의 본질이 특정한 재산권을 취득하는 데 있으므로, 수용권이란 **수용의 효과를 누리는 능력**이라고 한다. 따라서 수용권자는 사업시행자라고 한다. 이 설이 우리나라 다수설이다.

(3) 판례

대법원은 사업인정을 일정한 절차를 거칠 것을 조건으로 수용권을 설정해 주는 설권적 형성처분이라 판시하여 **사업시행자수용권설**의 입장이다.

(4) 검토

국가공권력의 개입이 수용의 효과를 야기한다 하더라도, 현행 공용수용제도는 공공단체는 물론 기업이나 사인에게도 수용권을 부여하고 있고, 수용권은 **수용의 효과를 누릴 수 있는 능력**이라 볼 수 있으므로, 사업시행자수용권설을 취하는 것이 타당하다.

03 사업시행자의 법적 지위

1) 권리

사업시행자의 권리에는

- ① 사업준비를 위한 타인 토지에의 출입권(제9조),
- ② 장애물 제거권(제12조),
- ③ 사업인정 신청권(제20조),
- ④ 토지 및 물건에 관한 조사권(제27조),
- ⑤ 재결신청권(제28조),
- ⑥ 협의성립확인 신청권(제29조),
- ⑦ 토지나 물건을 원시취득할 권리(제45조),
- ⑧ 토지나 물건의 인도 또는 이전이 없는 경우 대항신청권(제44조),
- ⑨ 재결에 불복하는 경우 행정쟁송권(제83조 및 제85조),
- ⑩ 의무 불이행 등에 대한 대집행신청권(제89조) 등이 있다.

2) 의무

사업시행자의 의무에는

- ① 타인 토지에의 출입 등에 의한 측량·조사, 장애물 제거 등으로 인한 손실보상 의무(제9조 제4항, 제12조 제4항),
- ② 협의 불성립시 피수용자의 재결신청청구에 응할 의무(제30조 제2항),
- ③ 피수용자의 고의·과실 없이 수용목적물의 멸실·훼손으로 인한 손실부담의 이전(제46조),
- ④ 재결로 인한 토지 등 취득시 손실보상 의무(제61조) 등이 있다.

3) 권리·의무의 승계

권리·의무의 승계는 사업의 승계와 절차의 승계로 구분된다. **사업승계**란 사업이 이전되면 사업시행자의 권리·의무는 그 사업을 승계한 자에게 이전되는 것을 말한다(제5조 제1항). **절차승계**란 이 법에 따라 이행한 절차와 그 밖의 행위는 사업시행자·토지소유자 및 관계인의 승계인에게도 효력이 미치게 되는 것을 말한다(제5조 제2항). 사업승계는 사업시행자에 대한 것인 반면, 절차승계는 사업시행자·토지소유자 및 관계인에 대한 것이다. 승계에 대하여는 사업인정 처분청의 승인을 요하지 아니한다. 승계를 인정하는 것은 수용절차의 중복을 피하고, 사업집행의 촉진을 도모함과 동시에 피수용자를 보호하기 위해서이다.

04 피수용자

1) 의의

피수용자란 수용의 목적물인 재산권의 주체 및 수용에 의해 영향을 받는 기타 관계 권리자를 말한다. 토지보상법상 수용권의 객체가 되는 토지소유자와 관계인이 피수용자가 된다(토지보상법 제2조 제4호 및 동조 제5호).

2) 토지소유자와 관계인

(1) 토지소유자

토지소유자란 공익사업에 필요한 토지의 소유자를 말한다(제2조 제4호). 진실한 소유자를 확정할 수 없는 경우 토지보상법은 사업시행자의 과실 없이 보상금을 받을 자를 알 수 없을 때 보상금을 공탁할 수 있도록 함으로써 사업시행자의 토지취득을 원활하게 하도록 하고 있다. (제40조 제2항 제2호).

(2) 관계인

관계인이란

- ① 사업시행자가 취득하거나 사용할 토지에 관하여 지상권·지역권·전세권·저당권·사용대차 또는 임대차에 따른 권리 또는 그 밖에 토지에 관한 소유권 외의 권리를 가진 자나
- ② 그 토지에 있는 물건에 관하여 소유권이나 그 밖의 권리를 가진 자를 말한다.

다만, 사업인정의 고시(제22조)가 된 후에 권리를 취득한 자는 기존의 권리를 승계한 자를 제외하고는 관계인에 포함되지 아니한다(제2조 제5호).

관계인에 관한 규정에서 열거하고 있는 권리는 하나의 예시에 불과하고, 토지소유권 외의 권리자 모두를 포함하는 것으로 해석된다. 또한, 관계인으로서의 지위가 인정되려면 사업인정고시를 할 때 이들 권리가 존재하고 있어야 한다. 이는 수용의 절차를 간소화하기 위해서이다. 관계인은 부동산물권의 경우를 제외하고는 반드시 등기된 권리자임을 요하지 아니하는 것으로 보고 있다.

3) 피수용자의 법적 지위

피수용자의 법적 지위란 토지소유자 및 관계인으로서의 권리·의무 관계를 말한다.

(1) 권리

피수용자의 권리에는

- ① 사업인정시 의견을 제시할 수 있는 권리(제21조),
- ② 재결신청에 따른 열람시 의견을 제시할 수 있는 권리(제31조 제2항),
- ③ 협의 불성립시 재결신청청구권(제30조 제1항),
- ④ 사용하는 토지의 매수청구권(제72조),
- ⑤ 잔여지 등의 매수 및 수용청구권(제74조 제1항),
- ⑥ 비용보상에 대한 협의 불성립시 재결신청권(제80조 제2항),
- ⑦ 환매권(제91조),
- ⑧ 재결에 불복시 행정쟁송권(제83조 제1항, 제85조 제1항) 등이 있다.

(2) 의무

피수용자의 의무에는

- ① 사업시행자의 토지출입에 따른 행위의 인용의무(제11조, 제27조 제1항),
- ② 토지 등의 보전의무(제25조 제1항), ③ 토지 또는 물건의 인도와 이전의무(제43조 제1항) 등이 있다.

(3) 권리·의무의 승계

피수용자에게는 단지 절차승계만이 인정될 수 있을 따름이다. 사업인정고시가 있을 후 새로운 권리를 취득한 자는 기존 권리를 승계하기 때문이다.

01 의미

공익사업의 목적물이란 공익사업을 위해 독립하여 취득의 대상으로 다루어질 수 있는 토지, 물건 등에 관한 소유권 및 기타 권리이다. 공익사업의 목적물은 사업을 위해 필요한 범위, 정도에 따라 취득하는 것이 원칙이다. 따라서 목적물은 사업의 원활한 시행의 필요성과 공익사업에 제공되는 토지 등 재산권자의 권리 보호의 관점에서 제한적으로만 적용되어야 하며, 목적물은 수용의 경우 사업인정의 절차에 의해 구체적으로 특정된다.

02 종류

1) 토지보상법 제3조 적용대상

토지보상법은 사업시행자가 다음에 해당하는 토지·물건 및 권리를 취득하거나 사용하는 경우에는 이 법을 적용한다고 규정한다(제3조).

- ① 토지 및 이에 관한 소유권 외의 권리,
- ② 토지와 함께 공익사업을 위하여 필요한 입목(立木), 건물, 그 밖에 토지에 정착된 물건 및 이에 관한 소유권 외의 권리,
- ③ 광업권·어업권·양식업권 또는 물의 사용에 관한 권리,
- ④ 토지에 속한 흙·돌·모래 또는 자갈에 관한 권리

2) 토지소유권과 토지소유권 외의 권리

(1) 토지소유권

공익사업을 위한 수용의 목적물 가운데 가장 중요한 것은 토지이다. 토지는 단순히 지표만을 의미하지 않고, 일정 면적의 지면에 정당한 이익이 미치는 범위 내에서 그 수직의 상하, 즉 공중과 지하를 포함하고 있다(민법 제212조).

(2) 토지에 관한 소유권 외의 권리

토지에 관한 소유권 외의 권리란 물권인 지상권·지역권·전세권·저당권·채권인 임차권 및 기타 공법상의 사용권 등을 말한다.

3) 토지에 정착한 물건 및 이에 관한 소유권 외의 권리

(1) 토지에 정착한 물건의 소유권

토지에 정착한 물건이란 건물이나 교량 또는 수목 등과 같이 토지에 고정적으로 부착되어 용이하게 이동할 수 없는 물건으로서 토지와는 독립한 것을 말한다. 토지보상법은 건축물·입목·공작물과 그 밖에 토지에 정착한 물건(“건축물 등”이라 함, 제75조)에 대해서는 이전에 필요한 비용(“이전비”라 함)으로 보상하고 이전하게 하는 것을 원칙으로 하고 있다.

(2) 토지에 정착한 물건의 소유권 외의 권리

토지에 정착한 물건의 소유권 외의 권리란 소유권 외의 물권, 채권 기타 공법상의 권리 등을 말한다. 이와 같은 권리를 취득의 대상으로 하는 것은 타인이 소유권 외의 권리를 지니고 있어 사업의 시행을 방해하는 것을 방지하고자 함이다.

4) 광업권·어업권·양식업권 및 물의 사용에 관한 권리

- ① 「광업법」은 미채굴의 광물을 토지소유권과 분리하여 독립적인 소유권의 대상으로 하고 있다. 광업권이란 탐사권과 채굴권을 말한다(광업법 제2조 제3호). 따라서 토지수용만으로는 광업권을 소멸시킬 수 없으므로 별도로 광업권을 소멸수용의 대상으로 하고 있다.
- ② 어업권이란 면허를 받아 어업을 경영할 수 있는 권리를 말한다(수산업법 제2조 제8호). 어업권은 광업권과 마찬가지로 독립적인 권리이므로 별도로 소멸수용의 대상으로 하고 있다.
- ③ 양식이란 수산동식물을 인공적인 방법으로 길러서 거두어들이는 행위와 이를 목적으로 어선·어구를 사용하거나 양식시설물을 설치·운영하는 행위를 말하고(양식산업발전법 제2조제1호), 양식업이란 「양식산업발전법」 제2조제2호에 따라 수산동식물을 양식하는 사업을 말한다(수산업법 제2조제2의2호). 양식업권이란 양식산업발전법 제10조에 따라 면허를 받아 양식업을 경영할 수 있는 권리를 말하며, 동법의 제정에 따라 재산권의 일종으로 명시되었다.
- ④ 유수·해수의 사용권 등도 그 자체로서 권리의 소멸수용의 목적물이 될 수 있다. 공익사업의 목적물이 되는 물의 사용에 관한 권리는 독립하는 권리로서 존재하기 때문이다.

5) 토지에 속한 흙·돌·모래 또는 자갈에 관한 권리

흙·돌·모래 또는 자갈은 토지의 구성부분이기 때문에 토지가 취득될 때 당연히 취득된다. 그러나 공익사업에 토지는 필요 없으나, 그에 속한 흙·돌·모래 또는 자갈만이 필요한 경우 토지와는 독립하여 목적물로 할 수 있다. 대법원은 흙·돌·모래 또는 자갈이 당해 토지와 별도로 취득 등의 대상이 되기 위해서는, 수용대상 토지에 관하여 토지의 형질변경 또는 채석·채취를 적법하게 할 수 있는 행정적 조치가 있거나 그것이 가능하고 구체적으로 토지의 가격에 영향을 미치고 있음이 객관적으로 인정되어 토지와는 별도의 경제적 가치가 있다고 평가되는 경우여야 한다고 보았다(대법원 2014. 4. 24. 선고 2012두16534 판결).

03 목적물의 제한

1) 수용제도 본질상 제한

수용의 목적물이 되려면 해당 목적물이 비대체적인 목적물이어야 할 뿐만 아니라, 그 목적물을 해당 사업에 이용하는 것이 객관적으로 보아 가장 합리적이고 타당하다고 인정되는 경우라야 한다. 또한 수용은 비록 공익사업을 위해 불가결하다 하더라도 수용할 목적물의 범위는 원칙적으로 사업을 위하여 **필요한 최소한도**에 그쳐야 한다(대판 2005. 11. 10. 2003두7507).

2) 토지세목에 따른 제한

사업인정고시는 수용 또는 사용할 토지세목을 내용으로 하므로, 이에 포함된 토지 등에 한하여 수용이 가능하게 된다. 따라서 토지세목에 **기재되지 아니한 토지** 등은 **수용의 목적물이 될 수 없다**. 그러나 잔여지를 수용하는 경우 잔여지는 사업인정 및 사업인정고시가 있는 것으로 보므로(제73조 제3항, 제74조 제3항), 그 예외가 인정된다.

3) 목적물의 성질에 따른 제한

(1) 사업시행자 소유의 토지

자기 소유의 토지를 수용한다는 것은 관념상 모순되므로, 사업시행자는 스스로 자기 소유의 토지를 수용하지 못하는 것으로 해석된다.

(2) 공익사업에 이용되고 있는 토지

① 수용권의 충돌

공익사업에 수용되거나 사용되고 있는 토지 등은 특별히 필요한 경우가 아니면 다른 공익사업을 위하여 수용하거나 사용할 수 없다(제19조 제2항). 이는 수용권 충돌 문제를 해결하기 위한 제도이며, 수용적격사업 간에 경합함으로써 충돌하는 공익의 조정을 목적으로 한다. 현재 공익사업에 제공되는 토지라 하더라도 현재의 사업보다 한층 공익성이 큰 사업에 해당 토지를 제공할 필요가 있고, 그렇게 하는 것이 토지의 적정하고 합리적인 이용에 기여하는 경우에는 예외적으로 해당 토지를 수용의 목적물로 하는 길을 열어두는 것이 바람직하다.

② 판단기준

새로운 사업을 위해 '특별한 필요'가 인정된다면 수용의 목적물이 될 수 있는 것으로 해석된다. 이 경우 특별한 필요는 현재 토지를 이용하고 있는 공익사업과 새로 수용하고자 하는 공익사업의 토지이용의 공공성 정도나 효율성 정도를 구체적으로 비교衡量하여 판단한다.

(3) 외국대사관 등의 부지·건물

외국의 대사관·공사관 등으로 사용하는 부지·건물은 치외법권이 존재하여 국가의 공권력이 미치지 못하므로 수용의 목적물이 되지 못한다(외교관계에 관한 비엔나조약 제22조 제3항).

(4) 국·공유재산

국·공유재산 중 일반재산은 그 성질상 당연히 수용의 목적물이 될 수 있으나, 행정재산이 수용의 목적물이 될 수 있는가에 대하여는 한마디로 말하기 어렵다. 이에 대해서 일반적으로 공물을 중심으로 논의되고 있으며, 공물이 공적 목적에 제공되고 있는 한 공용수용의 대상이 되지 않는 것으로 보고 있다. 그러나 토지보상법의 “공익사업에 수용되거나 사용되고 있는 토지 등은 특별히 필요한 경우가 아니면 다른 공익사업을 위해 수용하거나 사용할 수 없다(제19조 제2항).”는 규정의 해석에 대하여 견해가 나누어지고 있다.

(5) 공물의 수용가능성 논의

CASE

물음 3) 한편, 丙이 소유하고 있는 토지(이하 '이 사건 C토지'라 한다)는 문화재보호법 상 보호구역으로 지정된 토지로서 이 사건 시설 조성사업의 시행을 위한 사업구역 내에 위치하고 있다. 甲은 공물인 이 사건 C토지를 이 사건 시설 조성사업의 시행을 위하여 수용할 수 있는가?(15점) [31회, 1번]

① 문제점

토지보상법 제19조 제2항은 “공익사업에 수용되거나 사용되고 있는 토지 등은 특별히 필요한 경우가 아니면 다른 공익사업을 위하여 수용하거나 사용할 수 없다”고 규정하고 있어 공물의 수용시 별도의 공용폐지가 요구되는가와 관련하여 특별한 필요의 해석이 문제된다.

② 학설

① 공용폐지 불요설

토지보상법 제19조 제2항은 현재의 용도보다 한층 공익상 중요한 용도를 위한 특별한 필요가 있는 때에 **공용폐지 없이** 예외적으로 수용을 허용하는 것으로 본다.

② 공용폐지 필요설

공물의 수용은 공물의 목적에 반하므로 원칙적으로 허용되지 않지만, 더 큰 공익을 위해 수용이 필요한 경우 **공용폐지를 선행해야** 한다고 한다.

③ 판례의 태도

대법원은 (구)문화재보호법에 의하여 지방문화재로 지정된 토지가 **수용대상이 된다고** 하여 공적 보존물이 수용의 대상이 될 수 있다고 판시하였고(대판 1996. 4. 26. 95누13241 판결), 헌법재판소는 토지보상법 제19조 제2항에 대하여 공익 또는 수용권의 충돌문제를 해결하기 위한 것으로, 특별한 필요가 있는 경우에는 현재 공익사업에 이용되고 있는 토지도 예외적으로 수용의 목적물이 될 수 있다고 판시하였다(헌재 2000헌바32).

따라서 판례는 대체로 **공물의 수용도 가능하다는 입장**으로 보인다.

다만, 대법원은 (구)국유림법상 요존국유림은 (구)국유림법에서 정하는 절차와 방법에 따라서만 관리·사용할 수 있을 뿐이고, 불요존국유림으로 **재구분되지 않는 이상** 관리청이 임의로 처분하지 못하는 것이기 때문에, 토지보상법상 협의 또는 재결의 대상이 될 수 없다고 판시하여 **용도폐지가 선행되어야** 한다고 본다. (대판 2018. 11. 29. 2018두51904 판결).

④ 검토

생각건대, 공물은 현재 공익목적에 제공되고 있지만, **특별한 필요가 있다면** 다른 공익사업에 수용될 수 있다고 본다. 특별한 필요는 **비례의 원칙**에 따라 종래의 공익과 새로운 공익을 비교형량하여 판단해야 한다. 다만 이 경우에도 국유재산법 등 관련 법률의 규정에 따라 공물의 **용도폐지가 선행되어야** 한다고 본다.

04 목적물의 확장

1) 확장수용의 의의 및 취지, 종류

확장수용은 특정한 공익사업을 위하여 **목적물의 필요한 범위를 넘어서 수용**하는 것이다. 확장수용은 원칙상 인정되지 않는다. 그러나 예외적으로 수용권자와 피수용자간 이해관계를 합리적으로 조정하고, 피수용자에 대한 권리구제에 이바지하며, 사업의 원활한 실시를 위해 법률규정이 있는 경우 인정된다. 토지보상법상 규정된 확장수용에는 완전수용(제72조), 잔여지수용(제74조), 이전수용(제75조)이 있다.

2) 확장수용의 법적성질

(1) 문제점

확장수용이 일반적으로 피수용자의 청구에 의해 이뤄진다는 점에서 그 성질에 대하여 견해가 나뉜다. 적용법규 및 쟁송형태의 차이에 논의의 실익이 있다.

(2) 학설

① 사법상 매매설

사업시행자의 재산권 취득은 피수용자와의 합의를 바탕으로 하므로 사법상 매매의 성질을 띤다고 한다.

② 공법상 특별행위설

확장수용이 해당 공익사업의 시행상 필요 최소한도를 넘긴 하나, 피수용자의 청구에 의해 이뤄진다는 점에서 공법상 특별행위라고 한다.

③ 공용수용설

확장수용은 피수용자의 청구를 요건으로 하는 사업시행자의 일방적 권리취득 행위로서, 그 본질은 일반적 수용과 다른 것이 없다고 한다. 이 견해가 **다수설**이다.

(3) 판례의 태도

대법원은 잔여지 수용청구권이 그 요건을 갖춘 때에는 토지수용위원회의 특별한 조치를 기다릴 것 없이 청구에 의하여 **수용의 효과가 발생**하므로, 이는 **형성권적 성질**을 가진다고 판시하여 공용수용설 입장이라고 할 수 있다.

대법원 2015. 4. 9. 선고 2014두46669 [토지수용재결신청거부처분취소]

토지보상법 제72조의 문언, 연혁 및 취지 등에 비추어 보면, 위 규정이 정한 수용청구권은 토지보상법 제74조 제1항이 정한 잔여지 수용청구권과 같이 손실보상의 일환으로 토지소유자에게 부여되는 권리로서 그 청구에 의하여 수용 효과가 생기는 형성권의 성질을 지니므로, 토지소유자의 토지수용청구를 받아들이지 아니한 토지수용위원회의 재결에 대하여 토지소유자가 불복하여 제기하는 소송은 토지보상법 제85조 제2항에 규정되어 있는 '보상금의 증감에 관한 소송'에 해당하고, 피고는 토지수용위원회가 아니라 사업시행자로 하여야 한다.

심화

72조 수용청구권, 74조 잔여지수용청구권의 법적성질 : 형성권

소송방법 : 보상금증액청구소송 ○, 수용재결취소소송 ×

수용재결취소송 제기하면 부적법 각하판결

(4) 검토

확장수용은 피수용자에 대한 권리구제의 보충적 필요에 의의가 있으므로, 본래의 수용개념과는 구별된다. 그러나 확장수용은 피수용자의 청구를 요건으로 한 사업시행자의 권리취득 행위로서 **공용수용의 효과**가 발생하므로, **공용수용설이 타당하다**.

3) 완전수용

(1) 의의

완전수용이란 토지사용으로 인해 토지소유자가 받게 되는 현저한 장해에 갈음하여 수용보상을 가능하게 해주는 제도이다. 완전수용은 **'사용에 갈음하는 수용'**이라고도 한다(제72조).

(2) 요건

사업인정고시 후

- ① 토지사용기간이 **3년 이상인 경우**,
- ② 토지사용으로 인하여 **토지형질이 변경되는 경우**,
- ③ 사용하려는 토지에 그 토지소유자의 **건축물이 있는 경우**

해당 토지소유자는 사업시행자에게 **토지매수를 청구**하거나 관할 토지수용위원회에 **토지수용을 청구**할 수 있다. 여기에서 '토지사용'이란 토지보상법이 정하는 절차에 따라 적법하게 사용하는 것을 말한다.

(3) 완전수용청구권 및 관계인의 권리 존속 청구

완전수용청구권은 토지소유자만 갖는다. 이 경우 관계인은 사업시행자나 관할 토지수용위원회에 대하여 **그 권리의 존속을 청구**할 수 있다(제72조 제2문). 그 청구가 이유 있는 것으로 받아들여지면 수용재결이 있더라도 그 권리는 소멸하지 않고 존속한다.

4) 잔여지수용

(1) 의의

잔여지수용이란 동일한 토지소유자에게 속하는 수용 목적물인 일단의 토지 일부가 매수되거나 수용됨으로 인하여 **잔여지를 종래 목적에 사용하는 것이 현저히 곤란한 때** 토지소유자의 청구에 의해 사업시행자가 해당 토지의 전부를 매수하거나 수용하는 것을 말한다.

(2) 매수·수용의 절차

- ① 동일한 소유자에게 속하는 일단의 토지의 일부가 협의에 의하여 매수되거나 수용됨으로 인하여 잔여지를 종래의 목적에 사용하는 것이 현저히 곤란할 때에는 해당 토지소유자는 사업시행자에게 잔여지를 **매수하여 줄 것을 청구**할 수 있으며, **사업인정 이후에는** 관할 토지수용위원회에 **수용을 청구**할 수 있다.
- ② 이 경우 수용의 청구는 매수에 관한 협의가 성립되지 아니한 경우에만 할 수 있으며, **사업완료일까지** 하여야 한다(제74조 제1항).
- ③ 사업인정 이전에는 매수청구를 하고, 이후에는 수용청구가 가능하다. 잔여지에 대한 수용청구는 매수협의를 필수적 절차로 하고 있는 점에 특징이 있다.

(3) 매수·수용의 효과

① 관계인의 권리존속 청구

매수 또는 수용청구가 있는 잔여지 및 잔여지에 있는 물건에 관하여 권리를 가진 자는 사업시행자나 관할 토지수용위원회에 **그 권리의 존속을 청구할 수 있다**(제74조 제2항). 청구가 이유 있는 것으로 받아들여지면 수용재결이 있더라도 그 권리는 소멸하지 않고 존속한다. 이는 관계인의 권리보호를 위함이다.

② 사업인정 및 사업인정고시의 의제

잔여지의 매수·수용청구 규정에 따라 토지를 취득하는 경우는 그 잔여지에 대하여 사업인정(제20조) 및 사업인정고시(제22조)가 된 것으로 본다(제74조 제3항).

5) 이전수용

(1) 의의

토지상의 **지장물은 이전에 필요한 비용(이하 “이전비”라 함)을 보상하고 이전하는 것이 원칙**이다. 이전수용이란 물건 등의 이전을 강행하는 것이 소유자나 사업시행자에게 과중한 손실을 가져올 우려가 있는 예외적인 경우 수용할 수 있도록 하는 제도이다.

여기에서 지장물이란 공익사업시행지구 내의 토지에 정착한 건축물·공작물·시설·입목·죽목 및 농작물 그 밖의 물건 중에서 당해 공익사업 수행을 위하여 직접 필요하지 아니한 물건을 말한다(칙 제2조 제3호).

(2) 이전비보상의 원칙과 예외

① 원칙

건축물 등은 이전비로 보상하여야 한다(제75조 제1항 본문). 이전비란 대상물건의 유용성을 동일하게 유지 하면서 이를 당해 공익사업시행지구 밖의 지역으로 이전·이설 또는 이식하는 데 소요되는 비용(물건의 해체비, 건축허가에 일반적으로 소요되는 경비를 포함한 건축비와 적정거리까지의 운반비를 포함하며, 「건축법」등 관계 법령에 의하여 요구되는 시설의 개선에 필요한 비용을 제외)을 말한다(칙 제2조 제4호).

② 예외

a. 물건가격 보상

- ① 건축물 등을 **이전하기 어렵거나**, 그 이전으로 인하여 건축물 등을 종래의 목적으로 사용할 수 없게 된 경우,
- ② 건축물 등의 **이전비가 그 물건의 가격을 넘는 경우**,
- ③ 사업시행자가 공익사업에 **직접 사용할 목적으로 취득하는 경우**의 어느 하나에 해당하는 경우는 해당 물건의 가격으로 보상하여야 한다(제75조 제1항 단서).

b. “이전 곤란”의 의미

‘이전이 어렵다는 것’은 이전에 관한 **물리적인 곤란뿐만 아니라** 이전을 위하여 부당하게 많은 비용을 요하는 등 **사회적·경제적 곤란도 포함**되는 것으로 해석된다.

(3) 절차 및 효과

사업시행자는 사업예정지에 있는 건축물 등이 물건가격으로 보상해야 할 경우에 해당(제75조 제1항 제1호 또는 제2호)하는 경우 관할 토지수용위원회에 **그 물건의 수용재결을 신청할 수 있다**. 이는 사업시행자에게 수용청구권을 인정하여 사업시행자의 경제적 부담을 적게 함으로써 공익사업을 원활하게 시행하게 함을 목적으로 한다.

6) 확장수용재결에 대한 불복

(1) 문제점

확장수용은 공용수용의 성질을 갖고, 확장수용청구권의 법적성질은 공권으로서, 토지보상법 체계상 확장수용은 토지수용위원회의 재결에 의하여 이루어진다. 따라서 확장수용 거부 시 이에 대한 불복은 토지보상법 제83조 및 제85조의 규정에 따르면 된다. 이 때 항고소송을 제기하지 않고 보상금증감청구소송을 제기할 수 있는지, 민사소송의 제기는 가능한지 문제된다.

(2) 이의신청

토지보상법 제34조에 따른 재결에 이의가 있는 자는 토지보상법 제83조에 따라 재결서正本 송달일로부터 30일 이내에 이의신청을 할 수 있다. 토지보상법은 이의신청을 임의적 절차로 규정하여 행정심판법의 행정심판 임의주의의 입법취지와 균형을 맞추어 신속한 권리구제를 도모하고 있다. 토지보상법상 특례를 따르고 토지보상법에서 정하지 아니한 사항은 행정심판법을 따른다(행정심판법 제4조 제2항).

(3) 확장수용 거부(수용재결 중 기각재결)에 대한 보상금증감청구소송 가능성

① 문제점

분쟁의 일회적 해결을 위하여 보상금증감청구소송 하나로 잔여지의 목적물까지 심리 범위에 포함하여 심리할 수 있는지 논란이 있다.

② 학설

① 부정설

확장수용에 대한 다툼은 보상금액의 문제가 아니라 보상의 범위에 관련된 문제이므로, 취소소송이나 무효확인소송을 제기해야 한다고 한다. 보상금증감청구소송은 보상금액을 다투는 소송이라 한다.

② 긍정설

보상금액과 보상범위는 밀접한 관련이 있고, 확장수용의 실질을 형평의 원칙에 입각한 피수용자의 불이익 구제의 손실보상으로 보는 한 보상금증감청구소송에서 심리할 수 있다고 한다.

③ 판례

잔여지 수용청구권은 손실보상의 일환으로 토지소유자에게 부여되는 권리로서 그 요건을 구비한 때에는 잔여지를 수용하는 토지수용위원회의 재결이 없더라도 수용의 효과가 발생하는 형성권적 성질을 가지므로, 잔여지 수용청구를 받아들이지 않은 토지수용위원회의 재결에 대하여 토지소유자가 불복하여 제기하는 소송은 토지보상법 제85조 제2항에 규정되어 있는 “보상금의 증감에 관한 소송”에 해당하여 사업시행자를 피고로 하여야 한다고 판시하였다(대판 2010. 8. 19. 2008두822).

④ 검토

보상금증감청구소송의 제도 취지가 분쟁의 일회적 해결로서 피수용자의 권리구제를 위한 것이므로, 보상금증감청구소송에서 목적물 범위까지 심리하여 다룰 수 있도록 함이 타당하다.

(4) 민사소송의 가능성

잔여지 수용청구에 대한 불복방법으로 민사소송이 제기가능한가와 관련하여 잔여지수용청구권을 공권으로 볼 때 민사소송의 제기는 불가능하다. <대법원>도 수용재결 및 이의재결에 불복이 있으면 재결청과 기업자를 공동피고로 하여 그 이의재결의 취소 및 보상금의 증액을 구하는 행정소송을 제기하여야 하며 곧바로 기업자를 상대로 하여 민사소송으로 잔여지에 대한 보상금의 지급을 구할 수 없다고 하여 이를 부정하였다.

공익사업 절차 및 관련 규정

구분	절차(토지보상법 조문)	
공익사업 준비절차	타인토지출입(9), 방해물 제거(12) 등	토지보상법 9조~13조
	토지 및 물건조서 작성(14)	
	보상계획공고 및 열람(15)	
사업인정 전 협의절차	협의(16) 계약체결(17)	- 협의는 수용재결 전 반드시 거쳐야 함 - 사업인정 전 협의(임의), 후 협의(필수) - 협의 손실보상금을 위한 감정평가 진행
강제수용 취득절차	사업인정(20), 협의 및 의견청취 등(21)	- 주체 : 국토부장관 - 절차 : 중앙행정기관 장, 시도지사, 중토위(공공성판단)와 협의 이해관계자 의견청취 - 비고: 22조 사업인정은 고시한 날부터 그 효력이 발생/ 25조 사업인정고시가 된 후 누구든지 토지보전의무 발생
	사업인정후 협의(26): 사업인정 전 절차(14~16) 준용	26조 필수조항
	수용재결(34)	- 주체 : 관할 토지수용위원회 - 절차 : 사업시행자의 재결신청(28) (피수용자의 재결신청청구(30) 가능) - 화해(33), 협의성립확인(29) 가능 - 소유권 원시취득(45)과 가격시점(67①) - 수용재결 손실보상금을 위한 감정평가 진행
	이의재결(84)	- 주체 : 중앙토지수용위원회 - 절차 : 수용재결에 이의있는 자의 이의신청(83) 〈특별법상 행정심판〉 - 이의재결 손실보상금을 위한 감정평가 진행
	행정소송(85)	- 취소소송(1항), 무효등확인소송(판례) - 보증소(2항), 보증소 손실보상금을 위한 감정평가 진행

의의와 법적 성격

01 의의

공익사업 준비반 공익사업을 위해 조사·측량 및 장애물의 제거 등을 하는 일련의 준비행위이다. 사업시행자가 사업계획을 작성하고, 수용 또는 사용하려는 토지의 구역을 확정하기 위하여 사업지역에 출입하여 조사·측량 또는 장애물 제거 등의 행위를 할 필요가 있다.

02 법적 성격

공익사업의 준비에 대하여는 공용제한으로 이해하는 견해와 공용사용으로 이해하는 견해가 있다. 생각건대 **공익사업의 준비는 일시적 사용을 전제하므로, 공용사용으로 봄이 타당하다.** 공익사업 준비과정은 수용이나 사용에 비하여 재산권에 대한 침해 정도가 경미하고 일시적이므로, 토지수용절차를 거치지 않고 단지 허가에 의하도록 하는 특징을 지닌다.

제2절

타인토지출입

심화

		9조 사업인정 전 타토출	27조 사업인정 후 타토출
차 이 점	목적	공익사업 준비 & 조서작성	분쟁예방(조서작성, 감정평가), 심리와 재결의 신속
	절차	사업인정 전 (허가 필요)	사업인정 후 (허가 불요)
	출입근거	특시군구장 허가	사업인정 효과
	내용	장해물 제거 및 시굴권 등 동의 얻어 가능	준용규정 없어 장해물 제거 및 시굴권 등 불가능
	권리구제	허가를 대상으로 쟁송 가능 (사업인정에 대한 쟁송불가)	사업인정을 대상으로 쟁송 가능
공 통 점	법적근거	① 토지보상법 근거 ② 10③, 13조 준용(절차상 공통점), 11조(수인의무)	
	법적성격	① 사용제한 중 일시적 사용 ② 행정조사	
	손실보상	§9⑤~⑦준용	
관련문제		직접적인 실행행사 불가	

구분		토지보상법(9)상 타토출	부동산공시법(13)상 타토출
공통점		특허 & 타인토지출입행위의 법적성질(권력적 사실행위·행정조사) & 출입제한 및 증표 휴대	
차 이 점	목적	공익사업 준비 & 조서작성	표준지 가격 조사·평가 & 개별공시지가 산정
	수인의무	수인의무 규정 있음 & 벌칙규정 있음	수인의무 규정 없음 & 벌칙규정 없음
	장해물 제거 및 출입의 통지기간	장해물 제거 규정 있음 & 5일전	장해물 제거 규정 없음 & 3일전
	손실보상	손실보상 규정 있음	손실보상 규정 없음

01 출입의 허가과 통지

1) 의의 및 근거

사업시행자는 공익사업을 준비하기 위하여 타인이 점유하는 토지에 출입하여 측량하거나 조사할 수 있다(제9조 제1항). 사업시행자가 측량·조사를 하려면 사업의 종류와 출입할 토지의 구역 및 기간을 정하여 특별자치도지사, 시장·군수 또는 구청장의 **허가**를 받아야 한다.

2) 출입허가의 법적성질 및 권리구제

출입의 허가는 공용사용권의 설정으로서 성질을 갖는 행정처분이다. 출입허가를 강학상 허가, 강학상 특허 또는 예외적 승인이라고 보는 견해가 대립하나, **타인의 토지에 출입할 수 있는 권리를 부여한다는 점에서 강학상 특허**로 보아야 할 것이다. 사업인정 이전의 경우는 공공성을 판단하기 이전이므로, 허가의 성질을 고려할 때 공익 관련성이 크다는 점에서 **재량행위**로 봄이 타당하다. 허가는 행정쟁송법상 처분인 바, 행정쟁송으로 다툴 수 있다.

02 출입 측량·조사 행위

1) 의의 및 취지, 근거

타인토지에 출입하여 측량·조사하는 행위는 그 지역이 해당 공익사업에 적합한 지역인지 판단하는 **행정조사행위**이다(제9조).

2) 법적 성질

출입 측량·조사 행위 자체는 비권력적 사실행위이나, 토지보상법상 토지점유자의 인용의무(제11조)가 부과되므로, 사실행위와 수인하명이 결합된 합성행위로서 **권력적 사실행위**에 해당하고, **처분성이 인정**된다.

3) 요건 및 절차

사업시행자는 타인토지에 출입, 측량·조사하려면 특별자치도지사, 시장·군수 또는 구청장의 허가를 받아야 한다(제9조 제2항). 다만, 사업시행자가 국가일 때에는 그 사업을 시행할 관계 중앙행정기관의 장이 특별자치도지사 등에게 **통지**하여야 한다. 특별자치도지사 등은 위 허가 또는 통지를 받은 때 사업시행자, 사업의 종류와 출입할 토지의 구역 및 기간을 **공고**하고 이를 토지점유자에게 **통지**하여야 한다(제9조 제3항).

타인 토지에 출입하려는 사업시행자는 **출입하려는 날의 5일 전까지** 그 일시 및 장소를 특별자치도지사 등에게 **통지**하여야 하고(제10조 제1항), 통지를 받은 특별자치도지사 등은 통지를 받은 때 또는 직접 출입하려는 경우에는 지체 없이 이를 **공고**하고 그 토지점유자에게 **통지**하여야 한다(제10조 제2항). 사업시행자는 해가 뜨기 전이나 해가 진 후에는 토지점유자의 승낙 없이 그 주거(住居)나 경계표·담 등으로 둘러싸인 토지에 출입할 수 없다(제10조 제3항). 출입하려는 사람은 그 신분을 표시하는 증표와 허가증을 지녀야 하고(제13조 제1항), 증표 및 허가증은 토지 또는 장애물의 소유자 및 점유자 그 밖의 이해관계인에게 이를 보여 주어야 한다(제13조 제3항).

4) 효과

사업시행자가 타인토지출입의 공용사용권을 취득하면 토지점유자의 인용의무(제11조) 발생, 손실보상청구권(제9조 제4항), 장애물 제거·시굴허가 신청권(제12조 제1항), 사용기간 만료시 반환 및 원상회복의무(제48조), 행정쟁송권 등이 발생한다. 실효성 확보수단으로서, 제9조 제2항을 위반하여 허가를 받지 않고 타인 점유 토지에 출입하거나 출입하게 한 사업시행자는 200만 원 이하의 벌금에 처한다(제97조 제1호). 제11조의 인용의무를 위반하여 사업시행자 또는 감정평가법인등의 행위를 방해한 토지점유자는 200만 원 이하의 벌금에 처한다(제97조 제2호).

5) 실력 행사의 가부

(1) 문제점

타인토지출입 측량조사와 같은 권력적 행정조사 중, 상대방이 조사를 거부하는 경우 벌칙규정은 존재하지만, 실력행사에 관한 명문 규정이 없는 경우 직접 실력행사를 통해 필요한 출입 측량·조사를 할 수 있는지 문제된다.

(2) 학설

① 긍정설

제재규정을 둔 것은 피조사자의 수인의무 위반을 위법으로 보아 비례의 원칙 안에서 실력을 가할 수 있는 규정으로 볼 수 있다고 한다.

② 부정설

토지보상법상 벌칙 규정만을 둔 취지는 조사의 실효성을 간접적으로 확보하려는 것으로서 실력행사는 허용되지 않는다고 한다.

(3) 검토

국민의 신체나 재산에 대한 실력행사는 명문의 근거가 있어야 하므로 부정설이 타당하다.

6) 위법한 측량·조사와 그에 따른 사업인정의 효력

(1) 문제점

측량·조사의 내용에 흠이 있어 그 정보에 기초하여 내려진 사업인정은 내용상 위법하다.

그러나 내용상으로는 정확하나 측량·조사가 절차를 위반한 경우, 즉 상기와 같은 실력행사를 하여 측량·조사를 마쳤다가거나 하는 등과 같은 절차 위반 시, 그 측량·조사에 의해 수립된 정보에 기초하여 내려진 사업인정이 위법한 것으로 되는지 문제된다.

(2) 학설

① 적극설

절차의 적법성 보장 원칙에 비추어 행정조사가 위법한 경우 당해 조사를 기초로 한 행정행위는 위법하다.

② 소극설

행정조사는 법령에서 특히 행정행위의 전제조건으로 규정되어 있는 경우를 제외하고는 일응 별개의 제도로 볼 수 있어 조사의 위법이 바로 행정행위를 위법하게 하지는 않는다.

③ 절충설

행정조사와 행정처분은 하나의 과정을 구성하므로 적정절차 관점에서

행정조사에 중대한 위법사유가 있으면 그에 기초한 행정행위도 위법한 것으로 볼 수 있다.

(3) 판례

판례는 위법한 세무조사에 기초한 부가가치세 부과처분은 위법하다고 하여 적극설을 취하고 있다.

다만, 행정조사 절차하자가 경미한 경우에는 위법사유가 되지 않는 것으로 본다.

(4) 검토

사업인정에 필요한 정보를 수집하기 위해 행해진 측량·조사에 절차상 하자가 있는 경우 당해 행정행위의 절차하자가 있는 것으로 볼 수 있다. 따라서 이 경우 사업인정의 효력은 절차 하자의 문제가 될 것이다.

01 장해물 제거 등을 위한 허가

1) 의의 및 근거

측량·조사시 장해물 제거 등을 해야 할 부득이한 사유가 있는 경우 소유자 및 점유자의 **동의**를 얻어야 하고, 동의를 얻지 못한 때에는 **허가**를 받아 장해물 제거를 할 수 있다(제12조 제1항).

2) 법적성질 및 권리구제

장해물 제거 등을 위한 허가는 공용사용권의 설정으로서 성질을 갖는 행정처분이다. 허가에 대하여 강학상 허가, 강학상 특허, 예외적 승인 등의 견해가 대립하나, **장해물 등을 제거할 수 있는 권리를 부여하는 강학상 특허**로 봄이 타당하다. 사업인정 이전의 경우는 공공성을 판단하기 이전이므로, 허가의 성질을 고려할 때 공익 관련성이 크다는 점에서 **재량행위**로 봄이 타당하다. 허가는 행정쟁송법상 처분인 바, 행정쟁송으로 다룰 수 있다.

02 장해물 제거 등 행위

1) 의의 및 취지, 근거

장해물 제거란 측량·조사시 부득이하게 장해물을 제거하고 토지의 시굴·시추를 해야 하는 경우를 말한다(제12조 제1항). 허가를 받는 것은 사업시행자의 측량·조사 등을 원활하게 하고, 토지소유자 또는 점유자의 권리가 부당하게 침해되지 않도록 하기 위함이다.

2) 법적 성질

장해물 제거행위 자체는 비권력적 사실행위이다. 토지보상법은 타인토지 출입시 토지점유자의 인용의무를 규정하나, 장해물 제거행위에는 인용의무를 규정하지 않고 있다. 장해물 제거행위는 측량·조사의 원활함을 위한 것이므로, 정당하게 허가받고 제거하는 행위에 대하여는 명문 규정이 없다 하더라도, 타인토지 출입 시 인용의무를 준용함이 타당하다. 따라서 사실행위와 수인하명이 결합된 합성행위로서, **권력적 사실행위**에 해당하고, 이는 **처분성이 인정**된다.

3) 요건 및 절차

사업시행자는 소유자 및 점유자의 **동의**를 얻어야 하고, 동의를 받지 못할 경우에는 사업시행자는 **허가**를 받아 장해물 제거 등을 할 수 있다(제12조 제1항). 특별자치도지사 등이 허가를 하거나 장해물 제거 등을 하려면 **미리** 그 소유자 및 점유자의 **의견**을 들어야 한다(제12조 제2항). 장해물 제거 등을 하려는 자는 장해물 제거 등을 하려는 날의 **3일 전까지** 그 소유자 및 점유자에게 **통지**하여야 한다(제12조 제3항). 장해물 제거 등을 하려는 자는 그 신분을 표시하는 증표와 허가증을 지녀야 하고(제13조 제1항), 이를 장해물의 소유자 및 점유자, 그 밖의 이해관계인에게 보여주어야 한다(제13조 제3항).

4) 효과

장해물 제거권(제12조 제1항), 토지점유자의 인용의무(제11조 준용), 손실보상청구권(제12조 제4항), 사용기간 만료시 반환 및 원상회복의무(제48조), 행정쟁송권이 발생한다. 실효성 확보수단으로서, 제12조 제1항을 위반하여 장해물 제거 등을 한 자는 1년 이하의 징역 또는 1천만 원 이하의 벌금에 처한다(제95조의2 제1호).

01 사업시행자의 권리구제

1) 허가신청 거부에 대한 권리구제

허가는 행정쟁송법상 처분으로서 특별자치도지사 등의 공권력의 행사이고, 허가 거부로 인하여 사업시행자의 측량·조사 또는 장애물 제거의 공익사업 준비과정과 그 이후 공익사업 진행과 관련된 실체상 권리행사에 중대한 지장을 미칠 수 있다. 신청권 요구에 대하여 견해대립이 있으나, 토지보상법 제9조 및 제12조에 의해 사업시행자에게 신청권이 있는 것으로 해석된다. 따라서 **허가거부는 처분으로서 대상적격이 있다**. 기타 소송요건이 충족된다면, 허가거부처분의 위법성의 정도에 따라 항고소송을 제기할 수 있다. 위법·부당의 경우 항고심판 가능하다.

춘천지법 강릉지원 2015.5.21. 선고 2015구합1541 판결 : 확정

甲 시장이 원자력발전소 전원개발사업을 시행하는 乙 주식회사에 사업 예정구역에 대한 지적현황 측량 및 지장물 실태조사를 위한 출입허가를 하였다가, 민간기구 주관으로 실시한 원전 유치 찬반 주민투표 결과 원전 유치 반대의견이 압도적으로 높아 원전 건설사업이 더 이상 진행되기 어려운 상황이라는 등의 이유로 출입허가를 취소하는 처분을 한 사안에서, 공익사업의 시행에 관한 결정이 당연 무효에 해당하지 않고 취소 또는 철회되지 않아 효력을 유지하고 있다면 결정의 하자나 지역 주민 대다수가 사업의 추진을 반대하고 있다는 등의 사정을 들어 이미 확정된 공익사업의 준비를 위한 출입허가를 취소할 수 없으므로 위 처분은 정당한 처분사유를 갖추지 못하였고, 행정절차법 제21조에 따른 청문절차를 거치지 않아 절차상으로도 중대한 하자가 있어 위법하다고 한 사례.

2) 허가신청 부작위에 대한 권리구제

사업시행자에게 토지보상법 제9조 및 제12조에 의해 신청권이 있는 것으로 해석되고, 특별자치도지사 등에게 일정한 처분을 할 법률상 의무가 있다. 만약 상당한 기간 내에 특별자치도지사 등이 아무런 처분도 하지 않고 있다면 부작위가 성립한다. 사업시행자는 **의무이행심판**과 **부작위위법확인소송**을 제기할 수 있다.

02 토지소유자의 권리구제

1) 사전적 권리구제

출입 측량·조사 시 통지, 장애물 제거 시 통지, 장애물 제거 허가 시 소유자 및 점유자의 의견청취 등이 토지보상법에 규정되어 있다. 측량·조사와 장애물 제거 행위는 **권력적 사실행위**로서, 처분성이 인정되고, 토지소유자 및 점유자에게는 침익적 행위인 바, 예방적 금지소송과 가처분이 권리구제방법으로 논의될 수 있으나, 현행법상 인정되지 않고 있다.

2) 사후적 권리구제

(1) 손실보상 (제9조 제4항, 제12조 제4항)

사업시행자는 타인 토지에 출입하여 측량·조사함으로써 발생하는 손실을 보상하여야 한다(제9조 제4항).

사업시행자는 장애물 제거 등을 함으로써 발생하는 손실을 보상하여야 한다(제12조 제4항). 손실의 보상은 손실이 **있음을 안 날부터 1년이 지났거나 손실이 발생한 날부터 3년이 지난 후에는 청구할 수 없다**(제9조 제5항).

손실의 보상은 사업시행자와 손실을 입은 자가 **협의**하여 결정한다(제9조 제6항). 협의 불성립 시 사업시행자나 손실을 입은 자는 관할 토지수용위원회에 **재결을 신청할 수 있다**(제9조 제7항).

(2) 손실보상의 재결에 대한 불복

토지보상법 제9조 제7항에 의한 재결은 보상금만에 대한 재결이나, 제34조의 수용재결과 동일한 절차, 심리 과정을 거쳐 결정되므로, 양자의 불복수단을 일관성 있게 봄이 타당하다. 따라서 토지보상법상 이의신청(제83조), 보상금증감청구소송(제85조 제2항)으로 권리구제가 가능하다. 다만, 보상재결의 처분성을 부정할 경우 이 손실보상청구권의 법적 성질에 따라 민사소송 또는 공법상 당사자소송으로 다룰 수 있다.

(3) 수용재결절차 없이 사업시행자를 상대로 손실보상청구 가능한지

① 견해 대립

보상재결은 단순한 보상견적액 제시에 불과하므로 민사 또는 당사자소송으로 다뤄야 한다는 견해, 재결절차를 반드시 거쳐야 한다는 견해가 있다.

② 판례

판례는 재결절차를 거친 후 재결 불복 시 비로소 토지보상법 규정으로 권리구제를 받을 수 있을 뿐, 재결절차를 거치지 않고 곧바로 사업시행자에게 손실보상을 청구할 수 없다고 하였다.

③ 검토

생각건대, 보상재결은 수용재결과 주제, 형식, 절차 등이 동일하므로 양자를 같은 처분으로 보아, 토지보상법상 규정된 절차에 따라 손실보상청구를 해야 한다고 보는 것이 타당하다.

따라서 일반적인 보상과 마찬가지로 토지보상법상 절차에 따라 보상이 이루어지는 것이 타당하다.

(4) 측량·조사 및 장애물 제거에 대한 행정쟁송

출입 측량·조사행위, 장애물 제거행위는 권력적 사실행위로서 처분성이 인정되므로, 항고쟁송으로 다룰 수 있다. 다만 조사기간이 짧아 단기에 종료될 수 있으므로 협의 소익이 없어 각하될 가능성이 높다.

(5) 기타 (위법한 조사와 사업인정, 손해배상 및 결과제거 청구권 등)

① 위법한 행정조사에 기한 후속조치로 처분이 행해진 경우 적법절차 관점에서 행정조사의 위법을 이유로 후행처분의 취소를 구할 수 있다.

② 위법한 행정조사는 국가배상법에 의해 손해배상청구가 가능하며 위법한 행정조사 결과로 위법한 상태가 계속되는 경우 결과제거청구권 행사가 가능하다.

제1절

토지조서·물건조서의 작성(제14조)

01 의의 및 취지

- ① 토지조서와 물건조서란 공익사업을 위해 수용 또는 사용할 필요가 있는 토지와 그 토지 위에 있는 물건의 내용을 기재한 사업시행자가 작성하는 문서이다.
- ② 조서작성은 공익사업을 위해 취득 또는 사용할 토지 및 물건내용을 확정하고 문서로 작성하는 행위이다.
- ③ 취득 또는 사용절차 개시 전 사업시행자, 토지소유자 및 관계인에게 토지나 물건에 대하여 필요한 사항을 확인하게 하여 당사자간 분쟁소지를 미리 예방하고, 공익사업을 신속하게 진행하고, 수용의 경우 수용위원회의 원활한 심리와 신속한 재결을 도모하기 위함에 취지가 있다.

02 협의취득을 위한 조서의 작성

1) 조서의 작성 방법 및 내용

- ① 사업시행자는 공익사업의 계획이 확정된 때에는 지적도 또는 임야도에 대상물건인 토지를 표시한 용지도를 작성하여야 하고(령 제7조 제1항)
- ② 작성된 용지도를 기본으로 하여 토지조서 및 물건조서를 작성하여야 한다.(령 제7조 제2항)

2) 서명 및 날인

(1) 서명 또는 날인하는 경우

사업시행자는 토지조서와 물건조서를 작성하여 서명 또는 날인을 하고, 토지소유자와 관계인의 서명 또는 날인을 받아야 한다.(제14조 제1항)

(2) 서명 또는 날인을 거부하는 경우 등

- ① (a) 토지소유자 및 관계인이 정당한 사유 없이 서명 또는 날인을 거부하는 경우,
(b) 토지소유자 및 관계인을 알 수 없거나
(c) 그 주소·거소를 알 수 없는 등의 사유로 서명 또는 날인을 받을 수 없는 경우에는,
사업시행자는 해당 토지조서와 물건조서에 그 사유를 적어야 한다.(제14조 제1항 단서)
- ② 서명의 거부 또는 불가능시 그 사유를 해당 조서에 기재하도록 함으로써 최종적으로 수용재결에서 다룰 수 있도록 하고 있다.

01 보상계획의 공고

- ① 사업시행자는 토지조서와 물건조서를 작성하였을 때에는 공익사업의 개요, 토지조서 및 물건조서의 내용과 보상의 시기·방법 및 절차 등이 포함된 보상계획을 전국을 보급지역으로 하는 일간신문에 공고하고, 토지소유자 및 관계인에게 각각 **통지**하여야 하며, 특별자치도지사, 시장·군수 또는 구청장에게도 **통지**하여야 한다.
- ② 다만, 토지소유자와 관계인이 20인 이하인 경우에는 공고를 생략할 수 있다.(제15조 제1항)

02 보상계획의 열람

- ① 사업시행자는 공고나 통지를 하였을 때에는 그 내용을 14일 이상 일반인이 열람할 수 있도록 하여야 한다.
- ② 다만, 사업지역이 둘 이상의 시·군 또는 구에 걸쳐 있거나 사업시행자가 행정청이 아닌 경우에는 해당 특별자치도지사, 시장·군수 또는 구청장에게도 그 사본을 송부하여 열람을 의뢰하여야 한다.(제15조 제2항)

03 보상계획에 대한 이의신청

- ① 공고·통지된 토지조서 및 물건조서의 내용에 대하여 이의가 있는 토지소유자 또는 관계인은 열람기간 이내에 사업시행자에게 서면으로 이의를 제기할 수 있다.(제15조 제3항)
- ② 다만, 사업시행자가 고의 또는 과실로 토지소유자 또는 관계인에게 보상계획을 **통지하지 아니한 경우** 해당 토지소유자 또는 관계인은 제16조에 따른 **협약이 완료되기 전까지** 서면으로 이의를 제기할 수 있다.(제15조 제3항)
- ③ 사업시행자는 해당 토지조서 및 물건조서에 제기된 이의를 부기하고 그 이의가 이유 있다고 인정할 때에는 적절한 조치를 하여야 한다.(제15조 제4항)

01 감정평가법인등의 선정

- ① 사업시행자는 보상액을 산정하려는 경우 감정평가법인등 3인(시·도지사 및 토지소유자가 모두 감정평가법인등을 추천하지 아니하거나 시·도지사 또는 토지소유자 어느 한쪽이 감정평가법인등을 추천하지 아니하는 경우에는 2인)을 선정하여 토지 등의 평가를 의뢰하여야 한다.
- ② 다만, 사업시행자가 국토교통부령으로 정하는 기준에 따라 직접 보상액을 산정할 수 있을 때에는 그러하지 아니하다.(제68조 제1항)
- ③ 사업시행자가 감정평가법인등을 선정할 때 해당 토지를 관할하는 시·도지사 및 토지소유자는 감정평가법인등을 각 1인씩 추천할 수 있다.
- ④ 이 경우 사업시행자는 추천된 감정평가법인등을 포함하여 선정하여야 한다.(제68조 제2항)

02 재평가의 의뢰(칙 제17조)

1) 당해 감정평가법인등에게 재의뢰(칙 제17조 제1항)

- ① 사업시행자는 보상평가서를 검토한 결과 그 평가가 관계법령에 위반하여 평가되었거나 합리적 근거 없이 비교 대상이 되는 표준지의 공시지가와 현저하게 차이가 나는 등 부당하게 평가되었다고 인정하는 경우에는 당해 감정평가법인등에게 그 사유를 명시하여 다시 평가할 것을 요구하여야 한다.
- ② 이 경우 사업시행자는 필요하면 국토교통부장관이 보상평가에 관한 전문성이 있는 것으로 인정하여 고시하는 기관에 해당 평가가 위법 또는 부당하게 이루어졌는지에 대한 검토를 의뢰할 수 있다.

2) 다른 2인 이상의 감정평가법인등에게 의뢰(칙 제17조 제2항)

- ① 사업시행자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 다른 2인 이상의 감정평가법인등에게 대상물건의 평가를 다시 의뢰하여야 한다.

1. 사업시행자는 보상평가가 관계 법령에 위반 또는 부당하게 평가되었다고 인정될 때 당해 감정평가법인등에게 평가를 요구할 수 없는 특별한 사유가 있는 경우
2. 대상물건의 평가액 중 최고평가액이 최저평가액의 110퍼센트를 초과하는 경우(대상물건이 지장물인 경우 최고평가액과 최저평가액의 비교는 소유자별로 지장물 전체 평가액의 합계액을 기준으로 한다)
3. 평가를 한 후 1년이 경과할 때까지 보상계약이 체결되지 아니한 경우

- ② 사업시행자는 제2항에 따른 재평가를 하여야 하는 경우로서 종전의 평가가 영 제28조에 따라 시·도지사 및 토지소유자가 추천한 감정평가법인등을 선정하여 행하여진 경우에는, 시·도지사 및 토지소유자(보상계약을 체결하지 아니한 토지소유자를 말한다. 이하 이 항에서 같다)에게 다른 감정평가법인등을 추천하여 줄 것을 통지하여야 한다.

CASE

1. 공익사업을 위한 토지등의 취득 및 보상에 관한 법률상 사업인정 전 협의와 사업인정 후 협의의 차이점에 대하여 설명하시오.(10점) [25회 문4번]
2. 토지보상법상 다음의 법적 성격을 설명하시오.(10점) [36회 문1]
 - ① 사업인정 전과 후의 '보상에 관한 협의'
 - ② 사업인정 후 '협의취득'

01 의미 및 취지

- ① 사업인정 전에 사업시행자로 하여금 수용대상 토지에 관하여 권리를 취득하거나 소멸시키기 위하여 토지소유자 및 관계인과 교섭하도록 하는 절차이다.
- ② 협의는 피수용자의 자발적 의사에 기초하므로 최소침해의 원칙을 지킬 수 있고, 공익사업의 신속·원활한 진행을 도모할 수 있다.

02 법적성질

1) 학설

(1) 사법상 계약설

협의의 결과 성립하는 합의는 사업시행자와 토지소유자 및 관계인 사이에 대등한 관계에서 맺어진 임의적인 합의이므로 사법상 매매계약으로 보는 견해이다.

(2) 공법상 계약설

사업인정 이전이라 하더라도 협의가 불성립하는 경우 차후에 강제수용절차가 예정되어 있고, 공익사업이라는 공공의 목적을 달성하기 위해 체결되는 계약이므로 공법상 계약으로 보는 견해이다.

2) 판례

대법원은 (구)공특법에 의한 손실보상의 협의는 공공기관이 사경제주체로서 행하는 사법상 계약의 실질을 가지는 것으로서, 당사자 간의 합의로 같은 법 소정의 손실보상의 요건을 완화하는 약정을 할 수 있고, 그와 같은 당사자 간의 합의로 같은 법 소정의 손실보상 기준에 의하지 아니한 매매대금을 정할 수 있다고 판시하였다.(대판 2000. 9. 8. 99다26924).

3) 검토

사업시행자는 사업인정을 통해 행정주체로서의 지위를 갖는 것이므로 사업시행자가 사업인정을 받기 전에 행한 협의행위는 행정상 법률관계를 형성한다고 보여지지 않는바, 사법상 계약으로 봄이 타당하다고 본다.

03 절차 및 내용

- ① 사업시행자는 협의를 하려는 경우에는 국토교통부령으로 정하는 보상협의요청서에 다음 각 호의 사항을 적어 토지소유자 및 관계인에게 통지하여야 한다.(령 제8조 제1항)

1. 협의기간 · 협의장소 및 협의방법
2. 보상의 시기 · 방법 · 절차 및 금액
3. 계약체결에 필요한 구비서류

- ② 계약의 내용에는 계약의 해지 또는 변경에 관한 사항과 이에 따르는 보상액의 환수 및 원상복구 등에 관한 사항이 포함되어야 한다.(령 제8조 제4항)

- ③ 협의의 기간은 특별한 사유가 없으면 30일 이상으로 하여야 한다.

04 효과

1) 협의 성립시 효과

- ① 사업시행자는 협의를 성립된 때에는 토지소유자 및 관계인과 계약을 체결하여야 한다.(제17조)
- ② 협의가 성립하면 그것으로 취득 또는 사용의 절차는 종결되고, 협의의 내용에 따른 <사법상 계약의 효과>가 발생하며, 이때의 권리취득은 <승계취득>이 된다.

※ 보충설명

- ① 공법상 계약으로 보는 견해에 의하여도 승계취득이고, 수용재결의 경우에만 원시취득임.
- ② 다만, 사업인정 후 협의는 협의성립확인을 받으면 원시취득의 효과가 인정됨.
(이것은 사업인정 후 협의를 공법상 계약으로 보는 주장논거가 됨.)

- ③ 따라서 사업시행자는 보상금을 지불하고, 토지소유자 및 관계인은 토지·물건을 인도 또는 이전하게 되며, 사업시행자는 목적물에 대한 권리를 취득하고, 토지소유자 및 관계인은 권리를 상실하게 된다.
- ④ 이 경우 협의에 의한 토지 등의 취득은 [민법] 제186조에 따른 부동산에 관한 법률행위로 인한 물권의 득실변경에 해당하므로 소유권이전등기를 마쳐야 소유권을 취득한다.

대법원 2018.12.13. 선고 2016두51719

토지보상법상 수용은 일정한 요건하에 그 소유권을 사업시행자에게 귀속시키는 행정처분으로서 이로 인한 효과는 소유자가 누구인지와 무관하게 사업시행자가 그 소유권을 취득하게 하는 원시취득이다. 반면, 토지보상법상 협의취득의 성격은 사법상 매매계약이므로 그 이행으로 인한 사업시행자의 소유권 취득도 승계취득이다.

2) 협의 불성립시 효과(령 제8조 제5항)

- ① 협의 불성립시 사업시행자는 협의경위서를 작성하여 토지소유자 및 관계인의 서명 또는 날인을 받아야 한다.
- ② 정당한 사유 없이 서명 또는 날인을 거부하거나, 서명 또는 날인을 받을 수 없는 경우에는 받지 아니하되, 그 사유를 기재하여야 한다.
- ③ 이후 사업시행자는 공익사업의 진행을 위해 국토교통부장관에게 사업인정을 신청할 수 있다.

※ 보충자료(김원보 평가사님 저서내용 중 발췌)

1. 협의에서 [토지보상법] 적용의 배제 여부

- ① 협의과정에서 사업시행자 및 토지소유자 등 당사자 간의 합의로 [토지보상법]의 적용을 배제할 수 있는지 여부가 문제된다.
- ② [토지보상법]은 공익사업의 원활한 추진을 도모하는 한편, 수용권을 가지는 사업시행자에 비해 상대적으로 약자인 토지소유자 또는 관계인의 재산권 보호를 목적으로 하므로, 공익사업을 시행함에 있어서는 원칙적으로 [토지보상법]을 적용해야 한다.
- ③ 즉, 공익사업의 경우에도 토지소유자와 사업시행자 간의 합의에 의해 [토지보상법]에서 규정한 세입자에 대한 주거이전비, 영업보상, 영농보상 등의 적용을 임의로 배제할 수는 없다고 본다.

2. 협의의 취소 여부

1) 취소 여부의 판단기준

- ① 사업인정고시일 이전의 협의는 그 법적 성질이 사법상 계약의 실질을 가지므로 [민법] 제109조 제1항에 따라 의사표시에 법률행위 내용의 중요부분에 착오가 있는 때에는 취소할 수 있으나, 그 착오가 표의자의 중대한 과실로 인한 때에는 취소하지 못한다.
- ② 이 경우 취소여부는 체결된 계약의 내용 및 사실관계 등을 기준으로 판단한다.

2) 취소할 수 있는 경우

- ① 보상금을 산정하면서 토지의 용도지역 등을 잘못 적용하였다든지, 편입 면적의 오산 등으로 인하여 정당한 가액보다 과다 또는 과소한 보상액으로 협의한 경우에는 계약 내용의 중요한 부분의 착오에 해당한다고 볼 수 있으므로 이를 취소할 수 있다.
- ② 다만, 이 경우에도 착오가 표의자의 <중대한 과실>로 인한 때에는 취소하지 못하며, 여기서 <중대한 과실>이란 표의자의 직업, 행위의 종류, 목적 등에 비추어 보통 요구되는 주의를 현저히 결여하는 것을 의미한다.

제1절

사업인정

CASE

A대도시의 시장은 국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 따른 도시관리계획으로 관할구역 내 ○○동 일대 90,000㎡ 토지에 공영주차장과 자동차정류장을 설치하는 도시계획시설사업결정을 한 후 지방공기업법에 따른 A대도시 X지방공사를 도시계획시설사업의 시행자로 지정하고, X지방공사가 작성한 실시계획에 대해 실시계획인가를 하고 이를 고시하였다. 이에 따라 토지보상법에 의해 사업인정 및 고시가 이루어졌다.

토지보상법상의 사업인정과 사업인정고시의 법적 성질에 관하여 설명하시오.(10점) [34회 문1]

01 의미 및 취지(토지보상법 제20조)

- ① 사업인정이란 공익사업을 토지 등을 수용하거나 사용할 사업으로 결정하는 것을 말한다.(제2조 제7호)
- ② 사업인정은 당해 사업이 공공성이 있는가를 개별*구체적으로 판단하여 <피수용자의 권리를 보호>하고, 이에 의해 수용가능여부가 결정되는 수용절차의 제1단계로서 <수용행정의 적정화>, <사전적 권리구제>장치로서의 역할을 한다.

02 법적성질

1) 처분성(행정행위)

- ① 사업인정이 있으면 사업시행자는 토지수용 등을 위한 절차를 개시할 권리 및 토지 등을 수용하거나 사용할 권리가 창설되고,
- ② 토지소유자는 사업인정의 고시가 있는 후 고시된 토지 등에 보전 의무 및 손실보상청구권이 주어진다.
- ③ 따라서, 사업인정은 사업시행자와 토지소유자 등에게 일정한 구체적 법적효과가 발생하므로 행정행위이자, 항고소송의 대상인 <처분>이다.

2) 형성행위 여부

(1) 학설

① 형성행위설

사업인정을 사업시행자에게 사업인정 후 일정한 절차를 거칠 것을 조건으로 수용권을 설정하여 주는 형성행위라고 보는 견해이다.

② 확인행위설

사업인정이란 특정한 사업이 토지를 수용할 수 있는 사업에 해당하는 것을 확인하고 선언하는 확인행위라고 보는 견해이다.

(2) 판례

사업인정은 그 후 일정한 절차를 거칠 것을 조건으로 하여 일정한 내용의 수용권을 설정해 주는 행정처분의 성격을 띠는 것이라고 판시하였다.

(3) 검토

사업인정은 특정 사업이 토지보상법 제4조의 공익사업에 해당하는가를 단순히 확인하는 것이 아니라, 그 사업의 공익성 여부를 모든 사정을 참작하여 구체적으로 판단하여 수용권을 설정해 주는 것으로 <설권적 형성행위>로 보는 것이 타당하다.(강학상 특허)

3) 재량행위 여부

(1) 학설

- ① <설권적 형성행위설>은 사업인정이 사업시행자에게 일정한 내용의 수용권을 부여하는 행위이므로 재량행위라고 한다.
- ② 한편 <확인행위설>은 사업인정이 단순히 특정 사업이 법률에서 정하는 일정한 요건을 갖추고 있는지 여부를 판단하는 기속행위에 불과한 것으로 보고 있다.

(2) 판례

판례는 사업인정이 단순한 확인행위가 아니라 형성행위이고, 그 사업이 공용수용을 할 만한 공익성이 있는지의 여부를 모든 사정을 참작하여 구체적으로 판단하여야 하는 것이므로 사업인정의 여부는 행정청의 재량에 속한다고 하였다.(대판 1992. 11. 13. 92누596)

(3) 검토

- ① 1차적으로 법문언에 따를 때, 토지보상법 제20조는 “사업시행자는 ~ 사업인정을 받아야 한다.”라고 되어 있어 판단이 불분명하나,
- ② 토지보상법의 입법 목적, 취지, 행위의 성질, 공익 관련성 등을 종합적으로 판단할 때, <재량행위>로 봄이 타당하다.

4) 제3자효 행정행위

사업인정은 사업시행자에게 수용권을 설정하는 수익적 효과를, 피수용자에게는 재산권을 침해하는 침익적 효과를 발생시키는 바 <제3자효 행정행위>이다.

03 요건

1) 성립요건

(1) 주체

- ① 사업시행자는 토지 등을 수용하거나 사용하려면 국토교통부장관의 사업인정을 받아야 한다.(제20조 제1항)
- ② 개별 법률상 사업인정을 의제하는 경우에는 사업인정이 있는 것으로 의제되는 공익사업의 허가·인가·승인권자 등이 사업인정의 권한을 갖는다.

(2) 내용

- ① 공익사업이 토지보상법 제4조의 각 호 중 하나에 해당하여야 한다.
- ② 공공필요는 <공익성>과 <필요성>이라는 2가지 측면에서 판단한다. 먼저, <공익성>은 수용 또는 사용을 허용하고 있는 개별 법률의 입법목적*사업내용 및 사업이 입법목적에 이바지하는 정도 등을 고려하여 판단하고, <필요성>은 수용 또는 사용을 통하여 달성하려는 공익과 침해당하는 공익 및 사익을 비교·형량하여 공익 및 사익에 대한 침해를 정당화할 정도의 공익 우월성이 있는지 등을 고려하여 판단한다.
- ③ 또한 사업시행자에게 해당 공익사업을 수행할 **의사와 능력**이 있어야 한다.

헌법재판소 2014. 10. 30. 선고 2011헌바129,172

헌법 제23조 제3항에서 규정하고 있는 ‘공공필요’는 “국민의 재산권을 그 의사에 반하여 강제적으로라도 취득해야 할 공익적 필요성”으로서, ‘공공필요’의 개념은 ‘공익성’과 ‘필요성’이라는 요소로 구성되어 있는바, ‘공익성’의 정도를 판단함에 있어서는 공용수용을 허용하고 있는 개별법의 입법목적, 사업내용, 사업이 입법목적에 이바지 하는 정도는 물론, 특히 그 사업이 대중을 상대로 하는 영업인 경우에는 그 사업 시설에 대한 대중의 이용·접근가능성도 아울러 고려하여야 한다. 그리고 ‘필요성’이 인정되기 위해서는 공용수용을 통하여 달성하려는 공익과 그로 인하여 재산권을 침해당하는 사인의 이익 사이의 형량에서 사인의 재산권침해를 정당화할 정도의 공익의 우월성이 인정되어야 하며, 사업시행자가 사인인 경우에는 그 사업 시행으로 획득할 수 있는 공익이 현저히 해태되지 않도록 보장하는 제도적 규율도 갖추어져 있어야 한다.

대법원 2011. 1. 27. 선고 2009두1051

해당 공익사업을 수행하여 공익을 실현할 의사나 능력이 없는 자에게 타인의 재산권을 공권력적·강제적으로 박탈할 수 있는 수용권을 설정하여 줄 수는 없으므로, **사업시행자에게 해당 공익사업을 수행할 의사와 능력이 있어야 한다는 것도 사업인정의 한 요건**이라고 보아야 한다.

대법원 2019.2.28. 선고 2017두71031

참가인 송파구청장이 이 사건 사업비를 송파구의 자체 예산으로 조달하지 않는다는 사정만으로 참가인 송파구청장에게 사업수행의사나 능력이 없다고 볼 수 없다고 하였다.

(3) 절차

a. 사업인정의 신청(령 제10조)

사업인정을 받으려는 자는 국토교통부령으로 정하는 사업인정신청서를 시·도지사를 거쳐 국토교통부장관에게 제출하여야 한다.

b. 의견청취 등(법 제21조)

- ① 국토교통부장관은 사업인정을 하려면 관계 중앙행정기관의 장 및 시·도지사 및 중앙토지수용위원회와 **협의**하여야 하며, 대통령령으로 정하는 바에 따라 미리 사업인정에 이해관계가 있는 자의 **의견**을 들어야 한다.
- ② 별표에 규정된 법률에 따라 사업인정이 있는 것으로 의제되는 공익사업의 허가·인가·승인권자 등은 사업인정이 의제되는 지구지정·사업계획승인 등을 하려는 경우 **중앙토지수용위원회와 협의**하여야 하며, 대통령령으로 정하는 바에 따라 사업인정에 이해관계가 있는 자의 **의견**을 들어야 한다.

- ③ 국토교통부장관 또는 허가·인가·승인권자는 중앙토지수용위원회가 사업인정 등에 동의하지 않은 경우에는 이를 보완하여 다시 협의를 요청할 수 있다(칙 제9조의3).

c. 중앙토지수용위원회의 검토

- ① 중앙토지수용위원회는 상기 협의를 요청받은 경우 사업인정에 이해관계가 있는 자에 대한 의견수렴절차 이행여부, 허가·인가·승인대상 사업의 공공성, 수용의 필요성, 그 밖에 대통령령(사업시행자의 재원 및 사업수행능력 여부 등)으로 정하는 사항을 검토하여야 한다.(법 제21조 제3항)
- ② 중앙토지수용위원회는 검토를 위하여 필요한 경우 관계 전문기관이나 전문가에게 현지조사를 의뢰하거나 그 의견을 들을 수 있고, 관계 행정기관의 장에게 관련 자료의 제출을 요청할 수 있다.(법 제21조 제4항)
- ③ 중앙토지수용위원회는 상기 사항을 검토한 결과 자료 등을 보완할 필요가 있는 경우에는 해당 허가·인가·승인권자에게 14일 이내의 기간을 정하여 보완을 요청할 수 있다.(법 제21조 제6항)

d. 중앙토지수용위원회의 의견 제시

- ① 중앙토지수용위원회는 상기 협의를 요청받은 날부터 30일 이내에 의견을 제시하여야 한다.
(법 제21조 제5항)
- ② 다만, 그 기간 내에 의견을 제시하기 어려운 경우에는 한 차례만 30일의 범위에서 그 기간을 연장할 수 있다.(법 제21조 제5항)
- ③ 중앙토지수용위원회가 정한 기간 내에 의견을 제시하지 아니하는 경우에는 협의가 완료된 것으로 본다.
(법 제21조 제7항)

e. 사업인정의 고시(법 제22조)

국토교통부장관은 사업인정을 하였을 때에는 지체 없이 그 뜻을 사업시행자, 토지소유자 및 관계인, 관계 시·도지사에게 통지하고 사업시행자의 성명이나 명칭, 사업의 종류, 사업지역 및 수용하거나 사용할 토지의 세목을 관보에 고시하여야 한다.

(4) 형식

토지보상법상 특별한 규정이 없으므로, 사업인정처분은 행정절차법 제24조에 따라 문서로 하여야 한다.

2) 효력발생요건

(1) 사업인정의 고시

- ① 사업인정고시란 사업인정 효과가 미치는 범위를 누구나 확인할 수 있도록 나타내는 절차이다.
- ② 국토교통부장관은 사업인정을 하였을 때에는 지체 없이 그 뜻을 사업시행자, 토지소유자 및 관계인, 관계 시·도지사에게 통지하고 사업시행자의 성명이나 명칭, 사업의 종류, 사업지역 및 수용하거나 사용할 토지의 세목을 관보에 고시하여야 한다.(제22조 제1항)
- ③ 사업인정의 사실을 통지받은 시·도지사(특별자치도지사를 제외함)는 관계 시장·군수 및 구청장에게 이를 통지하여야 한다.(제22조 제2항)
- ④ 사업인정은 고시한 날부터 그 효력이 발생한다.(제22조 제3항)
- ⑤ 사업인정은 통지가 있었다 하더라도 고시가 없으면 효력이 발생되지 아니한다.

(2) 토지세목고시 누락이 사업인정처분의 절차하자인지

- ① 토지세목의 고시는 사업인정에 의해 지정된 범위 내에서 구체적으로 수용할 수 있는 목적물을 결정하는 행위이며, 이로써 목적물에 대해 막연한 효력밖에 없었던 사업인정이 현실화되고 구체화된다.
- ② 토지세목고시를 누락한 것은 절차상 위법으로서 사업인정의 취소사유가 된다.

대판 1988. 12. 27. 87누1141

도시계획사업허가의 공고시에 토지세목의 고시를 누락한 것은 절차상의 위법으로서 취소사유에 불과하고 그 하자가 중대하고 명백하여 사업인정 자체가 무효라고 단정하기는 어렵다 할 것이다.

04 사업인정고시의 효과 [수목관보조]

1) 토지수용권의 발생

사업인정이 고시됨으로써 사업시행자는 자기가 시행하는 공익사업을 위하여 일정한 절차를 거칠 것을 조건으로 목적물을 수용할 수 있는 권한이 부여된다.

2) 수용목적물의 확정

토지세목고시에 의해 수용 또는 사용할 토지의 범위가 특정된다.

3) 관계인의 범위 제한

- ① 사업인정의 고시가 된 후에 권리를 취득한 자는 기존의 권리를 승계한 자를 제외하고는 관계인에 포함되지 아니한다.
- ② 관계인을 사업인정시로 한정하는 것은 공용수용의 절차에 참여하는 자를 제한하여 그 절차의 이행을 간소하고 명확하게 함에 목적이 있다.

4) 토지 등의 보전의무

- ① 사업인정고시가 된 후에는 누구든지 고시된 토지에 대하여 사업에 지장을 줄 우려가 있는 형질의 변경이나, 물건을 손괴하거나 수거하는 행위를 하지 못한다.(법 제25조)
- ② 토지 등의 보전의무는 토지소유자 및 관계인에 한정되지 않고 누구에게나 부과된다.

5) 토지·물건조사권의 발생

- ① 사업인정고시 후 사업시행자가 사업의 준비나 토지물건조서를 작성하기 위해 필요한 경우, 또는 감정평가법인등이 감정평가를 위하여 필요한 경우에는, 허가 없이도 해당 토지나 물건에 출입하여 측량하거나 조사할 수 있다.(법 제27조 제1항)
- ② 이 경우 출입의 통지(제10조 제3항), 토지점유자의 인용의무(제11조) 및 증표 등의 휴대(제13조) 규정을 준용한다(제27조 제2항).

05 권리구제

1) 사업시행자입장에서의 권리구제

(1) 사업인정 신청 후 거부시 권리구제

- ① 사업시행자 입장에서는 사업인정신청 후 거부시의 경우, 행정심판에서는 의무이행심판과 거부처분취소심판이 가능할 것으로 보인다.
- ② 또한 사업인정의 거부가 처분인지에 대하여, 판례에 따르면 처분성이 인정될 수 있는바, 거부처분취소소송이 가능할 것으로 보인다.
- ③ 현행 행정소송법상 인정되지 않으나, 국민의 권리구제를 위하여 무명항고소송인 의무이행소송을 인정한다면 의무이행소송으로도 구제가 가능하다.

(2) 사업인정신청 후 부작위시 권리구제

사업인정신청 후 부작위의 경우, 사업시행자는 행정심판에서는 의무이행심판을, 행정소송에서는 부작위위법 확인소송이 가능하며, 무명항고소송인 의무이행소송을 인정한다면 의무이행소송으로도 구제가 가능하다.

2) 피수용자입장에서 권리구제

- ① 만약, 사업인정이 위법한 경우에는 행정쟁송 및 손해배상청구가 가능할 것이다.
- ② 인근주민(제3자)의 원고적격이 특히 문제되는데, 사업계획승인이 환경영향평가의 대상이 되는 경우에 환경영향평가 대상지역에 거주하는 주민은 당해 사업계획승인처분을 다룰 원고적격이 있는 것으로 <추정>되고, 환경영향평가 대상지역 밖의 주민이라도 처분 전과 비교하여 수인한도를 넘는 환경피해를 받을 것을 <입증>하면 원고적격이 인정될 것이다.

01 의미

사업인정의제란 토지보상법 제20조에서 사업인정에 관한 규정을 두고 있음에도 불구하고, 개별법에서 별도로 규정하고 있는 지구지정·실시계획승인 등이 있을 경우, 이를 토지보상법 상의 사업인정이 있는 것으로 보도록 하는 것을 말한다.

02 취지

개별 법률에서 사업인정에 준하는 절차를 이행하였을 때 이를 사업인정으로 의제함으로써 절차의 중복을 방지하고, 개별 법률에 따른 공익성의 특성을 반영하는 것이 필요하다는 취지에서 인정된다.

03 사업인정 의제제도의 문제점

1) 사업인정제도의 형해화

공공수용은 개인의 재산권을 강제로 취득하는 것이기 때문에 엄격한 절차가 요구되나, 개별법에서 정한 **간소한 절차**에 따라 사업인정을 받은 것으로 의제하고 토지 등을 수용하게 되면, 그것은 사업인정제도의 취지에 반하는 것으로서 사업인정제도를 형해화하는 문제점이 있다.

2) 재결신청기간 장기화

토지보상법상 사업인정고시일 이후 1년 이내에 재결을 신청해야 하나, 많은 개별법에서 재결신청기간의 **특례**를 인정하여 사업이 장기화되는 문제점이 있다.

[국계법] 제96조 (토지보상법의 준용)

- ① 제95조에 따른 수용 및 사용에 관하여는 이 법에 특별한 규정이 있는 경우 외에는 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」을 준용한다.
- ② 제1항에 따라 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」을 준용할 때에 제91조에 따른 **실시계획을 고시**한 경우에는 같은 법 제20조 제1항과 제22조에 따른 **사업인정 및 그 고시**가 있었던 것으로 본다.
다만, 재결신청은 같은 법 제23조 제1항과 제28조 제1항에도 불구하고 실시계획에서 정한 도시·군계획시설사업의 **시행기간**에 하여야 한다.

04 사업인정의제 제도의 개선방안

1) 사전적 권리구제 강화

공익사업의 홍보를 통한 지역주민의 참가와 이로 인한 사전적 권리구제의 가능성을 높일 필요가 있다.

2) 사업인정의제 제도 최소화

사업인정의제 제도를 최소한으로 제한할 필요가 있으며, 나아가 토지보상법 규정에 의한 사업인정 내지 표준적인 절차로 일원화, 재결신청기간의 제한 등의 입법적 개선이 필요하다.

CASE

[공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률] 제23조에 의한 사업인정의 실효가 있는 경우 이로 인하여 불이익을 받게 되는 피수용자에게 손실보상청구권이 있는 여부를 논하시오.(40점) [6회 문1]

01 재결신청기간의 경과로 인한 실효(제23조)

1) 실효의 사유 및 실효시기

사업시행자가 사업인정의 고시가 된 날로부터 1년 이내에 재결신청을 하지 아니한 경우에는, 사업인정고시가 된 날로부터 1년이 되는 날의 다음날에 사업인정은 그 효력을 상실한다.(제23조 제1항)

2) 취지

사업인정의 실효제도는 피수용자의 권리보호를 위한 방안이며, 사업인정 당시 인정된 공공성의 계속성을 확보하기 위해 인정되는 제도이다.

3) 실효의 효과

- ① 사업시행자는 사업이 실효됨으로 인하여 토지소유자나 관계인이 입은 손실을 보상하여야 한다.(제23조 제2항)
- ② 재결신청 기간 경과로 인한 피수용자의 금전적 손해는 사업시행자의 토지보상법 위반에 따른 위법한 행정작용에 기인한 것이다.
- ③ 그러나 피수용자의 입장에서 국가배상 청구요건을 입증하여야 하는 어려움에 대한 현실적인 문제를 손실보상 규정을 마련함으로써 입법적으로 해결한 것으로, 이 손실보상규정은 손해배상의 성격을 지닌다.

4) 관련 문제

개별법은 재결신청기간을 토지보상법과 달리 당해 사업시행기간 내로 하는 특례를 규정하고 있어, 재결신청의 해태로 인한 사업인정 실효 규정이 적용될 여지가 없어 제도 취지를 무의미하게 할 우려가 있다.

02 사업의 폐지 및 변경(제24조)

1) 의의 및 취지

사업인정고시 후 공익사업의 폐지 또는 변경 등으로 인하여 토지를 수용하거나 사용할 필요가 없게 된 경우, 시·도지사가 사업시행자의 신고 또는 직권으로 이를 고시하여 사업인정을 실효시키는 제도이다.

2) 내용

- ① 사업의 전부 또는 일부를 폐지하거나 변경함으로 인하여 토지 등의 전부 또는 일부를 수용하거나 사용할 필요가 없게 되었을 때에는 사업시행자는 지체 없이 사업지역을 관할하는 시·도지사에게 신고하고, 토지소유자 및 관계인에게 이를 통지하여야 한다.(제24조 제1항)

- ② 시·도지사는 이 규정에 따른 신고를 받으면 사업의 전부 또는 일부가 폐지되거나 변경된 내용을 관보에 **고시**하여야 한다.(제24조 제2항)
- ③ 시·도지사는 **신고가 없는 경우에도** 사업시행자가 사업의 전부 또는 일부를 폐지하거나 변경함으로 인하여 토지를 수용하거나 사용할 필요가 없게 된 것을 알았을 때에는 미리 사업시행자의 의견을 듣고 고시를 하여야 한다.(제24조 제3항)
- ④ 시·도지사는 제2항 및 제3항에 따른 고시를 하였을 때에는 지체 없이 그 사실을 국토교통부장관에게 **보고**하여야 한다.(제24조 제4항)

3) 실효 시기 및 고시의 법적성질

- ① 사업의 전부 또는 일부의 폐지나 변경의 고시가 된 날부터 그 고시된 내용에 따라 사업의 전부 또는 일부는 그 효력을 상실한다.(제24조 제6항)
- ② 사업인정의 폐지·변경에 관한 고시는 행정행위의 효력을 상실시키기 위한 새로운 행정행위로서 **강학상 철회**의 성격을 가지며, 이 경우 **소급효는 인정되지 않는다**.

4) 실효의 효과

- ① 사업시행자는 사업의 전부 또는 일부를 폐지·변경함으로 인하여 토지소유자 또는 관계인이 입은 **손실을 보상**하여야 한다.(제24조 제7항)
- ② 사업의 폐지·변경의 경우 피수용자가 입은 손실을 보상하게 하는 것은 공익사업에 대한 신뢰보호 및 피해구제를 위한 것이다. 이 규정에 따른 손실보상에 관하여는 손실보상의 청구(제9조 제5항), 협의결정(제9조 제6항), 재결신청(제9조 제7항) 규정을 준용한다.(제24조 제7항)
- ③ 사업인정 실효의 고시가 있을 때, 재결신청이 토지수용위원회에 계속되고 있을 때에는 사업시행자는 그 신청을 **취하**하여야 하고, 취하지 않으면 재결은 **각하**되어야 할 것이다.
- ④ 만약 재결이 있고, 수용 또는 사용의 개시일 이전에 사업인정 취소의 고시가 있으면, 재결의 취소를 요하지 않고 그 고시에 따라 **재결은 실효**가 되는 것으로 해석된다.

구 분	재결신청기간 경과	사업의 폐지·변경
근거	제23조	제24조
절차	사업인정고시일로부터 1년 되는 날 다음 날 실효	사업시행자의 신고, 통지 → 시도지사의 고시, 국토교통부장관에게 보고
법적성질	조건 성취로 인한 실효	강학상 철회와 유사(단, 시도지사가 실효 고시)
공동점	◎ 취지 : 공공성 계속적 담보 및 피수용자 보호 ◎ 손실 발생시 손실보상청구 가능(제9조 제5~7항)	

03 사업의 완료(제24조의2)

- ① 사업이 완료된 경우 사업시행자는 지체 없이 사업시행자의 성명이나 명칭, 사업의 종류, 사업지역, 사업인정고시일 및 취득한 토지의 세목을 사업지역을 관할하는 시·도지사에게 신고하여야 한다.(제24조의2 제1항)
- ② 시·도지사는 신고를 받으면 사업시행자의 성명이나 명칭, 사업의 종류, 사업지역 및 사업인정고시일을 관보에 고시하여야 한다.(제24조의2 제2항)
- ③ 시·도지사는 신고가 없는 경우에는 사업이 완료된 것을 알았을 때에는 미리 사업시행자의 의견을 듣고 제2항에 따른 고시를 하여야 한다.(제24조의2 제3항)
- ④ 별표에 규정된 법률에 따라 제20조에 따른 사업인정이 있는 것으로 의제되는 사업이 해당 법률에서 정하는 바에 따라 해당 사업의 준공·완료·사용개시 등이 고시·공고된 경우에는 제2항에 따른 고시가 있는 것으로 본다.
(제24조의2 제4항)

제1절

토지조서 및 물건조서의 작성(제14조)

01 조서의 의의 및 성질

1) 의의 및 취지

- ① 토지조서와 물건조서란 공익사업을 위해 수용 또는 사용할 필요가 있는 토지와 그 토지 위에 있는 물건의 내용을 기재한 사업시행자가 작성하는 문서이다.
- ② 조서작성은 공익사업을 위해 취득 또는 사용할 토지 및 물건내용을 확정하고 문서로 작성하는 행위이다.
- ③ 취득 또는 사용절차 개시 전 사업시행자, 토지소유자 및 관계인에게 토지나 물건에 대하여 필요한 사항을 확인하게 하여 당사자간 분쟁소지를 미리 예방하고, 공익사업을 신속하게 진행하고, 수용의 경우 수용위원회의 원활한 심리와 신속한 재결을 도모하기 위함에 취지가 있다.

2) 법적성질

- ① 타인토지출입 측량·조사행위는 점유자에게 인용의무가 부과되므로 <권력적 사실행위>에 해당하고,
- ② 조서작성행위 자체는 사실관계를 기재하는 것으로 <비권력적 사실행위>로 보는 것이 일반적이다.

02 조서의 작성절차

1) 토지 및 물건에 관한 조사권

(1) 의의

- ① 사업인정고시가 된 후에는 사업시행자 또는 제68조에 따라 감정평가를 의뢰받은 감정평가법인등은 사업준비나 조서작성 또는 감정평가를 위해 필요한 경우, 허가 또는 통지 없이, 해당 토지나 물건에 출입하여 측량하거나 조사할 수 있다(제27조 제1항).
- ② 이 경우 사업시행자는 해당 토지나 물건에 출입하려는 날의 5일 전까지 그 일시 및 장소를 토지점유자에게 통지하여야 하며, 출입의 통지(제10조 제3항), 인용의무(제11조) 및 증표 등의 휴대(제13조)를 준용한다.

(2) 법적성질

- ① 조사권은 사업인정고시의 효과로서 발생하는 권리로서 공용사용의 일종이다.
- ② 사업인정에 의해 당해 공익사업의 공익성이 인정된 바, 사업준비를 위한 타인토지출입에 비해 간단한 절차로 규정되어 있다.

2) 작성절차 및 작성의 특례

- ① 조서의 작성은 협의에 의한 취득 또는 사용을 위한 조서작성의 규정(제14조)을 준용한다.(제26조 제1항)
- ② 사업인정 이전에 토지조서 및 물건조서의 작성, 보상계획의 열람 등, 협의 및 보상액의 산정에 따른 절차를 거쳤으나, 협의가 성립되지 아니하고 사업인정을 받은 사업으로서, 토지조서 및 물건조서의 내용에 변동이 없을 때에는 토지조서 및 물건조서의 작성, 보상계획의 열람 등, 협의의 절차를 거치지 아니할 수 있다.(제26조 제2항 본문)

3) 손실보상의무

- ① 사업시행자는 타인이 점유하는 토지에 출입하여 측량·조사함으로써 발생하는 손실(감정평가법인등이 감정평가를 위하여 측량·조사함으로써 발생하는 손실도 포함)을 보상하여야 한다.
- ② 이 경우 손실보상에 관하여는 제9조 제5항부터 제7항까지의 규정을 준용한다.

4) 장애물 제거 관련 논의

- ① 조서작성을 위한 장애물 제거에 대하여는 아무런 규정을 두고 있지 않다.
- ② 조서작성을 위해 장애물을 제거할 필요가 있을 수 있고, 이로 인해 발생하는 손실에 대해 보상이 행해지는 것을 전제로 한다면 이 경우에도 장애물을 제거하는 것이 가능한 것으로 보아야 할 것이다.
- ③ 따라서 사업준비를 위한 장애물 제거 등에 관한 규정(제12조)은 사업인정 후 조서작성에도 준용된다고 보는 것이 타당하다.

03 조서의 효력

1) 사업인정고시일 이전

- ① 사업인정고시일 이전에는 사업시행자에게 수용권이 없으므로 사업시행자와 토지소유자 또는 관계인이 토지조서 및 물건조서의 내용에 대하여 다툼이 있는 경우 토지소유자 또는 관계인은 협의에 응하지 않음으로써 이에 대항할 수 있다.
- ② 따라서 사업인정고시일 이전에는 토지조서 및 물건조서에 추정력 등의 효력은 없다.

2) 사업인정고시일 이후

(1) 이의를 제기하지 않은 경우

a. 원칙

- ① 토지소유자나 관계인이 조서의 내용에 대하여 이의를 제기하지 않은 경우에는 그 이후 협의 또는 재결단계에서 이에 대해 이의를 제기할 수 없다.
- ② 위와 같이 작성된 토지조서 및 물건조서는 토지수용위원회의 재결을 위한 심리과정에서 그 조서 작성 당시의 토지나 물건의 상황을 나타내고, 그 조서에 기재된 내용은 별도의 입증 없이도 진정한 것으로 보며, 이를 <진실의 추정력>이라고 한다.

b. 예외

- ① [토지보상법] 제27조 제3항 단서에 따라 제15조 제3항에 따른 이의를 제기하지 않은 경우에도, 토지조서 및 물건조서의 내용이 진실과 다르다는 것을 입증할 때에는 조서의 내용을 진정한 것으로 보지 않는다.
- ② 즉, 토지조서나 물건조서의 내용이 진실하지 않다는 점은 이를 주장하는 토지소유자 또는 관계인이 반대의 증거를 제시하여 입증해야 한다.

(2) 이의를 제기한 경우

이의가 제기된 사항에 대해서는 사실과 같다는 추정을 받을 수 없으므로 토지수용위원회의 재결을 위한 심리과정에서 사업시행자, 토지소유자 또는 관계인이 대등하게 내용의 진실 여부를 주장할 수 있고, 토지수용위원회가 최종적으로 이를 결정한다.

(3) 서명 또는 날인을 거부한 경우

- ① [토지보상법] 제14조 제1항에 따라 사업시행자는 토지조서와 물건조서를 작성하여 토지소유자와 관계인의 서명 또는 날인을 받아야 하나,
- ② 토지소유자나 관계인이 정당한 사유없이 서명 또는 날인을 거부한 경우에도 그 조서의 기재사항은 진실하다는 추정을 받는다.

04 절차상 하자 있는 조서의 효력

1) 원칙

- (a) 조서작성을 위한 토지출입 등의 적법한 절차를 거치지 않았거나,
- (b) 토지소유자와 관계인의 서명·날인도 요구하지 않고 작성된 토지,
- (c) 토지소유자 또는 관계인 중 일부의 서명·날인만을 받아 작성한 조서 등은 적법하게 작성된 조서가 아니므로 원칙적으로 조서로서의 효력이 없다.

2) 조서 작성의 하자과 재결과의 관계

- ① 토지조서 및 물건조서의 작성에 위와 같은 절차상 하자가 있는 경우에도 이로 인해 이후의 수용재결 등이 무효가 되는 것은 아니다.
- ② 왜냐하면, 조서가 토지수용위원회의 심리상 중요한 판단 자료이긴 하지만 유일한 증거방법이 아니기 때문이며,
- ③ 조서의 기재내용이 토지수용위원회의 사실인정을 구속하는 법률상의 힘이 부여되는 것이 아니기 때문이다.
- ④ <판례>는 절차상 하자 있는 조서는 증명력에 관하여 추정력이 인정되지 않는 것일 뿐, 재결의 효력에 영향을 미치는 것은 아니라고 판시한 바 있다.

대판 1993.9.10. 93누5543

토지수용을 함에 있어 토지소유자 등에게 입회를 요구하지 아니하고 작성한 토지조서는 절차상의 하자를 지니게 되는 것으로서 토지조서로서의 효력이 부인되어 조서의 기재에 대한 증명력에 관하여 추정력이 인정되지 아니하는 것일 뿐,

토지조서의 작성에 하자가 있다 하여 그것이 곧 수용재결이나 그에 대한 이의재결의 효력에 영향을 미치는 것은 아니라 할 것이므로 토지조서에 실제 현황에 관한 기재가 되어 있지 아니하다거나 실측평면도가 첨부되어 있지 아니하다거나 토지소유자의 입회나 서명날인이 없었다든지 하는 사유만으로는 이의재결이 위법하다 하여 그 취소를 구할 사유로 삼을 수 없다.

기업자가 [토지수용법] 제23조 소정의 토지조서 및 물건조서를 작성함에 있어서 토지소유자를 입회시켜서 이에 서명날인을 하게 하지 아니하였다 하더라도 그러한 사유만으로는 그 토지에 대한 수용재결 및 이의재결까지 무효가 된다고 할 수 없고, 기업자가 토지소유자에게 성의있고 진실하게 설명하여 이해할 수 있도록 협의요청을 하지 아니하였다거나, 협의경위서를 작성함에 있어서 토지소유자의 서명날인을 받지 아니하였다는 하자 역시 절차상의 위법으로서 수용재결 및 이의재결에 대한 당연무효의 사유가 된다고 할 수도 없다.

05 내용상 하자 있는 조서의 효력

- ① 조서의 내용상 하자란 물적상태 및 권리관계에 대한 오산*오기 등을 말한다.
- ② 내용상 하자는 조서 자체의 효력에는 영향을 미치지 않고, 열람기간내 이의를 제기하거나, 열람기간이 지나더라도 조서내용이 진실과 다르다는 것을 입증할 때에는 조서의 추정력을 차단할 수 있다.
- ③ 단, 입증책임은 하자를 주장하는 피수용자에게 있다.

06 피수용자의 권리구제방안

1) 행정쟁송

- ① 조서작성행위는 <비권력적 사실행위>이므로 행정쟁송으로 다룰 수 없다.
- ② 조서작성을 위한 타인토지출입 측량·조사행위는 권력적 사실행위이므로 처분성이 인정되어 항고쟁송으로 다룰 수 있으나, 짧은 시간 안에 완성되는 것이므로 **협의 소익**이 없어 각하될 가능성이 높다.
- ③ 다만, 장기간을 요하는 측량·조사행위는 협의의 소익이 인정될 수 있고, <집행정지 신청>이 필요하다.

2) 손실보상

토지보상법 제9조 제5항에서 제7항을 준용한다.

CASE

1. 공익사업을 위한 토지등의 취득 및 보상에 관한 법률상 사업인정 전 협의와 사업인정 후 협의의 차이점에 대하여 설명하시오.(10점) [25회 문4번]
2. 토지보상법상 다음의 법적 성격을 설명하시오.(10점) [36회 문1]
 - ① 사업인정 전과 후의 '보상에 관한 협의'
 - ② 사업인정 후 '협의취득'
3. 「공익사업을 위한 토지등의 취득 및 보상에 관한 법률」제26조는 수용재결 신청 전에 사업시행자로 하여금 수용 대상 토지에 관하여 권리를 취득하거나 소멸시키기 위하여 토지소유자 및 관계인과 교섭하도록 하는 협의제도를 규정하고 있다. 이에 따른 협의가 수용재결 신청 전의 필요적 전치절차인지 여부와 관할 토지수용위원회에 의한 협의성립의 확인의 법적 효과를 설명하시오. (10점) [30회 문4]

01 의의 및 취지

1) 의의

수용재결신청 전에 사업시행자로 하여금 수용대상 토지에 관하여 권리를 취득하거나 소멸시키기 위하여 토지소유자 및 관계인과 교섭하도록 하는 절차이다.

2) 취지

- ① 토지보상법이 사업인정 이전과 이후에 협의절차를 중복적으로 두고 있는 것은 강제적으로 재산권을 취득하기보다 가급적 상대방의 협력을 구하여 사업의 원활을 기하기 위해서이다.
- ② 협의절차의 입법 취지는 피수용자에게 수용의 취지·절차 및 그에 따른 손실보상제도를 설명하고 이해시키며, 가능한 한 공권력 발동에 의하지 않고 원만하게 토지 취득의 목적을 달성하려는데 있다.

02 필수절차인지 여부

- ① 토지보상법 제26조는 제16조를 준용하여, 사업시행자가 피수용자와 성실하게 협의하여야 한다고 규정하면서 (제26조 제1항),
- ② 사업인정 이전에 협의절차를 거쳤으나, 협의가 성립되지 아니하여 사업인정을 받은 사업으로서 토지조서 및 물건조서의 내용에 변동이 없을 때에는 협의절차를 거치지 아니할 수 있다(제26조 제2항)라고 하여, **원칙상 필수절차**이나, 예외적으로 생략할 수 있도록 하였다.
- ③ 다만, 생략가능한 경우라 하더라도 사업시행자나 토지소유자 및 관계인이 협의를 요구할 때에는 협의하여야 한다. (제26조 제2항 단서)

03 법적성질

1) 논의의 실익

- ① 법적성질에 따라 적용법규와 쟁송형태가 달라지므로 논의의 실익이 있다.
- ② 협의성립 확인을 받으면 재결로 간주되므로, 논의의 대상은 협의성립확인을 받지 않은 협의를 말한다.

2) 학설

(1) 사법상 계약설

협의를 결과 성립하는 합의는 사업시행자와 토지소유자 및 관계인 사이에 대등한 관계에서 맺어진 임의적인 합의이므로 사법상 매매계약으로 보는 견해이다.

(2) 공법상 계약설

협의를 사업시행자가 국가적 공권의 주체로서 토지소유자 및 관계인에 대하여 **기득의 수용권**을 실행하는 방법의 하나이므로 공법상 계약으로 보아야 한다는 견해이다.

3) 판례

- ① 대법원은 토지보상법상 협의취득을 사법상의 법률행위로 본다.
- ② 다만, **최근 판례**에서 협의취득의 배후에는 수용에 의한 강제취득 방법이 남아 있어 토지 등의 소유자로서는 협의에 불응하면 바로 수용을 당하게 된다는 심리적 강박감이 자리 잡을 수밖에 없으며 협의취득 과정에는 여러 가지 공법적 규제가 있는 등 **공익적 특성**을 고려하여야 한다고 판시하였다.

대판 2012. 2. 23. 2010다91206

공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법령(이하 ‘공익사업법령’이라고 한다)에 의한 협의취득은 **사법상의 법률행위**이므로 당사자 사이의 자유로운 의사에 따라 채무불이행책임이나 매매대금 과부족금에 대한 지급의무를 약정할 수 있다. (중략)

다만 공익사업법은 공익사업의 효율적인 수행을 통하여 공공복리의 증진과 재산권의 적정한 보호를 도모하는 것을 목적으로 하고 협의취득의 배후에는 수용에 의한 강제취득 방법이 남아 있어 토지 등의 소유자로서는 협의에 불응하면 바로 수용을 당하게 된다는 심리적 강박감이 자리 잡을 수밖에 없으며 협의취득 과정에는 여러 가지 공법적 규제가 있는 등 공익적 특성을 고려하여야 한다.

4) 검토

생각건대,

- ① 협의는 공익사업을 통해 공공복리를 증진하는 것을 목적으로 한다는 점,
- ② 사업인정 후 협의는 사업인정 전 협의와 달리 사업시행자에게 사업인정을 통하여 **수용권이 주어진 상태**에서 이루어지는 협의라는 점,
- ③ 협의에 불응하면 수용재결을 당하게 된다는 심리적 강박감이 있는 **공익적 특성**을 고려하여 공법상 계약으로 보는 것이 타당하다.

04 협의의 성립절차

1) 상대방

- ① 사업시행자는 피수용자 전원을 대상으로 협의하여야 한다.
- ② 협의는 진정한 권리자와 하여야 하며, 협의취득의 대상 물건의 소유권이나 권리가 다수인에게 있을 때에는 상대방 모두가 협의의 상대방이 된다.

2) 협의기간

- ① 사업인정 후 협의는 사업인정 전 협의절차가 준용되므로(제26조 제1항), 특별한 사유가 없는 한 30일 이상으로 하여야 한다.
- ② 사업인정 후 협의는 사업인정고시가 된 날로부터 1년 이내에 하여야 한다.
- ③ 다만, 최근 판례는 수용재결 후 보상금 공탁 전에도 가능하다고 본 판례가 있다(대법원 2017. 4. 13. 선고 2016두64241).

대법원 2017. 4. 13. 선고 2016두64241

공익사업의 효율적인 수행을 통하여 공공복리를 증진시키고, 재산권을 적정하게 보호하려는 토지보상법의 입법목적에 비추어 보면 수용재결이 있는 후라고 하더라도 임의로 계약을 체결할 수 있다.

3) 협의의 내용

- ① 협의사항은 취득할 토지 등의 구체적 대상과 범위, 손실보상의 보상액과 보상시기 및 방법 등을 그 내용으로 한다.
- ③ 협의사항은 재결사항(제50조)과 내용적으로 거의 같다고 할 수 있다.

4) 협의의 절차(령 제8조 제1항)

- ① 사업시행자는 협의를 하려는 경우에는 토지소유자 및 관계인에게 협의기간·협의장소 및 협의방법, 보상의 시기·방법·절차 및 금액, 계약체결에 필요한 구비서류를 통지하여야 한다.
- ② 다만, 토지소유자 및 관계인을 알 수 없거나 그 주소·거소 또는 그 밖에 통지할 장소를 알 수 없을 때에는 공고로써 갈음할 수 있다.

05 협의 성립 및 불성립의 효과

1) 협의 성립의 효과

- ① 사업시행자는 협이가 성립된 때에는 토지소유자 및 관계인과 계약을 체결하여야 한다.(제17조)
- ② 협이가 성립하면 그것으로 취득 또는 사용의 절차는 종결되고, 협의의 내용에 따른 <사법상 계약의 효과>가 발생하며, 이때의 권리취득은 <승계취득>이 된다.
- ③ 따라서 사업시행자는 보상금을 지불하고, 토지소유자 및 관계인은 토지*물건을 인도 또는 이전하게 되며, 사업시행자는 목적물에 대한 권리를 취득하고, 토지소유자 및 관계인은 권리를 상실하게 된다.
- ④ 이 경우 협의에 의한 토지 등의 취득은 [민법] 제186조에 따른 부동산에 관한 법률행위로 인한 물권의 득실변경에 해당하므로 소유권이전등기를 마쳐야 소유권을 취득한다.

2) 협의 불성립의 효과

(1) 재결의 신청

사업시행자는 사업인정고시일로부터 1년 이내에 관할 토지수용위원회에 재결을 신청할 수 있다.(제28조 제1항)

(2) 재결신청의 청구

- ① 사업인정고시가 된 후 협의가 성립되지 아니하였을 때에는, 토지소유자와 관계인은 서면으로 사업시행자에게 재결을 신청할 것을 청구할 수 있다.(제30조 제1항)
- ② 사업시행자는 재결신청청구를 받은 날부터 60일 이내에 관할 토지수용위원회에 재결을 신청하여야 한다.(제30조 제2항)

06 사업인정 후 '협의취득'의 법적성격

- ① 수용재결에 의한 취득은 토지보상법 제45조에 의거 원시취득이지만 협의에 의한 취득은 계약에 의해 소유권이 이전되는 것으로 그 법적성격은 <승계취득>에 해당한다.
- ② 이에 토지보상법은 협의성립확인 제도(제29조)를 두어 사업인정 후 협의성립시 관할 토지수용위원회의 협의성립 확인을 받으면 수용재결과 같은 효력을 부여(원시취득)함으로써 계약 불이행에 따른 분쟁 예방, 공익사업의 원활한 진행이 가능하도록 하고 있다.

07 관련 문제

1) 협의절차하자와 재결의 관계

- ① 토지보상법은 협의전치주의를 취하여 사업시행자가 재결신청 전에 협의불능의 경우를 제외하고 반드시 협의를 거치도록 하고 있다.
- ② 따라서 사업시행자가 협의절차를 거치지 않고 재결을 신청하였다면 이는 위법한 재결신청이 된다.
- ③ 이 경우 협의절차를 거치지 않은 재결의 효력이 문제되는데, 이에 대하여는 중대한 법규위반이므로
 - (a) 당연무효라는 입장,
 - (b) 절차상 하자로서 취소사유라는 입장,
 - (c) 그런 경우는 사실상 존재하지 않기 때문에 논의의 실익이 없다는 입장등이 있다.
- ④ 이에 대해 판례는 기업자가 토지소유자와 협의를 거치지 아니한 채 토지의 수용을 위한 재결을 신청하였다는 등의 하자는 절차상의 위법으로서 이의 재결의 취소를 구할 수 있는 사유가 될지언정 당연무효의 사유라고 볼 수 없다고 판시하였다.(대판 1993.8.13. 93누2148)

2) 위험부담의 문제

- ① 민법상 위험부담은 채무자가 지게 되어 있다.
- ② 그러나 토지보상법 제46조는 재결이 있은 후 피수용자의 고의나 과실 없이 목적물이 멸실되거나 훼손된 경우 위험부담을 사업시행자에게 지우고 있어, 협의 후 목적물 멸실 등 경우에도 적용할 수 있는지 문제된다.

- ③ 대법원은 댐건설로 인한 수몰지역 내 토지를 매수하고 지상입목에 대하여 적절한 보상을 하기로 특약하였다면 보상금이 지급되기 전에 그 입목이 홍수로 멸실되었다 하더라도 매수 또는 보상하기로 한 자는 이행불능을 이유로 위 보상약정을 해제할 수 없다(대판 1977. 12. 27. 76다1472)라고 판시하였다.
- ④ 생각건대, 위험부담이전 규정 취지는 **피수용자 권리보호**를 위한 것이므로, 협의 후 귀책사유 없이 목적물이 멸실된 경우에도 **적용**될 수 있다고 보아야 할 것이다.

3) 사업시행자의 손실보상의무 불이행시 재결실효규정 적용여부

- ① 토지보상법상 재결실효규정(제42조, 보상금미지급시 재결실효)을 유추 적용하여 협의의 실효를 주장할 수 있는지가 문제되나, 협의 성립 시 이를 재결과 달리 취급할 이유가 없으므로 재결실효규정 적용을 긍정하는 견해가 있다.
- ② 그러나 토지보상법 명문 규정상 협의의 실효에 관한 **규정이 없으므로** 적용하기 어렵다고 봄이 타당하다.
- ③ 판례에 의하면 민사소송으로, 다수설에 의하면 공법상 당사자소송으로 해결이 가능할 것이다.

08 사업인정 전·후 협의의 비교

1) 임의적 절차인지 필수적 절차인지 여부

- ① 사업인정 전 협의는 임의적 절차이나, 사업인정 후 협의는 필수적 절차이다.
- ② 토지보상법은 사업인정 전 협의는 사업시행자의 성신�협의의무만을 규정하고 있지만, 사업인정 후 협의는 반드시 거칠 것을 의무로 규정하고 있다.
- ③ 단지 절차의 중복을 피하기 위하여 사업인정 후 협의를 일정한 경우 하지 않을 수 있는 규정을 두고 있다.

2) 사업인정을 기준으로 한 전·후의 절차

사업인정 전 협의는 아직 공익사업이 공적으로 승인되기 전에 **임의적 협력**을 바탕으로 이루어지는 반면, 사업인정 후 협의는 사업의 공공성이 인정되고 재결에 의한 **강제절차**에 들어가기 전에 상대방의 협력을 구하기 위한 제도이다.

3) 협의성립의 확인 가부

사업인정 전 협의에서는 관할 토지수용위원회로부터 **협의성립 확인**을 받을 수 없으나, 사업인정 후 협의에서는 받을 수 있다.

4) 법적 성질의 차이

- ① 학설 중 다수설은 사업인정 전 협의는 <사법상 계약>으로 보고, 사업인정 후 협의는 <공법상 계약>으로 본다.
- ② 다만, 판례는 양자 모두 <사법상 계약>의 성질을 가지는 것으로 본다.

〈사업인정 전·후 협의 비교〉

구분	사업인정 전 협의	사업인정 후 협의
공통점	최소침해원칙, 협의내용(법50조)	
필수적 전치절차 여부	임의절차 성신�협의의무만 있음	예외적 경우 제외하고 반드시 거쳐야 하는 필수절차
법적성질	사법상 계약(판례) & 사법상 계약(다수설)	사법상 계약(판례) & 공법상 계약(다수설)
확인제도 유무	없음	있음
협의성립시 효과	승계취득	- 협의성립확인 받기 전 승계취득, - 확인 후 재결간주 원시취득
협의 불성립시 효과	사업인정 신청	- 사업시행자 재결신청 - 피수용자 재결신청청구
권리구제	민사소송	- 판례 민사소송 - 다수설 공법상 당사자소송
양자의 관계	① 절차상 선후관계 ② 사업인정 전 협의 불성립하고 조서내용불변이면 당사자 협의 요구 없을 시 사업인정 후 협의 생략가능	

CASE

「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제26조는 수용 재결 신청 전에 사업시행자로 하여금 수용대상 토지에 관하여 권리를 취득하거나 소멸시키기 위하여 토지소유자 및 관계인과 교섭하도록 하는 협의제도를 규정하고 있다. 이에 따른 협의가 수용재결 신청 전의 필요적 전치절차인지 여부와 관할 토지수용위원회에 의한 협의성립의 확인의 법적 효과를 설명하시오.(10점) [30회 4번]

01 의의 및 취지 (토지보상법 제29조)

- ① 사업인정 후 협의가 성립하면 사업시행자가 피수용자의 동의를 받거나 또는 공증을 받아 관할 토지수용위원회의 확인을 받는 제도이다.
- ② 계약 불이행에 따른 분쟁 예방, 공익사업의 원활한 진행에 규정취지가 있다.

02 법적성질

- ① 협의성립의 확인은 의문 또는 다툼이 없는 특정한 사실 또는 법률관계의 존부를 공적 권위로서 증명하는 <공증>이라고 보는 견해가 있으나
- ② 이는 특정한 사실관계 또는 법률관계에 대해 의문이 있는 경우 공권적으로 그 존부 또는 정부를 판단하는 행위이므로 기존의 사실 또는 법률관계를 유권적으로 확정하는 행위인 행정행위의 <확인행위>로 봄이 일반적이다.
- ③ 협의성립확인을 받으면 토지보상법 규정에 의하여 <재결>로 간주되는 형성적 효과가 발생한다.

03 확인의 절차

1) 일반적 확인절차(제29조 제1항)

- ① 협의가 성립되었을 때 사업시행자는 재결신청기간 내에 피수용자의 동의를 얻어 관할 토지수용위원회에 협의성립의 확인을 신청할 수 있다.(제29조 제1항)
- ② 관할 토지수용위원회의 확인절차는 재결절차를 준용한다.
- ③ 따라서 토지수용위원회는 협의성립확인신청서를 접수한 때에는 대통령령이 정하는 바에 따라 지체없이 이를 공고하고 공고한 날로부터 14일 이상 관계서류의 사본을 일반이 열람할 수 있도록 하여야 한다.(제31조 제1항)
- ④ 토지수용위원회가 제1항의 규정에 의한 공고를 한 때에는 관계서류의 열람기간 중에 토지소유자 또는 관계인은 의견을 제시할 수 있다.(제31조 제2항)
- ⑤ 토지수용위원회는 열람기간이 지났을 때에는 지체 없이 해당 신청에 대한 조사 및 심리를 하여야 하고(제32조), 14일 이내에 확인(제35조)하여야 한다.

2) 공증에 의한 확인절차(제29조 제3항)

- ① 사업시행자가 협의가 성립된 토지의 소재지·지번·지목 및 면적 등 대통령령으로 정하는 사항에 대하여 「공증인법」에 따른 공증을 받아 제1항에 따른 협의 성립의 확인을 신청하였을 때에는, 관할 토지수용위원회가 이를 **수리함**으로써 협의성립이 확인된 것으로 본다.(제29조 제3항)
- ② 여기서 <수리>는 타인의 행위를 유효한 것으로 수령하는 인식표시인 점에서 사실행위와 다르며, 수리가 있으면 협의성립확인 효과 발생한다.
- ③ 이러한 공증에 의한 확인방법은 **열람, 심리 등의 절차를 필요로 하지 않기 때문에** 협의성립의 확인을 **조속히** 하고자 하는 경우에 활용된다.
- ④ 토지보상법 제29조 제3항에 따른 협의성립의 확인신청에 필요한 동意的 주체인 토지소유자는 협의 대상이 되는 <토지의 진정한 소유자>를 의미한다.

대법원 2018. 12. 13. 선고 2016두51719

간이한 절차만을 거치는 협의 성립의 확인에, 원시취득의 강력한 효력을 부여함과 동시에 사법상 매매계약과 달리 협의 당사자들이 사후적으로 그 성립과 내용을 다툴 수 없게 한 법적 정당성의 원천은 사업시행자와 토지소유자 등이 진정한 합의를 하였다는 데에 있다. 여기에 공증에 의한 협의 성립 확인 제도의 체계와 입법 취지, 그 요건 및 효과까지 보태어 보면, 토지보상법 제29조 제3항에 따른 협의 성립의 확인 신청에 필요한 동意的 주체인 토지소유자는 협의 대상이 되는 '토지의 진정한 소유자'를 의미한다.

04 확인의 효과

- ① 협의성립에 대한 확인이 있게 되면 재결로 간주되어, 재결과 동일한 효과가 발생한다.
- ② 즉, 사업시행자는 보상금의 지급 또는 공탁을 조건으로 수용목적물을 원시취득하고 피수용자의 의무불이행시 대항·대집행을 신청할 수 있으며 위험부담이 이전된다.
- ③ 피수용자에게는 목적물의 인도·이전의무와 손실보상청구권, 환매권이 발생하게 된다.
- ④ 또한, 협의성립확인이 있으면 사업시행자, 토지소유자 및 관계인은 그 확인된 협의의 성립이나 내용에 대하여 다툴 수 없는 확정력이 발생한다.(제29조 제4항)
- ⑤ 협의성립확인을 받은 후에도 협의에서 정한 보상일까지 보상금을 지급하지 않으면 **재결의 실효규정**(제42조)이 적용되어서 확인행위의 효력은 상실된다고 보아야 할 것이다.

대법원 2018. 12. 13. 선고 2016두51719 [협의성립확인신청수리처분취소]

1. 협의성립확인의 효과

토지보상법상 수용은 원시취득이다. 반면 토지보상법상 협의 취득은 승계취득이다. 협의성립확인 신청이 수리됨으로써 협의성립의 확인이 있었던 것으로 간주되면 재결이 있었던 것으로 재차 의제되고 원시취득하는 효과를 누리게 된다.

2. 협의성립확인의 법적 정당성 : 사업시행자와 토지소유자 등의 진정한 합의

협의성립의 확인의 법적 정당성의 원천은 사업시행자와 토지소유자 등이 진정한 합의를 하였다는 데에 있다. 토지보상법 제29조 제3항에 따른 토지소유자는 협의의 대상이 되는 토지의 진정한 소유자를 의미한다.

3. 진정한 소유자가 아닌 경우: 협의성립의 확인의 위법성 인정됨

따라서 사업시행자가 단순히 등기부상 소유명의자의 동의만을 얻은 후 협의성립의 확인을 신청하였음에도 토지수용위원회가 신청을 수리하였다면 소유자의 동의요건을 갖추지 못한 것으로서 위법하다.

사업시행자의 과실이 있었는지 여부와 무관하게 그 동의의 흠결은 위법사유가 된다.

이에 따라 진정한 토지소유자는 수리 행위가 위법함을 주장하여 항고소송으로 취소를 구할 수 있다.

05 불복

1) 확인에 대한 불복

확인 은 재결로 간주되므로, 처분에 해당하여 이에 불복하는 자는 중앙토지수용위원회에 이의신청(제83조)을 할 수 있고, 행정소송(제85조)으로 다룰 수 있다.

2) 협의 자체에 대한 불복

적법·유효한 확인이 있는 경우 협의에 확정력이 인정되어 다룰 수 없다. 따라서 확인의 효력을 행정쟁송으로 없앤 후, 협의에 대하여 다룰 수 있다.

〈협의성립확인 전과 후의 비교〉

구분		협의성립확인 전	협의성립확인 후
공통점		효과 동일(손실보상&환매권&위험부담의 이전&담보물권자의 물상대위)	
차 이 점	목적물취득의 법적성질	승계취득	원시취득
	물권변동의 형태	법률행위에 의한 물권변동(등기필요)	법률규정에 의한 물권변동(등기불요)
	착오의 경우 권리구제	민법규정 유추적용	확정력이 발생하여 못 다룸
양자의 관계		당사자 간의 계약을 공법상의 처분으로 전환시키는 관계	

제1장

재결신청청구권

CASE

협의 과정에서 일부 지장물에 관하여 협의가 이루어지지 않아 토지소유자 甲이 A공사에게 재결신청을 청구했으나 A공사가 재결신청을 하지 않는 경우, 甲의 불복 방법에 관하여 검토하시오. [32회 문1번]

01 의미, 취지(토지보상법 제30조)

- ① 사업인정 후 협의가 성립하지 아니한 때 피수용자가 사업시행자에게 조속히 재결신청을 할 것을 청구할 수 있는 권리를 말한다.
- ② 토지소유자 및 관계인은 재결신청권을 갖지 않으므로, 수용을 둘러싼 법률관계의 조속한 확정을 바라는 토지소유자 및 관계인의 이익을 보호하고, 수용 당사자 간의 공평을 기하기 위함에 있다(대판 1997. 10. 24. 97다31171).

02 법적성질

재결신청청구권은, 재결 보상금에 부수하여 (구)공익사업법상 인정되는 공법상 청구권의 성질을 지닌다. 판례도 같다(대법원 2010두9457).

03 요건

1) 당사자

재결신청 청구권자는 피수용자로서, 사업시행자에게 청구한다.

2) 청구기간

(1) 원칙

원칙적으로는 협의를 성실하게 하였으나 협의기간 내에 협의가 성립하지 않은 경우, 사업인정고시가 있는 날로부터 1년 이내에 재결신청청구를 하는 것이 원칙이다.

(2) 예외

- ① 판례는 협의기간이 도과하지 않았더라도 협의불성립이 명백한 경우에는 굳이 협의기간이 끝날 때까지 기다리게 하여야 할 필요성은 없는 것이므로 협의기간 만료 전이라도 재결신청의 청구를 할 수 있다고 한다.(대판 1993. 7. 13. 93누2902).
- ② 사업시행자가 사업인정 후 상당 기간 경과하도록 협의에 대한 통지를 토지 등의 소유자 등에게 하지 아니하였다면 토지 등의 소유자 등은 사업시행자에게 조속한 재결신청의 청구를 할 수 있다 (「손실보상 및 수용업무처리규정」 제44조 제2항).

수용에 관한 협의기간이 정하여져 있더라도 협의의 성립가능성 없음이 명백해졌을 때와 같은 경우에는 굳이 협의기간이 종료될 때까지 기다리게 하여야 할 필요성도 없는 것이므로 협의기간 종료 전이라도 기업자나 그 업무대행자에 대하여 재결신청의 청구를 할 수 있는 것으로 보아야 하며, 다만 그와 같은 경우 토지수용법 제25조의3 제2항에 의한 2월의 기간은 협의기간 만료일로부터 기산하여야 한다.

(3) 협의가 성립하지 아니한 때의 의미에 대한 판례

- ① 토지보상법 제30조 제1항은 재결신청을 청구할 수 있는 경우를 ‘협의가 성립하지 아니한 때’로 정하고 있을 뿐 그 사유를 제한하고 있지 않은 점, 위 조항이 토지소유자 등에게 재결신청청구권을 부여한 취지는 손실보상에 관한 법률관계를 조속히 확정함으로써 공익사업을 효율적으로 수행하고 토지소유자 등의 재산권을 적정하게 보호하기 위한 것인데, 손실보상대상에 관한 이견으로 손실보상협의를 성립하지 아니한 경우에도 재결을 통해 손실보상에 관한 법률관계를 조속히 확정할 필요가 있는 점 등에 비추어 볼 때,
- ② ‘협의가 성립되지 아니한 때’에는
 - (a) 사업시행자가 토지소유자 등과 토지보상법 제26조에서 정한 협의절차를 거쳤으나 보상액 등에 관하여 협의가 성립하지 아니한 경우는 물론
 - (b) 토지소유자 등이 손실보상대상에 해당한다고 주장하며 보상을 요구하는데도 사업시행자가 손실보상 대상에 해당하지 아니한다며 보상대상에서 이를 제외한 채 협의를 하지 않아 결국 협의가 성립하지 않은 경우도 포함된다고 보아야 한다.

3) 청구의 내용 및 형식

내용은 사업시행자에게 재결신청을 청구하는 것이다. 형식은 일정한 사항을 기재한 재결신청청구서를 사업시행자에게 제출하면 된다(령 제14조).

04 청구의 효과

- ① 사업시행자는 청구를 받았을 때에는 청구를 받은 날부터 60일 이내에 관할 토지수용위원회에 재결을 신청하여야 한다(제30조 제2항).
- ② 이 기간을 넘겨서 재결을 신청하였을 때에는 그 지연된 기간에 대하여 「소송촉진 등에 관한 특례법」 제3조에 의한 법정이율을 적용하여 산정한 금액을 재결한 보상금에 가산하여 지급하여야 한다(제30조 제3항).

05 권리구제

1) 사업시행자가 재결신청청구를 거부 또는 부작위하는 경우

(1) 민사소송 또는 공법상 당사자소송

- ① 판례는 가산금제도로 재결신청을 강제하고 있고, 사업인정의 효력 상실 규정제도 등을 이유로 민사소송 등의 방법으로는 그 이행을 청구할 수 없다고 하였다.
- ② 또한 재결신청의 거부는 거부처분에 해당하므로 공법상 당사자소송도 인정되기 어렵다.

(2) 항고소송 인정여부

a. 문제점

재결신청청구는 사인의 공법행위로서 사실행위이므로, 이에 대한 거부 또는 부작위가 항고소송의 대상적격이 있는가가 문제된다.

b. 재결신청청구 거부의 대상적격 인정여부

(가) 거부가 처분이 되기 위한 판례 요건

거부가 처분이 되려면, 법규상·조리상 신청권의 존재, 공권력행사의 거부일 것, 국민의 권리·의무에 직접 영향을 미칠 것이 요구된다.

(나) 재결신청청구 거부가 공권력행사 거부인지

재결신청의 거부는 토지소유자등의 손실보상에 직접적으로 영향을 주는 점, 재결신청은 사업시행자에 게만 독점적으로 인정되므로 적어도 토지소유자등에 대해서는 우월적 지위에서 하는 권력작용으로 봄이 타당한 점, 토지보상법이 토지소유자등의 재결신청청구에 따라 사업시행자에게 재결을 신청할 의무를 규정하는 점 등을 고려할 때 처분으로 봄이 타당하다.(서울고등법원 2018. 8. 28. 선고 2018누49293 판결)

(다) 판례의 태도

판례는 “토지소유자의 재결신청 청구에도 사업시행자가 재결신청을 하지 않을 때 토지소유자는 사업시행자를 상대로 거부처분 취소소송 또는 부작위 위법확인소송의 방법으로 다투어야 한다고 판시하였다. (대법원 2019.8.29. 선고2018두57865 판결)

(라) 검토

재결신청청구 거부 시 피수용자는 수용재결을 통한 권리의무에 직접 영향이 있다. 재결신청청구 거부는 상기 검토와 같이 공권력행사라 판단되는 바, 이 거부는 처분으로서 취소소송의 대상적격이 인정된다.

c. 소결

재결신청청구 거부가 항고소송의 대상적격이 인정되는 한, 기타 항고소송의 소송요건을 갖추고, 재결신청청구 거부가 위법한 경우 항고소송으로 권리구제를 받을 수 있다. 부작위의 경우 또한 같다.

2) 지연가산금에 대한 다툼

- ① 판례는, 지연가산금은 수용보상금에 대한 법정 지연손해금의 성격을 갖는 것이므로 이에 대한 불복은 수용보상금에 대한 불복절차에 의함이 상당할 뿐 아니라, 가산하여 지급할 금액은 관할 토지수용위원회가 재결서에 기재하여야 하며, 기업자는 수용 시기까지 보상금과 함께 이를 지급하여야 한다고 하여 지연가산금은 수용보상금과 함께 수용재결로 정하도록 규정하고 있으므로, 지연가산금에 대한 불복은 수용보상금의 증액에 관한 소에 의하여야 한다고 판시하였다.
- ② 토지보상법 제83조의 이의신청으로 지연가산금에 대한 다툼이 가능하다.

06 관련 문제

사업시행자가 재결신청청구를 받고도 재결신청을 하지 않을 경우 단지 지연된 기간에 대하여 가산금 규정만을 둔 것은, 조속히 수용관계를 해결하고자 하는 피수용자의 권리보호에 미흡한 제도라 할 것이다. 따라서 피수용자의 재결신청 청구권의 효력이 직접 재결신청을 한 것과 같은 효력이 부여될 정도로 강화될 필요가 있다.

01 의미 및 근거

재결신청은 협의 불성립 시 사업시행자가 토지수용위원회에게 수용 또는 사용의 재결을 구하는 절차 행위이다. 토지보상법 제28조에 근거를 둔다.

02 요건

- ① <재결신청권자> 재결신청권자는 오직 사업시행자 뿐이다.
- ② 재결신청은 협의 불성립 시 관할 토지수용위원회에 하며, 토지보상법상 사업인정고시일로부터 1년 이내에 할 수 있다.
- ③ 다른 개별법에서 재결신청기간이 특별히 규정되어 있다면 그 기간을 따르면 된다.

03 재결신청 기각시

사업시행자의 재결신청을 기각하는 재결이 확정되었다 하더라도 재결신청기간의 제한규정에 저촉되지 않는 한 재결신청을 할 수 있고, 토지수용위원회는 이에 근거하여 다시 수용재결을 할 수 있다.

04 사업시행자에게만 재결신청권을 인정하는 이유와 타당성

- ① 토지보상법 구조상 피수용자에게 재결신청권을 인정할 수 없고,
- ② 피수용자에게 재결신청권 부여 시 공익사업 계획에 지장이 생길 우려가 있으며,
- ③ 목적물 취득권과 보상의무는 사업시행자에게 있는 점,
- ④ 형평차원에서 피수용자에게 재결신청청구권(토지보상법 제30조)이 인정되는 점 등을 고려할 때, 사업시행자에게만 재결신청권을 인정함이 타당하다.

구 분	재결신청의 청구	재결신청
법적근거	30조	28조
당사자	피수용자가 사업시행자에게	사업시행자가 관할 토지수용위원회에
의미	재결신청을 조속히 해 달라	재결 결정을 내려 달라
비고	신청지연시 지연가산금 발생 가능	사업인정고시일 1년 내 하지 않으면 사업인정 실효

01 의의 및 취지

- ① 사업인정고시 후 협의불성립·불능의 경우 사업시행자의 재결신청에 의해 관할 토지수용위원회가 행하는 수용 또는 수용결정의 최종적 판단절차이다(제34조, 제50조).
- ② 강제적 권력행사를 통해 공익을 실현하고, 엄격한 절차와 형식을 통해 공익과 사익을 조절하기 위한 제도로서 취지가 있다.

02 법적 성질

1) 형성적 행정행위

- ① 재결은 일정한 법적 효과를 가져오는 <처분으로서 행정행위>의 성질을 가진다.
- ② 수용재결은 행정심판의 재결과는 구별되며 원행정행위에 속한다.
- ③ 재결은 행정행위이지만 준사법적인 절차에 의해 행해지는 <준사법적인 행정행위>이다.
따라서 재결에는 불가변력이 인정된다.

대법원 1993. 1. 19. 선고 91누8050 전원합의체

토지수용에 관한 중앙 또는 지방토지수용위원회의 수용재결이 그 성질에 있어 구체적으로 일정한 법률효과의 발생을 목적으로 하는 점에서 일반의 행정처분과 전혀 다를 바 없으므로 수용재결처분이 무효인 경우에는 그 재결 자체에 대한 무효확인을 소구할 수 있다.

2) 기속행위·재량행위 여부

(1) 수용목적물의 범위

- ① 수용목적물의 필요성은 사업인정단계에서 판단되므로, 재결단계에서는 사업시행자가 법령상 요건을 모두 구비하고 토지수용위원회에 재결신청을 하였다면, 토지수용위원회는 그에 따른 재결을 하여야 한다고 본다.
- ② 따라서 수용목적물의 범위와 관련하여서는 <기속행위의 성질>을 갖는다고 볼 것이다.

대법원 1994. 11. 11. 선고 93누19375

토지수용법은 수용·사용의 일차 단계인 사업인정에 속하는 부분은 사업의 공익성 판단으로 사업인정기관에 일임하고, 그 이후의 구체적인 수용·사용의 결정은 토지수용위원회에 맡기고 있는바, 이와 같은 토지수용절차의 2분화 및 사업인정의 성격과 토지수용위원회의 재결사항을 열거하고 있는 같은 법 제29조 제2항의 규정 내용에 비추어 볼 때, 토지수용위원회는 행정쟁송에 의하여 사업인정이 취소되지 않는 한 그 기능상 사업인정 자체를 무의미하게 하는, 즉 사업의 시행이 불가능하게 되는 것과 같은 재결을 행할 수는 없다.

(2) 손실보상금의 결정

- 토지보상법 제50조 제2항에서 손실보상의 경우에는 증액재결을 할 수 있다고 규정하고 있다.
따라서 보상금액의 결정에 대해서는 <재량행위의 성질>을 갖는다고 볼 것이다.

3) 공법상 대리

토지수용위원회가 독립적 판단작용을 하므로, 준사법작용과 유사한 당사자심판의 성격, 시심적 쟁송의 성질을 갖고, 수용권자와 피수용권자를 대신하여 수용재결의 사항을 판단하므로 공법상 대리의 성격도 갖고 있다.

03 재결의 성립

1) 재결의 주체

- ① 재결은 국민의 재산권을 강제적으로 수용하게 하는 결정을 내리게 되므로, 엄격한 형식과 절차가 요구되고, 이를 관장하는 재결기관의 독립성·중립성 및 전문성이 요구된다.
- ② 따라서 재결기관은 토지수용위원회로 하고 있다.
- ③ 재결기관으로서 토지수용위원회는 국토교통부에 중앙토지수용위원회를 두고, 특별시·광역시·도·특별자치도(이하 “시·도”라 한다)에 지방토지수용위원회를 둔다(제49조). 토지수용위원회는 독립된 합의제 행정청이다.

2) 재결의 내용과 범위

(1) 재결의 내용

- ① 토지수용위원회는 수용하거나 사용할 토지의 구역 및 사용방법,
- ② 손실보상,
- ③ 수용 또는 사용의 개시일과 기간,
- ④ 그 밖에 이 법 및 다른 법률에서 규정한 사항을 재결한다(제50조 제1항).

(2) 재결의 범위

- ① 토지수용위원회는 사업시행자, 토지소유자 또는 관계인이 신청한 범위에서 재결하여야 한다.
다만 손실보상의 경우에는 증액재결을 할 수 있다(토지보상법 제50조 제2항).
- ② <불고불리의 원칙>이 적용되어 신청 또는 주장이 없는 사항에 대하여 재결할 수 없다.

수원지방법원 2017가합15105

토지보상법 제50조 제2항은 토지수용위원회로 하여금 사업시행자, 토지소유자 또는 관계인이 신청한 범위 내에서 재결하도록 하는 처분권주의를 규정하면서, 다만 손실보상의 경우에 있어서는 증액재결을 할 수 있는 것으로 하여 그 예외를 정한 것으로 봄이 상당하고, 원고가 주장하는 바와 같이 위 조항이 토지수용위원회로 하여금 사업시행자가 제시한 협의보상금액보다 증액된 금액으로만 재결하는 것이 가능하도록 규정한 것으로 해석되지는 않는다.

3) 재결 형식

토지수용위원회의 재결은 서면으로 한다(제34조 제1항).

4) 재결의 절차

- ① 사업시행자는 재결신청서를 작성하여 관할 토지수용위원회에 제출하여야 한다(제28조, 령 제12조 제1항).
- ② 토지수용위원회는 재결신청서를 접수하였을 때에는 지체 없이 이를 공고하고, 공고한 날부터 14일 이상 관계 서류의 사본을 일반인이 열람할 수 있도록 하여야 한다(제31조 제1항).
- ③ 토지수용위원회가 공고를 하였을 때에는 관계 서류의 열람기간 중에 토지소유자 또는 관계인은 의견을 제시할 수 있다(제31조 제2항).
- ④ 이를 위해 시장·군수 또는 구청장은 공고를 한 경우에는 그 공고의 내용과 의견이 있으면 의견서를 제출할 수 있다는 뜻을 토지소유자 및 관계인에게 통지하여야 한다(령 제15조 제3항).
- ⑤ 토지수용위원회는 열람기간이 지났을 때에는 지체 없이 해당 신청에 대한 조사 및 심리를 하여야 한다(제32조 제1항). 토지수용위원회는 심리를 할 때 필요하다고 인정하면 사업시행자, 토지소유자 및 관계인을 출석시켜 그 의견을 진술하게 할 수 있다(제32조 제2항).
- ⑥ 토지수용위원회는 심리를 시작한 날부터 14일 이내에 재결을 하여야 한다.
- ⑦ 심리는 서면주의, 비공개주의, 직권주의에 의하여 행한다. 다만, 특별한 사유가 있을 때에는 14일의 범위에서 한 차례만 연장할 수 있다(제35조). 재결심리 기간을 규정한 것은 재결을 조속히 하여 법적안정성을 기함에 그 취지가 있다.

5) 재결의 결함

(1) 재결의 경정 (토지보상법 제36조)

- ① 재결에 계산상 또는 기재상의 잘못이나 그 밖에 이와 비슷한 잘못이 있는 것이 명백할 때에는 토지수용위원회는 직권으로 또는 당사자의 신청에 의하여 경정재결을 할 수 있다(제36조 제1항).
- ② 원칙적으로 재결은 형성적 행정행위로 행정쟁송에 의해 취소 또는 변경되지 않는 한 토지수용위원회도 임의로 당해 재결을 취소 또는 변경할 수 없다.
- ③ 그러나 재결의 오류가 명백한 경우까지 행정쟁송에 의하도록 하는 것은 비합리적이므로, 간편하게 정정할 수 있는 방안이 필요하며, 토지보상법은 이를 경정재결로 제도화하고 있다.

(2) 재결의 유탈 (토지보상법 제37조)

- ① 토지수용위원회가 신청의 일부에 대한 재결을 빠뜨린 경우에 그 빠뜨린 부분의 신청은 그 토지수용위원회에 계속된다.
- ② 즉, 사업시행자가 재결신청한 사항 또는 토지소유자나 관계인이 제출한 의견은 토지수용위원회가 기각재결하거나 인용재결해야 하고, 그 중 일부에 대하여 토지수용위원회가 재결하지 않은 경우에는 그 부분은 계속하여 해당 토지수용위원회에 계속된다.
- ③ 따라서 재결에서 유탈된 부분은 이의재결이나 행정소송의 대상이 되지 않는다.

6) 재결의 효과

(1) 목적물의 권리취득

- ① 재결의 효과로서 일정한 조건하에 사업시행자의 권리취득의 효과가 발생한다.
- ② 사업시행자는 수용의 개시일에 토지나 물건의 소유권을 취득하며, 그 토지나 물건에 관한 다른 권리는 이와 동시에 소멸한다(제45조 제1항).
- ③ 수용에 의한 사업시행자의 권리취득은 토지소유자와 사업시행자 사이의 법률행위에 의한 승계취득이 아니라, 법률의 규정에 의한 <원시취득>이다.

(2) 위험부담의 이전

- ① 토지수용위원회의 재결이 있은 후 수용하거나 사용할 토지나 물건이 토지소유자 또는 관계인의 고의나 과실 없이 멸실되거나 훼손된 경우 그로 인한 손실은 사업시행자의 부담으로 한다(제46조).
- ② 수용목적물에 대한 권리의 소멸과 그에 대한 보상금이 약정되어 있는 상황에서, 토지물건의 소유자 및 관계인에게 수용목적물의 보전책임을 지우는 것은 피수용자의 권익보호측면에서 바람직하다고 볼 수 없다.
- ③ 따라서 토지보상법에서는 사업시행자에게 위험부담을 전가시킴으로써, 피수용자의 권익을 보호하고 있다.

(3) 손실보상청구권

- ① 토지보상법상 명문의 규정은 없지만 재결의 효과로서 피수용자인 토지소유자 및 관계인은 손실보상청구권을 취득한다.
- ② 사업시행자는 천재·지변시의 토지의 사용 또는 시급을 요하는 토지의 사용의 경우를 제외하고는 수용 또는 사용의 시작일까지 관할 토지수용위원회가 재결한 보상금을 지급하여야 한다.
- ③ 그러나, 사업시행자는 토지보상법 제40조의 일정한 요건에 해당할 때에는 수용 또는 사용의 개시일까지 수용 또는 사용하려는 토지등의 소재지의 공탁소에 보상금을 공탁할 수 있다.

01 의의 및 취지

유효하게 성립한 재결효력이 객관적 사실의 발생에 따라 사후적으로 상실되는 것을 말한다.

02 내용**1) 보상금을 지급 또는 공탁하지 않은 경우 (토지보상법 제42조)**

- ① 사업시행자가 수용 또는 사용의 개시일까지 관할토지수용위원회가 재결한 보상금을 지급하거나 공탁하지 아니하였을 때 당해 재결은 효력을 상실한다.
- ② 사업시행자가 당해 공익사업을 위한 공사에 착수하기 이전에 토지소유자 및 관계인에 대하여 보상액의 전액을 지급하여야 한다는 <사전보상원칙>을 이행하기 위함이다.

2) 사업인정이 취소되는 경우

수용재결에 따른 수용개시일 전에, 사업인정이 취소 또는 변경되면, 그 고시의 결과에 따라서 당해 재결의 효력은 소멸된다. 수용개시일이 지난 이후에는 수용의 효과가 발생하므로 환매권이 문제될 것이다.

대법원 2015. 3. 20. 선고 2011두3746

실시계획의 인가 요건을 갖추지 못한 인가처분(사업인정)은 공공성을 가지는 도시계획시설사업의 시행을 위하여 필요한 수용 등의 특별한 권한을 부여하는 데 정당성을 갖추지 못한 것으로서 법규의 중요한 부분을 위반한 중대한 하자(무효)가 있다고 할 것이다. (중략)

원심이 같은 취지에서 이 사건 인가처분은 그 하자가 중대·명백하여 당연무효이고, 당연무효인 이 사건 인가처분에 기초한 이 사건 수용재결도 무효라고 판단한 것은 정당하다.

03 효과 (손실보상의무 발생)**1) 사업시행자의 손실보상**

[토지보상법] 제42조 제2항에 따라 사업시행자는 재결의 효력이 상실됨으로 인하여 토지소유자 또는 관계인이 입은 손실을 보상해야 한다.

2) 손실보상의 절차 및 방법

[토지보상법] 제42조 제3항에 따라 재결의 실효에 따른 손실보상에 관하여는 제9조 제5항부터 제7항까지의 규정을 준용한다.

04 관련 문제

1) 재결실효와 재결신청효력의 관계

(1) 문제점

재결의 효력이 상실된 경우 재결신청의 효력이 어떻게 되느냐에 대하여 견해가 나뉘어져 있다.

(2) 견해 대립

- ① 재결신청의 효력이 유효하다는 견해는 보상금을 지급하거나 공탁하지 않으면 토지보상법 제42조 규정에서 재결의 효력만을 상실시킬 뿐 재결신청의 효력까지를 상실시키는 것은 아니므로 유효하다고 한다.
- ② 그러나 재결과 그 기초가 되는 재결신청은 운명을 같이 하여야 하므로, 보상금을 지급하거나 공탁하지 않아 재결의 효력이 상실되면 그 효력이 상실되어야 한다는 견해가 있다.

(3) 판례

기업자가 그 재결된 보상금을 그 수용시기까지 지급 또는 공탁하지 않은 이상 위 수용위원회의 재결은 물론 재결의 전제가 되는 재결신청도 아울러 그 효력을 상실하는 것이라고 해석함이 상당하고, 그로 인하여 사업인정의 고시가 있는 날로부터 1년 이내에 재결신청을 하지 않는 것으로 되었다면 사업인정도 역시 효력을 상실한다고 판시하였다(대판 1987. 3. 10. 84누158).

(4) 검토

[토지보상법] 제42조 제1항의 취지는 사업시행자의 보상금 지급을 강제하여 토지소유자 또는 관계인의 재산권 보장을 도모하기 위한 것이므로, 사업시행자가 수용 또는 사용의 개시일까지 관할 토지수용위원회가 재결한 보상금을 지급하거나 공탁하지 않아 재결의 효력이 상실되면 그 재결신청도 효력이 상실된다는 견해가 타당하다고 본다.

2) 이의재결 증액보상금 미지급 시 이의재결의 실효

- ① 토지수용법 제84조 제2항은 보상금이 증액된 때에 사업시행자는 이의재결서 정본을 송달받은 날로부터 30일 이내에 증액된 보상금을 지급 또는 공탁하도록 규정하고 있을 뿐, 법 제42조와 같이 실효규정을 두지 않았고,
- ② 법 제88조는 관할 토지수용위원회의 재결에 대한 이의신청이 있더라도 사업의 진행 및 토지의 수용 또는 사용은 정지되지 아니한다고 한 규정들을 종합하여 판단하면
- ③ 이의재결에서 증액된 보상금을 지급·공탁하지 않았다하여 이의재결이 당연히 실효되는 것은 아니라고 본다.(대판 1989. 6. 27. 88누3956).

01 의의 및 취지 (토지보상법 제33조)

- ① 화해는 토지수용위원회의 심리과정에서 사업시행자와 토지소유자 및 관계인이 서로 양보하여 상호간의 주장을 일치시킴으로써 분쟁을 종결시키는 것을 말한다.
- ② 이는 당사자의 의사를 존중하면서 원만히 이해관계를 조정함으로써 재결에 의하지 않고도 수용목적을 달성할 수 있게 하기 위한 제도이다.

02 법적성질

- ① 당사자가 상호 양보하여 분쟁의 해결을 약정하는 것으로 일종의 공법상 계약으로 보는 견해
- ② 재판상 화해로 확정판결과 동일한 효력이 있다고 보는 견해
- ③ 명문의 규정은 없으나 협의성립확인제도와 균형 맞추기 위해서 재결로 보아야 한다는 견해 등이 있다.

03 협의와의 차이점

- ① 협의는 재결신청 전 수용 당사자 간에 공법상 계약에 의해 수용목적 달성하고자 하는 것이고, 화해는 재결신청 후 토지수용위원회의 중재에 의해 수용목적 달성하고자 하는 것이다.
- ② 협의는 협의전치주의를 취하고 있는 수용법제하에서는 필요적 절차이나, 화해는 토지수용위원회의 재량에 따른 임의적 절차이다.

04 절차

- ① 토지수용위원회는 그 재결이 있기 전에는 그 위원 3명으로 구성되는 소위원회로 하여금 사업시행자, 토지소유자 및 관계인에게 화해를 권고하게 할 수 있다(제33조).
- ② 화해의 권고는 토지수용위원회에게 재량이 주어져 있는 임의적 절차이다(대판 1986. 6. 24. 84누554).
- ③ 화해가 성립되었을 때에는 토지수용위원회는 화해조서를 작성하여 화해에 참여한 위원, 사업시행자, 토지소유자 및 관계인이 서명 또는 날인하도록 하여야 한다(제33조 제2항).
- ④ 토지수용위원회는 화해가 성립된 때에는 화해조서의 정본을 사업시행자, 토지소유자 및 관계인에게 송달하여야 한다(령 제17조).

05 화해조서의 효력

- ① [토지보상법] 제33조 제3항에 따라 화해조서에 서명 또는 날인이 된 경우에는 당사자간에 화해조서와 동일한 내용의 합의가 성립된 것으로 본다.
- ② 화해의 효력은 명문상 규정은 없으나, 합의성립확인 또는 재결과 같은 효력이 있다고 보아야 할 것이며, 사업시행자는 조서에서 정한 시기까지 보상금을 지급하거나 공탁하여야 하고, 피수용자는 목적물을 인도·이전해야 하는 의무가 발생하게 된다.

06 화해조서 작성에 대한 다툼

- ① 토지보상법은 화해조서에 대한 불복규정을 두고 있지 않다.
- ② 화해의 법적성질을 재결로 본다면 재결에 대한 불복방법을 준용할 수 있을 것이고, 재판상 화해로 본다면 판결과 동일한 효력을 갖게 되어 재심사유가 없는 한 다툴 수 없게 될 것이다.

CASE

토지보상법 제38조 천재지변시 토지사용과 동법 제39조 시급한 토지 사용을 비교하시오,

01 의미

- ① 약식절차란 토지의 수용 또는 사용에 관한 보통절차 가운데 그 일부를 생략하고 행하는 절차를 말한다.
- ② 토지의 수용 또는 사용 절차는 모든 단계를 거쳐야 함이 원칙이나, 특별한 사유가 있는 경우는 절차 중 일부를 생략할 필요가 있다.
- ③ 공익상 긴급할 경우 간소한 절차를 통해 수용 또는 사용을 인정할 필요가 있으나, 이는 재산권보장원칙에 대한 중대한 예외이므로, 반드시 법률에 근거를 둔 경우에만 인정될 수 있다.

02 천재지변 시의 토지의 사용

1) 의미

천재지변이나 그 밖의 사변으로 공공의 안전을 유지하기 위한 공익사업을 긴급히 시행할 필요가 있을 때 특별자치도지사·시장·군수·구청장의 허가를 받아 타인의 토지를 사용할 수 있게 하는 약식절차이다(제38조).

2) 요건

- ① 천재지변 그 밖의 사변 시에 한정된다.
- ② 공공의 안전을 유지하기 위한 공익사업을 긴급히 시행할 필요가 있어야 한다.
- ③ 토지보상법 제4조 각 호의 하나에 해당하는 공익사업이어야 한다.
- ④ 사업시행자의 신청을 전제한다.
- ⑤ 사용기간은 6개월을 넘지 못한다(제38조 제3항). 이 기간을 초과하여 사용하려면 공용수용의 보통절차를 거쳐야 한다.

3) 절차

- ① 사업시행자는 허가를 받아 즉시 사용할 수 있고, 사업시행자가 국가 또는 특별시·광역시 또는 도일 때에는 통지하고 사용할 수 있다(제38조 제1항).
- ② 사업시행자가 특별자치도, 시·군 또는 구일 때에는 특별자치도지사, 시장·군수 또는 구청장이 허가나 통지 없이 사용할 수 있다.
- ③ 허가를 하거나 통지를 받은 경우 또는 직접 사용하려는 경우 즉시 토지소유자 및 토지점유자에게 통지하여야 한다(동조 제2항).

4) 효과

- ① 사업시행자는 사용권을 취득하고, 사용기간 만료 시 반환 및 원상회복의무(제48조)를 지며, 대행(제44조)·대집행(제89조) 신청권을 갖는다.
- ② 토지소유자는 토지인도의무와 손실보상청구권을 갖는다.

5) 권리구제

(1) 위법한 허가에 대한 행정쟁송 및 손해배상

위법한 허가에 대하여 행정쟁송으로 다룰 수 있고, 손해배상 요건 충족 시 손해배상을 청구할 수 있다.

(2) 적법한 허가에 대한 손실보상

- ① 사업시행자는 타인의 토지를 사용함으로써 발생하는 손실을 보상하여야 한다(제38조 제4항).
- ② 손실보상에 관하여는 제9조 제5항부터 제7항까지의 규정을 준용한다.
- ③ 이 손실보상은 사후보상으로서 사전보상원칙의 예외에 해당한다.
- ④ 토지보상법 제9조 제7항에 의한 재결은 보상금만에 대한 재결이나, 제34조의 수용재결과 동일한 절차, 심리과정을 거쳐 결정되므로, 양자의 불복수단을 일관성 있게 봄이 타당하다.
- ⑤ 따라서 토지보상법상 이의신청(제83조), 보상금증감청구소송(제85조 제2항)으로 권리구제가 가능하다.

(3) 원상회복에 대한 공법상 결과제거청구권

사업시행자가 사용기간이 만료되었음에도 원상회복 및 반환하지 않을 때에는 공법상 결과제거청구권 행사가 가능하다.

03 시급한 토지사용에 대한 허가

1) 의의

공익사업이 진행되는 동안 재결이 지연됨으로써 재해를 방지할 수 없거나 공공의 이익에 현저한 지장을 줄 우려가 있다고 인정되는 경우 재결신청을 받은 토지수용위원회의 허가로서 토지를 사용할 수 있게 하는 약식절차이다(제39조).

2) 요건

- ① 보통절차에 의해 재결신청 중에 있는 공익사업이어야 한다.
- ② 토지수용위원회의 재결이 지연되고 있는 경우여야 한다.
- ③ 재결이 지연됨으로 인하여 재해를 방지하기 곤란하거나, 공공의 이익에 현저한 지장을 줄 우려가 있다고 인정되어야 한다.
- ④ 사업시행자의 신청을 전제한다.
- ⑤ 사업시행자가 국가나 지방자치단체인 경우를 제외하고 담보를 제공하여야 한다.
- ⑥ 사용기간은 6개월을 넘지 못한다(제39조 제2항). 이 기간을 초과하여 사용하려면 공용수용의 보통절차를 거쳐야 한다.

3) 절차

- ① 토지수용위원회가 허가한 때에는 토지소유자 및 점유자에게 통지하여야 한다.
- ② 담보의 제공은 토지수용위원회가 상당하다고 인정하는 금전 또는 유가증권을 공탁함으로써 행한다
(령 제19조 제1항).

4) 효과

- ① 사업시행자는 사용권을 취득하고, 사용기간 만료 시 반환 및 원상회복의무(제48조)를 지며, 대행(제44조)·대집행(제89조) 신청권을 갖는다.
- ② 토지소유자는 토지인도의무와 손실보상청구권을 갖는다.
- ③ 토지소유자나 관계인은 사업시행자가 재결에 따른 보상금의 지급시기까지 보상금을 지급하지 아니하면 제공된 담보의 전부 또는 일부를 취득한다(제41조 제2항).

5) 권리구제

(1) 위법한 허가에 대한 행정쟁송 및 손해배상

위법한 허가에 대하여 행정쟁송으로 다툴 수 있고, 손해배상 요건 충족 시 손해배상을 청구할 수 있다.

(2) 적법한 허가에 대한 손실보상

- ① 토지수용위원회의 재결이 있기 전에 토지소유자나 관계인이 청구할 때에는 사업시행자는 자기가 산정한 보상금을 토지소유자나 관계인에게 지급하여야 한다(제41조 제1항).
- ② 이 손실보상은 사후보상으로서 <사전보상원칙의 예외>에 해당한다.

(3) 원상회복에 대한 공법상 결과제거청구권

사업시행자가 사용기간이 만료되었음에도 원상회복 및 반환하지 않을 때에는 공법상 결과제거청구권 행사가 가능하다.

구분		천재지변 시 토지 사용(법38조)	시급한 토지 사용(법39조)
공 통 점	취지	보통절차를 거칠 여유가 없는 경우 원활한 사업진행을 도모	
	요건	관련 행정청의 허가&토지소유자 및 점유자에 대한 통지&공용사용의 경우만 허용	
	사용기간 및 효과	6월 이내 사용, 반환 및 원상회복 의무	
	보상의 특징	사후보상(사전보상의 예외)	
차 이 점	허가권자	시·군·구청장	재결신청전제&관할토지수용위원회
	담보물 제공 여부	제공X	제공O
	보상금 지급 절차	협의절차 있음 (9조5항~7항준용)	협의절차 없음 (재결로 보상금 결정)
	손실보상액에 대한 불복	별도규정 없음(9조)	별도규정 있음(41조)

제1절

공용수용의 일반적 효과

01 서

- ① 공용수용의 보통절차에 있어서 재결이 있게 되거나, 재결 단계에 이르기 전에 협의성립 및 협의성립의 확인 또는 화해조서작성은 재결로서 간주되므로, 이 경우에도 수용의 효과가 발생한다.
- ② 공용수용의 가장 기본이 되는 효과는 사업시행자가 공익사업에 필요한 목적물을 취득하고, 그 목적물에 대한 권리자인 토지소유자와 관계인은 그 권리를 상실하게 되는 권리변동이 생기는 것이다.

02 권리변동의 시기

1) 공용수용 절차 종결 시기

공용수용의 절차는 협의의 성립, 협의성립확인, 재결, 화해조서작성으로 종결된다.

2) 공용수용 효과 발생 시기

- ① 권리의 취득·상실의 효과는 수용 또는 사용의 개시일에 발생하게 되며, 사업시행자가 그 개시일까지 피수용자에 대한 보상금의 지급 또는 공탁을 하는 것을 조건으로 한다.
- ② 이것은 사전보상원칙(제62조)을 보장하고, 수용의 개시일까지 수용목적물의 인도·이전의무(제43조)를 이행하게 하려는 것이다.

03 사업시행자에 대한 효과

1) 권리의 원시취득

- ① 사업시행자는 수용의 개시일에 토지나 물건의 소유권을 취득하며, 그 토지나 물건에 관한 다른 권리는 이와 동시에 소멸한다(제45조 제1항). 수용에 의한 사업시행자의 권리 취득은 권리의 승계취득이 아니라 법률에 의한 원시취득이며(대판 2001. 1. 16. 98다58511, 대판 2000. 7. 4. 98다62961), 그 효과는 대물적으로 모든 권리자에 대해 발생한다.
- ② 그러나 토지수용위원회의 재결로 인정된 권리는 소멸되거나 그 행사가 정지되지 아니한다(제45조 제3항).
- ③ 사업시행자는 등기하지 않더라도 수용의 개시일에 소유권을 취득한다. 왜냐하면 그 민법 제187조 본문에 따라 공용징수는 등기를 요하지 아니하는 부동산물권취득이기 때문이다.
- ④ 그러나 수용의 경우에도 취득한 소유권을 타인에게 처분하기 위해서는 등기하여야 한다(민법 제187조 단서).

2) 손실보상의무

- ① 사업시행자는 천재지변시 토지사용 또는 시급한 토지사용의 경우를 제외하고는 수용 또는 사용의 개시일까지 관할 토지수용위원회가 재결한 보상금을 지급하여야 한다(제40조 제1항).
- ② 보상금의 지급은 피수용자에 대한 사업시행자의 의무이며, 수용의 정지조건이다. 수용은 보상금의 지급을 조건으로 그 효과가 발생한다.

3) 위험부담의 이전

토지수용위원회의 재결이 있은 후 수용하거나 사용할 토지나 물건이 토지소유자 또는 관계인의 고의나 과실 없이 멸실되거나 훼손된 경우 그로 인한 손실은 사업시행자가 부담한다(제46조).

4) 사용기간 만료 시 반환·원상회복의무

- ① 사업시행자는 토지나 물건의 사용기간이 끝났을 때나 사업의 폐지·변경 또는 그 밖의 사유로 사용할 필요가 없게 되었을 때에는 지체 없이 그 토지나 물건을 그 토지나 물건의 소유자 또는 그 승계인에게 반환하여야 한다(제48조 제1항).
- ② 사업시행자는 토지소유자가 원상회복을 청구하면 미리 그 손실을 보상한 경우를 제외하고는 그 토지를 원상으로 회복하여 반환하여야 한다(제48조 제2항).

04 피수용자에 대한 효과

1) 손실보상청구권

- ① 토지보상법은 직접 명문의 규정을 두고 있지 않지만, 재결이 있게 되면 사업시행자에 대해 피수용자는 손실보상청구권이 발생한다.
- ② 그러므로 재결절차를 거치지 않은 채 곧바로 사업시행자를 상대로 손실보상을 청구하는 것은 허용되지 않는다(대판 2008. 7. 10. 2006두19495).

2) 토지·물건의 인도·이전 의무

토지소유자 및 관계인과 그 밖에 토지소유자나 관계인에 포함되지 아니하는 자로서 수용하거나 사용할 토지나 그 토지에 있는 물건에 관한 권리를 가진 자는 수용 또는 사용의 개시일까지 그 토지나 물건을 사업시행자에게 인도하거나 이전하여야 한다(제43조).

3) 담보물권자의 물상대위

담보물권의 목적물이 수용되거나 사용된 경우 그 담보물권은 그 목적물의 수용 또는 사용으로 인하여 채무자가 받을 보상금에 대하여 행사할 수 있다. 다만, 그 보상금이 채무자에게 지급되기 전에 압류하여야 한다(제47조).

01 사업시행자의 보상금 지급의무

- ① 사업시행자는 천재지변 시 토지사용 또는 시급한 토지사용의 경우를 제외하고는 수용 또는 사용의 개시일까지 관할 토지수용위원회가 재결한 보상금을 지급하여야 한다(제40조 제1항)
- ② 보상금의 지급은 피수용자에 대한 사업시행자의 의무이며, 수용의 정지조건이다. 수용은 보상금의 지급을 조건으로 그 효과가 발생한다.

02 보상금의 공탁

CASE

사업시행자 甲은 피수용자 乙의 수용보상금에 대하여 공탁을 하면서, 공탁금 수령시 앞으로 물건의 인도이전등 사업에 협조할 것을 조건으로 공탁하였다. 그러나 乙는 이에 대하여 이익유보없이 보상금을 수령하였다. 乙의 공탁금 수령의 효과를 검토하시오

1) 의의 및 취지

- ① 보상금의 공탁이란 일정한 사유(제40조 제2항)가 있을 때, 사업시행자가 보상금을 공탁함으로써 보상금 지급에 갈음하는 제도이다.
- ② 이는 보상금이 미지급되면 재결이 실효되고, 그에 따라 공익사업의 원활한 시행이 불가능하게 되는 등을 고려하여 사전보상원칙을 실현하고, 피수용자의 권익을 보호함에 취지가 있다.

2) 요건

(1) 보상금 받을 자가 수령을 거부하거나 보상금을 수령할 수 없을 때

- ① 사업시행자는 원칙적으로 보상금 채권자인 토지소유자에게 보상금을 현실적으로 제공하였음에도 토지소유자가 수령거부를 하였을 때에만 수령거부를 이유로 공탁을 할 수 있다고 할 것이다.
- ② 또한 보상금 받을 자가 보상금을 지급하여도 그것을 수령하지 않을 것이 명백하다고 인정되는 경우에는 바로 보상금을 공탁할 수 있다.
- ③ <보상금을 수령할 수 없을 때>란 토지소유자 등의 부재, 주소불명 등 사실상의 수령불능인 경우뿐만 아니라 토지소유자 등이 무능력자로서 법정대리인이나 후견인이 없는 법률상의 불능인 경우도 포함된다.

(2) 사업시행자의 과실 없이 보상금을 받을 자를 알 수 없을 때

- ① 우리 공탁제도는 채권자가 누구인지 전혀 알 수 없는 절대적 불확지의 공탁은 허용되지 않는 것이 원칙이다.
- ② 그러나 토지보상법은 절대적 불확지의 공탁을 허용함으로써, 사업시행자는 공탁에 의해 보상금 지급의무를 면하고, 토지에 대한 소유권을 취득하도록 하고 있는 바, 이는 공익을 위하여 신속한 수용이 불가피하기 때문에 사업시행자의 공탁으로 보상금 지급의무를 면하게 하는 것이다.

(3) 관할 토지수용위원회가 재결한 보상금에 대하여 사업시행자가 불복할 때

- ① 사업시행자가 재결한 보상금액에 대하여 불복할 때 보상금 받을 자에게 자기가 산정한 보상금을 지급하고 그 금액과 토지수용위원회가 재결한 보상금과의 차액을 공탁하여야 한다.
- ② 이 경우 보상금 받을 자는 그 불복절차가 종결될 때까지 공탁된 보상금을 수령할 수 없다(제40조 제4항).
- ③ 이와 같은 <차액공탁제도>를 인정한 것은 쟁송에 의하여 보상금액이 변경(감액)되었을 때, 그 반환을 쉽게 하기 위한 제도이다.

(4) 압류나 가압류에 의하여 보상금의 지급이 금지되었을 때

토지소유자 등의 보상금지급청구권에 대하여 일반 채권에 근거한 압류 또는 가압류, 담보권자의 물상대위권 행사에 의한 압류, 처분금지가처분이 있는 경우 공탁이 가능하다.

3) 공탁의 성질

(1) 문제점

토지보상법상의 공탁이 <민법상 변제공탁>과 그 성질이 같은 것인지 문제된다.

※ 보충자료 - 공탁의 종류

1. 변제공탁

[민법] 제487조에 따라 채권자가 변제를 받지 않거나 받을 수 없는 때 또는 변제자가 과실 없이 채권자를 알 수 없는 경우에 변제자가 채권자를 위하여 변제의 목적물을 공탁하여 그 채무를 면할 수 있는 공탁을 말한다.

2. 집행공탁

집행공탁은 [민사집행법]상의 강제집행이나 보전집행절차의 어느 단계에서 집행기관이나 집행당사자 또는 제3채무자가 강제집행상의 권리 또는 의무로서 집행의 목적물을 공탁소에 맡겨 그 목적물의 관리와 집행당사자 사이의 교부를 공탁절차에 따라 이행하도록 하기 위한 공탁을 말한다.

3. 담보공탁

담보공탁은 기존 또는 장래 피공탁자에게 발생할 손해배상채권을 담보하기 위한 공탁을 말한다.

(2) 학설

- ① 사업시행자가 수용의 개시일까지 보상금을 지급할 수가 없어 수용의 효력이 상실되지 않도록 하기 위해 보상금 지급에 갈음하여 하는 공탁은 채무자가 채무를 변제한 것과 같은 효과를 발생시키기 위하여 변제의 대응으로 행하는 <변제공탁>과 그 목적 및 요건이 같다고 보는 견해가 있다.
- ② 민법상 변제공탁은 변제의 목적물 전부를 공탁해야 하고 특별한 사정이 없는 한 일부만의 공탁은 그 효력이 없음에 반하여, [토지보상법] 제40조 제2항에 따른 공탁은 사업시행자가 지급해야 할 보상금 전부가 아니라 관할 토지수용위원회가 재결한 금액이므로 이후 쟁송의 절차를 거쳐 보상금이 증액되어, 그 공탁금이 사업시행자가 지급해야 할 의무가 있는 보상금의 일부가 되었다 하더라도 그 공탁의 효력이 없어지지 않으므로, 변제공탁으로 볼 수 없다는 견해가 있다.
- ③ 사업시행자가 재결에 불복하여 공탁하는 경우는 일종의 담보공탁, 압류·가압류에 의한 공탁은 집행의 목적물 관리와 집행당사자 사이의 교부를 공탁절차에 따라 행하는 집행공탁이라 보는 견해가 있다.

(3) 판례

- ① 토지수용위원회가 재결한 토지수용보상금을 공탁하는 경우, 그 공탁금은 기업자가 토지의 수용에 따라 토지소유자에 대하여 부담하게 되는 보상금의 지급의무를 이행하기 위한 것으로서, 민법 제487조에 의한 **변제공탁**과 다를 바 없다(대판 1990. 1. 25. 89누4109).
- ② 압류·가압류에 의한 공탁에 대하여는 **변제공탁**으로 보는 듯한 판례와 **집행공탁**으로 보는 듯한 판례가 있다.

대법원 1999. 5. 14. 선고 98다62688

토지수용법상의 보상금청구권에 대하여 압류의 경합이 있는 때에는 기업자는 보상금을 공탁함으로써 면책될 수 있는바, 그 경우에 기업자가 하는 공탁의 성격은 변제공탁이 아니라 집행공탁이고, 집행공탁에 있어서는 배당절차에서 배당이 완결되어야 피공탁자가 비로소 확정되고, 공탁 당시에는 피공탁자의 개념이 관념적으로만 존재할 뿐이므로, 공탁 당시에 기업자가 특정 채권자를 피공탁자에 포함시켜 공탁하였다 하더라도 그 피공탁자의 기재는 법원을 구속하는 효력이 없다.

(4) 검토

- ① 사업시행자가 보상금을 공탁하는 것은 보상금 지급의무를 면하고자 하는 채무 변제와 같은 효과를 위한 것이므로 **변제공탁**으로 볼 수 있을 것이다.
- ② 그러나 사업시행자가 재결에 불복하여 보상금액의 차액을 공탁한 경우 그 공탁의 성질은 변제공탁이 아니고 일종의 **담보공탁**이라고 할 수 있다.

4) 공탁의 구체적 내용

(1) 공탁의 당사자

- ① 공탁자는 사업시행자이며, 피공탁자는 수용대상토지의 소유자로서 재결서에 기재된 토지 등 소유자가 원칙적으로 피공탁자가 된다.
- ② 사업인정고시가 된 후 권리의 변동이 있을 때에는 그 권리를 승계한 자가 공탁금을 받는다(제40조 제3항).

(2) 관할 공탁소

- ① 보상금 공탁은 민법상 변제공탁과 그 성질이 같은 것이므로, 보상금을 수령할 토지소유자 또는 관계인이 거주하는 현주소지의 공탁소에 공탁하는 것이 원칙이다.
- ② 그러나 토지소유자 또는 관계인이 여러 지역에 산재하여 있는 경우 그 현 주소지를 찾는 것이 쉽지 않을 뿐만 아니라 많은 인력과 시간이 소요되기 때문에 예외적으로 토지보상법은 **토지 등의 소재지 공탁소**에 공탁할 수 있도록 하고 있다(제40조 제2항).

(3) 공탁물

손실보상은 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 **현금**으로 지급하여야 하고(제63조 제1항 본문), 그 예외로서 채권보상을 인정하고 있으므로(제63조 제7항부터 제9항까지), 보상금을 공탁하는 경우에도 현금보상의 경우에는 현금을, 채권보상을 하는 경우에는 채권을 공탁의 목적물로 할 수 있다.

5) 공탁의 효과 및 공탁하지 아니한 경우 효과

(1) 공탁의 효과

- ① 보상금의 공탁이 있게 되면 보상금지급의무의 이행 효과가 발생하며, 사업시행자는 수용의 개시일에 목적물의 권리를 <원시취득>하게 된다.
- ② 수용의 개시일 이전에 공탁이 있었다 하더라도 수용의 효과는 수용의 개시일에 발생하며, 쟁송절차에 의한 보상금 증액이 있어도 공탁한 보상금에 대해서는 지연이자 발생하지 않는다.

(2) 보상금 미공탁의 효과

a. 원재결에서 정한 보상금의 미공탁

- ① 사업시행자가 원재결에서 정한 보상금을 수용 또는 사용의 개시일까지 공탁하지 아니한 경우에는 당해 재결은 그 효력을 상실한다(제42조).
- ② 또한 재결이 실효되면 그에 따른 재결신청의 효력도 상실된다.
- ③ 다만, 사업인정은 그 고시일로부터 1년이 경과되지 않았다면 실효되지 않는다고 본다.

b. 이의재결에서 정한 보상금의 미공탁

판례는 이의재결에서 증액된 보상금을 공탁하지 아니한 경우에도 이의재결이 실효되는 것은 아니라고 한다.

6) 하자 있는 공탁 및 수령의 효과

(1) 하자 있는 공탁의 효과

a. 공탁요건에 해당하지 아니하는 공탁

토지보상법 제40조 제2항 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니한 경우에 한 공탁은 보상금 지급으로서의 효력을 발생하지 못한다.

b. 보상금 일부의 공탁

보상금 일부만의 공탁은 그 일부공탁이 유효한 것이라고 인정되는 특별한 사정이 있는 경우를 제외하고는 그 공탁은 **무효**가 되어 보상금을 지급한 것과 같은 효력이 없다.

c. 조건부 공탁

토지소유자 또는 관계인이 이행의무가 없는 반대급부의 제공을 조건으로 한 공탁은 토지소유자 또는 관계인이 그 조건을 **수락하지 않는 한** 그 조건 뿐만 아니라 공탁 자체까지도 **전체가 무효**로 된다.

(2) 공탁 하자의 치유

- ① 보상금 일부 공탁이나 조건부 공탁은 무효가 되지만, 그 공탁금을 토지소유자 또는 관계인 등 채권자가 **수령**하면, 채권자가 일부의 공탁이나 조건을 수락한 것이 되어 그 공탁은 공탁일에 **소급하여 유효**한 것으로 된다.
- ② 따라서 사업시행자가 조건을 붙여 공탁한 보상금이라도 **이의 유보 없이 이를 수령하면** 그 공탁은 **유효**하다(대판 1983. 6. 14. 81누254).

(3) 하자 있는 공탁금 수령의 효과

a. 이의를 유보하지 않고 수령한 경우

토지소유자 또는 관계인이 사업시행자에게 아무런 이의도 유보함 없이 사업시행자가 지급하는 보상금을 수령한 경우에는 관할 토지수용위원회가 행한 **재결에 대하여 승복한 것으로 본다**.

b. 이의신청 및 행정소송 제기 후 이의유보 없이 수령한 경우

(가) 견해 대립

- ① 이의신청 또는 행정소송의 제기는 관할 토지수용위원회의 **재결에 대한 불복방법**으로써, 그 자체를 이의유보로 보아 공탁금을 수령했다 하더라도 재결에 승복한 것이 아니라는 견해가 있다.
- ② 다른 견해는 이의신청이나 행정소송의 제기와 이의유보는 **별개의 것**으로서 이의신청 및 행정소송의 제기 후라도 이의유보 없이 공탁금을 수령하였다면, 그 토지소유자 또는 관계인은 그 재결에 승복한 것이라고 보아야 한다고 한다.

(나) 판례

- ① 기업자가 공탁한 토지수용보상금을 아무런 이의를 유보하지 아니하고 수령한 토지소유자는 비록 그 재결에 대한 이의를 신청하였다고 하더라도 그 재결에 승복하고 공탁의 취지에 따라 이를 수령한 것으로 보아야 한다(대판 1981. 2. 10. 80누492)고 판시하였다.
- ② 또한 토지소유자가 수용재결에서 정한 보상금을 수령할 당시 이의유보의 의사표시를 하였다 하여도 이의재결에서 증액된 보상금을 수령하면서 일부 수령이라는 등 유보의 의사표시를 하지 않은 경우에는 중앙토지수용위원회가 이의재결에서 정한 결과에 승복하여 그 공탁의 취지에 따라 수령한 것이라고 봄이 상당하며, 공탁금수령 당시 이의재결을 다투는 행정소송이 계속 중이라는 사실만으로 공탁금 수령에 관한 이의유보의 의사표시가 있는 것과 같이 볼 수는 없다(대 1991.8.27. 90누7081)고 판시하였다.
- ③ 반면, 이의유보의 의사표시는 반드시 명시적으로 하여야 하는 것은 아니므로, 원고가 이의재결에 따라 증액된 보상금을 수령할 당시 수용보상금의 액수를 다투어 행정소송을 제기하고 상당한 감정비용을 예납하여 시가감정을 신청한 점, 원고가 수령한 이의재결의 증액 보상금은 원고가 이 사건 소장에 시가감정을 전제로 잠정적으로 기재한 최초 청구금액의 1/4에도 미치지 못하는 금액인 점 등을 고려하면, (중략) 이 사건 수용보상금에 관한 다툼을 일체 종결하려는 의사는 아니라는 점은 피고도 충분히 인식하였거나 인식할 수 있었다고 봄이 상당하고, 따라서 원고는 위와 같은 소송 진행 과정과 시가감정의 비용지출 등을 통하여 이의재결의 증액 보상금에 대하여는 이 사건 소송을 통하여 확정될 상당한 수용보상금의 일부로 수령한다는 묵시적인 의사표시의 유보가 있었다고 볼 수 있다라고 판시한 판례도 있다.(대법원 2009. 11. 12. 선고 2006두15462 판결)

(다) 검토

- ① 재결된 보상금의 공탁을 변제공탁으로 보는 한 공탁금의 수령을 재결에 대한 승복으로 보아야 할 것이다.
- ② 그러나 공탁에 하자가 있는 경우 토지소유자 등은 이의신청이나 행정소송의 제기 자체를 이의의 유보를 한 것으로 볼 수 있으므로, 피수용자의 권리보호를 위하여 공탁금 수령 시 불복여부에 관한 사항을 확인하는 절차를 마련하여 불이익을 방지할 필요가 있다.

c. 이의를 유보하고 수령한 경우

- ① 피공탁자가 하자 있는 공탁에 대하여 이의를 유보하고 그 공탁된 보상금을 수령한 경우에는 공탁의 취지에 따라 공탁금을 수령한 것으로 볼 수 없기 때문에 무효가 된 공탁의 하자가 치유될 수 없다(대판 1993. 8. 24. 92누9548).
- ② 토지수용위원회가 재결한 보상금에 대하여 불복한다는 의사를 유보하고 보상금을 수령한 경우에는 토지소유자 또는 관계인은 그 재결에 승복하지 아니한 것이 된다(대판 1987. 5. 12. 86누498).
- ③ 이의유보의 의사표시는 사업시행자에게 하되, 공탁공무원에게 하여도 되며, 보상금 수령 전 그 의사를 표시하여야 하고, 의사표시의 형식은 정해져 있지 않으나 ‘재결에 불복’ 또는 ‘보상금 중 일부의 수령’ 등 관할 토지수용위원회에 재결에 승복하여 보상금을 수령하는 것이 아님을 분명히 표시함으로써 족하다(대판 1987. 2. 24. 86누759).

CASE

토지보상법상 수용목적물의 인도·이전의무에 대한 실효성 확보수단에 대해 설명하시오. [16회 문3]

01 인도 및 이전의무

1) 의의

토지소유자나 관계인과 그 밖에 토지소유자나 관계인에 포함되지 아니하는 자로서 수용하거나 사용할 토지나 그 토지에 있는 물건에 관한 권리를 가진 자는 수용 또는 사용의 개시일까지 그 토지나 물건을 사업시행자에게 인도하거나 이전하여야 한다(제43조).

2) 인도·이전 의무가 수용효과의 발생조건인지 여부

피수용자가 인도의무를 이행하지 아니하는 경우에도 수용의 개시일이 도래하면 수용의 효과가 발생하기 때문에 인도의무는 수용효과의 발생조건이 아니라고 보는 것이 일반적이다.

3) 인도·이전의무와 손실보상이 동시이행의 관계인지 여부

- ① 긍정하는 견해는 수용의 시기가 재결에서 정한 날인 수용의 개시일이라 하더라도 그 효과는 사업시행자가 보상금을 지급하거나 공탁하고 피수용자가 목적물을 인도 또는 이전할 때 비로소 발생한다 할 것이므로 양자는 동시이행의 관계에 있다고 한다.
- ② 그러나 목적물의 인도·이전의무를 이행하는 것과 관계없이 사업시행자는 보상금을 지급 공탁함으로써 수용의 시기가 도래함으로써 목적물에 대한 권리를 취득하기 때문에 동시이행의 관계에 있지 않다고 봄이 타당하다.

02 토지보상법상 의무이행확보수단

1) 개설

- ① 피수용자 등의 수용목적물의 인도·이전의무의 불이행 등에 대하여 토지보상법에는 대행(제44조) 및 대집행(제89조)이 인정되어 제도적 목적의 실현을 공법적으로 보장하고 있다.
- ② 또한 토지보상법에는 인도·이전 의무 불이행시 벌칙규정(제95조의2 제2호)을 두어 간접적으로 실효성을 확보하고 있다.

2) 대행

(1) 의의 및 취지

- ① 토지·물건을 인도·이전해야 할 자가 고의나 과실 없이 의무를 이행할 수 없거나, 사업시행자가 과실 없이 토지나 물건을 인도·이전할 자를 알 수 없을 때, 사업시행자의 청구에 의하여 특별자치도지사·시장·군수 또는 구청장이 인도·이전의무를 대행하는 제도이다(제44조).
- ② 공익사업을 원활하게 추진하기 위한 의무이행의 실효성 확보수단이다.

(2) 법적성질

- ① 행정대집행의 일종으로 보는 견해가 있으나,
- ② 이는 대집행의 요건 및 절차가 적용되지 않으므로 토지보상법 제89조 요건에 해당하지 않는 부분의 특례로 보는 것이 타당하다.

(3) 요건 및 절차

- ① 특별자치도지사, 시장·군수 또는 구청장은 토지나 물건을 인도하거나 이전하여야 할 자가 고의나 과실 없이 그 의무를 이행할 수 없을 때
- ② 사업시행자가 과실 없이 토지나 물건을 인도하거나 이전하여야 할 의무가 있는 자를 알 수 없을 때, 사업시행자의 청구에 의하여 토지나 물건의 인도 또는 이전을 대행하여야 한다(제44조 제1항).
- ③ 특별자치도지사, 시장·군수 또는 구청장이 대행하는 경우 그로 인한 비용은 그 의무자가 부담한다(제44조 제2항).
- ④ 의무자가 그 비용을 내지 아니할 때에는 지방세 체납처분의 예에 따라 징수할 수 있다(제90조).

(4) 대행청구의 대상이 되는 토지·물건의 범위

인도·이전의무는 사업시행자의 소유권에 기한 의무는 아니므로, 대행청구의 대상범위도 수용목적물뿐만 아니라 사업시행에 방해가 되는 것이면 대행청구의 대상이 된다고 볼 것이다.

3) 대집행

CASE

A시는 시가지 철도이설사업을 시행하기 위하여 토지보상법 제16조에 따라 주택용지를 협의취득하면서 그에 따른 일체의 보상금을 B에게 지급하였고, B는 해당 주택을 자진철거하겠다고 약정하였다. B가 자진철거를 하지 않을 경우 B의 주택에 대하여 대집행을 할 수 있는지 판단하시오. [22회 문3]

(1) 의의 및 취지

- ① 대체적 작위의무의 불이행에 대하여 당해 행정청이 스스로 또는 제3자로 하여금 의무를 이행하게 하고, 의무자에게 비용을 징수하는 제도이다.
- ② 공익사업을 원활하게 시행하기 위한 의무이행 확보수단이다. 토지보상법 제89조에 근거 규정 있으며, 토지보상법에서 규정되지 않은 것은 행정대집행법을 따른다.

(2) 요건

a. 토지보상법상 요건 [이완공]

- ① 이 법 또는 이 법에 따른 처분으로 인한 의무를 이행하여야 할 자가
- ② 그 정하여진 기간 이내에 의무를 이행하지 아니하거나 완료하기 어려운 경우
- ③ 또는 그로 하여금 그 의무를 이행하게 하는 것이 현저히 공익을 해친다고 인정되는 사유가 있는 경우에는
- ④ 사업시행자는 시·도지사나 시장·군수 또는 구청장에게 「행정대집행법」에서 정하는 바에 따라 대집행을 신청할 수 있다.

b. 행정대집행법상 요건

- ① 법률에 의하여 직접 명령되었거나 또는 법률에 의거한 행정청의 명령에 의한 행위로서
- ② 타인이 대신하여 행할 수 있는 행위를 의무자가 이행하지 아니하는 경우
- ③ 다른 수단으로써 그 이행을 확보하기 곤란하고
- ④ 또한 그 불이행을 방치함이 심히 공익을 해할 것으로 인정될 때에는
- ⑤ 당해 행정청은 스스로 의무자가 하여야 할 행위를 하거나 또는 제삼자로 하여금 이를 하게 하여 그 비용을 의무자로부터 징수할 수 있다.

(3) 인도·이전 의무가 대집행 대상인지

a. 문제점

- ① 물건의 이전은 의무자가 의무를 이행하지 않을 경우 그 의무가 대체적 작위의무이므로 대집행의 대상이 될 수 있다.
- ② 그러나 토지·물건의 인도의무는 대집행에 적합한 대체적 작위의무가 아니므로 대집행에 제한이 따른다.
- ③ 이와 관련하여 토지보상법 제89조의 이 법 또는 이 법에 따른 처분으로 인한 의무에 토지·물건의 인도의무 까지 포함하여 대집행의 대상이 되는 것으로 볼 수 있는지 논란이 있다.

b. 학설

① 부정설

토지·물건의 인도의무는 대체적 작위의무가 아니므로 토지보상법 제89조의 규정에 불구하고 대집행할 수 없다는 견해이다. 의무자가 토지나 건물을 신체로 점유하며 인도를 거부할 때에는 그 신체에 실력에 의한 구속을 가함으로써 점유를 푸는 것이 필요하며, 그러한 작용은 대집행에 포함되지 않고 직접강제에 속하는 것으로서, 토지보상법 규정이 그러한 작용까지 허용하고 있다고 볼 수 없다고 한다.

② 긍정설

토지보상법 제89조 규정이 토지 등 소유자가 그 인도의무를 이행하지 않을 때 시장·군수의 행위에 의해 본인이 당해 토지를 인도한 것과 같은 법적 효과를 발생시키는 것을 인정한 데에 그 기본적 취지가 있다는 것을 전제로 하고 있다고 한다.

c. 판례

대법원은 '인도'에는 명도도 포함되는 것으로 보아야 하고, 이러한 명도의무는 그것을 강제적으로 실현하면서 직접적인 실력 행사가 필요한 것이지 대체적 작위의무라고 볼 수 없으므로 특별한 사정이 없는 한 대집행의 대상이 될 수 있는 것이 아니라 한다(대판 2005. 8. 19. 2004다2809).

d. 검토

- ① 인도의무는 성질상 비대체적 작위의무이므로 대집행의 개념상 인정되기 어려울 것이다.
- ② 토지보상법 제89조는 단지 의무라고만 규정하고 있으므로 법치행정의 원리상 명확한 법적 근거 없이 대집행을 비대체적 작위의무까지 확대하여 적용하는 것은 국민의 권익 보호 측면에서 문제가 있다고 판단한다.
- ③ 따라서 토지보상법 제89조의 규정은 불완전한 규정이라 볼 수 있고, 사업시행자가 공익사업을 원활하게 수행하기 위해서는 직접강제제도의 도입에 대한 검토가 요구된다.

01 개설

- ① 사법상 계약에 있어서 위험부담은 매도인이 진다(민법 제537조).
- ② 즉 소유권이 이전되기까지 계약목적물의 멸실·훼손에 의한 손해는 채무자가 부담하게 된다.
- ③ 그러나 토지보상법 제46조는 민법상 채무자위험부담주의의 예외를 규정하여 피수용자를 보호하기 위한 제도를 마련하고 있다.

02 의의 및 취지

- ① 재결이 있다 하더라도 수용의 시기까지는 목적물의 권리가 피수용자에게 있기 때문에 목적물의 멸실·훼손에 대하여는 토지소유자나 관계인이 책임을 져야 한다.
- ② 그러나 공용수용의 경우에도 이러한 위험부담을 피수용자에게 지도록 하는 것은 공평의 원리에 비추어 보아 피수용자에게 너무 가혹한 결과가 되기 때문에 토지보상법은 피수용자의 손실과 부담을 최소화하여 완전보상을 실현하기 위하여 이 경우 부담을 사업시행자에게 전가하고 있으며, 이를 위험부담이라 한다(제46조).

03 요건**1) 재결이 있을 후**

- ① 재결이 있을 후 수용 또는 사용의 목적물이 사업시행자에게 인도 또는 이전되기 이전에 멸실·훼손되었다더라도 사업시행자는 재결에서 정한 보상금을 지급해야 하고, 이행불능을 이유로 보상금 지급을 거부하거나 보상금의 감면을 청구할 수 없다.
- ② 그러나 재결이 있기 전에는 사업시행자에게 위험부담의 책임이 있는 것은 아니다.

2) 피수용자의 고의나 과실이 없을 것

- ① 목적물의 멸실·훼손은 피수용자의 귀책사유에 의하지 아니한 모든 경우를 포괄한다.
- ② 따라서 사업시행자의 귀책사유로 인한 경우는 물론이고, 제3자의 불법행위에 의한 경우나 불가항력에 의한 경우 등과 같이 사업시행자나 피수용자 어느 한 쪽에도 귀책사유가 없는 경우도 포함한다.
- ③ 사업시행자와 피수용자의 귀책사유가 경합하는 경우에는 과실상계의 법리가 적용될 것이다.

04 대상에 대한 검토

- ① 위험부담의 이전 문제는 오직 수용목적물의 멸실·훼손으로 인한 경우에 한하며, 목적물의 가격하락의 경우에는 해당되지 않는다.
- ② 토지보상법 제67조 제1항에 따라 손실보상액 산정은 재결 당시의 가격을 기준으로 정해지는 것이기 때문이다.
- ③ 수용재결이 있는 후 목적물에 하자가 숨어 있을 경우도 위험부담의 대상이 되는가 문제된다.
예를 들어 수용목적물인 토지에 폐기물이 묻혀 있는 경우가 그러하다.
- ④ 이 경우 비록 목적물의 훼손에 해당한다 하더라도 재결이 있기 전부터 하자가 숨어 있었기 때문에 위험부담의 문제가 아니라 손실보상금의 감액 문제로 된다. 목적물에 하자가 숨어 있었다면 사업시행자는 고의·과실을 불문하고 행정소송을 통해 손실보상금의 감액을 요구할 수 있을 것이다.

05 효과

- ① 재결 후 수용 또는 사용의 목적물이 사업시행자에게 인도 또는 이전되기 전에 멸실 또는 훼손되었더라도 사업시행자는 재결에서 정한 보상금을 지급하여야 하며, 이행불능을 이유로 보상금의 지급을 거부하거나 보상금의 감면을 청구할 수 없다.
- ② 판례는 댐건설로 인한 수몰지역 내의 토지를 매수하고 지상입목에 대하여 적절한 보상을 하기로 특약하였다면 보상금이 지급되기 전에 그 입목이 홍수로 멸실되었다고 하더라도 매수 또는 보상하기로 한 자는 이행불능을 이유로 위 보상약정을 해제할 수 없다고 판시하였다.

01 물상대위의 의미

- ① 물권은 물건을 직접 지배하는 권리이므로 물건이 멸실하면 물권도 소멸하게 된다.
- ② 담보물권에 있어서는 목적물에 대위하는 가치적 변형물에도 미치는 것이 원칙인데, 이것을 물상대위라 한다.

02 물상대위의 인정 범위

- ① 수용의 목적물에 유치권·질권·저당권 등의 담보물권이 설정되어 있는 경우에 그 목적물이 수용됨으로 인하여 그 담보물권도 소멸한다(제45조).
- ② 토지보상법은 손실보상에 관한 개인별 보상원칙을 채택하고 있어(제64조) 담보물권도 그에 따라 보상을 받게 되는 것이므로, 개인별보상원칙이 적용되는 한 그 보호에 아무런 문제가 없다.
- ③ 그러나 보상금을 개인별로 산정하지 못하는 경우(제64조 단서) 또는 사업인정고시 후 설정된 저당물권 (이 경우 담보물권자는 관계인이 되지 못한다)에 대하여는 그 권리 보호를 위해 이 제도를 인정하고 있다.

03 보상금에 대한 물상대위

- ① 담보물권의 목적물이 수용되거나 사용된 경우 그 담보물권은 그 목적물의 수용 또는 사용으로 인하여 채무자가 받을 보상금에 대하여 행사할 수 있다.
- ② 다만, 그 보상금이 채무자에게 지급되기 전에 압류하여야 한다(제47조).
- ③ 압류는 물상대위의 목적인 채권의 특정성을 유지하여 그 효력을 보전함과 동시에 제3자에게 불측의 손해를 입히지 않으려는 데 있다.

04 물상대위의 효력이 미치는 보상의 범위

- ① 토지보상법 제47조의 ‘그 목적물의 수용 또는 사용으로 인하여 채무자가 받을 보상금에 대하여’가 어떤 범위까지를 말하느냐 하는 것이 문제된다.
- ② 수용되는 토지의 가격 이외에 잔여지에 대한 보상금이 이에 포함되는 것은 별다른 의문이 없다.
- ③ 담보물권의 목적물과 직접적 관련성이 없는 그 밖에 다른 보상금에 대해서는 물상대위의 효력이 미치지 않는다고 보는 것이 타당하다.

CASE

A지방자치단체는 도로사업 부지를 취득하기 위하여 甲의 토지에 대하여는 수용재결에 의하여 소유권을 취득한 후 소유권이전 등기를 마쳤다. 그러나 甲의 토지가 관내의 택지개발예정지구에 포함되자 A지방자치단체는 이 사건 토지가 도로 사업에 더 이상 제공될 수 없는 상황에서 도로사업의 목적 달성이 불가능 하다고 판단하여, 당초 협의취득 및 수용의 목적이 된 해당 도로사업을 폐지하였다. 이에 따라 甲에게 [토지보상법]에 의한 환매권이 발생하였다.

甲이 환매권을 행사할 무렵 환매금액에 관한 A지방자치단체와 甲의 협의가 성립되지 아니하여, A지방자치단체는 환매 대상 토지의 현재가격이 취득일 당시에 비하여 현저히 상승하였음을 들어 환매대금의 증액을 구하는 소송을 제기 하였다.

甲의 환매권 및 환매대금증액청구소송의 법적 성질을 각각 설명하시오.(15점) [35회 문1]

01 의미

공익사업의 폐지·변경 또는 그 밖의 사유로 취득한 토지의 전부 또는 일부가 필요 없게된 경우, 원소유자가 보상금에 상당하는 금액을 사업시행자에게 지급하고 토지를 다시 취득할 수 있는 권리를 말한다.

02 근거

1) 이론적 근거

원소유자가 사업시행자로부터 정당한 보상을 받았다 하더라도 자발적 의사에 기한 소유권 상실이 아니므로 공익상 필요가 소멸한 경우 토지의 소유권을 회복해 주는 것이 <공평의 원칙>, <재산권 보장이념>, <원소유자의 감정존중>에 부합한다.

2) 실정법적 근거

- ① 헌법으로부터 직접 도출되는 권리라는 견해,
- ② 개별 법령의 근거가 있어야 한다는 견해가 있다.
- ③ 생각건대 헌법 제23조 제1항은 재산권의 내용과 한계를 법률에 유보하고 있으므로 법률에 근거가 있어야 함이 타당하다.

[관련자료] 대법원 및 헌법재판소 입장

- ① 대법원은 개별 법령의 규정에 의하여 구체적으로 형성되어야만 인정되는 권리로 보는 반면 (대판 1998. 4. 10. 96다52359),
- ② 헌법재판소는 헌법상 재산권 보장으로부터 도출되는 것으로서 헌법상의 권리로 보고 있다 (헌재 1994. 2. 24. 92헌가15 내지 17 내지 24).

03 법적 성질

1) 공권설 및 사권설

(1) 문제점

환매권의 법적 성질에 대하여 사업인정 전 협의취득의 경우는 사법상 권리로 보는 데 문제가 없으나, 사업인정 후 취득의 경우는 공권설과 사권설이 대립되고 있다.

(2) 학설

① 공권설

환매권은 수용 등 공법적 원인에 의해 형성된 법률관계를 전제로 하는 공권이라 본다.

② 사권설

환매권은 원소유자와 그 포괄승계인에게만 한정되고, 환매권자의 이익을 위해 행사하므로 사권으로 본다.

(3) 판례

- ① 대법원의 주류적 입장은 환매권을 사권으로 보며,
- ② 헌법재판소도 환매권은 헌법소원심판의 대상이 되는 공권력의 행사로 볼 수 없다고 하였다 (헌재 1994. 2. 24. 92헌마283).

(4) 검토

- ① 환매권은 공권력 행사의 주체인 사업시행자에 대하여 행사하며, 그 구체적 발생요건이 되는 공공필요의 소멸 여부의 판단 역시 공익적 판단에서 비롯하므로 공권으로 봄이 타당하다.
- ② 따라서 환매권과 관련된 법적분쟁은 행정소송으로서 당사자소송으로 해결해야 한다. 다만, 실무적으로는 환매권을 사권으로 보고 민사소송으로 해결하고 있다.

2) 형성권

환매권은 환매기간 내에 환매의 요건이 발생하면 환매권자가 수령한 보상금 상당금액을 사업시행자에게 지급하고 일방적으로 의사표시를 함으로써 **사업시행자의 의사에 관계없이 성립되는** <형성권의 일종>으로 보는 것이 타당하다.

대법원 1999. 4. 9. 선고 98다46945

공공용지의취득및손실보상에관한특별법에 의한 절차에 따라 국가 등에 의하여 협의취득된 토지의 전부 또는 일부가 취득일로부터 10년 이내에 당해 공공사업의 폐지, 변경 기타의 사유로 인하여 필요 없게 되었을 때 취득 당시의 소유자 등에게 인정되는 같은 법 제9조 소정의 환매권은 당해 토지의 취득일로부터 10년 이내에 행사되어야 하고, 위 행사기간은 제척기간으로 보아야 할 것이며, 위 환매권은 재판상이든 재판 외이든 그 기간 내에 행사하면 되는 것이나, 환매권은 상대방에 대한 의사표시를 요하는 형성권의 일종으로서 환매의 의사표시가 상대방에게 도달한 때에 비로소 환매권 행사의 효력이 발생함이 원칙이다.

3) 물건적 효력설과 채권적 효력설

(1) 문제점

환매권 행사시 물건적 효력이 발생하는지 채권적 효력이 발생하는지 문제된다.

(2) 견해 대립

a. 물건적 효력설

- ① 환매는 환매권자의 의사표시만으로 성립하고, 수용토지 현재 소유자의 동의를 요하지 않으므로 바로 소유권이 환매권자에게 이전된다고 한다.
- ② 이 경우 소송은 소유권이전확인소송의 유형을 취하게 된다.

b. 채권적 효력설

- ① 환매권자가 환매권을 행사하면 현재 소유자에 대하여 소유권이전등기청구권이 발생할 뿐이고, 이 청구에 따라 현재 소유자가 소유권이전등기를 이행해야 소유권이 이전된다고 보는 견해이다.
- ② 이 때 소송은 소유권이전등기청구소송을 내지는 소유권이전등기말소청구소송의 유형을 취하게 된다.

(3) 판례

판례는 환매권 행사는 채권적 효력으로서 소유권이전등기청구권이 발생하며, 10년의 소멸시효에 걸린다고 판시했다.

(4) 검토

- ① 환매권 행사만으로 소유권이 환매권자에게 이전되는 물건적 효력을 인정한다면 등기 없이 소유권이 변동되는 결과가 초래된다.
- ② 환매권행사에 의하여 소유권이전등기청구권이라는 청구권이 발생하고, 현재 토지소유자의 등기이전이 있어야 소유권이 이전되므로 채권적 효력으로 보는 것이 타당하다.

04 요건

1) 환매권자

- ① 환매권자는 협의취득일 또는 수용의 개시일(이하 “취득일”이라 함) 당시의 토지소유자 또는 포괄승계인이다(제91조 제1항).
- ② 환매권은 일신전속적인 성격을 지닌다. 따라서 환매권은 제3자에게 양도할 수 없다. 그러나 환매권자가 환매의 목적물을 환매 받는 것을 조건으로 목적물인 토지를 양도하는 계약의 체결은 가능하다 할 것이다.

2) 환매의 상대방

- ① 환매권 행사의 상대방은 사업시행자이지만, 토지가 제3자에게 매각되는 경우도 있을 수 있으므로, 제3자인 현재의 소유자도 환매권 행사의 상대방이 될 수 있다.
- ② 그래서 환매권은 「부동산등기법」에서 정하는 바에 따라 공익사업에 필요한 토지의 협의취득 또는 수용의 등기가 되었을 때에는 제3자에게 대항할 수 있다고 규정되어 있다(제91조 제5항).

3) 환매의 목적물

(1) 토지소유권

- ① 환매의 목적물은 토지소유권이다.
- ② 토지의 소유권 이외의 권리 및 토지 이외의 물건 등은 환매의 대상이 되지 않는다.
- ③ 헌법재판소는 입법자가 건물에 대한 환매권을 부인한 것은 헌법적 한계 내에 있는 입법재량권의 행사이므로 재산권을 침해하는 것으로 볼 수 없다고 한다(헌재 2005. 5. 26. 2004헌가10).

(2) 토지 일부에 대해 선택적 행사 불가능

취득한 토지 전부가 필요 없게 된 경우 환매권자는 그 중 임의의 일부에 대해서만 환매권을 행사할 수 있는지 문제되나, 토지수용에 의한 환매의 목적물을 토지소유권에 한정하고 환매요건에 해당하는 토지가 있을 경우 그 요건에 해당하는 토지 전부에 대하여 환매권을 행사하여야 하며, 그 중 일부만 선택적으로 환매권을 행사할 수는 없다고 할 것이다.

(3) 잔여지만의 환매 불가능

잔여지 매수 또는 수용청구에 관한 규정(제74조)에 의하여 잔여지를 수용한 경우 그 잔여지에 대하여는 잔여지에 접한 일단의 토지가 필요 없게 된 경우가 아니면 원래의 수용 토지를 제외하고 잔여지만을 환매할 수는 없다(제91조 제3항).

4) 행사요건

(1) 전부 또는 일부가 필요 없게 된 때

a. 환매의 행사요건 (토지보상법 제91조 제1항)

- ① 공익사업의 폐지·변경 또는 그 밖의 사유로 취득한 토지의 전부 또는 일부가 필요 없게 된 경우 토지의 취득일 당시의 토지소유자 또는 그 포괄승계인은
- ② 사업의 폐지·변경으로 인한 경우에는 관계 법률에 따라 사업이 폐지·변경된 날, 그 밖의 사유로 인한 경우에는 사업완료일로부터, 10년 이내에 그 토지에 대하여 받은 보상금에 상당하는 금액을 사업시행자에게 지급하고 그 토지를 환매할 수 있다.

b. 구체적인 의미

- ① <폐지·변경> 공익사업을 아예 그만두거나 다른 공익사업으로 바꾸는 것을 말한다
- ② <필요 없게 된 때>란 취득 목적사업을 위해 취득한 토지가 사용할 필요 자체가 없어진 경우를 말하며, 필요 없게 되었는지는 사업시행자의 주관적인 의사를 표준으로 하는 것이 아니라 객관적·합리적으로 판단해야 한다.

대법원 2021. 4. 29. 선고 2020다280890

판례는 시행자 지정이 처음부터 효력이 없거나 토지의 취득 당시 해당 도시계획시설사업의 법적 근거가 없었던 것으로 볼 수 있는 등 협의취득이 당연무효인 경우, 협의취득일 당시의 토지소유자가 소유권에 근거하여 등기 명의를 회복하는 방식 등으로 권리를 구제받는 것은 별론으로 하더라도 토지보상법 제91조 제1항에서 정하고 있는 환매권을 행사할 수는 없다고 판시하였다.

(2) 전부를 이용하지 않을 때

a. 토지보상법 제91조 제2항 규정

취득일부터 5년 이내에 취득한 토지의 전부를 해당 사업에 이용하지 아니하였을 때에는 취득일부터 6년 이내에 그 토지에 대하여 받은 보상금 상당 금액을 사업시행자에게 지급하고 그 토지를 환매할 수 있다.

b. 구체적인 의미

- ① <전부>란 특정 환매권자의 해당 필지를 기준으로 판단해서는 안되고, 사업시행자가 취득한 토지의 전부를 기준해야 한다.
- ② <이용하지 아니하였을 때>의 의미는 사업에 이용할 필요가 없게 된 것이 아니라, 단지 사실상 사업에 제공되지 않은 경우를 말한다.

(3) 각 요건의 관계

그 요건을 서로 달리하고 있으므로, 어느 한쪽 요건에 해당되면 다른 쪽의 요건을 주장할 수 없게 된다고 할 수 없고, 양쪽 요건에 모두 해당한다고 하여 더 짧은 제척기간을 정한 제2항에 의하여 제1항의 환매권 행사가 제한된다고 할 수도 없다.

05 환매금액

1) 지급받은 보상금 상당금액

환매를 하기 위해서는 단지 환매의 의사표시만으로는 부족하고, 환매금액을 현재 소유자에게 지불해야 한다. 환매 금액은 “그 토지에 대하여 받은 **보상금에 상당하는 금액**”이다(제91조 제1항).

2) 토지가격이 취득일 당시에 비해 현저히 변동된 경우

(1) 의미

- ① <환매권 행사 당시의 토지가격>이 지급한 보상금에 환매 당시까지의 해당 사업과 관계없는 인근 유사토지의 지가변동률을 곱한 금액보다 높은 경우로 한다(령 제48조).
- ② <대법원>은 이 경우 환매가격은 보상금에다 환매 대상 토지의 환매 당시의 감정평가금액에서 보상금에 인근 유사토지의 지가변동률을 곱한 금액을 공제한 금액을 더한 금액이고, 인근 유사토지의 지가변동률이란 환매 대상 토지와 지리적으로 인접하고 그 공부상 지목과 토지의 이용상황 등이 유사한 토지의 지가변동률을 말하나, 합리적인 지가변동률을 산출할 수 있을 정도의 토지를 선정하면 족하다고 한다(대판 2000. 11. 28. 99두3416).

(2) 금액의 협의 및 협의불성립 시 법원에 청구

- ① 토지보상법은 토지 등 가격이 현저히 변동되어 협의가 성립되지 아니할 때 환매 당사자가 법원에 청구하여 이 문제를 해결하도록 하고 있다.
- ② 즉 토지의 가격이 취득일 당시에 비하여 현저히 변동된 경우 사업시행자와 환매권자는 환매금액에 대하여 서로 **협의**하되, 협의가 성립되지 아니하면 그 금액의 증감을 **법원에 청구**할 수 있다(제91조 제4항).
- ③ 이는 공익사업의 시행으로 발생하는 개발이익은 그 비용의 부담자인 사업시행자를 통하여 궁극적으로는 공익에 귀속되어야 할 것이지, 특정의 토지소유자에게 귀속될 성질의 것이 아니어서 환매권자에게 이를 보장해 줄 수 없다는 것이다(헌재 2005. 4. 28. 2002헌가25).

(3) 소송으로 증액청구

판례는 환매는 **수용의 해제**가 아니라 사법상의 행위라고 보아 금액 증감의 청구는 <민사소송>으로 해야 한다고 본다. 위 증감청구소송은 토지보상법 제85조 제2항의 보상금증감청구소송과 다른 소송이다.

1) 환매통지·공고

(1) 사업시행자의 환매권 통지 의무

- ① 사업시행자는 환매할 토지가 생겼을 때에는 지체 없이 그 사실을 환매권자에게 **통지**하여야 한다.
- ② 다만, 사업시행자가 과실 없이 환매권자를 알 수 없을 때에는 **공고**하여야 한다(토지보상법 제92조 제1항).
- ③ 판례는 환매권 통지규정이 단순히 선언적인 것이 아니라 사업시행자의 **법적인 의무**라고 한다.
- ④ 이는 법률상 당연히 인정되는 환매권 행사의 실효성을 확보하기 위한 것으로 법적 의무로 봄이 타당하다.
- ⑤ 사업시행자의 환매통지는 환매권 행사의 요건이 아니라 **일종의 최고에 불과**하기 때문에 사업시행자의 **환매통지가 없는 경우라도** 환매요건이 발생하면 **환매권자는 환매권을 행사할 수 있다**.

(2) 통지의무 위반으로 환매권 행사기간이 도과한 경우

a. 학설 및 판례

- ① 일부 견해는, 환매권은 형성권으로서 자기의 의사결정에 따라 행사 가능한 권리이며, 단순 통지의무 불이행이 불법행위를 구성하지는 않는다고 한다.
- ② 판례는 사업시행자가 통지·공고를 하지 않아 환매권 행사가 불가능하게 되어 환매권을 상실하게 하는 손해를 가한 때에는 불법행위를 구성한다고 판시하고 있다.

b. 검토

환매권의 통지 의무는 **법적의무**이고, 환매권의 의의 및 기능을 감안할 때, 이를 위반한 것은 **불법행위**로 평가함이 타당하다.

2) 환매의 협의

- ① 사업시행자는 환매권자의 환매에 대한 의사표시가 있게 되면 서로 협의하여야 하고, 환매권자가 협의에서 정해진 환매가격을 지급함으로써 환매가 성립한다.
- ② 환매는 법률상 환매권자의 권리로서 인정되기 때문에 환매권자의 일방적인 의사표시로 성립하며, 사업시행자의 환매동의를 요하지 아니한다.
- ③ 헌법재판소는 환매권의 행사는 형성권의 행사로서 사업시행자의 동의를 얻어야 하거나 의사여하에 따라 효과가 좌우되는 것이 아니라 한다(헌재 1995. 3. 23. 91헌마143).

3) 환매권의 행사방법 및 행사의 효력발생 시점

- ① 사업시행자는 협의취득 또는 수용 토지 전부 또는 일부가 사업을 위해 이용하지 않은 경우 이를 환매권자에게 통지할 의무가 있다.
- ② 이 통지는 환매권 행사의 **최고**이자 **매매의 신청**으로 볼 수 있다.
- ③ 이에 대하여 환매권자가 법정 기간 내에 환매의 의사표시를 하면 바로 매매의 승낙에 상당하고, 매매계약이 성립하여 사업시행자는 그 토지소유권을 환매권자에게 이전해야 할 의무가 발생하게 된다.
- ④ 대법원은 환매 의사표시가 상대방에게 도달한 때 환매권 행사의 효력이 발생한다고 본다.

07 환매권 행사의 효과

1) 환매권의 효과에 대한 견해대립

- ① 물권적 효력설의 입장에서는 소유권 이전의 효과가 발생한다고 한다.
- ② 채권적 효력설의 입장에서는 소유권이전등기청구 또는 소유권이전등기말소청구권이 발생하는 효과가 있다고 한다.
- ③ <판례>는 환매권을 사권으로 보면서 환매권 행사의 효과를 **채권적 효과**로 보아, 사법상 매매계약의 효력이 생기는 것으로 보면서 **소유권이전등기 청구권이 발생**하고, 이 청구권은 10년을 시효로 소멸한다고 한다.

2) 대항력

- ① 환매권은 「부동산등기법」이 정하는 바에 따라 공익사업에 필요한 토지의 **협의취득 또는 수용의 등기**가 되었을 때에는 제3자에게 대항할 수 있다(제91조 제5항).
- ② 여기에서 '제3자에게 대항할 수 있다'고 하는 것은 토지 등 협의취득 또는 수용의 목적물이 제3자에게 양도되더라도, 협의취득 또는 수용의 등기가 된 때에는 제3자가 그 환매권자에 대하여 권리가 있음을 주장하지 못한다는 의미이다.

08 환매권의 소멸

1) 사업시행자의 통지나 공고가 있는 경우

환매권은 통지를 받은 날 또는 공고한 날로부터 6월의 기간이 경과함으로써 소멸하게 된다(제92조 제2항).

2) 사업시행자의 통지나 공고가 없는 경우

사업시행자의 통지나 공고가 없는 경우, 토지보상법 제91조 제1, 2항에서 정한 기간에 환매권을 행사하지 않으면 환매권은 소멸한다.

09 환매권에 대한 다툼

1) 행사요건에 관한 다툼

- ① 환매권을 공권으로 보는 입장에서는 공법상 당사자소송으로 다툼 수 있다.
- ② 환매권을 사권으로 보는 입장에서는 민사소송으로 다투되, 소유권이전등기청구권에 대한 확인 또는 이행청구, 소유권이전등기말소청구권에 대한 확인 또는 이행청구가 그 내용이 될 것이다.

2) 환매금액에 관한 다툼 (91조 4항)

토지의 가격이 취득일 당시에 비하여 현저히 변동된 경우 사업시행자와 환매권자는 환매금액에 대하여 서로 협의하되, 협의가 성립되지 아니하면 그 금액의 증감을 법원에 청구할 수 있다.

환매권을 행사하기 위하여는 지급받은 보상금의 상당금액을 미리 지급하여야 하고 또한 이로써 족한 것이며, 사업시행자는 소로써 법원에 환매대금의 증액을 청구할 수 있을 뿐 환매권 행사로 인한 소유권이전등기 청구소송에서 환매대금 증액청구권을 내세워 증액된 환매대금과 보상금 상당액의 차액을 지급할 것을 선이행 또는 동시이행의 항변으로 주장할 수는 없다.(환매대금지급의무가 선이행이라는 것이 우리 토지보상법의 태도)

10 환매금액 증감 소송

1) 문제점

환매금액 증감 소송이 민사소송인지 행정소송인지에 대해서는 [토지보상법]에 규정하고 있지 않으므로, 이에 대해서는 견해의 대립이 있다.

2) 학설

(1) 민사소송이라는 견해

환매권자의 개인적인 재산권을 보장하기 위하여 인정되는 것이기 때문에 그 법률상의 관계는 순수한 사법상의 법률관계이며, 특히 재산권의 조정을 위한 환매금액의 증감은 민사소송으로 다투어야 한다는 주장이다.

(2) 행정소송이라는 견해

협의취득한 토지에 대한 환매에 대하여서는 민사소송으로 다투어야하지만, 수용한 토지에 대하여서는 환매권 자체가 공용수용제도의 일환으로서 공법상 법률관계에 대한 다툼으로 행정소송법상 당사자소송이 되어야 한다는 주장이다.

(3) 검토

- ① 사업인정 전 협의취득은 사법상 매매계약으로 보므로 이에 대한 환매권도 사권으로 보는 것이 타당하다.
- ② 그러나 사업인정 후 협의취득이나 수용재결에 의한 취득은 공법적 원인에 의해 소유권을 취득한 것이므로, 이에 대한 환매권은 공권으로 보아 공법상 당사자소송으로 다투는 것이 타당하다.

〈사권으로 보는 경우〉

- ① 환매권은 환매권자 재산권을 보장하기 위하여 인정되는 것이기 때문에, 그 법률상의 관계는 순수한 사법상의 법률관계에 해당한다.
- ② 따라서, 협의취득한 토지에 대한 환매금액의 증감을 구하는 소송은 물론이고, 수용한 토지에 대한 환매금액의 증감을 구하는 소송도 민사소송으로 다투어야 한다고 본다.

CASE

A시는 X초등학교의 수용시설이 열악하다고 판단하고, 인근에 Y초등학교의 건립을 위한 사업인정과 재결을 거쳐 해당 부지(甲 소유의 토지)를 취득하였다. 2년 후, A시는 인근의 다른 택지(아파트 단지 예정)에 새 초등학교부지가 있다는 사실을 알고, 아파트건설 사업을 하던 제3자인 B회사와 그 아파트 단지 내에 들어설 새 초등학교 부지와 이 학교용지를 교환하였다. 이 사실을 알게된 甲은 당초 사업이 폐지, 변경되었으므로 환매권을 행사하였다. 이에 A시는 B회사와 교환한 당초 초등학교 부지를 중학교부지로 변경하는 도시관리계획을 결정, 고시하면서 당초 토지는 초등학교에서 중학교부지로 공익사업이 변경되었으므로 환매권 행사가 제한된다고 주장한다. A시의 주장은 타당한가?

1) 의의 및 취지 (토지보상법 제91조 제6항)

- ① 공익사업변환이란 공익사업의 토지취득 후 다른 공익사업으로 변경된 경우 별도의 취득절차 없이 다른 공익사업에 이용하도록 하는 제도이다.
- ② 공익사업을 위해 토지를 재취득하는 무용한 절차의 반복을 방지하기 위한 제도이다.

2) 요건

- ① 변환 전 사업주체는 국가, 지방자치단체 또는 공공기관이어야 한다.
- ② 변환 전 공익사업은 사업인정을 받았어야 하고, 변환 후 공익사업은 공익성의 정도가 높은 토지보상법 제4조 제1호 내지 제5호의 공익사업으로 변경된 경우여야 한다.
- ③ 판례는 변환된 공익사업도 사업인정을 받거나 사업인정을 받은 것으로 의제 되어야 한다고 본다.
- ④ 환매토지가 제3자에게 처분되지 않았어야 한다.

대판 2010. 9. 30. 2010다30782

공익사업 변환은 새로운 공익사업에 관해서도 사업인정을 받거나 또는 사업인정을 받은 것으로 의제하는 다른 법률 규정에 의해 사업인정을 받은 것으로 볼 수 있는 경우에만 공익사업의 변환에 의한 환매권 행사의 제한을 인정할 수 있다.

	변경 전	변경 후
사업시행자	국가, 지자체, 공공기관	요건 없음 사업시행자가 바뀐 경우에도 인정(判)
공익사업	-	토지보상법 4조 1호~5호
사업인정여부	O	O (判)
처분	제3자에게 처분되지 않을 것(判)	

3) 기산일 규정의 해석

〈환매권 행사기간은 관보에 당해 공익사업 변경을 고시한 날로부터 기산한다.〉는 의미는 새로 변경된 공익사업을 기준으로 다시 환매권 행사의 요건을 갖추지 못하는 한 환매권을 행사할 수 없고, 환매권 행사요건을 갖추어 행사할 수 있는 경우에 그 환매권 행사기간은 당해 공익사업 변경을 관보에 고시한 날로부터 기산한다는 의미로 해석해야 한다는 것이다(대판 2010. 9. 30. 2010다30782).

4) 사업시행자의 동일성 문제

(1) 문제점

토지보상법 규정상 변경 전 사업시행자에 관한 규정은 존재하나, 변경 후 사업시행자가 누구인지에 대한 규정은 없기 때문에, 공익사업 변환이 사업시행자가 동일한 경우에만 인정될 수 있는 것인지 문제된다.

(2) 견해 대립

- ① 공익사업 변환은 그 인정 자체가 보다 높은 공익성을 갖는 사업으로의 전환을 의도하는 것이므로 사업시행자의 변경까지 제한하는 것은 아니어서 변경시에도 적용된다는 견해와
- ② 사업시행자 변경시 폐지된 공익사업시행자가 아무런 이유 없이 토지가액의 변동으로 차액을 얻게 되는 불합리함이 있으므로 동 규정은 적용할 수 없다는 견해가 있다.

(3) 대법원

대법원은 (구)토지수용법 등 관계 법령의 규정 내용이나 그 입법 이유 등으로 미루어 볼 때 공익사업 변환이 국가, 지방자치단체 또는 정부투자기관 등 사업시행자가 동일한 경우에만 허용되는 것은 아니라 한다 (대판 1994. 1. 25. 93다11760, 11777, 11778 병합 판결).

(4) 검토

- ① 공익사업변환제도로 인해 환매권이 형해화되는 결과를 초래할 우려가 있으므로, 가급적 좁게 해석함이 국민의 권리구제에 유리하다.
- ② 따라서 사업시행자 변경시에는 공익사업 변환은 인정되지 않는 것으로 봄이 타당하다.(이견 있음)

5) 변환의 효과

- ① 공익사업 변환이 인정되면, 공익사업의 폐지·변경으로 인해 취득한 토지가 필요 없게 되더라도 환매권을 행사할 수 없다.
- ② 즉 변경된 공익사업의 내용을 관보에 고시한 때부터 환매권 행사기간을 다시 기산하여 환매권 행사기간이 연장되는 효과가 발생하게 된다.

6) 제도의 위헌성

(1) 문제점

- ① 환매권 행사기간의 기산점을 공익사업 변경고시일로 늦추도록 한 것은 실질적으로 환매권이 형해화 될 수 있는 문제가 있다.
- ② 이는 헌법상 보장된 환매권을 법률로 제한하는 것으로서, 기본권의 본질적 내용을 침해하는 제한으로서 비례의 원칙에 위반되는지 문제된다.

(2) 합헌설

이 규정은 공익사업의 원활한 시행을 위한 목적에서 만들어진 것으로, 우선 그 입법 목적에 있어 정당하고, 사업 목적 또한 공익성이 높은 공익사업으로 한정하고 있어서 그 입법목적 달성을 위한 수단으로서 적정성이 인정될 뿐만 아니라, 피해최소성의 원칙 및 법익균형의 원칙에도 부합된다 할 것이므로 기본권 제한에 관한 과잉금지원칙에 위배되지 아니한다고 한다.(헌재입장)

(3) 위헌설

- ① 원래의 공익사업의 폐지·변경 등을 이유로 원소유자가 환매권을 행사할 수 없도록 제한하는 것은 공익사업의 원활한 시행 확보라는 행정편의만을 중시한 일방적인 것이며, 비례의 원칙에도 위배될 뿐만 아니라 환매권의 본질적인 내용을 침해하는 제한으로 환매권 제도를 형해화하는 것이라 한다.
- ② 또한 공익사업이 변환되는 경우와 그렇지 않은 경우 사이에 형평이 취해지지 않아 평등권 침해 문제를 야기하므로 위헌의 소지가 있다고 한다.

(4) 검토

① 위헌설

이 제도는 사실상 환매권을 폐지하는 제도와 같으며, 평등권 침해 문제, 행정편의만을 중시한 제도 등이라는 점 등을 고려할 때, 위헌소지가 있다.

② 합헌설

토지보상법은 공익사업의 원활화를 위해 제한적으로 공익사업 변환을 제도화하고, 변환 전 사업시행자 및 변환 후 공익성 높은 사업으로 한정하여 전환을 허용하는 점 등을 볼 때, 위헌으로 볼 것은 아니다. 그러나 이 제도는 어디까지나 예외적인 경우에 허용되는 것에 불과하므로, 공적 사업시행자의 편의를 앞세워 입법이 자행되어서는 안 될 것이다.

CASE

토지수용의 재결에 대한 불복을 논하라. [3회 문1]

제1절

개설

01 재결의 불복

- ① 토지수용위원회의 재결에 대한 불복절차로 이의신청과 행정소송이 인정된다.
- ② 수용재결 또는 이의재결에 대한 불복에는 수용 자체를 다투는 경우와 보상액을 다투는 경우가 있다.
- ③ 불복이 수용 자체를 다투는 것인 때에는 재결에 대하여 이의신청(토지보상법 제83조), 취소소송 또는 무효확인소송을 제기하고(토지보상법 제85조 제1항), 보상금의 증감을 청구하는 것인 때에는 이의신청과 보상액의 증감을 청구하는 소송을 제기하여야 한다(제85조 제2항).

불복대상	수용재결 자체를 다투는 것	보상금의 증감을 청구하는 것
불복방법	제83조 : 이의신청 제85조 제1항 : 취소소송 또는 무효확인소송	제83조 : 이의신청 제85조 제2항 : 보상금증감청구소송

02 수용재결 전치주의

1) 문제점

수용재결을 거치지 않고 곧바로 행정소송을 제기할 수 있는지 문제된다.

2) 수용재결 전치주의의 개념

수용재결전치주의는 행정소송을 제기하기 앞서 토지수용위원회의 재결을 반드시 거쳐야 하는 것을 의미한다.

3) 토지보상법 제85조 제1항 태도

“재결에 불복할 때 행정소송을 제기할 수 있다”고 규정하여, 수용재결 전치주의를 취한 것으로 볼 수 있다.

4) 관련 판례

판례 역시 토지보상법 제85조의 행정소송을 제기하기 위해서는 규정 문언상 수용재결을 반드시 거쳐야 한다고 판단하였고, 이는 행정감독의 효과를 도모하고, 사건을 전문적·기술적으로 처리함으로써 전체적으로 국민의 권리구제 도모에 그 취지가 있다고 보았다(94누1410판결 참조).

CASE

토지소유자 甲은 “사업시행자인 B구청장이 도로개설공사를 시행하면서 사업인정고시가 된 2010. 4. 6. 이후 3년 이상 이 사건 토지를 사용하였다”고 주장하면서 토지보상법 제72조제1호를 근거로 이 사건 토지의 수용을 청구하였다.

이에 대해 A광역시지방토지수용위원회는 “사업인정고시가 된 날부터 1년 이내에 B구청장이 재결신청을 하지 아니하여 사업인정은 그 효력을 상실하였으므로 甲은 토지수용법 제72조제1호를 근거로 이 사건 토지의 수용을 청구할 수 없다”며 甲의 수용청구를 각하하는 재결을 하였다.

A광역시지방토지수용위원회의 각하재결에 대하여 행정소송을 제기하기 전에 강구할 수 있는 甲의 권리구제수단에 관하여 설명하시오.

01 의의 및 성격 (특별법상 행정심판, 임의전치주의)

- ① 관할토지수용위원회의 위법부당한 재결에 불복이 있는 토지소유자 및 사업시행자가 중앙토지수용위원회에 이의를 신청하는 것으로서 특별법상 행정심판에 해당한다.
- ② 따라서 특별법인 토지보상법에 행정심판의 규정이 있으면 먼저 적용되며, 그 외 사항은 일반법인 행정심판법이 적용된다.
- ③ 종래에는 이의신청절차가 행정심판전치주의인지에 대하여 논란이 있었으나, 토지보상법 제 83조에서 <~할 수 있다>고 규정하여 임의주의적 성격을 갖는다.

02 요건

- ① 중앙토지수용위원회의 재결에 이의가 있는 자는 중앙토지수용위원회에 이의를 신청할 수 있다.
- ② 지방토지수용위원회의 재결에 이의가 있는 자는 해당 지방토지수용위원회를 거쳐 중앙토지수용위원회에 이의를 신청할 수 있다.(처분청 경유주의)
- ③ 이의의 신청은 재결서의 정본을 받은 날부터 30일 이내에 하여야 하는데, 판례는 30일의 불복기간은 토지수용의 특수성, 전문성을 고려하여 수용의 신속을 기한 것으로 국민의 재판을 받을 권리를 제한한 것이 아니라고 하였다.(기간특례)

03 이의신청에 대한 재결 (제84조)

- ① 중앙토지수용위원회는 수용재결이 위법 또는 부당하다고 인정할 때에는 그 재결의 전부 또는 일부를 취소하거나 보상액을 변경할 수 있다.(감액재결 가능)
- ② 보상금이 늘어난 경우 재결서 정본을 받은 날로부터 30일 이내에 사업시행자는 증액된 보상금을 지급 또는 공탁해야 한다.

04 재결의 효력

- ① 쟁송기간 도과 등으로 이의재결의 확정시 민사소송법상의 **확정판결**이 있는 것으로 보고 재결서정본은 집행력 있는 판결의 정본과 동일한 효력을 갖는 것으로 본다.(제86조)
- ② 이의신청은 사업의 진행 및 토지의 사용·수용을 정지시키지 아니한다.(집행부정지)(제88조)

05 대상

- ① 이의신청의 대상은 토지수용위원회의 제34조에 따른 재결이다.
- ② 토지수용위원회의 재결은 수용재결부분(토지등을 수용한다는 결정부분)과 보상재결부분(보상액을 결정하는 부분)으로 분리될 수 있는데, 수용재결과 보상재결 중 한 부분만에 대하여 불복이 있는 경우에도 토지수용위원회의 재결 자체가 이의신청의 대상이 된다.

01 취소소송

1) 의의 및 행정심판의 임의적 전치주의

- ① 토지수용위원회의 재결에 대한 불복이 보상금의 증감에 관한 것이 아닌 경우(수용 자체를 다투는 경우)에는 이의재결을 거쳐 취소소송을 제기하거나, 이의신청을 제기함이 없이 취소소송을 제기할 수 있다.
(무효등확인소송도 제기 가능)
- ② 또한 (구)토지수용법과 달리 (현)토지보상법은 관할 토지수용위원회의 재결에 대해 중앙토지수용위원회에 이의신청을 할 수 있다고 하여 임의적 전치주의로 규정하고 있다.

2) 소송의 대상

(1) 취소소송의 대상(원처분주의와 재결주의)

이의재결을 거친 후에 취소소송을 제기하는 경우 소송의 대상이 수용재결인지 이의재결인지가 문제된다.

(2) 토지보상법의 규정내용

토지보상법은 사업시행자, 토지소유자 또는 관계인은 제34조에 따른 재결에 불복할 때에는 재결서를 받은 날부터 90일 이내에, 이의신청을 거쳤을 때에는 이의신청에 대한 재결서를 받은 날부터 60일 이내에 각각 행정소송을 제기할 수 있다고 규정하고 있다(제85조 제1항).

(3) 판례

대법원은 수용재결에 불복하여 취소소송을 제기하는 때에는 이의신청을 거친 경우에도 수용재결을 한 중앙토지수용위원회 또는 지방토지수용위원회를 피고로 하여 수용재결의 취소를 구하여야 한다는 원처분주의를 취하고 있다(대판 2010. 1. 28. 2008두1504).

(4) 검토

- ① 종래 토지수용법은 <이의신청의 재결에 대하여 불복이 있을 때에는>이라는 표현을 사용하여 재결주의를 채택하고 있었다.
- ② 그러나 토지보상법은 이와 같은 문구를 삭제하고, <제34조에 따른 재결에 불복할 때>라고 규정하여, 행정소송법상 원칙대로 원처분주의를 명확히 규정하고 있다.
- ③ 다만, 이의재결 자체의 고유한 위법이 있을 경우에는 중앙토지수용위원회를 상대로 이의재결의 취소를 구할 수 있다.

3) 행정심판(이의신청) 임의주의

- ① 토지보상법은 이의재결을 거치지 않고도 수용재결을 다투는 행정소송을 제기할 수 있도록 규정하고 있다.
- ② 이는 피수용자의 신속한 권리구제와 분쟁의 조속한 해결을 위해서이다.
- ③ 행정소송은 토지수용위원회의 재결에 불복이 있는 때에 제기할 수도 있고, 이의신청을 거친 때에는 이의재결이 있는 다음에 제기할 수도 있다.

4) 취소소송의 피고

- ① 토지보상법은 취소소송의 피고적격에 관하여 아무런 규정을 두지 않고 있어, 일반법인 행정소송법이 적용된다.
- ② [행정소송법] 제13조 제1항은 다른 법률에 특별한 규정이 없는 한 그 <처분 등을 행한 행정청>을 피고로 한다고 규정하고 있다.
- ③ 따라서 관할 토지수용위원회의 재결에 대하여 불복하는 소송의 경우 관할 토지수용위원회가 피고가 되며, 이의신청에 대한 중앙토지수용위원회의 재결에 불복하는 소송의 경우는 중앙토지수용위원회가 피고가 된다.
- ④ 다만, 이의재결에 불복하는 경우 이의재결 자체에 고유한 위법이 있어야 한다.(원처분주의)

5) 제소기간 (제85조 제1항)

- ① 재결서를 받은 날부터 90일 이내에, 이의신청을 거쳤을 때에는 이의신청에 대한 재결서를 받은 날부터 60일 이내에 각각 행정소송을 제기해야 한다.
- ② 사업시행자는 행정소송을 제기하기 전에 제84조에 따라 늘어난 보상금을 공탁하여야 하며, 보상금을 받을 자는 공탁된 보상금을 소송이 종결될 때까지 수령할 수 없다.
- ③ 이의재결을 거친 후 취소소송은 이의재결이 있는 사실과 그 재결의 내용을 알 수 있었다고 하더라도 이의재결서 송달일로부터 제소기간이 진행된다(대판 1992. 7. 28. 91누12905).
- ④ 2018. 12. 31. 개정 이전에는 제소기간이 현 규정에 비해 짧게(60일, 30일) 규정되어 있었는데, <대법원>은 제소기간을 짧게 규정한 것은 토지수용과 관련하는 공익사업을 신속히 수행할 그 특수성과 전문성을 살리기 위해 필요하다는 취지의 판결을 하였다(대판 1992. 8. 18. 91누9312).

6) 제소 효과

(1) 법원에 대한 효과

- ① 취소소송이 제기되면 당해 사건은 법원에 계속되며, 법원은 심리·판결할 의무를 진다.
- ② 당사자는 동일한 사건에 대하여 중복하여 소를 제기하지 못하게 된다.

(2) 처분에 대한 효과

- ① 토지보상법은 이의신청이나 행정소송의 제기는 사업의 진행 및 토지의 수용 또는 사용을 정지시키지 아니한다고 규정하여 집행부정지원칙을 취하고 있다(제88조).
- ② 다만, 행정소송법에 따라 예외적으로 요건이 충족하는 경우 집행정지가 인정될 것이다.

7) 심리

- ① 심리는 요건심리와 본안심리로 나눌 수 있다.
- ② 취소소송의 심리에 있어서는 <변론주의 및 불고불리원칙>이 적용된다. 따라서, 법원은 원고의 청구범위를 넘어 심리·재판할 수 없다.
- ③ 그러나 행정소송법은 변론주의 원칙에 직권탐지주의를 가미하고 있다.

8) 판결

- ① 소송요건을 갖추지 못하면 각하판결이 행해진다.
- ② 본안판결은 기각판결과 인용판결이다.
- ③ 원고의 청구가 이유 있다고 인정되는 경우에는 처분 등을 취소하는 것이 현저히 공공복리에 적합하지 아니하다고 인정하는 때에 사정판결(행정소송법 제28조)이 인정된다.

9) 관련 문제

(1) 확정판결의 집행력

- ① 취소소송에서 인용판결을 하게 되면 소송 당사자와 관계 행정청은 판결의 내용에 따라 행해야 할 판결의 효력이 발생하고, 기존의 법률관계에 변동을 가져오는 형성력이 생긴다.
- ② 취소판결이 확정되면 당해 처분 효력은 별도의 행위를 기다릴 것 없이 처분시에 소급하여 소멸되고, 기존의 법률관계에 변동을 가져오게 된다.
- ③ 당사자가 확정판결에 따라 이행하지 않을 때 강제집행할 수 있는 집행력도 발생하게 된다.

(2) 사업시행자의 법정이율 가산지급

- ① 사업시행자는 사업시행자가 제기한 행정소송이 **각하·기각 또는 취하**된 경우 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 날부터 **판결일 또는 취하일까지의 기간**에 대하여「소송촉진 등에 관한 특례법」 제3조에 따른 법정이율을 적용하여 산정한 금액을 보상금에 가산하여 지급하여야 한다.

1. 재결이 있는 후 소송을 제기하였을 때에는 재결서 정본을 받은 날
2. 이의신청에 대한 재결이 있는 후 소송을 제기하였을 때에는 그 재결서 정본을 받은 날

- ② 가산금제도를 둔 것은 사업시행자가 보상금 지급을 지연시킬 목적 등으로 행정소송을 남용하는 사례를 막고, 토지소유자의 귀책사유 없는 행정소송으로부터 피수용자의 권리침해를 방지하기 위해서이다.

02 무효등확인소송

1) 의의

- ① 무효등확인소송이란 관할 토지수용위원회의 재결 또는 이의재결의 효력유무 또는 존재여부를 확인하는 소송이다.
- ② 토지보상법은 무효등확인소송을 규정하지 않고 있다.

2) 무효등확인소송의 인정

수용재결이 그 흠이 중대하고 명백한 경우에는 무효등확인소송을 제기할 수 있다.

3) 취소소송에 관한 사항의 일부 적용배제

무효등확인소송은 관계법에서 행정심판 필요적 전치를 규정하고 있는 경우에도 그 적용을 받지 않고, 제소기간의 제한도 적용되지 않는다.

CASE

토지소유자 甲은 위 토지수용위원회의 재결에 불복하여 공익사업법에 따라 보상금의 증액을 구하는 소송을 제기하고자 한다. 이 소송의 의의와 그 특수성을 설명하시오.[26회 문1]

1) 의의 및 취지등

- ① 보상금증감청구소송은 수용재결 중 보상금에 대하여서만 이익이 있는 경우에 보상금의 증액 또는 감액을 청구하는 소송이다.
- ② 종래에는 원고가 손실보상액만을 다투어 제소한 경우에도 법원은 재결 전부를 취소하였다.
- ③ 이 경우 관할 토지수용위원회는 법원의 취소판결에 따라 다시 손실보상액을 정하는 재결을 하고, 여기에도 만족하지 못하는 당사자는 다시 취소소송을 제기하여야 하는 분쟁이 무한히 반복되는 불편이 있었다.
- ④ 이러한 문제를 시정하기 위하여 보상금에 대해서만 불복하는 경우 보상금증감청구소송을 제기할 수 있도록 함으로써, 분쟁을 일회적으로 해결하고, 권리구제의 신속성·실효성 확보를 도모하고 있다.

2) 소송의 성질

(1) 형식적 당사자소송

보상금증감청구소송은 기본적으로 보상금액을 다투는 소송이며 소송을 제기함에 있어 재결청을 피고로 하는 것이 아니라 그 법률관계의 일방 당사자를 피고로 하는 소송에 해당하게 되므로 형식적 당사자소송이라 할 것이다.

(2) 소송의 법적 성질

a. 학설

① 형성소송설

보상금증감청구소송은 실질적으로는 보상액의 취소·변경을 구하는 항고소송으로서, 법원이 재결을 취소하고 정당한 보상액을 판단함으로써 비로소 구체적 손실보상청구권이 형성된다고 한다.

② 확인·금부소송설

보상청구권은 헌법조항에 근거하여 당연히 발생하므로, 법원은 정당보상액을 직접 확인·금부하는 것에 대한 판단이면 충분하다 보는 견해이다.

b. 검토

보상당사자 사이에서 보상금의 증감에 관한 분쟁을 종국적으로 해결하도록 한 입법취지를 고려하고, 분쟁을 일회적으로 해결하도록 한 취지 등을 고려할 때, <확인·금부소송>으로 봄이 바람직하다.

3) 소송의 대상

보상금증감청구소송은 관할 토지수용위원회가 행한 재결로 형성된 법률관계인 보상금의 증감에 관한 것을 소송의 대상으로 삼아야 하며 보상금의 증감에 관한 사항 외에는 소송의 대상이 될 수 없다.

4) 소제기의 요건

- ① 관할 토지수용위원회의 재결에 대하여 토지소유자 또는 관계인이 소송을 제기하는 경우에는 사업시행자를 피고로, 사업시행자가 소송을 제기하는 경우에는 토지소유자 또는 관계인을 피고로 하여,
- ② 재결서를 받은 날로부터 90일 이내에, 이의신청을 거친 경우에는 이의재결서를 받은 날로부터 60일 이내에 피고의 소재지를 관할하는 행정법원 또는 토지 소재지 관할 행정법원에 소송을 제기할 수 있다(제85조 제1항, 제2항).

5) 심리

(1) 소송의 범위

a. 문제점

보상금증감청구소송의 범위에 잔여지수용청구에 관한 것까지 포함할 것인가에 관하여 견해의 대립이 있다.

b. 학설

① 긍정설

확장수용청구의 실질은 피수용자의 이익을 고려한 손실보상의 문제이고, 손실의 범위와 보상의 금액은 밀접한 관련을 지니므로, 보상금증감청구소송 속에 보상의 원인인 **손실의 범위 결정**에 관한 다툼까지도 **포함**하는 것이라고 해석하고 있다.

② 부정설

잔여지수용은 수용의 범위와 관련된 것이며, 수용거부결정은 '처분'이므로 수용재결 자체를 다투어야 한다고 본다.

c. 판례

잔여지 수용청구권은 손실보상의 일환으로 토지소유자에게 부여되는 권리로서 그 요건을 구비한 때에는 잔여지를 수용하는 토지수용위원회의 재결이 없더라도 그 청구에 의하여 수용의 효과가 발생하는 **〈형성권적 성질〉**을 가지므로, 잔여지 수용청구를 받아들이지 아니한 토지수용위원회의 재결에 대하여 토지소유자가 불복하여 제기하는 소송은 토지보상법 제85조 제2항에 규정되어 있는 **‘보상금의 증감에 관한 소송’**에 해당하여 사업시행자를 피고로 하여야 한다(대판 2010. 8. 19. 2008두822).

d. 검토

잔여지 수용청구 등 보상의 원인인 손실범위는 보상금액과 **밀접한 관련**이 있으므로, **분쟁의 일회적 해결**을 위하여 손실범위 결정에 관한 다툼까지도 포함하는 것으로 해석함이 바람직하다.

(2) 입증책임

- ① 원고가 책임을 진다는 견해, 원고와 피고가 부담하여 진다는 견해, 민사소송법상 입증책임 분배에 관한 일반원칙에 의하여야 한다는 견해, 독자적으로 정해야 한다는 견해로 나뉜다.
- ② 당사자소송에 있어서 입증책임은 민사소송법상 일반원칙에 따라 분배된다고 보는 것이 일반적이다.
(법률요건분배설)
- ③ 그러나 대법원은 보상금증감청구소송에 있어서 재결에서 정한 보상금액보다 정당한 손실보상액이 많다는 점에 대한 입증책임은 원고에게 있다고 판시하고 있다(대판 1997. 11. 28. 96누2255).

(3) 보상항목간의 유용

a. 문제점

[토지보상법] 제64조에서는 손실보상은 토지소유자나 관계인에게 개인별로 하도록하는 **개인별 보상의 원칙**을 규정하고 있으므로, 동일인에 속하는 일부 보상항목은 재결보상금보다 과소하고 다른 보상항목은 과다한 경우 법원은 보상항목 **상호 간의 유용**을 허용하여 항목별로 과다 부분과 과소 부분을 합산하여 보상금을 정할 수 있는지 문제된다.

b. 판례

보상은 수용대상이 되는 물건별로 하는 것이 아니라 <피보상자의 개인별>로 행하여지는 것이므로, 피보상자는 수용대상 물건 중 일부에 대하여만 불복이 있는 경우 그 부분에 대하여만 불복의 사유를 주장하여 행정소송을 제기할 수 있다고 할 것이나, 행정소송의 대상이 된 물건 중 일부 항목에 관한 보상액이 과소하고 다른 항목의 보상액은 과다한 경우에는 그 항목 상호간의 유용을 허용하여 과다 부분과 과소 부분을 합산하여 보상금의 합계액을 결정하여야 한다(대판 1998. 1. 20. 96누12597).

c. 검토

개인별보상원칙에 비추어 볼 때, 보상금에 관한 항목별로 액수가 정해져 있다 하더라도 소송물을 개개 항목별로 구분하는 것이 아니라 전체를 불가분의 1개 소송물로 보기 때문에 개인별 총액으로서 보상액의 당부를 소송물로 보아 항목간 유용을 허용함이 합리적일 것이다.

(4) 보상대상 판단 (사업시행자 또는 토지수용위원회가 보상대상을 부정하는 경우)

어떤 토지보상법상 손실보상대상에 해당함에도 <관할 토지수용위원회가 사실을 오인하거나 법리를 오해함>으로써 손실보상대상에 해당하지 않는다고 잘못된 내용의 재결을 한 경우에는, 피보상자는 관할 토지수용위원회를 상대로 그 재결에 대한 취소소송을 제기할 것이 아니라, 사업시행자를 상대로 제85조 제2항에 따른 **보상금증감 청구소송**을 제기하여야 한다(대판 2018.7.20., 2015두4044).

(5) 판결의 효력

- ① 보상금증감청구소송에서 법원은 스스로 보상액의 증감을 결정할 수 있고 토지수용위원회는 별도의 처분을 할 필요가 없다.
- ② 법원의 판결이 있게 되면 기판력·형성력·기속력이 발생하고, 소의 각하·기각 또는 취하의 효과로서 법정이율의 가산지급(제87조)은 보상금증감청구소송에 있어서도 적용되는 것으로 보아야 할 것이다.

6) 청구의 병합

- ① 수용 자체에 대하여 불복이 있을 뿐만 아니라 보상금액에도 불복이 있는 경우에는 수용재결의 취소소송과 보상금증액청구소송을 별도로 제기할 수 있다.
- ② 그런데, 토지소유자는 우선 수용 자체를 다투고 만일 이것이 받아들여지지 않는 경우에는 보상금액의 증액을 청구할 필요가 있을 것이다.
- ③ 이 경우에 수용재결에 대한 취소소송에서 보상금증액청구소송을 예비적으로 병합하여 제기할 수 있는가 하는 것이 문제된다.
- ④ 분쟁의 일회적 해결을 위한다는 점에서 청구의 병합을 인정함이 타당하다.

제1절

토지수용위원회

CASE

공익사업을 위한 토지등의 취득 및 보상에 관한 법률상 토지수용위원회에 대하여 설명하시오.

01 개설

- ① 토지수용위원회는 사업시행자와 토지소유자 또는 관계인과의 사이에서 수용이나 손실보상에 관한 다툼을 당사자가 주장하는 바에 따라 공정·중립의 입장에서 판단하고, 이를 최종적으로 재결하는 **준사법적 행정기관**이다.
- ② 이와 같은 임무를 실현하기 위해 위원회는 독립성을 지니고, 이에 소속되는 위원의 신분을 보장하고 있다.

02 성격

1) 독립된 행정기관

- ① 토지수용위원회는 독립된 행정기관이다.
- ② 토지수용위원회는 공익사업에 필요한 토지등의 수용·사용에 대한 재결을 목적으로 설치되어 있다는 점에서 특별관청으로 이해되기도 한다.

2) 합의제 행정기관

토지수용위원회가 구성위원의 합의에 의해 독립적으로 수용·사용에 관한 재결을 하는 점에서 합의제 행정기관으로서의 성격을 지닌다.

3) 준사법적 행정기관

토지수용위원회는 토지 등의 수용·사용에 관한 재결 사항을 판단하고 결정하는 것을 임무로 하기 때문에, 준사법적 행정기관으로서의 지위를 갖는다.

4) 독립성 및 전문성 인정

토지보상법은 토지수용위원회의 재결사항, 구성위원의 자격 및 임명, 위원의 결격사유와 임기, 신분보장 등에 대하여 규정하고 있고, 위원의 공정성이 의심되는 경우에는 제척·기피·회피 제도를 두고 있으며, 판사·검사 또는 변호사의 직에 15년 이상 있었던 자나 토지수용에 관한 학식과 경험이 풍부한 자 등이 위원이 된다.

03 설치와 구성

1) 위원회의 설치

토지 등의 수용과 사용에 관한 재결을 하기 위하여 국토교통부에 중앙토지수용위원회를 두고, 특별시·광역시·도·특별자치도(이하 “시·도”라 한다)에 지방토지수용위원회를 둔다.

2) 구성

- ① 중앙토지수용위원회는 위원장 1명을 포함한 20명 이내의 위원으로 구성하며, 위원 중 대통령령으로 정하는 수의 위원은 상임으로 한다(토지보상법 제52조 제1항).
- ② 지방토지수용위원회는 위원장 1명을 포함한 20명 이내의 위원으로 구성한다(토지보상법 제53조 제1항).

04 관할

1) 관할의 의의 및 구분(범위)

(1) 관할의 의의

토지수용위원회의 관할이란 토지의 수용·사용에 관한 사업시행자의 재결의 신청에 대하여 중앙토지수용위원회와 지방토지수용위원회 중 어디에서 심의하고 재결할 것인가를 정하는 것을 말한다.

(2) 관할의 구분

- ① 중앙토지수용위원회 : 국가 또는 시·도가 사업시행자인 사업, 수용하거나 사용할 토지가 둘 이상의 시·도에 걸쳐 있는 사업
- ② 지방토지수용위원회 : 중앙토지수용위원회 이외의 사업의 재결(시·도 해당 관할의 사업)

2) 관할 범위내 재결의 종류

- ① 중앙토지수용위원회는 관할 범위내 재결과, 1차적 재결에 대한 불복으로서 이의재결을 담당한다.
- ② 지방토지수용위원회는 관할 범위내 재결만 담당한다.

05 재결사항 (토지보상법 제50조 제1항)

- ① 수용하거나 사용할 토지의 구역 및 사용방법
- ② 손실보상
- ③ 수용 또는 사용의 개시일과 기간
- ④ 그 밖에 이 법 및 다른 법률에서 규정한 사항

CASE

토지보상법상 보상협의회에 대하여 설명하시오.

01 개설

- ① 공익사업을 위한 용지의 취득과 보상은 개인의 재산권과 직접 관련되고, 사업시행자와 토지소유자간에 이해관계가 대립하는 것이다.
- ② 따라서 토지보상법은 주민의 의견수렴과 민원 해소를 위하여 보상협의회를 설치·운영하도록 하고 있다.

02 의의 및 성격 등 (토지보상법 제82조)

1) 의의 및 취지

- ① 보상업무에 관한 사항을 협의하기 위해서 시·군·구에 설치하는 합의제 행정기관이다.
- ② 규정 취지는 보상업무의 지연 초래를 방지하기 위함이다.

2) 성격

(1) 자문기관인지 여부

위원회가 보상업무에 대해 단순히 자문하는 기능을 갖는 것에 불과하고, 위원회에서 논의하여 결정된 사항이라 하더라도 사업시행자를 결코 구속하는 것이 아니기 때문에 의결기관이나 심의기관으로 볼 수 없고 **자문기관**으로 보는 타당하다.

(2) 임의적 및 의무적 보상협의회

a. 의무적 보상협의회

대통령령이 정하는 규모이상의 공익사업을 시행하는 경우 의무적으로 설치하도록 규정한다.
(10만㎡이상이고, 토지소유자 50인 이상인 경우).

b. 임의적 보상협의회

공익사업이 시행되는 해당 지방자치단체의 장은 필요한 경우 보상협의회를 둘 수 있도록 규정한다.

03 협의 사항 (협의회의 기능)

- ① 보상액 평가를 위한 사전 의견수렴에 관한 사항,
- ② 잔여지의 범위 및 이주대책 수립에 관한 사항,
- ③ 해당 사업지역 내 공공시설의 이전 등에 관한 사항,
- ④ 토지소유자나 관계인 등이 요구하는 사항 중 지방자치단체의 장이 필요하다고 인정하는 사항,
- ⑤ 그 밖에 지방자치단체의 장이 회의에 부치는 사항

PART 02

손실보상

Chapter 01 손실보상 일반론

Chapter 02 토지보상법상 손실보상 기준

Chapter 03 손실보상의 내용

Chapter 04 손실보상액의 산정과 평가각론

제1절

손실보상 개요

01 의의 및 취지

행정상 손실보상이란 공공필요에 의한 적법한 공권력 행사로 인하여 개인의 재산권에 가해진 특별한 희생에 대하여, 사유재산권 보장과 공평부담의 차원에서 행정주체가 행하는 조절적인 재산적 보상을 말한다.

02 근거

1) 이론적 근거

특별희생설에 따라 공익을 위해 특정 개인의 재산권에 특별한 희생이 발생한 경우, **공평부담**의 견지에서 이를 사회 전체가 부담해야 한다고 본다.

2) 실정법적 근거

(1) 헌법적 근거

헌법 제23조 제3항은 “공공필요에 의한 재산권의 수용·사용 또는 제한 및 그에 대한 보상은 법률로써 하되, 정당한 보상을 지급하여야 한다.”고 하여 재산권의 제한과 보상에 대한 일반원칙을 규정하고 있다.

(2) 법률상 근거

- ① 행정상 손실보상에 관한 일반법은 없다.
- ② 그러나 토지보상법이 공익사업에 필요한 토지 등 수용과 손실보상에 관하여 일반법적 지위를 가진다.
그 외 하천법, 소방기본법 등 각 개별법에서 손실보상에 관한 규정을 두고 있다.

03 손실보상청구권의 성질

1) 문제점

손실보상청구권의 법적 성질이 공권인지 사권인지 문제된다. 이는 적용 법률 및 쟁송형태 결정에 논의의 실익이 있다.

2) 견해 대립

(1) 공권설

- ① 손실보상은 그 원인행위가 공법적인 것이므로 그 효과로서의 손실보상청구권도 공권이라는 견해이다.
- ② 이에 따르면 손실보상청구에 관한 소송은 공법상 당사자소송에 의하게 된다.

(2) 사권설

- ① 사권설은 손실보상의 원인행위가 비록 공법적인 것이라 하더라도 그에 대한 보상은 사법상 채권·채무관계이기 때문에, 손실보상을 청구하는 권리는 사권이라는 견해이다.
- ② 이에 따르면 손실보상청구에 관한 소송은 민사소송에 의하게 된다.

3) 대법원 입장

- ① 손실보상청구권의 성질에 대하여 대법원은 전통적으로 사권설의 입장이었다.
- ② 그러나 최근 전원합의체 판결에서 [하천법]상의 손실보상청구권을 공법상 권리로 보아 행정상 당사자소송의 대상이 된다고 판시하여 기존 판례의 입장을 변경하였다.
- ③ 그 외 토지보상법상 손실보상청구권도 공법상 권리로 보고 있다.

대법원 2006. 5. 18. 선고 2004다6207 전원합의체

그 법적 성질은 하천법 본칙이 원래부터 규정하고 있던 하천구역에의 편입에 의한 손실보상청구권과 하등 다를 바가 없는 것이어서 공법상의 권리임이 분명하므로 그에 관한 쟁송도 행정소송절차에 의하여야 한다.

대법원 2008. 5. 29. 선고 2007다8129

적법하게 시행된 공익사업으로 인하여 이주하게 된 주거용 건축물 세입자의 주거이전비 보상청구권은 공법상의 권리이고, 따라서 그 보상을 둘러싼 쟁송은 민사소송이 아니라 공법상의 법률관계를 대상으로 하는 행정소송에 의하여야 한다.

4) 검토

손실보상은 공법상 원인을 이유로 이루어지고 있는 점에 비추어 공권으로 봄이 타당하다.

[헌법] 제23조

- ① 모든 국민의 재산권은 보장된다. 그 내용과 한계는 법률로 정한다.
- ② 재산권의 행사는 공공복리에 적합하도록 하여야 한다.
- ③ 공공필요에 의한 재산권의 수용·사용 또는 제한 및 그에 대한 보상은 법률로써 하되, 정당한 보상을 지급하여야 한다.

01 존속보장과 가치보장**CASE**

재산권 가치보장과 존속보장에 관하여 서술하십시오.[17회 문4번]

1) 존속보장**(1) 의의**

- ① 존속보장이란 재산권자가 재산권을 보유하고 향유(사용, 수익, 처분)하는 것을 보장하는 것을 말한다.
- ② 사유재산제도 하에서 재산권은 생활의 기초가 되므로, 존속보장은 중요한 의미를 갖는다.

(2) 헌법적 근거 및 내용과 한계

- ① 헌법 제23조 제1항은 재산권을 기본권으로 보장하고 있고, 재산권의 기본적 내용은 사용권, 수익권, 처분권이다.
- ② 그런데 오늘날 재산권은 공공복리상 사회적 제약을 받는다(헌법 제23조 제2항).
- ③ 따라서 헌법은 재산권은 보장하되, 그 내용과 한계는 법률로 정하는 것으로 규정하고 있다.

(3) 존속보장 실현제도

존속보장의 실현제도로는 공용침해에서의 공공필요 요건, 환매제도, 분리이론, 위법한 재산권 침해행위에 대한 취소소송 등이 있다.

2) 가치보장**(1) 의의**

가치보장이란 공공필요에 의해 재산권에 대한 공권적 침해가 행해지는 경우 재산권의 가치를 보장하기 위해 보상 등으로 가치보장조치를 취하는 것을 말한다.

(2) 헌법적 근거 및 내용과 한계

- ① 헌법 제23조 제3항은 공용침해시 손실보상 의무를 규정하고 있다.
- ② 특히 **정당보상원칙**을 선언하고 있다. 다만, 재산권에 대한 공권적 침해가 재산권의 사회적 제약에 그치는 경우는 보상이 주어지지 않는다.

(3) 손실보상의 요건

- ① 공공필요에 의해 ② 적법한 공권력에 의해 ③ 재산권에 침해가 있고 ④ 이로 인하여 특별한 희생이 발생하여야 하며 ⑤ 손실보상규정이 존재해야 한다.

3) 존속보장과 가치보장의 관계

공공필요를 위해 공용침해가 행해져서 손실보상이 이루어지는 경우, 재산권의 존속보장은 가치보장으로 **전환**된다.

02 경계이론과 분리이론

CASE

손실보상에 있어서 사회적 제약과 특별한 희생의 구별기준에 관하여 경계이론과 분리이론의 입장을 설명하시오.
[14회 문2번]

1) 헌법 제23조의 내용

- ① 헌법 제23조 제1·2항은 재산권의 내용과 한계에 대해서 규정하고 있으므로 **<내용규정>**이라고 하고, 제3항은 공용침해가 있는 경우 손실보상이 필요하다고 규정하고 있으므로 **<공용침해규정>**이라고 한다.
- ② 제2항에서는 재산권에 사회적 제약이 가해지는 경우에는 보상이 필요없으나, 제3항에서 공용침해로 인해 특별한 희생이 발생하는 경우에는 손실보상이 필요하다고 규정하고 있다.
- ③ 그러나 현실적으로 재산권에 대한 어떠한 제한이 사회적 제약인지 특별한 희생인지 구별이 쉽지 않다.
- ④ 이에 이를 구분하기 위한 이론이 **<경계이론과 분리이론>**이다.

2) 경계이론

(1) 의의

경계이론은 재산권의 사회적 제약과 공용침해는 서로 분리된 별개의 제도가 아니라 **<재산권 침해의 정도>**에 따라 경계 지어진 것에 불과하다고 보는 견해이다.

(2) 사회적 제약과 특별한 희생의 구분

보상이 필요하지 않은 사회적 제약에 해당하는 재산권 침해의 경우에도 재산권 침해가 일정 정도를 넘어서게 되면 특별한 희생이 되어 보상이 필요한 공용침해로 **전환**된다.

(3) 재산권의 가치보장에 중점

사회적 제약을 벗어나는 침해에 의해 특별한 희생이 발생하면 보상규정의 유무를 불문하고 보상이 따라야 한다고 본다.

3) 분리이론

(1) 의의

분리이론은 재산권에 대한 사회적 제약과 공용침해를 완전히 서로 독립된 제도로 보아, 양자를 재산권 제한의 정도가 아니라 **<입법의 형식과 목적>**에 의해 구분한다.

(2) 위헌심사기준

위헌심사의 기준도 재산권의 내용규정(사회적 제약)은 일반적인 기본권제한 법률과 마찬가지로 **비례의 원칙**, **평등의 원칙** 등을 기준으로 위헌여부를 판단하지만, 공용침해규정은 공공필요, 정당한 보상 등 헌법 제23조 제3항이 정하고 있는 요건만을 기준으로 판단한다.

(3) 사회적 제약이 수인한계를 넘으면 위헌성

분리이론에 따르면 재산권의 사회적 제약이 경우에 따라 과도한 침해(수용적 효과)를 가져오더라도 이로 인하여 그것이 공용침해로 전환되어 개인에게 보상이 필요한 것이 아니고, 그러한 규정이 비례의 원칙, 평등의 원칙 등을 위반한 경우에 위헌·위법이 되는 것이다.

(4) 재산권의 존속보장에 중점

재산권에 대한 위헌적 침해의 경우에는 침해행위를 배척함으로써 재산권의 존속자체를 원칙적으로 보장해야 한다는 입장이다.

4) 판례의 입장

(1) 대법원

종래 우리 대법원은 경계이론의 입장이라고 보았으나, 최근에는 분리이론을 따르고 있다는 견해도 제기되고 있다.

(2) 헌법재판소

- ① 개발제한구역지정으로 인한 토지소유자의 재산권행사의 제한에 대해, 사회적 제약을 넘는 가혹한 부담을 가져오는 예외적인 경우에는 보상규정을 두지 않은 것이 비례원칙에 위반되어 위헌이라고 헌법불합치결정을 한 바 있다.
- ② 재산권 침해와 공익간의 비례성을 다시 회복하기 위해서 보상규정을 두어야 하고, 반드시 금전보상을 해야 하는 것은 아니고 토지매수청구권과 같은 방법도 사용할 수 있다고 판시하였다.

헌법재판소 1998. 12. 24. 선고 89헌마214

도시계획법 제21조에 규정된 개발제한구역제도 그 자체는 원칙적으로 합헌적인 규정인데 다만 개발제한구역의 지정으로 말미암아 일부 토지소유자에게 사회적 제약의 범위를 넘는 가혹한 부담이 발생하는 예외적인 경우에 대하여 보상규정을 두지 않은 것에 위헌성이 있는 것이고, 보상의 구체적 기준과 방법은 헌법재판소가 결정할 성질의 것이 아니라 광범위한 입법형성권을 가진 입법자가 입법정책적으로 정할 사항이므로, 입법자가 보상입법을 마련함으로써 위헌적인 상태를 제거할 때까지 위 조항을 형식적으로 존속케 하기 위하여 헌법불합치결정을 하는 것인바, 입법자는 되도록 빠른 시일내에 보상입법을 하여 위헌적 상태를 제거할 의무가 있고, 행정청은 보상입법이 마련되기 전에는 새로 개발제한구역을 지정하여서는 아니되며, 토지소유자는 보상입법을 기다려 그에 따른 권리행사를 할 수 있을 뿐 개발제한구역의 지정이나 그에 따른 토지재산권의 제한 그 자체의 효력을 다투거나 위 조항에 위반하여 행한 자신들의 행위의 정당성을 주장할 수는 없다.

재산권의 침해와 공익간의 비례성을 다시 회복하기 위한 방법은 헌법상 반드시 금전보상만을 해야 하는 것은 아니다. 입법자는 지정의 해제 또는 토지매수청구권제도와 같이 금전보상에 갈음하거나 기타 손실을 완화할 수 있는 제도를 보완하는 등 여러 가지 다른 방법을 사용할 수 있다.

03 헌법 제23조 제3항이 불가분 조항인지

1) 의의 및 기능

- ① 불가분조항이란 공용침해의 근거규정과 이에 대한 손실보상규정이 하나의 법률로 규정되어야 하고, 서로 불가분의 관계를 형성하고 있어야 한다는 것이다.
- ② 이는 재산권보장의 실효성 확보 및 가치보장 실현 등에 의의가 있고, 재산권자의 권리보호, 입법자에 대한 경고기능 등을 한다.

2) 우리 헌법상 인정여부

(1) 학설

- ① 헌법 제23조 제3항의 해석과 관련하여 독일 기본법과 우리 헌법은 조문규정방식이 다르다는 점을 들어 불가분조항이 아니라는 견해와
- ② 우리 헌법 제23조 제3항도 불가분조항이라고 보는 견해(다수설)의 대립이 있다.

(2) 판례

“헌법 제23조 제3항 규정은 보상청구권의 근거에 관하여서 뿐만 아니라 보상의 기준과 방법에 관하여서도 법률의 규정에 유보하고 있는 것으로 보아야 하고, (구) 토지수용법과 지가공시법의 규정들은 바로 헌법에서 유보하고 있는 그 법률의 규정들로 보아야 할 것이다.”라고 하여 **불가분조항으로 보고 있는 입장**이다 (대판 1993. 7. 13. 93누2131).

(3) 검토

- ① 헌법 제23조 제3항은 공용침해의 근거규정과 보상규정이 하나의 법률안에 규정될 것을 요구한다고 해석되므로, 불가분조항으로 봄이 타당하다.
- ② 우리 헌법 제23조를 불가분조항으로 해석할 때, 개별법률에서 공용침해를 규정하면서 **손실보상규정을 두고 있지 않는 경우**, 헌법 제23조 제3항에 근거하여 손실보상을 청구할 수 있는지가 문제된다.(후술)

CASE

甲은 하천부지에 임시창고를 설치하기 위하여 관할청에 하천점용허가를 신청하였다. 이에 관할청은 허가기간 만료 시에 위 창고건물을 철거하여 원상복구할 것을 조건으로 이를 허가하였다. 甲은 창고건물철거에 따른 손실보상을 청구할 수 있는지 검토하시오.[20회 문2번]

01 서

손실보상청구권이 인정되려면 손실보상의 요건이 충족되어야 한다.

02 공공필요

1) 개념

- ① 공공필요는 전형적인 불확정개념으로서, 헌법재판소는 이를 <국민의 재산권을 그 의사에 반하여 강제적으로라도 취득해야 할 공익적 필요성>으로 이해하여 왔다.
- ② 공공필요는 기본권의 일반적 제한요건인 <공공복리>보다 엄격한 개념이다.

2) 공공필요의 판단

구체적인 사안에서 공용침해를 통해 얻게 되는 공익과 재산권을 침해당하는 사인의 이익을 비교형량에서, **공용침해를 정당화할 정도의 공익의 우월성이 인정되어야 한다.**(헌재)

3) 공공성의 확대화 경향

오늘날에는 공공성 개념이 복리국가주의의 요청, 행정수요의 증대 등으로 인해 그 개념이 **확대**되고 있는 추세이다.

03 공권력에 의한 적법한 침해

1) 공권적 침해

- ① **공권력 주체에 의하여 직접적으로 의도된 재산권에 대한 침해**가 있어야 한다. 따라서 비의도적 침해의 경우에는 수용적 침해의 법리가 적용된다.
- ② 손실보상이 인정되기 위해서는 재산권에 대한 침해가 현실적으로 발생하고 공익사업과 손실 사이에 **상당한 인과관계**가 있어야 한다.

2) 적법한 침해

- ① 적법한 침해란 법률에 근거한 침해를 의미한다. 여기서 법률은 형식적 의미의 법률을 의미한다.
- ② 불법행위로 인한 손해는 손실보상이 아니라 손해배상의 문제가 된다.

04 재산권에 대한 침해

- ① 재산권이란 소유권 뿐만 아니라 법에 의하여 보호되고 있는 재산적 가치가 있는 일체의 권리를 의미한다.
- ② 재산가치는 현존하는 것이어야만 하므로, 기대이익은 포함되지 않는다.

05 특별한 희생

1) 의의 및 문제점

- ① 손실보상이 인정되려면, 그 침해로 인한 손실이 **특별한 희생**에 해당하여야 한다.
- ② 다만, 구체적인 경우에 있어서 어떤 손실이 보상을 요하는 특별한 손실인지 보상을 요하지 않는 사회적 제약인지 구분이 문제된다.

2) 학설

(1) 형식적 기준설

- ① 침해행위의 <인적범위를 특정할 수 있는지 여부>를 기준으로 판단한다.
- ② 즉, 재산권에 대한 침해가 특정인 또는 한정된 범위의 사람에게 가해진 경우에는 특별한 희생에 해당하고, 재산권 침해가 일반적으로 행해지면 사회적 제약에 해당한다고 본다.

(2) 실질적 기준설

a. 의의

실질적 기준설은 재산권을 침해하는 행위의 실질적 내용(**침해의 본질성 및 강도**)에 따라 공공수용의 개념을 규정하려고 하는 이론이다.

b. 종류

- ① 보호가치가 있는 재산권에 대한 침해만을 보상을 요하는 특별한 희생으로 보는 **보호가치성설**,
- ② 재산권의 본질인 배타적 지배를 침해한 것은 수인 한도를 넘는 것으로 특별한 희생에 해당한다고 보는 **수인한도설**,
- ③ 재산권의 침해가 종래 재산권의 이용목적에 침해하는 경우에 특별한 희생으로 보는 **목적위배설**,
- ④ 재산권의 사적 효용을 본질적으로 침해하는 경우에는 특별한 희생에 해당한다고 보는 **사적효용설**,
- ⑤ 재산권마다 그 위치나 상황이 다를 수 있으므로 보상 여부 결정에 있어서도 구체적인 상황을 고려하여야 한다는 **상황구속성설**,
- ⑥ 재산권 침해의 중대성과 정도를 기준으로 특별희생인지를 판단하는 **중대성설** 등이 있다.

3) 판례

(1) 대법원

(구)도시계획법상 개발제한구역지정으로 인한 토지소유자의 재산권행사의 제한은 **사회적 제약**에 불과하다고 보았다.

(2) 헌법재판소

- ① 개발제한구역 지정으로 인한 개발가능성 소멸과 그에 따른 지가하락은 토지소유자가 감수해야 하는 사회적 제약이라고 판시하였다.
- ② 그러나 토지를 종래의 목적으로도 사용할 수 없거나 실질적으로 토지의 사용·수익의 길이 없는 경우 등 사회적 제약의 한계를 넘는 가혹한 부담이 발생하는 예외적인 경우에도 보상규정을 두지 않은 것은 비례의 원칙에 위반되어 헌법에 위반된다고 판시하였다.

4) 검토 (복수기준설)

- ① 우리나라의 통설은 형식적 기준설과 실질적 기준설을 종합하여 특별한 희생과 사회적 제약을 구별하여야 한다고 본다.
- ② 형식적 기준설에 따라 재산권의 침해가 특정 범위의 사람에 대하여 가해진 것인지 여부와, 실질적 기준설에 따라 침해의 본질성 및 강도를 고려하여 특별한 희생인지 여부를 판단해야 한다.

06 보상규정의 존재

CASE

甲은 A도내 일정지역에서 20년 이상 제조업을 운영하여 왔다. A도지사는 (가칭) 청정자연 보호구역의 지정 및 관리에 관한 법률을 근거로 甲의 공장이 포함되는 B지역 일대를 청정자연보호구역으로 지정하였다. 그 결과 B지역 내의 모든 제조업자들은 법령상 강화된 폐수 배출허용기준을 준수하여야 한다. 이에 대해 甲은 변경된 기준을 준수하는 것이 기술적으로 어려울 뿐만 아니라, 수질정화시설을 갖추는 데 과도한 비용이 소요되므로, 이는 재산권의 수용에 해당하는 것으로 손실보상이 주어져야 한다고 주장한다.

甲재산권의 규제에 대한 보상규정이 위 법률에 결여되어 있는 경우 甲주장의 타당성을 검토하십시오.[18회 문1번 변형]

1) 문제점

- ① 개별법률에서 손실보상에 관한 규정이 있어야 공용침해에 대한 손실보상이 가능하다.
- ② 공용침해가 특별한 희생임에도 불구하고 개별법률에서 손실보상규정을 두지 않은 경우, 헌법 제23조 제3항의 규정만으로 손실보상을 청구할 수 있는지가 문제된다.

2) 학설 [직방위보유]

(1) 직접효력설

헌법 제23조 제3항이 직접 국민에 대하여 효력을 가진다고 보아, 개별규정에 보상규정이 없는 경우에도 헌법 제23조 제3항을 직접 근거로 하여 손실보상을 청구할 수 있다고 한다.

(2) 방침규정설

헌법 제23조 제3항은 규범적 효력은 없고 단지 입법자에 대한 입법방침규정에 불과하므로 보상규정을 둘 것인가 하는 문제는 입법자의 재량판단의 문제라고 본다. 따라서 보상규정이 없으면 손실보상을 청구할 수 없다고 한다.

(3) 위헌무효설

헌법 제23조 제3항을 불가분조항으로 보아 공용침해를 규정하면서 보상규정을 두지 않은 법률은 위헌으로 무효이고, 그에 근거한 공용침해행위는 위법한 직무행위가 되므로, 그 경우 「국가배상법」에 의거한 손해배상 청구만 가능하고 직접 헌법규정에 근거하여 손실보상을 청구할 수는 없다고 한다.

(4) 보상입법부작위 위헌설

공공필요를 위하여 공용침해를 규정하면서 손실보상규정을 두지 않은 경우 그 공용침해규정 자체는 헌법에 위반되는 것은 아니고, 손실보상을 규정하지 않은 입법부작위가 위헌이라고 한다.

(5) 유추적용설

공용침해에 따르는 보상규정이 없는 경우에는 헌법 제23조 제1항(재산권 보장규정) 및 제11조(평등원칙)를 근거하여 헌법 제23조 제3항 및 관계규정을 유추적용하여 손실보상을 청구할 수 있다고 한다.

3) 판례

(1) 대법원

최근 대법원은 유추적용설 입장에서 공용침해로 인한 특별한 손해에 대해 보상규정이 없는 경우 관련 보상규정을 유추적용하여 손실보상을 하여야 한다고 판시하고 있다.

(2) 헌법재판소

개발제한구역 지정으로 토지소유자에게 사회적 제약의 범위를 넘는 가혹한 부담이 발생하는 예외적인 경우에도 보상규정을 두지 않은 것은 위헌성이 있는 것이고, 보상의 구체적인 기준과 방법은 입법자가 정할 사항이라고 판시하였다. 이는 위헌무효설을 취한 것으로 평가되기도 한다.

4) 검토

현행 헌법 제23조 제3항이 정당보상의 원칙을 선언하고 있고, 정당보상액을 법원이 결정할 수 있으므로 국민의 권리구제의 실효성을 위하여 <직접효력설>이 타당하다.

※ 보충자료 - 그 밖의 손실보상이론

1. 수용유사침해이론

(1) 의의

<위법한> 공용침해로 인하여 특별한 희생을 입은 자에 대하여 그 근거법령에 보상규정이 없는 경우에도 수용에 준하여 그 손실을 보상해 주어야 한다는 이론을 말한다.

(2) 성립요건

- ① 본래 행정상 손실보상의 모든 요건은 갖추어야 하고, 침해의 위법성 요건만이 다르다.
- ② 이 경우 침해의 위법성은 행정상 손해배상에 있어서의 위법개념이 아니라, 공용침해 자체는 법률에 근거하여 적법하나, 헌법이 요구하는 보상규정을 두지 않아 그 근거 법률이 위헌이라는 점에서 위법을 의미한다.

2. 수용적 침해이론

(1) 의의 및 법적 근거

- ① 수용적 침해란 적법한 공권력 행사의 비정형적이고 비의도적인 부수적 효과로서 발생한 개인의 재산권 손실에 대하여 손실보상을 인정하자는 이론이다.
- ② 이는 보상규정이 없는 경우에도 당해 행위의 위법성 문제를 제기하지 않고 그로 인한 손실을 전보해 주려는 데 의의가 있다.
- ③ 우리나라의 경우 헌법상 기본권 보장, 법치국가 원리, 사회국가 원리 등에서 근거를 찾을 수 있다.

(2) 인정요건

- ① 공공필요에 의한 재산권의 침해로서, 적법한 공권력 행사로 의도하지 않은 비정형적*비의도적인 손실이 발생해야 한다.
- ② 손실은 사회적 제약을 넘은 특별한 희생이어야 한다. 예를 들어, 공익사업의 공사 때문에 인근 상가의 매출에 타격을 주는 경우가 해당한다.

01 서

헌법 제23조 제3항의 정당보상원칙에 의거하여 공용수용의 일반법인 토지보상법은 손실보상에 관하여 기본원칙을 정하고, 손실보상의 내용에 관하여 구체적인 규정을 두고 있다.

02 사업시행자 보상 원칙 (제61조)

- ① 공익사업에 필요한 토지 등의 취득 또는 사용으로 인하여 토지소유자나 관계인이 입은 손실은 사업시행자가 보상하여야 한다.
- ② 사업시행자수용권설에 의하면 보상해야 할 손실의 원인을 제공한 자가 사업시행자이기 때문에 손실의 보상도 사업시행자가 해야 하는 것으로 보고 있다.

03 사전보상의 원칙 (제62조)

1) 의의 및 취지

- ① 사업시행자는 해당 공익사업을 위한 공사에 착수하기 이전에 토지소유자와 관계인에게 보상액의 전액을 지급하여야 한다.
- ② 사전보상원칙은 피수용자가 권리를 상실하기 전에 보상받을 수 있도록 하여 보상받지 않은 상태에서 권리를 상실하는 일이 없도록 하고, 피수용자의 대체지 취득 등을 고려하여 피수용자를 보호하기 위한 입법정책상 배려라 할 수 있다.

2) 사전보상원칙 보장제도

토지보상법은 사업시행자가 수용 또는 사용의 개시일까지 관할 토지수용위원회가 재결한 보상금을 지급 또는 공탁하지 않으면 재결의 효력이 실효되도록 규정함으로써 사전보상원칙을 보장하고 있다.

3) 사전보상원칙의 예외

(1) 제62조 단서에 의한 경우

천재지변시 토지사용에 대한 보상(제38조)과 시급한 토지사용의 경우의 보상(제39조)은 사전보상의 예외가 인정된다. 또한 토지소유자 및 관계인의 승낙이 있는 경우에는 사후보상이 가능하다.

(2) 사전보상이 불가능한 경우

타인토지출입의 측량 및 조사로 인한 손실(제9조 제4항), 장애물 제거로 인한 손실(제12조 제4항), 사업인정 실효로 인한 손실(제23조 제2항), 사업의 폐지 및 변경으로 인한 손실(제24조 제7항), 재결의 실효로 인한 손실(제42조 제2항) 등의 경우에 사전보상의 예외가 인정된다.

04 현금보상의 원칙 (제63조)

1) 의의 및 취지

- ① 손실보상은 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 현금으로 지급하여야 한다.
- ② 현금보상이 자유로운 유통이 보장되고 대체지를 신속하게 취득할 수 있는 수단이므로, 재산권 침해로 인해 상실된 재산가치를 복원하는 데 가장 유효한 수단이 될 수 있다.

2) 현금보상의 문제점

대규모 공익사업이 시행으로 인하여 인근지역의 지가가 상승하게 되면 현금보상금으로 편입면적과 동일한 면적의 대체지 구입이 사실상 어렵게 된다.

3) 현금보상원칙의 예외

(1) 채권보상

채권보상이란 일정한 요건에 해당하는 피수용자에 대하여 채권으로 보상하도록 하는 방법이다.

(2) 대토보상

- ① 토지보상법상 현물보상의 방법에는 대체지보상, 공사대행에 의한 보상, 이전대행에 의한 보상이 있다.
- ② 이 외에도 조성택지의 공급에 의한 보상 등도 현물보상에 해당한다. 이는 당사자 쌍방의 편의, 특히 생활의 재건을 완전하게 함으로써 얻어지는 피수용자의 이익 및 사회경제상의 편리를 고려한 것이다.

05 개인별 보상의 원칙 (제64조)

손실보상은 토지소유자나 관계인에게 개인별로 하여야 한다. 다만 개인별로 보상액을 산정할 수 없을 때에는 그러하지 아니하다.

06 일괄보상의 원칙 (제65조)

- ① 사업시행자는 동일한 사업지역에 보상시기를 달리하는 동일인 소유의 토지 등이 여러 개 있는 경우 토지소유자나 관계인이 요구할 때에는 한꺼번에 보상금을 지급하도록 하여야 한다.
- ② 이는 보상액을 동시에 일괄지급함으로써 피보상자의 대토구입을 용이하게 하기 위한 취지이다.

07 사업시행 이익과의 상계금지원칙 (제66조)

- ① 사업시행자는 동일한 소유자에게 속하는 일단의 토지의 일부를 취득하거나 사용하는 경우, 해당 공익사업의 시행으로 인하여 잔여지의 가격이 증가하거나 그 밖의 이익이 발생한 경우에도 그 이익을 그 취득 또는 사용으로 인한 손실과 상계할 수 없다.
- ② 수용대상이 되지 않는 토지와 보상금은 직접 관계가 없으므로, 잔여토지의 개발이익을 보상금에서 차감할 수 없도록 하여 피수용자를 보호하기 위한 제도이다.
- ③ 잔여지의 개발이익은 비록 공익사업으로 발생한 것이라 하더라도 국가가 개발이익으로 환수할 수는 있어도 사업시행자가 취득한 목적물에 대한 보상과는 상계할 것이 아니다(대판 1998. 9. 18 97누13375).

08 시가보상의 원칙 (제67조 제1항)

- ① 보상액의 산정은 협의에 의한 경우에는 협의 성립 당시의 가격을, 재결에 의한 경우에는 수용 또는 사용의 재결 당시의 가격을 기준으로 한다(제67조 제1항).
- ② 현행법은 시가보상원칙을 채용하고 있으며, 이는 헌법에서 수용에 대하여 정당보상을 하도록 규정하고 있는 것과 합치하는 것이라고 보는 것이 일반적이다.

09 개발이익 배제의 원칙 (제67조 제2항)

보상액을 산정할 경우에 해당 공익사업으로 인하여 토지등의 가격이 변동되었을 때에는 이를 고려하지 아니한다.

CASE

채권보상에 대하여 서술하시오. [3회 문3번]

01 개설

- ① 토지보상법은 정당보상 실현을 위해 현금보상원칙을 채용하고 있으나, 현금보상원칙은 인근지역에 일시에 대토수요, 투기적 수요의 증대로 지가상승을 야기하는 문제가 있었다.
- ② 이러한 현금보상원칙의 문제점을 해결하고, 사업시행자의 자금 확보를 지원하고자 채권보상이 도입되었으나, 그 위헌성 여부에 대하여 논란이 있다.

02 의의 및 취지

- ① 채권보상이란 보상금 지급시 일정한 경우 채권으로 지급하는 것이다.
- ② 공익사업에 필요한 용지보상비가 사업비에서 차지하는 비율이 점차 증가됨에 따라 사회간접자본시설의 설치에 어려움을 겪고 있는 현실을 반영하여 사업시행자의 자금 확보를 지원하고자 하는 제도이다.

03 채권보상제도의 위헌성 여부

1) 문제점

- ① 헌법상 정당보상에 대하여 판례는 보상금액 및 보상의 시기·방법에도 어떠한 제한을 두어서는 안 된다고 판시한다.
- ② 채권보상이 환가나 수익률에서 현금보상보다 불리함에도 강제하는 것은 헌법상의 재산권보장규정 및 정당보상의 원칙에 반하여 위헌은 아닌지,
- ③ 또한 채권보상의 대상이 되는 부채부동산소유자의 토지에 대하여는 다른 재산권과 구별하여 채권보상을 하도록 한 것은 헌법상 평등원칙에 위배될 수 있는지 위헌성 논란이 있다.

2) 학설

(1) 위헌설

- ① 정당보상은 보상의 시기나 방법 등에 제한이 있어서는 안되므로 채권보상은 보상방법의 선택권을 제한하는 것이 되어 정당보상에 위배된다고 보며,
- ② 국가의 열악한 재정목적을 위한 과도한 수단이므로 비례의 원칙에 위배된다는 점 및
- ③ 부채부동산소유자의 토지에만 채권보상을 강제하는 것은 평등원칙에 위배된다는 점에서 채권보상은 위헌이라고 본다.

(2) 합헌설

- ① 통상적인 수익만 보장되고 유동성이 확보된다면 정당보상에 해당하며,
- ② 부채지주 등은 토지를 자산증식수단으로 소유하고 있으므로 통상적인 수익만 보장된다면 합헌이라는 점
- ③ 상환기간, 이율이 명확하게 규정되어 있어 비례의 원칙에 위배된 것이 아니라는 점 및
- ④ 사회간접시설의 확충과 국가예산부족이라는 공익적 사정을 고려할 때 채권으로 보상한다고 하여 합헌이라고 본다.

3) 검토

- ① 토지보상법은 채권보상에 의하더라도 정당보상의 수준이 될 수 있도록 상환기간, 이자율을 명확히 정하고 있으며, 통상적인 경우에는 토지소유자 등이 원하는 경우에만 인정하므로 위헌이라고 판단되지 않는다.
- ② 또한 공익사업의 원활화 및 손실보상금의 투기자금화를 방지한다는 점에서도 채권보상은 정당하다고 볼 수 있다.

※ 보충자료 - 채권보상의 요건

1. 임의적 채권보상 (토지보상법 제63조 제7항)

- ① 사업시행자가 국가, 지방자치단체, 대통령령으로 정하는 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따라 지정·고시된 공공기관 및 공공단체인 경우로서
- ② 토지소유자나 관계인이 원하는 경우 또는
- ③ 사업인정을 받은 사업의 경우 부채부동산 소유자의 토지에 대한 보상금이 1억 원을 초과하는 경우로서 그 초과금액에 대하여 사업시행자가 발행하는 채권으로 지급할 수 있다.

2. 의무적 채권보상 (토지보상법 제63조 제8항)

- ① 토지투기가 우려되는 지역(대통령령으로 별도 정함)에서 공공기관 및 공공단체(대통령령으로 별도 정함)가 「택지개발촉진법」에 의한 택지개발사업 등 대규모 개발사업(대통령령으로 별도 정함)을 시행하는 경우,
- ② 부채부동산 소유자의 토지에 대한 보상금 중 1억 원 이상의 일정금액(1억원) 초과 부분에 대하여는 해당 사업시행자가 발행하는 채권으로 지급하여야 한다.

CASE

택지개발사업이 시행되는 지역에 농지 4,000㎡를 소유하고 있던 甲은 보상금으로 사업주변지역에서 같은 면적의 농지를 대토하고자 하였다. 이 지역의 농지가격수준은 사업이 시행되기 이전만 하더라도 주변지역과 같게 형성되고 있었다. 그러나 해당 사업으로 인해 주변지역의 지가가 상승하여 甲은 보상금으로 3,000㎡밖에 매입할 수 없었다. (40점)

- 1) 甲이 받은 보상은 정당보상에 해당한다고 볼 수 있는가 (20점)
- 2) 甲과 사업주변지역 토지소유자와의 불공평관계에서 나타나는 문제점과 개선대책은 (20점) [9회 1번]

01 의의 및 취지 (토지보상법 제63조 제1항)

- ① 대토보상이란 공익사업으로 조성된 토지로 보상받을 수 있는 제도를 말한다.
- ② 사업시행자의 손실보상금의 부담을 경감하고, 토지구입 수요를 줄임으로써 인근지역 부동산 가격의 상승을 억제할 수 있으며 토지소유자가 개발혜택을 일정 부분 공유할 수 있도록 하는 기능을 갖는 제도이다.
- ③ 대토보상은 현물보상의 하나로 유사토지 구입의 어려움을 해소해 주는 기능도 한다.

02 토지로 보상받을 수 있는 자

- ① 토지로 보상받을 수 있는 자는 토지의 보유기간 등 대통령령으로 정하는 요건을 갖춘 자로서 건축법 제57조 제1항에 따른 대지의 분할제한 면적 이상의 토지를 사업시행자에게 양도한 자가 된다.
- ② 이 경우 대상자가 경합하는 때에는 제7항 제2호에 따른 부채부동산소유자가 아닌 자 중 해당 공익사업지구내 거주하는 자로서 토지 보유기간이 오래된 자 순으로 토지로 보상하며, 그 밖의 우선순위 및 대상자 결정방법 등에 관하여는 사업시행자가 정하여 공고한다(제63조 제1항 제1호).
- ③ 공익사업을 위한 관계 법령에 따른 고시 등이 있는 날 당시 중앙행정기관, 지방자치단체, [공공기관의운영에 관한 법률] 제4조에 따른 공공기관 및 [지방공기업법]에 따른 지방공기업 어느 하나에 해당하는 기관에 종사하는 자 및 종사하였던 날부터 10년이 경과하지 아니한 자는 제외한다.

03 대토보상의 내용

1) 요건

토지소유자가 원하는 경우로서 사업시행자가 해당 공익사업의 합리적인 토지이용계획과 사업계획 등을 고려하여 토지로 보상이 가능한 경우이어야 한다.(제63조 제1항)

2) 범위

토지소유자가 받을 보상금 중 본문에 따른 현금 또는 채권으로 보상받는 금액을 제외한 부분에 대하여 대토보상이 행해진다.(제63조 제1항)

3) 보상하는 토지가격의 산정 기준금액

다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 <일반 분양가격>으로 한다(제63조 제1항 제2호).

4) 토지로 보상하는 면적

- ① 제1항 단서에 따라 토지소유자에 대하여 토지로 보상하는 면적은 사업시행자가 그 공익사업의 토지이용계획과 사업계획 등을 고려하여 정한다.
- ② 이 경우 그 보상면적은 주택용지는 990평방미터, 상업용지는 1,100평방미터를 초과할 수 없다.(제63조 제2항)

5) 현금보상으로 전환

(1) 토지소유자의 현금보상으로 전환 요청

- ① 보상계약체결일부터 1년이 지나면 이를 현금으로 전환하여 보상해 줄 것을 요청할 수 있다.
- ② 사업시행자는 토지소유자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하여 토지로 보상받기로 한 보상금에 대하여 현금보상을 요청한 경우에는 현금으로 보상하여야 한다.(법63조 6항)

- 1호. 국세 및 지방세의 체납처분 또는 강제집행을 받는 경우
- 2호. 세대원 전원이 해외로 이주하거나 2년 이상 해외에 체류하려는 경우
- 3호. 그 밖에 제1호·제2호와 유사한 경우로서 국토교통부령으로 정하는 경우

(2) 사업시행자가 현금보상으로 전환

사업시행자는 해당 사업계획의 변경 등 국토교통부령으로 정하는 사유로 보상하기로 한 토지의 전부 또는 일부를 토지로 보상할 수 없는 경우에는 현금으로 보상할 수 있다.(법63조 5항)

제1절

정당보상

01 헌법상 기준

CASE

토지보상법 제70조에 따라 취득한 토지의 보상액을 공시지가 기준으로 산정하는 것이 정당보상 원칙에 부합하는지 논하시오. [12회 문2 변형]

1) 정당보상

(1) 문제점

- ① 헌법 제23조 제3항은 <공공필요에 의한 재산권의 수용·사용 또는 제한 및 그에 대한 보상은 법률로써 하되, 정당한 보상을 지급하여야 한다>고 규정하고 있다.
- ② <정당한 보상>이 무엇을 의미하는가에 관하여 학설상 견해의 대립이 있다.

(2) 견해 대립

a. 완전보상설

- ① 공용침해로 인하여 발생한 객관적 손실 전부를 보상하여야 한다는 견해이다.
- ② 우리나라에서 다수 견해는 완전보상설을 지지하고 있고, 일반적으로 완전보상은 피침해재산의 <객관적 가치의 보상과 함께 부대적 손실의 보상>도 포함하는 것으로 이해하고 있다.
- ③ 오늘날에서는 <생활보상>을 완전보상의 범주에 포함시키며 완전보상을 공용침해가 일어나기 전의 생활과 유사한 생활수준을 회복하도록 하는 보상으로 이해하는 견해가 새롭게 제기되고 있다.
- ④ 단, 정신적 손해와 개발이익은 완전보상에 포함되지 않는다고 보는 것이 일반적 견해이다.

b. 상당보상설

- ① 재산권의 사회적 제약 내지 사회적 구속성, 재산권의 공공복리 적합의무의 관점에서 공·사익을 형량하여 보상내용이 결정되어야 한다는 견해이다.
- ② 이 견해는 완전보상을 원칙으로 하되 합리적인 이유가 있는 경우에는 완전보상을 하회할 수도 있다는 입장이다.

c. 절충설

학자에 따라서는 정당한 보상이 상황에 따라 완전보상 또는 상당보상일 수 있다는 견해를 언급하기도 한다.

(3) 판례

- ① <대법원>은 보상의 시기·방법 등에 어떠한 제한도 없는 완전한 보상을 의미한다고 하였다.
- ② <헌법재판소>는 원칙적으로 피수용재산의 객관적인 재산가치를 완전하게 보상하는 것이어야 한다는 완전보상을 뜻하는 것으로서, 보상금액 뿐만 아니라 보상의 시기나 방법 등에 있어서도 어떠한 제한을 두어서는 아니 된다는 것을 의미한다고 하였다.(헌재 1990. 6. 25. 89헌마107)

(4) 검토

- ① 헌법 제23조 제3항의 정정보상이 상황에 따라 완전보상을 하회할 수 있다는 상당보상설은 평등원칙에 위배될 소지가 있다.
- ② 따라서 피침해자의 재산적 가치를 완전하게 보상하는 **완전보상설**이 타당하다.

2) 정정보상 의미의 확대

- ① 보상대상은 일반적으로 당해 재산권에 대한 보상으로 이해되어 왔다.
- ② 손실보상 이론에 사회복리국가 이념이 도입됨에 따라 보상은 부대적 손실까지 포함하는 재산권보상은 물론 피수용자의 생활안정까지 확대하여 생활보상도 포함해야 한다는 주장이 일반화되고 있다.

01 객관적 기준평가

기준시점에 있어서의 **일반적인 이용방법**(일반인이 이용할 것으로 기대되는)에 의한 **객관적 상황**(제3자의 입장에서)을 기준으로 평가하여야 하며, 토지소유자가 갖는 주관적 가치(개인적 애착심, 감정가치)나 특별한 용도(토지가 소재한 지역의 일반적인 이용상황이 아닌 특정한 용도)에 사용할 것을 전제로 한 것은 이를 고려하지 아니한다.

02 현실적인 이용상황 기준 감정평가

1) 원칙 (제70조 제2항)

토지에 대한 보상액은 **가격시점에서의 현실적인 이용상황과 일반적 이용방법**에 의한 객관적 상황을 고려하되, 일시적인 이용상황과 토지소유자나 관계인이 갖는 주관적 가치 및 특별한 용도에 사용할 것을 전제로 한 경우 등은 고려하지 아니한다.

2) 현실적인 이용상황의 의미

〈현실적인 이용상황〉이란 지적공부상의 지목에 불구하고 가격시점에 있어서의 당해 토지의 주위환경이나 공법상 규제 정도 등으로 보아 인정 가능한 범위의 이용상황을 말한다.

대판 1994. 4. 12. 93누6904

토지가격의 평가를 함에 있어 공부상 지목과 실제 현황이 다른 경우에는 공부상 지목보다는 실제 현황을 기준으로 하여 평가하여야 함이 원칙이며, 평가대상 토지에 형질변경이 행하여지는 경우 형질변경행위가 완료되어 현황의 변경이 이루어졌다고 보여지는 경우에는 비록 공부상 지목변경절차를 마치기 전이라고 하더라도 변경된 실제 현황을 기준으로 평가함이 상당하다.

3) 예외

(1) 현황평가 예외의 정당성

- ① 일시적 이용상황, 미지급용지 등은 현황평가의 예외로서 **본래의 지목**에 따라 평가한다.
- ② 이는 위법행위의 합리화 조장 방지, 토지소유자 보호 등의 취지가 반영된 것으로서 정당보상에 해당한다고 봄이 타당하다.

(2) 일시적인 이용상황

- ① 〈일시적인 이용〉이란 관계 법령에 의한 국가 또는 지방자치단체의 계획이나 명령 등에 의하여 당해 토지를 본래의 용도로 이용하는 것이 일시적으로 금지 또는 제한되어 그 본래의 용도 외의 다른 용도로 이용되고 있거나 당해 토지의 주위환경의 사정으로 보아 현재의 이용방법이 임시적인 것을 말한다(령 제38조).
- ② 대법원은 채석지의 경우 산림복구가 법령상 예정되어 있어 그 이용상황은 일시적인 것에 불과하므로 공부상 지목에 따라 임야로 평가하는 것이 마땅하다고 한다.(대판 2000.2.8. 97누15845)

(3) 무허가건축물 등의 부지, 불법형질변경 토지

무허가건축물 등의 부지와 불법형질변경 토지는 위법행위로 인한 불합리한 보상을 차단하기 위해, 현황이 아닌 종전의 이용상황을 기준으로 판단한다.

(4) 미지급용지

- ① 미지급용지는 종전 공익사업에 편입될 당시의 이용상황을 상정하여 평가한다.
- ② 공익사업에 편입될 당시의 이용상황이란 편입될 당시의 지목, 실제용도, 지형, 지세, 면적, 도로와의 접근정도 등 개별요인을 의미한다.

03 개별 감정평가

- ① 토지와 건물은 제도적 측면에서 별개의 부동산으로 취급되므로 각각 평가한다.
- ② 그리고 토지도 개별필지마다 개별성이 있으므로 필지별로 평가한다.
- ③ 또한 부동산의 가치는 본질적으로 권익에 대한 가치로, 권익마다 가치형성요인이 다르므로 권익마다 개별로 감정평가한다.
- ④ 다만, 토지의 개별감정평가에 대한 예외로서 일괄평가, 구분평가, 부분평가를 하는 경우가 있다.

04 건축물 등이 없는 상태 기준

- ① 토지에 건축물·입목·공작물 그 밖에 토지에 정착한 물건(이하 "건축물등")이 있어도 건축물등이 없는 상태를 상정하여 평가한다.
- ② 이는 건부감가를 고려하지 않고 토지의 보상액을 산정하라는 취지로 해석할 수 있다.

05 해당 공익사업으로 인한 가격변동 배제

보상금액의 산정에 있어서 해당 공익사업으로 인하여 토지 등의 가격이 변동되었을 때에 이를 고려하지 않는 것을 말한다.(토지보상법 제67조 제2항)(후술)

06 공시지가기준 감정평가

취득하는 토지를 평가함에 있어서는 평가대상 토지와 유사한 이용가치를 지닌다고 인정되는 하나 이상의 표준지의 공시지가를 기준으로 한다(칙 제22조 제1항).(후술)

01 개설

협이나 재결에 의하여 취득하는 토지에 대하여는 부동산공시법에 따른 공시지가를 기준으로 보상액을 산정하도록 하고 있다(제70조 제1항).

02 공시지가의 선정

1) 사업인정 전 협의취득의 경우

- ① 공시지가는 해당 토지의 가격시점 당시 공시된 공시지가 중 **가격시점과 가장 가까운 시점에 공시된 공시지가**로 한다(제70조 제3항).
- ② 일반적으로 협의취득의 경우 보상액 산정은 이 기준에 의하고 있다.
- ③ 그러나 협의취득은 사법상 계약이기 때문에 당사자 간 협의에 의해 매매대금을 따로 정하여 보상액으로 한다고 하여 위법한 것은 아니다(대판 1998. 5. 22. 98다2242,2259).
- ④ 따라서 당사자 간 합의로 손실보상의 요건을 완화하는 약정도 가능하고, 손실보상의 기준에 의하지 아니하는 매매대금도 정할 수 있다(대판 1999. 3. 23. 98다48866).

2) 사업인정 후 취득의 경우

(1) 기준, 취지

- ① 사업인정 후 취득의 경우 공시지가는 **사업인정고시일 전의 시점을 공시기준일로 하는 공시지가**로서, 해당 토지에 관한 협의의 성립 또는 재결 당시 공시된 공시지가 중 **사업인정고시일과 가장 가까운 시점에 공시된 공시지가**로 한다(제70조 제4항).
- ② 이는 사업인정 후에 발생한 **개발이익을 보상액 산정에서 배제하기 위한 목적으로** 두어진 규정이다.

(2) 관련 헌법재판소 판례

이 규정에 대하여 헌법재판소는 공시지가에 개발이익이 포함되는 것을 방지하기 위한 것으로 개발이익이 배제된 손실보상액을 산정하는 적정한 수단에 해당되므로 헌법 제23조 제3항에 위반된다고 할 수 없다고 한다 (헌재 2009. 12. 29. 2009헌바142, 헌재 2009. 9. 24. 2008헌바112, 헌재 2009. 7. 30 2007헌바76).

3) 당해 사업으로 인한 가격변동시 적용 공시지가

상기 규정에 불구하고 공익사업의 계획 또는 시행이 공고되거나 고시됨으로 인하여 취득해야 할 토지의 가격이 변동되었다고 인정되는 경우 공시지가는 **해당 공고일 또는 고시일 전의 시점을 공시기준일로 하는 공시지가**로서 그 토지의 가격시점 당시 공시된 공시지가 중 그 공익사업의 공고일 또는 고시일과 가장 가까운 시점에 공시된 공시지가로 한다(제70조 제5항, 시행령 제38조의2).

03 시점수정에 의한 산정

공시기준일부터 가격시점까지의 해당 공익사업으로 인한 지가의 영향을 받지 아니하는 지역의 지가변동률, 생산자물가상승률 등을 고려하여 평가한다.(제70조 제1항)

04 지역요인의 비교 및 개별요인의 비교

1) 지역요인 비교

- ① 토지보상법은 지역요인의 고려에 대하여는 규정하고 있지 않다. 그러나 대법원은 보상액의 산정시 지역요인의 비교를 긍정하고 있다(대판 1995. 7. 25. 93누4786).
- ② 그리고 개별요인 및 지역요인을 대비하여 분석하려면 공시기준일 현재의 표준지 상태와 수용재결될 당시의 수용대상토지의 상태를 비교하여야 한다고 한다.(대판 1993. 2. 9. 92누5485)

2) 개별요인 비교

- ① 보상액은 당해 토지의 위치·형상·환경·이용상황 등을 고려하여 평가한 적정가격으로 정하여야 한다.
- ② 대법원은 보상액을 평가하면서 어떤 개별요인을 어떻게 품등비교하였는지에 대하여 실시하지 아니한 적용은 위법하다고 한다.(대판 1996. 5. 28. 95누13173)

3) 감정평가서 기재정도

- ① 보상평가에서는 관련 법령에서 들고 있는 모든 가격산정요인들을 구체적·종합적으로 참작하여 그 각 요인들이 빠짐없이 반영된 적정가격을 산출하여야 한다.
- ② 따라서 감정평가서에는 모든 가격산정요인의 세세한 부분까지 일일이 실시하거나 그 요소가 감정평가에 미치는 영향을 수치로 표현할 필요는 없다고 하더라도, 적어도 그 가격산정요인들을 특정·명시하고 그 요인들이 어떻게 참작되었는지를 알아볼 수 있는 정도로 지역요인 및 개별요인의 비교내용을 기술한다(대판 2000. 7. 28. 98두 6081).
- ③ 개별요인 비교에 관하여 구체적으로 어떤 요인들을 어떻게 품등비교하였는지에 관하여 아무런 이유 설시를 하지 않은 감정평가는 위법하다.(대판 1996. 5. 28. 95누13173)
- ④ 수용대상 토지 자체가 표준지인 경우 지역요인·개별요인 비교는 있을 수 없다.(대판 1995. 5. 12. 95누2678)
- ⑤ 개별요인 비교시 용도지역의 차이점을 보정하지 않은 것은 위법하다.(대판 1993. 10. 12. 93누197)

05 그 밖의 요인 보정(후술)

06 보상액의 결정

- ① 보상액의 산정은 각 감정평가법인등이 평가한 평가액의 산술평균치를 기준으로 한다(칙 제16조 제6항).
- ② 재평가 규정에 의하여 평가를 행한 경우 보상액의 산정은 각 감정평가법인등이 다시 평가한 평가액의 산술평균치를 기준으로 한다(칙 제17조 제4항).

07 공시지가 기준보상과 정당보상

CASE

공익사업을 위한 토지등의 취득 및 보상에 관한 법률상 공시지가를 기초로 한 보상액 산정에 있어서 개발이익 배제 및 포함을 논하시오. [17회 문3번]

1) 문제점

공시지가를 기준으로 한 보상이 정당보상의 원칙에 합치하는지에 관하여 논의가 있다.

2) 학설

(1) 위헌설

공시지가기준보상은 보상액 산정방법을 제한하고, 공시지가는 시가에 미달하므로 정당보상이라 할 수 없다는 견해이다.

(2) 합헌설

공시지가기준보상은 개발이익을 배제하기 위한 방법으로서 보상액 산정방법의 제한이 아니라고 하여 정당보상에 합치한다고 보는 견해가 있다.

3) 판례

- ① 대법원은 공시지가를 기준으로 보상액을 산정하는 것은 개발이익을 배제하기 위한 것으로 보상액 산정방법의 제한이 아니라고 하고, 공시지가는 인근 토지의 거래가격 등 제 요소를 종합적으로 고려하여 산정되므로 정당보상에 해당한다고 판시하였다.
- ② 헌법재판소는 공시지가가 적정가격을 반영하지 못하고 있다면 이는 제도운영상 문제로서 정하여진 절차에 의해 시정할 수 있으므로 공시지가 기준보상이 정당보상과 괴리되는 것은 아니라고 하였다.

4) 검토

공시지가기준보상은 **개발이익배제**라는 입법취지가 인정되고, 공시지가가 시가에 미달한다고 하여도 인근 토지의 거래가격 등 제 요소를 모두 고려하여 보상액이 산정되므로, 공시지가 기준보상은 **정당보상에 합치**한다고 보는 견해가 타당하다.

※ 보충자료 - 관련 대법원 판례 정리

- ① 다른 특별한 사정이 없는 한 용도지역이 같은 토지를 당해 토지에 적용할 표준지로 선정함이 상당하다.
(대판 2004. 5. 14. 2003다38207)
- ② 당해 토지와 같은 용도지역의 표준지가 있으면 다른 특별한 사정이 없는 한 용도지역이 같은 토지를 당해 토지에 적용할 표준지로 선정하면 되고, 표준지와 당해 토지의 이용상황이나 주변 환경 등에 다소 상이한 점이 있더라도 지역요인이나 개별요인의 분석 등 품등비교에서 고려하면 된다.(대판 2009. 3. 26. 2008두22129)
- ③ 표준지가 수용대상토지로부터 상당히 떨어져 있다는 것만으로는 표준지 선정이 위법하다고 할 수 없다.
(대판 1999. 1. 15. 98두8896)
- ④ 공시지가를 기준으로 보상액을 산정한 금액이 개별공시지가보다 낮게 되었다 하더라도 이것만으로 정당보상에 위배되는 것은 아니다.(대판 2001. 3. 27. 99두7968)
- ⑤ 공시지가는 표준지의 공시지가이며, 표준지는 지목, 용도, 주위환경, 위치 등 제반 특성을 고려하여 자연적, 사회적 조건이 수용대상토지와 동일하거나 유사한 토지를 선정하여야 한다.(대판 1996. 5. 14. 95누14350)
- ⑥ 보상액이 낮게 평가된 것은 인근 유사토지에 대한 거래사례 또는 보상사례 등의 정상적인 거래가격 수준을 고려하거나 그 공시지가가 현실적인 가격수준과 어느 정도의 괴리율이 있는지에 대하여 충분한 입증이 있어야 한다.
(대판 1996. 9. 20 96다22594)

01 그 밖의 요인의 의의

그 밖의 요인 보정이란 시점수정, 지역요인 및 개별요인의 비교 외에 대상토지의 가치에 영향을 미치는 요인을 보상액에 반영하는 것을 말한다.

02 인정여부

1) 문제점

토지보상법에서 그 밖의 요인 보정에 대한 명문의 규정을 두지 않아, 그 적용가능성이 문제된다.

2) 견해 대립

(1) 부정설

공시지가 자체가 인근 유사토지의 정상적 거래가격 등 그 밖의 사항을 반영하고 있고, 토지보상법은 개별요인의 비교항목을 열거하고 있으며, 감정평가법인등의 자의성이나 재량을 배제하기 위해서는 법정 고려항목 이외에 어떤 요인도 고려할 수 없다고 한다.

(2) 긍정설

공시지가는 매년 1월 1일을 기준으로 가격시점 현재 적정시가에 미달할 수도 있으므로 정당보상이 되기 위해서는 그 밖의 사항을 고려할 수 있도록 해야 하고, 토지보상법은 개별요인의 비교항목을 예시한 것에 지나지 않으므로 그 밖의 요인 보정이 가능하다고 본다.

3) 판례

(1) 대법원 입장

대법원은 인근유사토지가 거래되거나 보상이 된 사례가 있고, 그 가격이 정상적인 것으로서 적절한 보상액 평가에 영향을 미칠 수 있는 것임이 입증된 경우에는 인근 유사토지의 정상거래가격을 고려할 수 있고, 보상선례가 인근 유사토지에 관한 것으로서 당해 수용대상토지의 적정가격을 평가하는 데 있어 중요한 자료가 되는 경우에는 이를 고려하는 것이 상당하다고 한다.(대판 2007. 7. 12 2006두11507)

(2) 헌법재판소 입장

부동산가격공시법 제9조 제1항 단서 조항의 표준지공시지가를 적용하여 산정된 가격에 대해 가감조정이 '필요하다고 인정하는 때'란 "정당한 보상의 관점에서 보상대상자 사이의 형평, 보상선례 등을 고려하여 토지가격의 조정이 필요하다고 인정하는 경우"로 판단하였고, 이러한 "가감조정을 거쳐 헌법 제23조 제3항의 정당한 보상이 산정된다."라고 결정한 바 있다.(헌재 2009. 11. 26. 2009헌마141)

5) 검토

- ① 생각건대 헌법 제23조 제3항의 정당보상은 재산권의 객관적 가치를 완전하게 보상하는 것이므로, 그 밖의 요인 보정을 통해 정상거래가격, 보상선례 등을 고려하여 정당한 보상금을 산출할 필요성이 있다.
- ② 다만, 입법적으로는 그 밖의 요인 보정에 관한 명확한 근거 규정을 마련하는 것이 필요하다고 생각된다.

CASE

甲 소유의 토지를 포함하는 일단의 토지가 공공토지의 비축에 관한 법률에 따라 X읍-Y읍간 도로사업용지 비축사업 지역으로 지정되었고, 한국토지주택공사를 사업시행자로 하여 2014. 3. 31. 이 사건 비축사업에 대하여 「공익사업을 위한 토지등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 따른 사업인정 고시가 있었다. 한편, 관할 도지사는 X읍-Y읍간 도로확포장공사와 관련하여 2016. 5. 1. 도로구역결정·고시하였는데, 甲의 토지는 도로확포장공사가 시행되는 도로구역 인근에 위치하고 있다. 이후 이 사건 비축사업을 위하여 甲 소유의 토지에 대해 2016. 7. 5. 관할 토지수용위원회의 수용재결이 있었는 바, 위 도로확포장공사로 인하여 상승된 토지가격이 반영되지 않는 감정평가가격으로 보상금이 결정되었다.

이에 甲은 도로확포장공사로 인한 개발이익이 배제된 보상금 결정은 위법하다고 주장하는 바, 甲의 주장이 타당한지에 관하여 설명하시오. [28회 문4]

01 개설

- ① 공익사업의 경우에는 사업의 시행계획이 공표되면, 통상의 경우 그 대상토지의 이용가치가 장차 증가될 것을 기대하여 지가는 그 기대치만큼 미리 상승하게 된다.
- ② 그런데 이러한 개발이익도 당해 토지의 객관적 가치의 일부로서 보상액 산정시 당연히 시가에 포함되어야 하는지 여부가 문제된다.

02 개발이익의 의미

개발이익이라 함은 공익사업의 계획 또는 시행이 공고 또는 고시되거나 공익사업의 시행, 그 밖에 공익사업의 시행에 따른 절차로서 행하여진 토지이용계획의 설정·변경·해제 등으로 인하여 토지소유자가 **자기의 노력에 관계없이** 지가가 상승되어 현저하게 받은 이익으로서 **정상지가 상승분을 초과하여 증가된 부분**을 말한다.(표준지 조사 평가기준 제2조 제2호)

03 개발이익 배제의 취지 및 필요성

- ① 공익사업의 개발이익은 기업자의 투자에 의하여 발생하는 것으로서 피수용자인 토지소유자의 노력이나 자본에 의하여 발생한 것이 아니다.
- ② 따라서 이러한 개발이익은 <형평의 관념>에 비추어 볼 때, 토지소유자에게 당연히 귀속되어야 할 객관적 가치는 아니고, 오히려 투자자인 기업자 또는 궁극적으로 국민 모두에게 귀속되어야 함에 취지가 인정된다.
- ③ 또한, 공익사업이 시행되기도 전에 미리 그 시행으로 기대되는 이용가치의 상승을 감안한 지가의 상승분을 보상액에 포함시킨다는 것은 피수용토지의 사업시행 당시의 객관적 가치를 초과하여 보상액을 산정하는 셈이 된다.
- ④ 따라서, 개발이익을 배제함이 정당보상의 원칙에 부합될 뿐 아니라, 평등의 원칙에도 부합된다고 할 수 있다.

04 개발이익의 범위와 한계

대법원은 당해 사업과 관계없는 다른 사업의 시행으로 인한 개발이익은 이를 배제하지 않는 가격으로 평가해야 한다고 판시하고 있다.

대법원 1999. 1. 15. 선고 98두8896

토지수용으로 인한 손실보상액을 산정함에 있어서 당해 공공사업의 시행을 직접 목적으로 하는 계획의 승인·고시로 인한 가격변동은 이를 고려함이 없이 수용재결 당시의 가격을 기준으로 하여 적정가격을 정하여야 하나, 당해 공공사업과는 관계없는 다른 사업의 시행으로 인한 개발이익은 이를 배제하지 아니한 가격으로 평가하여야 한다.

05 개발이익 배제의 내용

1) 적용공시지가의 적용 (사업인정고시일 전 공시지가 기준)

토지보상법이 사업인정고시일 전의 공시지를 기준으로 보상액을 결정하는 것으로 하고 있는 것은 손실보상에서 공익사업으로 인한 개발이익을 배제하기 위한 것이다.

2) 해당 공익사업으로 인한 가격변동 배제

- ① 보상액을 산정할 경우에 해당 공익사업으로 인하여 토지 등의 가격이 변동되었을 때에는 이를 고려하지 아니한다.
(토지보상법 제67조 제2항)
- ② 보상액을 산정함에 있어서 당해 공익사업으로 인한 지가의 영향을 받지 않는 지역의 지가변동률을 참작하여야 한다.(동법 제70조 제1항)

대법원 2014. 2. 27. 선고 2013두21182

공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 제67조 제2항은 '보상액을 산정할 경우에 해당 공익사업으로 인하여 토지 등의 가격이 변동되었을 때에는 이를 고려하지 아니한다'라고 규정하고 있는바, 수용 대상 토지의 보상액을 산정함에 있어 해당 공익사업의 시행을 직접 목적으로 하는 계획의 승인, 고시로 인한 가격변동은 이를 고려함이 없이 재결 당시의 가격을 기준으로 하여 적정가격을 정하여야 하나, 해당 공익사업과는 관계없는 다른 사업의 시행으로 인한 개발이익은 이를 포함한 가격으로 평가하여야 하고, 개발이익이 해당 공익사업의 사업인정고시일 후에 발생한 경우에도 마찬가지이다.

3) 변경되기 전의 용도지역을 기준

공법상 제한을 받는 토지에 대하여는 제한받는 상태로 평가하되, 그 공법상 제한이 당해 공익사업의 시행을 직접 목적으로 하여 가하여진 경우에는 제한이 없는 상태를 기준으로 평가하여 개발이익을 배제한다.(시행규칙 제23조 제1항)

06 개발이익의 배제의 정당보상 합치여부

1) 문제점

- ① 개발이익이 당해 토지의 객관적 가치의 일부로서 보상액 산정에 포함되어야 하는지 견해가 대립한다.
- ② 이는 토지보상법상 개발이익 배제제도가 헌법상 정당보상원칙에 위반되는지의 논의이다.

2) 학설

(1) 위헌설

주변토지소유자와 피수용자 사이의 **형평성이 심히 침해되고**, 개발이익이 배제된 보상금으로는 도저히 **종전과 같은 생활을 유지할 수 없는 경우** 등에는 개발이익을 일체 보상하지 않는 것이 헌법상의 재산권보장 및 평등원칙에 위배된다고 본다.

(2) 합헌설

개발이익은 국가 등의 공공투자 또는 사업시행자의 투자에 의해 발생하는 것으로서 피수용자의 노력이나 자본에 의해 발생하는 것이 아닌 **〈불로소득〉**이므로, 그러한 개발이익은 형평의 관념에 비추어 볼 때, 토지소유자에게 귀속시키는 것은 타당하지 않다고 보는 견해이다.

3) 판례

(1) 대법원

대법원은 개발이익을 배제한 보상액 산정이 타당하다는 입장을 유지해 오고 있다. 개발이익을 배제하고 손실보상액을 평가하는 것이 정당보상의 원리에 합당하다거나(대판 1993. 7. 13. 93누227), 당해 공익사업의 시행을 직접 목적으로 하는 계획의 승인·고시로 인한 가격변동은 고려하지 아니하여야 한다고 한다. (대판 1999. 10. 22 98두7770)

(2) 헌법재판소

공익사업의 시행으로 지가가 상승하여 발생하는 개발이익은 기업자의 투자에 의하여 발생하는 것으로서 피수용자인 토지소유자의 노력이나 자본에 의하여 발생한 것이 아니므로, 오히려 투자자인 기업자 또는 궁극적으로는 국민 모두에게 귀속되어야 할 성질의 것이라고 판시한 바 있다.(2009.9.24. 2008헌바112)

4) 검토

- ① 생각건대, 개발이익은 공익사업의 진행으로 인해 발생하는 것이고 피수용자의 노력이나 자본의 투자에 의해 발생하는 것이 아니므로 토지소유자에게 귀속시키는 것은 타당하지 않으며 사회로 환원시켜야 한다.
- ② 다만, 공익사업시행지 주변 토지의 **개발이익을 환수하는 법제도를 정비하여야 할 필요성**이 있다.

07 평등원칙 위반 여부

1) 문제점

피수용자에 대한 보상금에서는 개발이익을 배제하나 사업시행지역 밖의 토지소유자는 개발이익을 향유한다면 헌법 제11조의 평등원칙에 위반되지 않는지가 문제된다.

2) 평등의 원칙의 의미

헌법 제11조 제1항이 규정하는 평등의 원칙은 결코 일체의 차별적 대우를 부정하는 절대적 평등을 의미하는 것이 아니라, 법의 적용이나 입법에 있어서 불합리한 조건에 의한 차별을 하여서는 안 된다는 것을 뜻한다.

3) 헌법재판소의 태도

이에 관하여 헌법재판소는 개발이익을 환수할 수 있는 제도적 장치가 마련되지 아니한 제도적 상황에서 보상액 산정에 있어서 개발이익을 배제한다고 하여, 토지소유자와 인근 토지소유자를 차별하는 것이라고 할 수는 없는 것이므로 평등원칙에 위반되는 것은 아니라고 보고 있다.

제1절 재산권 보상

01 개요

재산권 보상이란 피침해재산의 손실에 대한 객관적인 가치의 보상과 공용침해로 필연적으로 발생된 부대적 손실에 대한 보상을 의미한다.

02 객관적 가치보상

1) 의의

수용목적물의 객관적 가치를 보상하는 것을 말한다.

2) 토지

토지의 취득 또는 사용으로 인한 토지의 재산권적 가치에 대한 보상을 말한다. 토지보상법 제70조, 제71조에서 구체적 보상액 산정기준을 마련하고 있다.

3) 토지이외의 재산권 보상

토지상의 건물, 공작물, 입목, 농작물에 대한 보상, 권리, 잔여지 가치하락보상, 잔여건축물 가치하락보상 등이 있다.

03 부대적 손실보상

1) 의의

수용목적물의 취득이 원인이 되어 부수적으로 발생한 손실을 보상하는 것을 말한다.

2) 실비변상적 보상

재산권의 상실·이전 등에 따라 비용의 지출을 요하는 경우에 그 비용을 보상하는 것을 말한다. 토지보상법상의 건축물 등의 이전비 보상(제75조 제1항), 분묘의 이장비 보상(제75조 제4항), 잔여지 공사비 보상(제73조) 등은 그 예이다.

3) 일실손실 보상

재산권에 대한 수용에 부수하여 또는 독립적으로 사업을 폐지하거나 휴업하게 되는 경우에 있어 전업기간 또는 휴업기간 중에 사업경영으로 얻을 수 있는 **기대이익의 일실에 대한 보상**을 말한다. 토지보상법상 영업의 폐지·휴업에 따르는 보상(제77조 제1항), 농업손실보상(제77조 제2항), 휴직 또는 실직보상(제77조 제3항) 등은 그 예이다.

CASE

2. 생활보상에 관하여 약술하시오.(20점) [15회, 문3]

01 생활보상의 의미

피수용자가 종전과 같은 생활을 유지할 수 있도록 보상하는 것으로 재산권보상으로 채워지지 아니하는 손실에 대한 보상을 말한다.

02 근거

1) 헌법적 근거

(1) 학설

① 정당보상설 (헌법 제23조설)

헌법 제23조 제3항의 정당보상에 피수용자가 종전과 같은 생활을 유지하도록 하는 보상이 포함된다고 보는 견해이다.

② 생존권설 (헌법 제34조설)

생활보상의 헌법적 근거를 “모든 국민은 인간다운 생활을 할 권리를 가진다.”고 규정한 헌법 제34조 제1항의 사회권적 기본권조항에서 찾는 견해이다. 이 견해에 따르면 생활보상은 헌법 제23조의 정당보상에 포함되지 않는 것으로 본다.

③ 통일설

생활보상을 정당보상에 포함되는 것으로 보면서도 생활보상이 경제적 약자에 대한 생존배려의 관점에서 행해지는 것이므로 생활보상은 헌법 제23조 제3항과 제34조 제1항에 동시에 근거하는 것으로 보는 견해이다.

(2) 판례

① 헌법재판소는 이주대책은 공익사업의 시행으로 생활근거를 잃게 된 사람들에게 생활보호 차원에서 실시하는 시혜적인 조치에 불과하므로 헌법 제23조 제3항에서 말하는 정당보상에 해당하지 아니한다고 한다(헌재 1993. 7. 29. 92헌마30).

② 대법원은 이주대책의 본래 취지는 이주자들에 대하여 종전의 생활 상태를 원상으로 회복시키면서 동시에 인간다운 생활을 보장해 주기 위한 이른바 생활보상의 일환으로 국가의 적극적이고 정책적인 배려에 의하여 마련된 제도라 하여(대판 1994. 5. 24 92다35783) 제34조설을 취하고 있다. 다만 최근에는 생활대책이 헌법 제23조 제3항에 따른 정당한 보상에 포함되는 것으로 본 판례가 있다.

(3) 검토

북리국가주의 이념의 등장과 함께 정당보상이 대물보상 뿐만 아니라 생활보상까지 포함하는 것으로 확대되고 있고, 생활보상의 내용에 경제적 약자에 대한 생존배려형 보상이 포함되어 있다는 점을 고려할 때, 통일설이 타당하다.

2) 토지보상법상 근거

토지보상법 제78조의 주거용 건축물에 대한 이주대책을 생활보상으로 볼 수 있고 동법 제78조의 2에서 공장부지 제공자에 대한 이주대책과 동법 시행규칙 제54조의 주거이전비 보상 또한 인간다운 생활을 보장하는 생활보상으로 해당된다.

03 생활보상의 범위

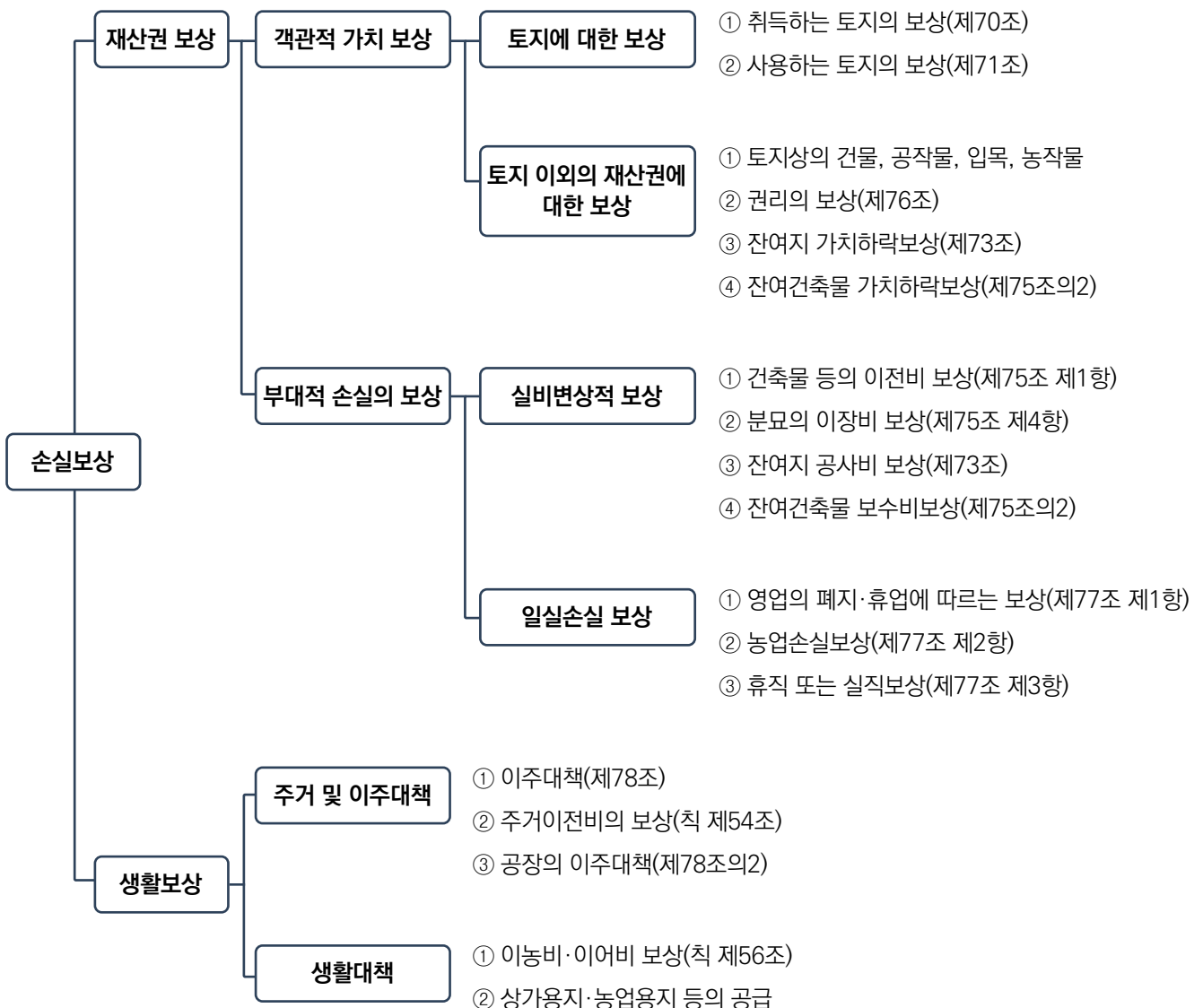
1) 주거 및 이주대책

- ① 주거대책은 피수용자가 종전과 같은 주거를 획득하는 것을 보장하는 보상을 말한다.
- ② 주거대책으로는 이주대책(이주정착지의 조성과 분양, 이주정착금의 지급)(제78조), 주거이전비의 보상(칙 제54조), 공장의 이주대책(제78조의2) 등이 있다.

2) 생계대책

- ① 생활대책은 종전과 같은 경제수준을 유지할 수 있도록 하는 조치를 말한다.
- ② 생계대책으로는 이농비·이어비 보상(칙 제56조), 상가용지·농업용지 등의 공급 등이 있다.

[손실보상의 구분]



제1절 공법상 제한받는 토지 평가

CASE

중앙토지수용위원회는 보상금을 산정하면서, X토지는 그 용도지역이 제1종 일반주거지역이기는 하지만 기업도시 개발사업의 시행을 위해서 제3종 일반주거지역으로 변경되지 않은 사정이 인정되므로 제3종 일반주거지역으로 변경이 이루어진 상태를 상정하여 토지가격을 평가한다고 실시하였다. 이에 대해 사업시행자인 乙은 X토지를 제1종 일반주거지역이 아닌 제3종 일반주거지역으로 평가한 것은 공법상 제한을 받는 토지에 대한 보상금 산정에 위법이 있다고 주장하면서 보상금감액청구소송을 제기하고자 한다. 乙의 소송상 청구가 인용될 수 있는 가능성에 관하여 설명하시오. (단, 소송요건은 충족된 것으로 본다.) [28회, 문1번]

01 의미

- ① 공법상 제한을 받는 토지란 관계 법령에 의해 가해지는 토지 이용규제나 제한을 받는 토지를 말한다.
- ② 공법상 제한에는 일반적 계획제한과 개별적 계획제한이 있다.

02 종류

1) 일반적 계획제한

- ① 일반적 계획제한은 제한 그 자체로 목적이 완성되고 구체적 사업시행이 필요하지 않은 제한을 말한다.
- ② 국토계획법에 따른 용도지역 등 지정 및 변경, 「군사기지 및 군사시설보호법」에 따른 군사시설보호구역의 지정 및 변경, 「수도법」에 따른 상수원보호구역의 지정 및 변경, 「자연공원법」에 따른 자연공원 및 공원보호구역의 지정 및 변경 등이 있고, 그 밖에 이와 유사한 토지이용계획제한 등이 있다.

2) 개별적 계획제한

- ① 개별적 계획제한이란 그 제한이 구체적 사업시행을 필요로 하는 제한이다.
- ② 국토계획법에 따른 도시·군계획시설 및 도시·군관리계획의 결정고시, 토지보상법상 사업인정고시, 그 밖에 관련 법령에 따른 공익사업 계획 또는 시행의 공고 또는 고시 등이 있다.

03 보상평가기준

1) 원칙

공법상 제한받는 토지는 **제한받는 상태대로** 평가한다(칙 제23조 제1항 본문).

2) 예외

(1) 해당 공익사업시행을 직접 목적으로 하여 가하여진 경우

공법상 제한이 당해 공익사업의 시행을 직접 목적으로 하여 가하여진 경우에는 **제한이 없는 상태를 상정하여** 평가한다(칙 제23조 제1항 단서).

(2) 해당 공익사업 시행을 직접 목적으로 하여 용도지역 등이 변경된 경우

해당 공익사업의 시행을 직접 목적으로 하여 용도지역 또는 용도지구 등이 변경된 토지에 대하여는 **변경되기 전의** 용도지역 또는 용도지구 등을 기준으로 평가한다(칙 제23조 제2항).

관련 판례

토지수용 보상액을 산정함에 있어서는 토지수용법 제46조 제1항에 따라 당해 공공사업의 시행을 직접 목적으로 하는 계획의 승인·고시로 인한 가격변동은 이를 고려함이 없이 수용재결 당시의 가격을 기준으로 하여 정하여야 할 것이므로, 당해 사업인 택지개발사업에 대한 실시계획의 승인과 더불어 그 용도지역이 주거지역으로 변경된 토지를 그 사업의 시행을 위하여 후에 수용하였다면 그 재결을 위한 평가를 함에 있어서는 그 용도지역의 변경을 고려함이 없이 평가하여야 할 것이다.

04 일반적 계획제한과 개별적 계획제한

1) 일반적 계획제한

- ① 일반적 계획제한은 **제한받는 상태**를 기준으로 감정평가한다.
- ② 다만, 그 공법상 제한이 해당 공익사업 시행을 직접 목적으로 하여 가하여진 경우는 제한이 없는 상태를 상정하여 감정평가한다.

2) 개별적 계획제한

- ① 개별적 계획제한은 **제한을 받지 않는 상태**를 기준으로 하여 감정평가한다.
- ② 판례는 당초 목적사업은 물론 **다른** 목적의 공익사업에 수용되는 경우에도 그 제한을 받지 않는 상태대로 평가하여야 한다고 본다.(대판 1989. 7. 11. 88누11797).
- ③ 이와 같이 확장해석하는 것은 사업변경 내지 고의적 사전제한 등으로 인한 토지소유자의 불이익을 방지하기 위한 것으로 보고 있다.

05 관련 판례 (공익사업의 시행을 위하여 용도지역 등의 변경이 이루어지지 않은 경우)

어느 수용대상 토지에 관하여 특정 시점에서 용도지역 등의 지정 또는 변경을 하지 않은 것이 특정 공익사업의 시행을 위한 것일 경우 이는 **당해 공익사업의 시행을 직접 목적으로 하는 제한이라고 보아** 용도지역 등의 지정 또는 변경이 이루어진 상태를 상정하여 토지가격을 평가하여야 한다. 여기에서 특정 공익사업의 시행을 위하여 용도지역 등의 지정 또는 변경을 하지 않았다고 볼 수 있으려면, 토지가 특정 공익사업에 제공된다는 사정을 배제할 경우 **용도지역 등의 지정 또는 변경을 하지 않은 행위가 계획재량권의 일탈남용에 해당함이 객관적으로 명백하여야만** 한다(대판 2015. 8. 27. 2012두7950).

CASE

공부상 지목이 과수원(果)으로 되어 있는 토지의 소유자 甲은 이 토지의 일부에 토지의 형질변경허가 및 건축허가를 받지 않고 2005년 8월 26일 임의로 지상 3층 건물을 건축하였다. 위 토지에 대한 보상평가기준에 대해 설명하시오. [18회, 문3번]

01 무허가건물 등의 부지

1) 의의

무허가건물 등의 부지라 함은 관계법령에 의해 허가를 받거나 신고를 하고 건축 또는 용도변경을 하여야 하는 건물을 허가를 받지 아니하거나 신고를 하지 아니하고 건축 또는 용도변경한 건물의 부지를 말한다.

2) 보상평가기준

(1) 건축당시 이용상황 상정 평가원칙

- ① 무허가건축물 등의 부지에 대하여는, 무허가건축물 등이 건축 또는 용도변경 될 당시의 이용상황을 상정하여 평가한다(칙 제24조).
- ② 이는 무허가건축물 등의 부지를 현실 이용상황에 따라 평가하게 되면 불법이 적법으로 전환되어 공정하지 못한 보상이 행해질 수 있기 때문에 현황평가의 예외로서 인정된다.

(2) 예외

1989년 1월 24일 당시의 무허가건축물등에 대하여는 이 규칙에서 정한 보상을 함에 있어 이를 적법한 건축물로 본다(2002.12.31 규칙개정 부칙 제5조).

(3) 부지의 범위

대법원은 ‘무허가건물 등의 부지’란 당해 무허가건물 등의 용도·규모 등 제반 여건과 현실적인 이용상황을 감안하여 무허가 건물 등의 사용·수익에 필요한 범위 내의 토지와 무허가건물 등의 용도에 따라 불가분적으로 사용되는 범위의 토지를 의미하는 것이라고 해석하고 있다(대법원 2002.9.4 선고 2000두8325 판결).

3) 입증책임의 문제

- ① 기준시점(1989년 1월 24일) 이전에 건축된 사실을 누가 주장하고 입증해야 하는지 문제된다.
- ② <토지소유자에게 있다는 입장>은 사업시행자가 작성한 조서의 이용상황에 대하여 다른 의견이나 사실이 있는 경우 그것을 주장하는 사람이 입증하여야 할 책임이 있다고 보며,
- ③ <사업시행자에게 있다는 입장>은 취득할 토지에 대한 평가는 현실적인 이용상황에 따라 평가하여야 하는 것이기 때문에 그와 같이 토지평가의 대원칙에 대한 예외로서 건축할 당시의 이용상황을 상정하여 평가하기 위해서는 그것을 주장하는 사업시행자가 입증하여야 한다고 한다.
- ④ 생각건대, 토지평가의 대원칙인 현황평가주의의 예외를 인정하려면 그것을 주장하는 자인 <사업시행자가 입증>하여야 할 것이다.

02 불법형질변경토지

1) 의의

불법형질변경토지라 함은 개발행위 허가를 받지 않고 토지형질을 변경하거나 농지 또는 산지를 전용허가를 받지 않거나 신고하지 않고 형질변경된 토지를 말한다.

2) 보상평가기준

(1) 형질변경당시 이용상황 상정 평가원칙

- ① 관계 법령에 의하여 허가를 받거나 신고를 하고 형질변경을 해야 하는 토지를 허가받지 아니하거나 신고를 하지 아니하고 형질변경한 토지에 대하여는 토지가 **형질변경될 당시의 이용상황을 상정**하여 평가한다(칙 제24조).
- ② 이는 조성된 가치는 물론 조성비도 인정하지 않도록 하는 것이다. 이것은 위법행위가 합리화되어 공정성을 상실하여 불합리한 보상이 될 우려가 있기 때문이다.

(2) 예외

1995년 1월 7일 당시 공익사업시행지구내 편입된 불법형질변경토지 또는 무허가개간토지(관계 법령에 의하여 허가·인가 등을 받고 개간을 하여야 하는 토지를 허가·인가 등을 받지 아니하고 개간한 토지를 말함)에 대하여는 현실적인 이용상황에 따라 보상하거나 개간비를 보상하여야 한다(2002.12.31 규칙개정 부칙 제6조).

3) 관련문제

(1) 현황평가 예외가 정당보상원칙 위반인지

- ① 불법형질변경토지는 위법하게 토지가치를 상승시켜 놓은 상태이므로, 현황을 기준으로 보상액을 산정하면 위법성을 인정하게 된다.
- ② 따라서 현황평가의 예외로서 보상하는 것이 정당보상에 위반된다고 볼 수 없다.

(2) 소급입법에 의한 재산권박탈금지 원칙에 위배되는지

- ① 헌법 제13조 제2항은 모든 국민은 소급입법에 의하여 재산권을 박탈당하지 아니한다고 한다고 규정한다.
- ② 동조에서 금지되는 것은 진정소급효입법이고, 부진정소급효입법의 경우에는 원칙적으로 허용된다고 본다.
- ③ 불법형질변경 토지의 평가방법이 진정소급효로서 소급입법에 의한 재산권 박탈금지 원칙 위반이 아닌가 문제된다. 불법형질변경토지는 일반적으로 국민이 소급입법을 예상할 수 있어서 보호할 신뢰이익이 작고, 신뢰보호요청에 우선하는 심히 중대한 공익성의 사유로 보아 소급입법이 **예외적으로 허용**되는 경우라 할 수 있다.

(3) 입증책임의 문제

- ① 불법으로 형질변경되었는지 여부를 사업시행자와 토지소유자 중 누가 입증해야 하는지 문제된다.
- ② 사업시행자의 토지조서작성권은 반증 없이는 현황평가주의를 따라야 하므로 원칙적으로 **사업시행자**가 불법으로 형질변경되었다는 것을 입증하여야 한다고 할 것이다(판례 동지).

01 의미

- ① 미지급용지란 종전에 시행된 공익사업의 부지로서 **보상금이 지급되지 아니한 토지**를 말한다(칙 제25조).
- ② 미지급용지는 같은 토지에 대하여 둘 이상의 공익사업이 시행되고, 새로운 공익사업이 시행되기까지 종전 시행된 공익사업에 의하여 보상금이 지급되지 아니한 토지를 말한다(대판 2009. 3. 26. 2008두22129).

02 보상평가기준

- ① 종전에 시행된 공익사업의 부지로서 보상금이 지급되지 아니한 토지(이하 이 조에서 “미지급용지”라 한다)에 대하여는 **종전의 공익사업에 편입될 당시의 이용상황을 상정하여 평가한다**(칙 제25조 제1항).
- ② 다만, 종전의 공익사업에 편입될 당시의 이용상황을 알 수 없는 경우에는 편입될 당시의 지목과 인근토지의 이용상황 등을 참작하여 평가한다(칙 제25조 제1항).

03 평가규정의 취지

- ① 미지급용지는 용도가 공익사업 부지로 제한되고 있어 거래도 불가능할 뿐만 아니라 가격시점의 이용상황에 따라 공익사업의 부지로 평가하게 되면 적정가격으로 보상액을 산정할 수 없게 되어 피보상자에게 지나친 희생을 강요하게 되는 결과가 된다(대판 1992. 11. 10. 92누4833).
- ② 이와 같은 경우 피보상자를 구제하기 위해 특별히 종전의 공익사업에 편입될 당시의 이용상황을 상정하여 평가하도록 하고 있다.

04 미지급용지의 판단기준

미지급용지에 대한 판단은 사업시행자가 사실관계를 조사하여 판단·결정할 사항이다. 예를 들어 도로부지의 경우 사업시행자가 도로의 개설 경위, 이용상황 등을 종합적으로 검토하여 판단해야 한다.

05 미지급용지 적용 범위에 대한 논의

1) 문제점

종전의 공익사업으로 인해 **지가가 상승하였을 때에도** 미지급용지로 보아 평가해야 하는지 적용범위에 논란이 있다.

2) 학설

- ① 무제한적으로 적용되어야 한다는 견해는 미지급용지에 대한 적용을 토지소유자의 이익 여부와는 관계없이 모두 적용되어야 한다고 보는 반면,
- ② 제한적으로 적용되어야 한다는 견해는 **토지소유자에게 불리한 경우에는 적용이 제한된다고** 보며 이 견해가 **다수설**이다.

3) 판례

대법원은 종전의 공익사업의 시행으로 인하여 토지의 현실적인 이용상황을 변경시킴으로써 가격이 상승하였다면 **미지급용지에 포함되지 않는 것으로 보고 있다**(대판 1992. 11. 10. 92누4833).

06 관련 법적 문제

1) 보상의무자

- ① 미지급용지는 종전에 시행된 공익사업에서 보상되지 않은 토지이기 때문에 마땅히 당시의 사업시행자가 보상하여야 한다. 그렇지만 현실적으로 볼 때 이미 당해 공익사업은 완료된 상태이고, 그 공익사업이 실제로 존재하지 않기 때문에 당시의 사업시행자는 보상할 수 없는 불능 상태에 있다고 볼 수 있다.
- ② 따라서 원칙적으로는 종전 공익사업시행자가 보상의무자이나, 미지급용지 보상이 새로운 공익사업이 시행됨에 따라 종전에 보상받지 못한 토지소유자 등의 권리구제를 위한 제도 취지를 고려하여 종전 사업시행자의 보상의무가 **〈새로운 공익사업의 시행자에게 전가〉**된 것으로 볼 수 있다.

2) 보상대상자

- ① 종전 공익사업 시행시점과 새로운 공익사업의 가격시점 사이에 미지급용지의 소유자가 변경되었을 경우, **새로운 소유자에게도** 미지급용지의 평가규정을 **적용**하여 산정한 보상금을 지급하는 것이 **타당**한지 논란이 있다.
- ② 미지급용지의 소유자는 새로운 공익사업에 편입되지 않는 한 보상청구를 할 수 없게 되므로, 새로운 소유자에게 적용을 부정하게 되면, 미지급용지의 거래를 더욱 어렵게 하여 원소유자에게 더 큰 피해를 줄 수 있으므로 적용함이 바람직하다.

3) 미지급용지에 대한 부당이득반환청구권 행사

(1) 행사여부

미지급용지 중 부당이득과 관련하여 주로 문제가 생기는 부분은 미지급된 도로부지이다. 도로를 구성하는 부지는 그 사용·수익을 침해당함으로써 입은 손해에 상당한 금액을 **부당이득으로 반환**청구할 수 있다.

(2) 관련 판례

대법원은 어느 사유지를 국가 또는 지방자치단체가 점유하여 사실상의 도로로서 일반 공중의 교통에 제공함으로써 그 토지소유자의 독점적·배타적인 사용·수익이 제한되고 있는 경우에는 그 소유자가 그 토지에 대한 독점적·배타적인 사용수익권을 포기하였다는 등의 특별한 사정이 없는 한, 국가 또는 지방자치단체는 그 토지를 점유하여 사용·수익하는 이득을 얻고 토지소유자는 그만큼의 손해를 입고 있는 것으로 보아야 한다고 한다(대판 2008. 2. 1. 2007다8914).

(3) 부당이득 평가

공공이 사인의 토지를 토지소유자의 점유·관리를 배제한 채 일반 공중의 통행로로 제공한 경우에는 **임료(차임)** 상당의 이익을 법률상 원인 없이 이득을 보고 있는 것이므로 부당이득금 반환의무가 있는 것이다.(판례)

CASE

공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 시행규칙 (이하 '토지보상법 시행규칙'이라 함) 제26조 제1항에 따른 '사실상의 사도'의 요건을 설명하고, 이에 따라 A토지가 사실상의 사도로 인정되는 경우와 그렇지 않은 경우에 보상기준이 어떻게 달라지는지 설명하시오.(10점) [33회, 문1]

01 토지보상법상 도로의 분류

토지보상법은 ① 사도법상의 사도, ② 사실상의 사도, ③ 그 외의 도로부지로 분류하여 그 평가기준을 달리 정하고 있다(시행규칙 제26조).

02 평가기준

1) 사도법상 사도의 평가

(1) 의의

- ① 사도법상 사도란 사도법에 따라 개설허가권자의 **개설허가**를 받은 도로를 말한다.
- ② 사도법상 사도는 비록 토지대장상 지목이 도로라고 하더라도 사도개설 허가를 얻지 않은 것은 사도로 볼 수 없다고 할 것이다.

(2) 평가방법

- ① 인근토지에 대한 평가액의 **5분의 1 이내**로 평가한다(칙 제26조 제1항).
- ② <인근토지>라 함은 당해 도로부지 또는 구거부지가 도로 또는 구거로 이용되지 아니하였을 경우에 예상되는 **표준적인 이용상황과 유사한 토지**로서 당해 토지와 위치상 가까운 토지를 말한다(칙 제26조 제4항).

2) 사실상 사도의 평가

(1) 의의 (칙 제26조 제2항)

사실상의 사도란 [사도법]에 의한 사도 외의 도로로서

- ① 도로개설당시의 토지소유자가 자기 토지의 편익을 위하여 스스로 설치한 도로,
- ② 토지소유자가 그 의사에 의하여 타인의 통행을 제한할 수 없는 도로,
- ③ [건축법] 제45조에 따라 건축허가권자가 그 위치를 지정·공고한 도로,
- ④ 도로개설당시의 토지소유자가 대지 또는 공장용지 등을 조성하기 위하여 설치한 도로의 어느 하나에 해당하는 도로를 말한다.

(2) 사실상 사도의 개념과 관련된 판례

① 자기토지의 편익을 위해 스스로 설치한 도로의 의미 (1호)

토지 소유자가 자기 소유 토지 중 일부에 도로를 설치한 결과 도로 부지로 제공된 부분으로 인하여 나머지 부분 토지의 편익이 증진되는 등으로 그 부분의 가치가 상승됨으로써 도로부지로 제공된 부분의 가치를 낮게 평가하여 보상하더라도 전체적으로 정당보상의 원칙에 어긋나지 않는다고 볼 만한 객관적인 사유가 있다고 인정되어야 하고, 이는 도로개설 경위와 목적, 주위환경, 인접토지의 획지 면적, 소유관계 및 이용상태 등 제반 사정을 종합적으로 고려하여 판단할 것이다(대법원 2011두7007).

② 토지소유자가 그 의사에 의하여 타인의 통행을 제한할 수 없는 도로의 의미 (2호)

법률상 소유권을 행사하여 통행을 제한할 수 없는 경우뿐만 아니라 사실상 통행을 제한하는 것이 곤란하다고 보이는 경우도 해당한다고 할 것이나, 적어도 도로로의 이용상황이 고착화되어 당해 토지의 표준적 이용상황으로 원상회복하는 것이 용이하지 않은 상태에 이르러야 할 것이어서 단순히 당해 토지가 불특정 다수인의 통행에 장기간 제공되어 왔고 이를 소유자가 용인하여 왔다는 사정만으로는 사실상의 도로에 해당한다고 할 수 없다(대법원 2006두18492).

③ 기타

- ㉠ <사실상의 사도>의 부지로 보고 인근토지 평가액의 3분의 1 이내로 보상액을 평가하려면, 도로법에 의한 일반 도로 등에 연결되어 일반의 통행에 제공되는 등으로 **사도법에 의한 사도에 준하는 실질을 갖추고** 있어야 하고, 나아가 위 규칙 제26조 제2항 제1호 내지 제4호 중 어느 하나에 해당하여야 할 것이다 (대법원 2011두7007).
- ㉡ 인근 농민이나 주민들을 포함한 불특정 다수인의 통행에 20년 이상 장기간 제공되어 사실상 도로화 되었고, 소유권을 행사하여 통행을 금지시킬 수 있는 상태에 있다고 보기 어려우므로, 사도법에 의한 사도 이외의 도로부지에 해당하는 것으로 봄이 상당하고, 따라서 인근 토지에 대한 평가금액의 3분의 1로 평가할 수 있다.(대판 1998. 5. 12. 97누13542).

(3) 평가방법

- ① 인근 토지에 대한 평가액의 **3분의 1 이내**로 평가한다(칙 제26조 제1항).
- ② <인근토지>라 함은 당해 도로부지 또는 구거부지가 도로 또는 구거로 이용되지 아니하였을 경우에 예상되는 표준적인 이용상황과 유사한 토지로서 당해 토지와 위치상 가까운 토지를 말한다(칙 제26조 제4항).

3) 그 외의 도로 (제1호 또는 제2호외의 도로의 부지)

(1) 공도의 의의

국가 또는 지방자치단체가 일종의 행정권의 작용으로서 토지를 일반 공중의 통행에 제공한 도로로서, 그 도로를 둘러싼 법률관계가 「도로법」, 「국계법」 기타의 공법에 의하여 규율되는 도로를 말한다.

(2) 평가방법

공도의 부지가 도로로 이용되지 아니하였을 경우에 예상되는 인근지역에 있는 표준적인 이용상황을 기준으로 평가한다(공도부지가 처분의 대상이 되기 위해서는 공용폐지를 전제로 하기 때문).

4) 기타 도로

(1) 새마을 도로

새마을 도로는 인근토지 평가액의 **3분의 1 이내**로 평가한다.

대법원 2006. 5. 12. 선고 2005다31736

새마을 농로 확장공사로 인하여 자신의 소유 토지 중 도로에 편입되는 부분을 도로로 점유함을 허용함에 있어 손실보상금이 지급되지 않았으나 이의를 제기하지 않았고 도로에 편입된 부분을 제외한 나머지 토지만을 처분한 점 등의 제반 사정에 비추어 보면, 토지소유자가 토지 중 도로로 제공한 부분에 대한 독점적이고 배타적인 사용수익권을 포기한 것으로 봄이 상당하다고 한 사례

(2) 예정공도

- ① 예정공도란 [국계법]에 따른 도시·군관리계획에 의하여 도로로 결정된 후부터 도로로 사용되고 있는 도로이다.
- ② 예정공도부지는 **공도부지의 보상평가방법을 준용**한다.
- ③ 공도부지는 도로로 이용되지 아니하였을 경우에 예상되는 인근지역의 표준적인 이용상황을 기준으로 평가한다.
- ④ 그러나 토지소유자가 도시계획도로 입안내용에 따라 스스로 도로로 제공한 토지는 예정공도가 아니라 사실상 사도에 해당한다.

대법원 1997. 8. 29. 선고 96누2569

토지수용으로 인한 손실보상액을 산정함에 있어서는 당해 공공사업의 시행을 직접 목적으로 하는 계획의 승인·고시로 인한 가격변동은 이를 고려함이 없이 수용재결 당시의 가격을 기준으로 하여 적정가격을 산정하여야 하며, 도시계획 결정은 도시계획고시일에 그 효력을 발생하는 것이므로, 당해 토지소유자가 도시계획(도로)입안의 내용에 따라 스스로 토지를 도로로 제공하였고 도시계획(도로) 결정고시는 그 후에 있는 경우, 도시계획입안의 내용은 그 토지 지가 하락의 원인과 관계가 없어서 토지에 대한 손실보상금산정에 참작할 사유가 아니라고 한 사례

03 도로보상기준의 정당보상 여부

1) 문제점

- ① 헌법 제23조 제3항은 정당보상을 지급하도록 규정하고 있고, 이에 토지보상법 시행규칙은 도로평가방법에 대하여 인근토지 평가금액의 일정비율로 평가하도록 규정하고 있다.
- ② 이러한 보상기준이 헌법상 정당보상과 관련하여 문제된다.

2) 도로부지를 감가보상하는 이유

(1) 화체이론설

도로가치의 일부가 **도로에 접한 토지의 가치로 이전**되었기 때문에 도로부분은 그 만큼 가치를 낮게 평가하는 것이 정당하다고 보는 견해이다.

(2) 사용·수익권 제한 가치설

국가 또는 지방자치단체 등의 공공기관이 소유권을 취득하지 못한 타유공물인 사유의 도로는 도로로서의 공적인 목적달성을 위하여 필요한 범위 안에서 그 **사용·수익권을 제한**당하고 있으므로, 이를 반영하여 감가한다는 견해이다.

(3) 판례의 태도

대법원 판례는 도로에 관한 규정의 취지는 사실상 불특정 다수인에게 제공되어 있는 토지이기만 하면 그 모두를 인근 토지의 3분의 1 이내로 평가하여야 하는 것이 아니라, 그 도로의 개설경위, 목적, 주위환경 등의 제반사정에 비추어 당해 토지소유자가 자기 토지의 편익을 위하여 스스로 공중의 통행에 제공하는 등 **인근토지에 비하여 낮은 가격으로 보상하여 주어도 될 만한 객관적 사유가 인정되는 경우에만 인근토지의 3분의 1이내에서 평가**하고, 그러한 사유가 인정되지 아니하는 경우에는 위 규정의 적용에서 제외되어야 한다고 판시하여 종래 공특별상의 규정의 불합리성을 지적하였다.(대판 1997.7.22. 96누13675)

(4) 검토

도로부지를 인근토지에 비하여 감가보상하는 것이 화체이론상 타당시되며, 감가보상을 한다 하더라도 모든 도로에 대하여 감가보상을 하는 것이 아니라, 판례의 태도처럼 인근토지에 비하여 낮게 보상하여도 될 만한 객관적 사유가 있는 경우에만 적용된다는 점에서 정당보상의 원칙에 위배되지 않는다고 본다.

CASE

한국수자원공사는 한국수자원공사법 제9조 및 제10조에 근거하여 수도권 광역상수도 사업 실시계획을 수립하여 국토해양부장관의 승인을 얻은 후, 1필지인 甲의 토지 8,000㎡ 중 6,530㎡를 협의취득하였다. 협의취득 후 甲의 잔여지는 A지역 495㎡, B지역 490㎡, 그리고 C지역 485㎡로 산재하고 있다.

- 1) 甲은 위 잔여지의 토지가격의 감소를 이유로 손실보상을 청구하려고 한다. 이 경우 잔여지의 가격감소에 대한 甲의 권리구제방법을 설명하시오.
- 2) 호텔을 건립하기 위해 부지를 조성하고 있던 甲은 자신의 잔여지를 더 이상 종래의 사용목적대로 사용할 수 없게 되자 사업시행자와 매수에 관한 협의를 하였으나, 협의를 성립되지 아니하였다. 이에 甲은 관할 토지수용위원회에 잔여지의 수용을 청구하였지만, 관할 토지수용위원회는 이를 받아들이지 않았다. 이 경우 잔여지수용청구의 요건과 甲이 제기할 수 있는 행정소송의 형식을 설명하시오. [23회, 문2]

I 잔여지 손실보상

01 의미 및 취지 (토지보상법 제73조)

잔여지 손실보상이란 일정한 요건하에서 잔여지의 가치가 하락하거나, 공사가 필요한 때 그 비용을 보상하는 것을 말하며 정당보상 실현에 취지가 있다.

02 요건

1) 규정 검토

- ① 사업시행자는 동일한 소유자에 속하는 일단의 토지의 일부가 취득되거나 사용됨으로 인하여 잔여지의 가격이 감소하거나 그 밖의 손실이 있을 때 또는 잔여지에 통로·도랑·담장 등 신설 등 그 밖의 공사가 필요할 때에는 국토교통부령이 정하는 바에 따라 그 손실이나 공사의 비용을 보상하여야 한다.
- ② 다만, 잔여지의 가격 감소분과 잔여지에 대한 공사의 비용을 합한 금액이 잔여지의 가격보다 큰 경우에는 사업시행자는 그 잔여지를 매수할 수 있다(제73조 제1항).

2) 일단의 토지의 의미

‘일단의 토지’란 연속된 토지로서 그 전체가 어떤 단일의 목적에 공용되고 있는 것으로 전체로서 경제상의 이용가치를 지니는 것을 말하며, 반드시 공부상의 한 필지임을 요하지 않는다. 다만, 일단의 토지는 동일한 소유자에게 속하는 것 이어야 한다.

03 보상청구 기간 (토지보상법 제73조 제2항)

잔여지의 손실 또는 비용의 보상은 사업이 완료된 날 또는 제24조의2에 따른 사업완료의 고시가 있는 날부터 1년이 지난 후에는 청구할 수 없다(제73조 제2항).

04 잔여지 매수의 효과

사업인정고시가 된 후 사업시행자가 잔여지를 매수하는 경우 그 잔여지에 대해서는 사업인정 및 사업인정고시가 된 것으로 본다(제73조 제3항).

05 손실보상 청구 절차

- ① 잔여지의 손실 또는 비용의 보상이나 토지의 취득에 관하여는 손실에 대한 협의 및 협의 불성립시 재결신청에 관한 규정을 준용한다(제73조 제4항).
- ② 즉 손실보상은 사업시행자와 손실을 입은 자가 협의하여 결정하며, 협의가 성립되지 아니하면 사업시행자나 손실을 입은 자는 관할 토지수용위원회에 재결을 신청할 수 있다.
- ③ 수용재결에서 정한 손실보상금에 불복하고자 하는 경우 이의신청(제83조) 또는 보상금증감청구소송(제85조 제2항)으로 다툴 수 있다.

06 소송제기 전 재결이 선행되어야 하는지 여부 (재결전치주의)

판례는 토지보상법이 협의, 재결, 쟁송의 절차를 규정한 내용 및 입법 취지 등을 종합하여 보면, 토지소유자가 사업시행자로부터 공익사업법 제73조에 따른 잔여지 가격감소 등으로 인한 손실보상을 받기 위해서는 토지보상법 제34조, 제50조 등에 규정된 재결절차를 거친 다음 그 재결에 대하여 불복이 있는 때에 비로소 공익사업법 제83조 내지 제85조에 따라 권리구제를 받을 수 있을 뿐, 이러한 재결절차를 거치지 않은 채 곧바로 사업시행자를 상대로 손실보상을 청구하는 것은 허용되지 않는다고 봄이 상당하다고 판시했다(2006두19495).

01 의의 및 취지 (토지보상법 제74조)

잔여지수용청구란 일정한 요건하에 토지소유자가 사업시행자에게 잔여지를 매수하여 줄 것을 청구하는 것을 말한다. 확장수용의 일환으로 피수용자의 권리구제 확대 및 원활한 사업수행에 그 취지가 인정된다.

02 요건**1) 토지보상법 제74조**

- ① 동일한 소유자에게 속하는 일단의 토지의 일부가 협의에 의하여 매수되거나 수용됨으로 인하여 잔여지를 종래의 목적에 사용하는 것이 현저히 곤란할 때에는 해당 토지소유자는 사업시행자에게 잔여지를 매수하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사업인정 이후에는 관할 토지수용위원회에 수용을 청구할 수 있다.
- ② 이 경우 수용의 청구는 매수에 관한 협의가 성립되지 아니한 경우에만 할 수 있으며, 사업완료일까지 하여야 한다.

2) 토지보상법 시행령 제39조

- ① 대지로서 면적이 너무 작거나 부정형등의 사유로 건축물을 건축할 수 없거나 건축물의 건축이 현저히 곤란한 경우
- ② 농지로서 농기계의 진입과 회전이 곤란할 정도로 폭이 좁고 길게 남거나 부정형 등의 사유로 영농이 현저히 곤란한 경우
- ③ 공익사업의 시행으로 교통이 두절되어 사용이나 경작이 불가능하게 된 경우
- ④ 위와 유사한 정도로 잔여지를 종래의 목적대로 사용하는 것이 현저히 곤란하다고 인정되는 경우 중 하나에 해당하여야 한다.

3) 관련 판례

- ① '종래의 목적'이라 함은 수용재결 당시에 당해 잔여지가 현실적으로 사용되고 있는 구체적인 용도를 의미하고,
- ② '사용하는 것이 현저히 곤란한 때'라고 함은 물리적으로 사용하는 것이 곤란하게 된 경우는 물론 사회적, 경제적으로 사용하는 것이 곤란하게 된 경우, 즉 절대적으로 이용 불가능한 경우만이 아니라 이용은 가능하나 많은 비용이 소요되는 경우를 포함한다고 판시한 바 있다.

※ 보충자료 - 취득하는 잔여지의 평가

동일한 토지소유자에 속하는 일단의 토지의 일부가 취득됨으로 인하여 종래의 목적에 사용하는 것이 현저히 곤란하게 된 잔여지에 대하여는 그 일단의 토지의 전체가격에서 공익사업시행지구내 편입되는 토지의 가격을 뺀 금액으로 평가한다(토지보상법 시행규칙 제32조 제3항).

03 잔여지수용거부시 제기할 수 있는 소송의 형식

1) 잔여지수용청구권의 법적성질 (형성권)

잔여지 수용청구권은 손실보상의 일환으로 토지소유자에게 부여되는 권리로서 그 요건을 구비한 때에는 잔여지를 수용하는 토지수용위원회의 재결이 없더라도 그 청구에 의하여 수용의 효과가 발생하는 **형성권**에 해당한다.

2) 잔여지수용 거부에 대한 보상금증감청구소송 가능성

(1) 학설

- ① 보상금액과 보상범위는 밀접한 관련이 있으므로 보상금증감청구소송에서 심리할 수 있다고 보는 <긍정설>과
- ② 확장수용에 대한 다툼은 보상금액의 문제가 아니라 보상의 범위에 관련된 문제이므로, 취소소송이나 무효등 확인소송을 제기해야 한다 보는 <부정설>이 있다.

(2) 판례

잔여지 수용청구권은 손실보상의 일환으로 토지소유자에게 부여되는 권리로서 그 요건을 구비한 때에는 잔여지를 수용하는 토지수용위원회의 재결이 없더라도 수용의 효과가 발생하는 **형성권적 성질**을 가지므로, 잔여지 수용청구를 받아들이지 않은 토지수용위원회의 재결에 대하여 토지소유자가 불복하여 제기하는 소송은 토지보상법 제85조 제2항에 규정되어 있는 **“보상금의 증감에 관한 소송”**에 해당하여 사업시행자를 피고로 하여야 한다고 판시했다.

(3) 검토

보상금증감청구소송의 제도 취지가 **분쟁의 일회적 해결**로서 피수용자의 권리구제를 위한 것이므로, 보상금증감 청구소송에서 목적물 범위까지 심리하여 다룰 수 있도록 함이 타당하다.

04 관련문제 (잔여지의 수용청구와 잔여지의 가격감소의 선택적 병합 가부)

대법원 2014. 4. 24. 선고 2012두6773

청구의 선택적 병합은 원고가 양립할 수 있는 수 개의 경합적 청구권에 기하여 동일 취지의 급부를 구하거나 양립할 수 있는 수 개의 형성권에 기하여 동일한 형성적 효과를 구하는 경우에 그 어느 한 청구가 인용될 것을 해제조건으로 하여 수 개의 청구에 관한 심판을 구하는 병합 형태이므로, 논리적으로 양립할 수 없는 수 개의 청구는 **선택적 병합이 허용되지 아니한다**. 그런데 잔여지의 수용청구와 잔여지의 가격감소로 인한 손실보상청구는 서로 양립할 수 없는 관계에 있어 선택적 병합이 불가능한데 원심이 위 두 청구의 선택적 병합 청구를 허가한 것 또한 잘못이다.

01 개설

- ① <건축물 등>이라 함은 건축물·입목·공작물과 그 밖에 토지에 정착한 물건을 말한다(제75조 제1항).
- ② 건축물 등은 공익사업 시행을 위하여 직접 필요한 경우도 있으나 대부분은 당해 공익사업 수행을 위하여 직접 필요로 하지 않는 지장물이다.
- ③ 토지보상법은 건축물 등 물건에 대하여는 **이전에 필요한 비용**으로 보상하도록 규정하고, 예외적으로 **물건의 가격**으로 보상하는 방법을 규정하고 있다.

02 건축물에 대한 보상평가

1) 건축물의 의미

- ① <건축물>이란 토지에 정착하는 공작물 중 지붕과 기둥 또는 벽이 있는 것과 이에 딸린 시설물, 지하나 고가의 공작물에 설치하는 사무소·공연장·점포·차고·창고 등을 말한다(건축법 제2조 제1항 제2호).
- ② 건축물(담장 및 우물 등의 부대시설을 포함한다. 이하 같다)에 대하여는 그 구조·이용상태·면적·내구연한·유용성 및 이전가능성 그 밖에 가격형성에 관련되는 제요인을 종합적으로 고려하여 평가한다(칙 제33조 제1항).

2) 보상평가기준

(1) 건축물 가격의 평가

가. 이전비 보상의 원칙

건축물 등에 대한 보상은 **이전비로 보상함이 원칙**이다(제75조 제1항).

나. 물건가격으로 보상하는 경우

- ① 건축물의 가격은 **원가법**으로 평가한다.
- ② 다만, **주거용 건축물**에 있어서는 거래사례비교법에 의하여 평가한 금액이 원가법에 의하여 평가한 금액보다 큰 경우와 구분소유권의 대상이 되는 건물의 가격은 **거래사례비교법**으로 평가한다(칙 제33조 제2항).

다. 개발이익의 배제

- ① 주거용 건축물을 거래사례비교법으로 평가함에 있어 공익사업의 시행에 따라 이주대책을 수립·실시하거나 주택임주권 등을 당해 건축물의 소유자에게 주는 경우 또는 개발제한구역안에서 이전이 허용되는 경우에 있어서의 당해 사유로 인한 **가격상승분은 제외**하고 평가하도록 규정하고 있다(칙 제33조 제2항).
- ② 이는 공익사업이 없었더라면 발생하지 아니하였을 일종의 <개발이익>이라 볼 수 있으므로 이를 배제하고 평가하여야 한다는 취지이다.

CASE

공부상 지목이 과수원으로 되어 있는 토지의 소유자 甲은 토지상에 식재되어 있던 사과나무가 이미 폐목이 되어 과수농사를 할 수 없는 상태에서 사과나무를 베어내고 인삼밭으로 사용하여 왔다. 또한 甲은 이 토지의 일부에 토지의 형질변경허가 및 건축허가를 받지 않고 2005년 8월 26일 임의로 지상 3층 건물을 건축하고, 영업허가 등의 절차 없이 식당을 운영하고 있다. 위 토지 및 지장물에 대한 보상평가기준에 대해 설명하시오. [18회, 문3]

1) 무허가건축물의 의의

「건축법」 등 관계법령에 의하여 허가를 받거나 신고를 하고 건축 또는 용도변경을 하여야 하는 건축물을 허가를 받지 아니하거나 신고를 하지 아니하고 건축 또는 용도변경한 건축물이다(칙 제24조).

2) 무허가건축물의 보상여부

(1) 문제점

토지보상법은 무허가건축물의 보상 여부에 대해서는 직접적으로 규정하고 있지 않아서 무허가건축물도 보상대상이 되는지 문제된다.

(2) 학설

① 보상대상이 아니라는 견해

무허가건축물을 보상한다면 결과적으로 무질서한 건축행위까지 승인하는 결과가 되기 때문에 부정하는 견해

② 보상대상이라는 견해

위반건축물에 대한 제재와 보상은 별개의 것으로 보아야 한다는 견해이다.

③ 사업인정을 기준으로 하는 견해

토지보전의무에 관한 이 규정과 관련하여 사업인정 후의 무허가건축물은 보상의 대상이 아니나 사업인정 전의 무허가건축물은 보상대상이라고 보는 견해이다.

(3) 판례

판례는 지장물인 건물은 그 건물이 적법한 건축허가를 받아 건축된 것인지 여부에 관계없이 토지수용법상의 사업인정의 고시 이전에 건축된 건물이기만 하면 손실보상의 대상이 됨이 명백하다(대판 99두10896).

(4) 검토

생각건대 허가는 그 성질에 비추어 행위의 적법성 여부에만 관여하고 유효성 여부와는 무관하므로 재산권 요건을 충족하므로, 사업인정을 기준으로 하여 판단하는 견해가 타당하다.

3) 보상평가기준

- ① 보상대상이 되는 무허가건축물은 당해 무허가건축물이 허가를 받지 않은 사정을 고려하지 않은 상태로 평가하여야 할 것이므로, 결국 평가방법에 있어 적법한 건축물의 평가방법과 동일한 평가방법을 적용해야 할 것이다.
- ② 그러나 무허가 건축물은 인허가에 드는 행정적 비용과 보유기간 동안의 재산세 등은 이를 부담하지 않았으므로, 이를 고려하여 평가하여야 한다.

04 주거용 건축물 등의 보상에 관한 특례

1) 주거용 건축물의 최저 보상에 관한 특례

- ① 주거용 건축물에 대하여는 최저 보상의 한계를 정하여 철거 대상자의 생계대책을 기하고 공익사업의 원활화를 위해 사회정책적 보상을 하도록 하고 있다.
- ② 주거용건축물로서 건축물 평가 규정에 따라 평가한 금액이 6백만 원 미만인 경우 그 보상액은 6백만 원으로 한다. 다만, 무허가건축물 등에 대하여는 그러하지 아니하다(칙 제58조 제1항).
- ③ 그러나 1989년 1월 24일 당시 무허가건축물 등에 대하여는 적법한 건축물로 본다고 규정하고 있으므로(규칙 부칙 제5조), 당시 무허가건축물에 대해서도 이 특례규정이 적용된다.

2) 재편입 주거용 건축물에 대한 가산금

- ① 공익사업의 시행으로 인하여 주거용 건축물에 대한 보상을 받은 자가 그 후 당해 공익사업시행지구밖의 지역에서 매입하거나 건축하여 소유하고 있는 주거용 건축물이 그 보상일부터 20년 이내에 다른 공익사업시행지구내 편입되는 경우 그 주거용 건축물 및 그 대지(보상을 받기 이전부터 소유하고 있던 대지 또는 다른 사람 소유의 대지위에 건축한 경우에는 주거용 건축물에 한한다)에 대하여는 당해 평가액의 30퍼센트를 가산하여 보상한다.
- ② 다만, 무허가건축물등을 매입 또는 건축한 경우와 다른 공익사업의 사업인정고시일등 또는 다른 공익사업을 위한 관계법령에 의한 고시 등이 있는 날 이후에 매입 또는 건축한 경우에는 그러하지 아니하다(칙 제58조 제2항).
- ③ 가산금이 1천만 원을 초과하는 경우에는 1천만 원으로 한다(칙 제58조 제3항).
- ④ 1989년 1월 24일 당시의 무허가건축물에 대해서도 특례를 적용하여 보상금이 가산지급된다.

CASE

주식회사 甲은 30년 넘게 서울특별시 A구에서 콘크리트 제조 공장을 허가 받아 적법하게 운영하고 있다. 甲이 창고로 사용하고 있는 부지(이하 '이 사건 부지'라 함)는 백제 한성기의 왕성 유적으로 알려진 국가지정문화유산 B유적지의 보호구역에 있다. 학계 등은 B유적지의 완전한 복원을 위해서는 이 사건 부지의 수용 필요성을 오래전부터 제기해 왔고, 이 사건 부지에 있는 창고의 증축과정에서 백제 토성의 유물이 발견되기도 하였다.

한편, 관련 법령에 따라 B유적지를 관리하는 A구청장 乙은 B유적지의 정비 및 복원을 위하여 이 사건 부지에 대한 공익사업을 계획하고 국토교통부장관에게 사업인정 신청을 하였다. 국토교통부장관은 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」(이하 '토지보상법'이라 함)에 따라 사업인정(이하 '이 사건 사업인정'이라 함)을 하고 이를 고시하였다. 甲은 다음과 같은 이유로 이 사건 사업인정 및 고시가 위법하다고 주장한다.

물음 3) 이 사건 부지에 대한 수용이 진행될 경우, 甲의 영업손실에 대한 보상 요건을 설명하시오. [36회, 문1]

01 의미 및 성격

- ① 영업손실이란 수용대상이 된 토지·건물 등을 이용하여 영업을 하다가 그 토지·건물 등이 수용됨으로 인하여 영업을 할 수 없거나 제한을 받게 됨으로 인하여 생기는 직접적인 손실을 말한다.
- ② 영업손실보상(제77조 제1항)은 주로 재산권보상 중에서 일실손실의 보상이며 구체적 내용에 따라 생활보상의 성격과 간접보상의 성격도 가진다.

02 영업손실의 보상대상인 영업 (토지보상법 시행규칙 제45조)

1) 시간적 요건

영업손실보상의 대상이 되려면 **사업인정고시일등**(사업인정고시일과 보상계획공고일 중 빠른 날) **이전부터** 영업을 하고 있어야 한다.

2) 장소적 요건

영업손실보상의 대상이 되려면 **적법한 장소**에서 이루어진 영업이어야 한다. 이는 불법행위에 의한 영업은 보상대상에서 제외하는 것에 취지가 있다. 다만, **무허가건축물등에서 임차인**이 영업하는 경우에는 그 임차인이 사업인정 고시일등 **1년 이전부터** 「부가가치세법」 제8조에 따른 **사업자등록**을 하고 영업을 행한 경우에는 보상대상이 된다.

3) 시설적 요건

영업손실보상의 대상이 되려면 일정한 정도의 인적·물적 시설을 갖추어야 한다.

4) 계속적 요건

영업손실보상의 대상이 되기 위해서는 계속적으로 영업을 하여야 한다. 판례는 매년 일정한 계절이나 일정한 기간에만 영업을 하는 경우에도 계속적 영업에 해당한다고 판시하였다.

5) 허가 등의 요건

영업을 함에 있어 관계 법령에 따른 허가 등을 필요로 하는 경우에는, 사업인정고시일등 전에 그 허가 등을 받아 그 내용대로 영업을 하고 있어야 한다.

03 영업의 폐지와 휴업의 구분

1) 토지보상법상 기준 (칙 제46조 제2항)

- ① 영업장소 또는 배후지(당해 영업의 고객이 소재하는 지역을 말한다. 이하 같다)의 특수성으로 인하여 당해 영업소가 소재하고 있는 시·군·구(자치구를 말한다. 이하 같다) 또는 인접하고 있는 시·군·구의 지역안의 다른 장소에 이전하여서는 당해 영업을 할 수 없는 경우
- ② 당해 영업소가 소재하고 있는 시·군·구 또는 인접하고 있는 시·군·구의 지역안의 다른 장소에서는 당해 영업의 허가등을 받을 수 없는 경우
- ③ 도축장 등 악취 등이 심하여 인근주민에게 혐오감을 주는 영업시설로서 해당 영업소가 소재하고 있는 시·군·구 또는 인접하고 있는 시·군·구의 지역안의 다른 장소로 이전하는 것이 현저히 곤란하다고 특별자치도지사·시장·군수 또는 구청장(자치구의 구청장을 말한다)이 객관적인 사실에 근거하여 인정하는 경우

2) 영업의 폐지와 휴업의 구별 기준 (이전가능성)

대법원은 영업의 폐지로 볼 것인지 아니면 영업의 휴업으로 볼 것인지를 구별하는 기준은 당해 영업을 그 영업소 소재지나 인접 시·군·구 또는 그 지역 안의 다른 장소로 이전하는 것이 가능한지 여부에 달려 있고, 이러한 **이전 가능성 여부**는 법령상의 이전 장애 사유 유무와 당해 영업의 종류와 특성, 영업시설의 규모, 인접 지역의 현황과 특성, 그 이전을 위하여 당사자가 들인 노력 등과 인근 주민들의 반대 등과 같은 사실상의 이전 장애 사유 유무 등을 종합하여 판단하여야 한다고 한다(대판 2005. 9. 15. 2004두14649 등).

04 보상평가기준

1) 폐업보상

(1) 평가기준

2년간의 영업이익(개인영업인 경우에는 소득을 말함)에 영업용 고정자산·원재료·제품 및 상품 등의 매각손실액을 더한 금액으로 평가한다(칙 제46조 제1항).

(2) 영업이익 및 소득의 산정

- ① 영업이익은 해당 영업의 최근 3년간(특별한 사정으로 인하여 정상적인 영업이 이루어지지 아니한 연도를 제외한다)의 평균 영업이익을 기준으로 하여 이를 평가하되, 공익사업의 계획 또는 시행이 공고 또는 고시됨으로 인하여 영업이익이 감소된 경우에는 해당 공고 또는 고시일전 3년간의 평균 영업이익을 기준으로 평가한다.
- ② 이 경우 개인영업으로서 최근 3년간의 평균 영업이익이 다음 산식에 의하여 산정한 연간 영업이익에 미달하는 경우에는 그 연간 영업이익을 최근 3년간의 평균 영업이익으로 본다.

- ③ 연간 영업이익 = 「통계법」 제3조제3호에 따른 통계작성기관이 같은 법 제18조에 따른 승인을 받아 작성 · 공표한 제조부문 보통인부의 임금단가 × 25(일) × 12(월)
- ④ 영업이익의 산정은 실제의 영업이익을 반영할 수 있는 합리적인 방법에 의하면 된다고 대법원은 판시하였다(대판 2004. 10. 28. 2002다3662).

2) 휴업보상

공익사업의 시행으로 인하여 영업장소를 이전하여야 하는 경우의 영업손실은 휴업기간에 해당하는 영업이익과 영업장소 이전 후 발생하는 영업이익감소액에 다음 각호의 비용을 합한 금액으로 평가한다(칙 제47조 제1항).

- ① 휴업기간중의 영업용 자산에 대한 감가상각비 · 유지관리비와 휴업기간중에도 정상적으로 근무하여야 하는 최소인원에 대한 인건비 등 고정적 비용
- ② 영업시설 · 원재료 · 제품 및 상품의 이전에 소요되는 비용 및 그 이전에 따른 감손상당액
- ③ 이전광고비 및 개업비 등 영업장소를 이전함으로 인하여 소요되는 부대비용

05 무허가건축물 임차인의 영업에 대한 보상

1) 폐업보상

무허가건축물 등에서 임차인이 영업하는 경우 폐업보상액 중 영업용 고정자산 등 매각손실액을 제외한 금액은 1천만 원을 초과하지 못한다(칙 제46조 제5항).

2) 휴업보상

영업시설의 이전비용 및 감손상당액을 제외한 금액은 1천만 원을 초과하지 못한다(칙 제47조 제6항).

06 무허가영업의 손실보상에 관한 특례

1) 3개월 수준의 가계지출비 수준의 보상

사업인정고시일등 전부터 허가 등을 받아야 행할 수 있는 영업을 허가등 없이 행하여 온 자가 공익사업의 시행으로 인하여 적법한 장소에서 영업을 계속할 수 없게 된 경우에는 「통계법」에 따른 가계조사통계의 도시근로자가구 월평균 가계지출비를 기준으로 산정한 3인 가구 3개월분 가계지출비에 해당하는 금액을 영업손실에 대한 보상금으로 지급하되, 영업시설 등의 이전비용은 별도로 보상한다(칙 제52조 본문).

2) 무허가영업에 대한 손실보상의 배제 및 한도

본인 또는 생계를 같이 하는 동일 세대안의 직계존속 · 비속 및 배우자가 해당 공익사업으로 다른 영업에 대한 보상을 받은 경우에는 영업시설 등의 이전비용만을 보상하여야 한다(칙 제52조 단서).

07 공익사업시행지구 밖의 영업손실에 대한 보상

1) 보상기준

공익사업시행지구 밖에서 영업손실 보상대상이 되는 영업을 하고 있는 자가, 공익사업의 시행으로 인하여,

- ① 배후지의 3분의 2 이상이 상실되어 그 장소에서 영업을 계속할 수 없는 경우,
- ② 진출입로의 단절, 그 밖의 부득이한 사유로 인하여 일정한 기간 동안 휴업하는 것이 불가피한 경우의 어느 하나에 해당하면, 그 영업자의 청구에 의하여 당해 영업을 공익사업시행지구에 편입되는 것으로 보아 보상하여야 한다(칙 제64조 제1항).

2) 보상금의 환수

사업시행자는 영업자가 보상을 받은 이후에 그 영업장소에서 영업이익을 보상받은 기간 이내에 동일한 영업을 하는 경우에는 실제 휴업기간에 대한 보상금을 제외한 영업손실에 대한 보상금을 환수하여야 한다(칙 제64조 제2항).

08 관련 문제

1) 가설건축물 안에서의 영업이 보상대상이 되는지

- ① 가설건축물은 무허가건축물은 아니나 가설건축물은 공익사업이 시행될 때 철거가 예정되어 있으므로 가설건축물 내의 영업도 보상대상이 아니라고 보는 것이 타당하다.
- ② 대법원도 가설건축물의 철거는 물론 이에 다른 영업손실의 보상도 청구할 수 없다는 입장을 취하고 있다.

2) 자유영업의 경우 사업자등록이 영업의 적법요건인지

- ① 견해의 대립이 있으나, 생각건대 사업자등록은 납세의무와 관련이 있는 것이지 영업의 적법요건으로 볼 수는 없다.
- ② 따라서 자유영업은 사업자등록을 하지 아니하였다고 하여 영업보상 대상에서 제외할 수 없을 것이다.

CASE 1

A시는 도시개발사업을 하면서 주거를 상실하는 거주자에 대한 이주대책을 수립하였다. 이주대책의 주요내용은 다음과 같다. 이를 근거로 다음 물음에 답하시오.(45점) [20회, 문1]

- 기준일 이전부터 사업구역 내 자기 토지상 주택을 소유하고 협의 계약 체결일까지 당해 주택에 계속 거주한 자가 보상에 합의하고 자진 이주한 경우 사업구역 내 분양아파트를 공급한다.
- 분양아파트를 공급받지 않은 이주자에게는 이주정착금을 지급한다.
- 무허가건축물 대장에 등록된 건축물 소유자는 이주대책에서 제외한다.

- 1) 이주대책의 이론적 및 헌법적 근거를 설명하시오.(5점)
- 2) 주택 소유자 甲이 보상에 합의하고 자진 이주하지 아니한 경우에도 이주대책에 의한 분양아파트의 공급 혹은 이주정착금의 지급을 요구할 수 있는지의 여부를 검토하시오.(20점)
- 3) 무허가건축물대장에 등록되지 않은 건축물 소유자 乙이 당해 건축물이 무허가건축물이라는 이유로 이주대책에서 제외된 경우에 권리구제를 위하여 다룰 수 있는 근거와 소송방법에 관하여 검토하시오.(20점)

CASE 2

도지사 A는 “X국가산업단지 내 국도 대체우회도로개설사업”(이하 ‘이 사건 개발사업’이라 함)의 실시계획을 승인·고시하고, 사업시행자로 B시의 시장을 지정하였다. B시의 시장은 이 사건 개발사업을 시행함에 있어 사업시행으로 인하여 건물이 철거되는 이주대상자를 위한 이주대책을 수립하면서 훈령의 형식으로 ‘B시 이주민지원규정’을 마련하였다.

위 지원규정에서는 ① 이주대책대상자 선정과 관련하여 공익사업을 위한 토지등의 취득 및 보상에 관한 법률 및 그 시행령이 정하고 있는 이주대책대상자 요건 외에 ‘전세대원이 사업구역 내 주택 외 무주택’이라는 요건을 추가적으로 규정하는 한편, ② B시의 이주택지 지급 대상에 관하여, 과거 건축물양성화기준일 이전 건물의 거주자의 경우 소지가(조성되지 아니한 상태에서의 토지가격) 분양대상자로, 기준일 이후 건물의 거주자의 경우 일반우선 분양대상자로 구분하고 있는 바, 소지가 분양대상자의 경우 1세대당 상업용지 3평을 일반분양가로 추가 분양하도록 하고, 일반우선 분양대상자의 경우 1세대 1필지 이주택지를 일반분양가로 우선분양할 수 있도록 하고 있다.

B시의 시장은 이주대책을 실시하면서 이 사건 개발사업 구역 내에 거주하는 甲과 乙에 대하여, 甲은 공익사업을 위한 토지등의 취득 및 보상에 관한 법령이 정한 이주대책대상자에 해당됨에도 위 ①에서 정하는 요건을 이유로 이주대책대상자에서 배제하는 부적격 통보를 하였고, 소지가 분양대상자로 신청한 乙에 대해서는 위 지원규정을 적용하여 소지가 분양대상이 아닌 일반우선분양대상자로 선정하고, 이를 공고하였다. 다음 물음에 답하시오. (30점)

- 1) 甲은 ‘B시 이주민지원규정’에서 정한 추가적 요건을 이유로 자신을 이주대책 대상자에서 배제한 것은 위법하다고 주장한다. 甲의 주장이 타당한지에 관하여 설명하시오.(15점)
- 2) 乙은 자신을 소지가 분양대상자가 아닌 일반우선 분양대상자로 선정한 것은 위법하다고 보아 이를 소송으로 다투려고 한다. 乙이 제기하여야 하는 소송의 형식을 설명하시오.(15점) [28회, 문2]

01 의미

- ① 이주대책이란 공익사업의 시행으로 인하여 생활의 근거를 상실하게 되는 자를 종전과 같은 생활상태를 유지할 수 있도록 다른 지역으로 이주시키는 것을 말한다.
- ② 최근에는 주거용 건축물을 제공하여 생활근거를 상실한 자뿐만 아니라, 공장부지를 제공한 자에게도 사업시행자가 공장의 이주대책을 수립·실시하도록 하고 있다.

02 이주대책의 범위

- ① 협의의 이주대책은 사업시행자가 수립하는 계획에 따라 이주대책대상자를 이주정착지에 이주시키는 것을 말하고,
- ② 광의의 이주대책은 이주정착금의 지급 등을 포함하여 사업시행자가 이주대책대상자의 이주를 지원하는 모든 것을 말한다.

03 근거

1) 이론적 근거

원상회복, 생활보장, 생활안정, 감정존중 등의 근거를 들 수 있다.

2) 헌법적 근거

(1) 학설

- ① 헌법 제23조 제3항의 완전보상에 포함될 수 있다는 헌법 제23조설
- ② 생활보상은 인간다운 생활을 보장하기 때문에 헌법 제34조의 사회보장수단으로서의 성격을 지닌다는 헌법 제34조설
- ③ 헌법 제23조 제3항의 공적부담의 평등의 성격과 헌법 제34조의 생존배려 성격이 결합된 것으로 보는 헌법 제23조 및 제34조 통일설이 대립한다.

(2) 판례

- ① <헌법재판소>는 이주대책은 생활보호 차원에서 실시하는 시혜적 조치로서 헌법 제23조 제3항에 해당하지 않는다고 하였고,
- ② <대법원>은 인간다운 생활을 보장하기 위한 국가의 정책적 배려라고 하여 제34조설을 취하고 있다.
다만 최근에는 생활대책이 헌법 제23조 제3항에 따른 정당한 보상에 포함되는 것으로 본 판례가 있다.

(3) 검토

복리국가주의 이념의 등장과 함께 정당보상이 대물보상 뿐만 아니라 생활보상까지 포함하는 것으로 확대되고 있고, 생활보상의 내용에 경제적 약자에 대한 생존배려형 보상이 포함되어 있다는 점을 고려할 때, **통일설**이 타당하다.

3) 토지보상법상 근거

토지보상법 제78조의 주거용 건축물에 대한 이주대책을 생활보상으로 볼 수 있고 동법 제78조의 2에서 공장부지 제공자에 대한 이주대책이 규정되어 있다.

1) 이주대책의 수립·실시 의무

(1) 이주대책의 수립·실시 의무

사업시행자는 공익사업의 시행으로 인하여 주거용 건축물을 제공함에 따라 생활의 근거를 상실하게 되는 자 (이하 "이주대책대상자"라 한다)를 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 이주대책을 수립·실시하거나 이주정착금을 지급하여야 한다(제78조 제1항).

(2) 이주대책 수립·실시의 의제

사업시행자가 「택지개발촉진법」 또는 「주택법」 등 관계 법령에 따라 이주대책대상자에게 택지 또는 주택을 공급한 경우(사업시행자의 알선에 의하여 공급한 경우를 포함한다)에는 이주대책을 수립·실시한 것으로 본다 (령 제40조 제2항 단서). 이 경우에는 이주정착금의 지급 대상도 아니다.

2) 이주대책 수립요건

- ① 공익사업시행지구의 인근에 택지 조성에 적합한 토지가 없는 경우 또는
- ② 이주대책에 필요한 비용이 당해 공익사업의 본래의 목적을 위한 소요비용을 초과하는 등 이주대책의 수립·실시로 인하여 당해 공익사업의 시행이 사실상 곤란하게 되는 경우(칙 제53조 제1항)를 제외하고는
- ③ 이주대책대상자 중 이주정착지에 이주를 희망하는 자의 가구 수가 10호(戶) 이상인 경우에 수립·실시한다 (령 제40조 제2항).

3) 이주대책대상자에서 제외되는 경우 (령 제40조 제5항)

- ① 허가를 받거나 신고를 하고 건축 또는 용도변경을 하여야 하는 건축물을 허가를 받지 아니하거나 신고를 하지 아니하고 건축 또는 용도변경을 한 건축물의 소유자,
- ② 해당 건축물에 공익사업을 위한 관계 법령에 따른 고시 등이 있는 날부터 계약체결일 또는 수용재결일까지 계속하여 거주하고 있지 아니한 건축물의 소유자. (다만, 질병으로 인한 요양, 징집으로 인한 입영, 공무, 취학, 해당 공익사업지구 내 타인이 소유하고 있는 건축물에서의 거주, 그 밖에 이들에 준하는 부득이한 사유로 거주하고 있지 아니한 경우에는 제외대상자가 아니다.)
- ③ 타인이 소유하고 있는 건축물에 거주하는 세입자. 다만, 해당 공익사업지구에 주거용 건축물을 소유한 자로서 타인이 소유하고 있는 건축물에 거주하는 세입자는 제외한다.

4) 절차

- ① 사업시행자는 이주대책계획을 수립하려는 경우 미리 그 내용을 이주대책대상자들에게 통지하여야 한다 (령 제40조 제1항).
- ② 사업시행자는 이주대책계획을 수립하고자 하는 때에는 미리 관할 지방자치단체의 장과 협의하여야 하고, 공익사업 면적이 10만 제곱미터 이상이고, 토지등의 소유자가 50인 이상인 공익사업 시행시는 보상협의회를 두어야 하는데, 이주대책 수립에 관한 사항에 대해 보상협의회의 협의를 거쳐야 한다(제82조 제1항).

5) 이주대책의 내용

(1) 이주대책 수립 시 사업시행자의 재량

- ① 사업시행자는 이주대책을 수립할 의무를 지지만, 이주대책의 내용 결정에 대해서는 재량권을 갖는다.
- ② 대법원은 일관되게 사업시행자가 이주대책의 내용 결정에 재량을 갖는다는 입장을 취하고 있다(2007.2.22. 2004두7481)

(2) 이주정착지의 조성 및 공급

- ① 이주대책의 내용에는 이주정착지(이주대책의 실시로 건설하는 주택단지를 포함한다)에 대한 도로, 급수시설, 배수시설, 그 밖의 공공시설 등 통상적인 수준의 생활기본시설이 포함되어야 하며, 이에 필요한 비용은 사업시행자가 부담한다. 다만, 행정청이 아닌 사업시행자가 이주대책을 수립·실시하는 경우에 지방자치단체는 비용의 일부를 보조할 수 있다(제78조 제4항).
- ② 이주단지조성사업이 완료되면 이주대상자에게 이주택지를 분양한다. 국가나 지방자치단체는 이주대책의 실시에 따른 주택지의 조성 및 주택의 건설에 대하여는 「주택도시기금법」에 따른 주택도시기금을 우선적으로 지원하여야 한다(제78조 제3항).
- ③ 이주정착지 안의 택지나 주택의 취득 또는 사업시행자가 이주대상자에게 택지 또는 주택을 공급한 경우 택지나 주택의 취득에 소요되는 비용은 이주대책대상자의 희망에 따라 지급받을 보상금과 상계할 수 있다(령 제40조 제4항).

6) 사업시행자가 수립한 이주대책 기준의 대외적 구속력 여부

- ① 대법원은 한국토지주택공사가 수립한 이주대책기준에 대하여 <사업시행자 내부의 사무처리준칙>에 불과하고, 대외적으로 국민이나 법원을 기속하는 효력이 없다고 판시하였다(대법원 96누140672).
- ② 다만, 사업시행자는 이주대책을 수립·실시하는데 재량을 가지므로 사업시행자가 설정한 이주대책기준은 그것이 객관적으로 합리적이 아니라거나 타당하지 않다고 볼 만한 특별한 사정이 없는 한 존중되어야 한다고 하였다(대법원 2008두12610).

※ 보충자료 - 이주대책 권리의 전매제한과 형사처벌

- ① 이주대책 권리(주택지 또는 주택을 공급받기로 결정된 권리)는 제78조 제5항에 따라 소유권이전등기를 완료할 때까지 전매할 수 없다(다만, 상속은 제외).
- ② 이를 위반(토지보상법, 한국토지주택공사법 등 일부 규정 위반도 포함)할 때에는 사업시행자는 이주대책의 실시가 아닌 이주정착금으로 지급하여야 한다.

05 이주자의 법적 지위

1) 문제점

이주대책대상자는 이주대책상의 권리(이주대책계획수립청구권, 분양신청권, 수분양권)를 취득하는데, 이 권리를 언제 취득하는지가 문제된다.

2) 이주대책계획수립청구권

- ① 이주대책은 법상 부득이한 사유가 있는 경우를 제외하고는 이주대책대상자 중 이주정착지에 이주를 희망하는 자가 10호 이상인 경우 수립·실시를 의무로 하고 있다.
- ② 따라서 이주대책대상자는 사업시행자에게 특정한 이주대책을 청구할 권리는 발생하지 않지만, 이주대책을 수립할 것을 청구할 권리, 즉 이주대책계획수립청구권을 갖는다.
- ③ 법상의 이주대책대상자가 이주대책계획의 수립을 청구하였음에도 불구하고 사업시행자가 이주대책을 수립하지 않는 경우에는 의무이행심판 또는 부작위위법확인소송을 제기할 수 있고, 이주대책수립을 거부한 경우에는 의무이행심판(또는 거부처분취소심판) 또는 거부처분취소소송을 제기할 수 있다고 보아야 한다.

3) 분양신청권

이주대책계획이 수립되면 이주대책대상자는 분양신청권을 취득한다.

4) 수분양권의 발생시기

(1) 문제점

- ① 수분양권이란 이주단지조성사업에 의해 조성된 택지의 분양권이나 아파트입주권 등을 취득할 수 있는 구체적 권리이다.
- ② 수분양권이라는 특정한 실체법상의 권리가 언제 이주대책대상자에게 발생하는지 문제된다.

(2) 학설

① 법상 취득설 (=이주대책수립 이전설)

토지보상법 제78조의 규정에 의하여 당연히 이주자에게 구체적인 수분양권이 발생한다고 본다.

② 이주대책계획수립시설

토지보상법 규정에 의한 추상적·포괄적 권리가 사업시행자가 이주대책을 수립·실시한 때 구체적 권리인 수분양권으로 발생한다고 본다.

③ 확인·결정시설

이주자가 사업시행자에게 이주대책대상자 선정신청을 하고 사업시행자가 이를 받아들여 이주대책 대상자로 확인·결정하여야만 비로소 구체적인 수분양권이 발생한다고 본다.

(3) 판례

- ① 판례의 다수의견은 <확인·결정시설>의 입장에서 사업시행자의 이주대책 대상자 확인·결정은 행정처분에 해당하므로 이에 불복하는 자는 항고소송으로 다룰 수 있다는 입장이다.
- ② 다만 반대이견은 <법상 취득설>의 입장에서 사업시행자의 분양처분의 성질은 이는 이주자가 이미 취득하고 있는 수분양권을 구체화 시켜주는 과정에 불과하다고 본다.
- ③ 그리고 반대보충의견은 <이주대책계획수립시설>을 취하고 있다.

(4) 검토

- ① 토지보상법 제78조는 이주대책 수립에 대한 원론적인 규정만 있을 뿐 구체적인 내용이 없으므로 이 규정에 의하여 바로 수분양권이 발생한다고 볼 수는 없다.
- ② 따라서 사업시행자가 이주대책에 관한 **구체적인 계획을 수립하면** 그것만으로 법상 이주대책대상자는 수분양권 등 이주대책상 구체적인 권리를 취득한다고 보아야 할 것이다.
- ③ 그러나 법상 이주대책대상자가 아닌 이주자는 이주대책대상자선정신청을 하고 사업시행자가 이를 받아들여 이주대책대상자로 **확인·결정하여야** 비로소 실제적인 권리를 취득한다고 보아야 한다.

06 수분양권의 발생시기별 권리구제 방법

1) 법상 취득설 (=이주대책수립 이전설)

- ① 구체적 이주대책의 이행을 신청하고 그 이행이 없을 때 **부작위위법확인소송**을 제기하여 그 권리구제를 받을 수 있고, 그 권리를 포기한 것으로 볼 수 없는 한 언제나 신청이 가능하고 구체적 이주대책이 종료한 경우에도 **추가 이주대책을 요구**할 수 있다.
- ② 그리고 이주대책대상자 선정신청의 거부에 대하여 **거부처분의 취소를 청구**할 수 있을 뿐만 아니라, 구체적 이주대책계획에서 제외된 이주대책대상자는 자기 몫이 참칭 이주대책대상자에게 이미 분양되어 분양신청을 하더라도 거부당할 것이 명백한 특수한 경우에는 이주대책대상자로서 분양을 받을 권리 또는 그 **법률상 지위의 확인**을 구할 수 있다고 보아야 한다. 이때에 확인소송은 **확인소송의 보충성**이라는 소송법의 일반법리에 따라 그 확인소송이 권리구제에 유효 적절한 수단이 될 때에 한하여 그 소의 이익이 인정된다(대법원 92다35783 전원합의체 판결에서 반대의견).

2) 이주대책계획수립시절

- ① 사업시행자가 실제로 이주대책계획을 수립하기 이전에는 이주자의 수분양권은 아직 추상적인 권리나 법률상의 지위 내지 이익에 불과한 것이어서 이 단계에 있어서는 확인의 이익이 인정되지 아니하여 그 권리나 지위의 확인을 구할 수 없다고 할 것이고, 사업시행자가 이주대책계획을 수립하지 아니하는 경우에는 사업시행자에게 이를 청구하여 거부되면 **취소소송**을, 방치되면 **부작위위법확인**을 소구할 수 있다고 볼 것이다.
- ② 그러나 이주대책계획을 수립한 이후에는 이주대책대상자의 추상적인 수분양권이 그 이주대책이 정하는 바에 따라 구체적 권리로 바뀌게 되므로, 이주대책에서 제외된 이주대책대상자는 위와 같은 수분양권에 터잡은 **분양신청**을 하여 거부당한 경우에는 그 거부의 취소를 구하는 **항고소송**을 제기할 수 있을 것이고, 신청기간을 도과한 경우, 사업시행자가 미리 수분양권을 부정하거나 이주대책에 따른 분양절차가 종료되어 분양신청을 하더라도 거부당할 것이 명백한 경우, 또는 분양신청을 묵살당한 경우, 기타 확인판결을 얻음으로써 분쟁이 해결되고 권리구제가 가능하여 그 확인소송이 권리구제에 유효 적절한 수단이 될 수 있는 특별한 사정이 있는 경우에는, 당사자소송으로 수분양권 또는 그 **법률상의 지위의 확인**을 구할 수 있다고 보아야 한다(대법원 92다35783 전원합의체 판결에서 반대의견에 대한 보충의견).

3) 확인·결정시절

- ① 판례와 같이 사업시행자에 의해 이주대책대상자로 확인·결정되어야 비로소 실제적인 권리를 취득한다고 보면, 이주대책대상자 선정신청에 대한 거부는 거부처분이 되므로 이에 대하여 **취소소송**을 제기하고 부작위인 경우에는 **부작위위법확인소송**을 제기하여야 한다.

- ② 이주자가 사업시행자에 대한 이주대책대상자 선정신청 및 이에 따른 **확인·결정 등 절차를 밟지 아니하여 구체적인 수분양권을 아직 취득하지도 못한 상태에서** 곧바로 분양의무의 주체를 상대방으로 하여 민사소송이나 공법상 당사자소송으로 이주대책상의 **수분양권의 확인 등을 구하는 것은 허용될 수 없고**, 나아가 그 공급대상인 택지나 아파트 등의 특정부분에 관하여 그 수분양권의 확인을 소구하는 것은 더욱 불가능하다고 본다(대법원 92다35783 전원합의체 판결에서 다수의견).

4) 검토

- ① 생각건대, 법상 이주대책대상자는 구체적인 이주대책계획이 수립된 경우에는 그에 따라 구체적인 수분양권을 취득하므로 이주대책대상자 선정은 **확인행위**이다.
- ② 따라서 선정거부는 **확인행위의 거부**가 되므로 **취소소송**을 제기하거나 수분양권의 확인을 구하는 소송을 제기할 수 있다고 보아야 한다. 취소소송의 제기에는 불복기간의 제한이 있으므로 불복기간을 넘은 경우에는 **수분양권의 확인을 구하는 소송**을 제기하여야 할 것이다.
- ③ 만약 수분양권의 확인을 구하는 소송을 인정한다면, 이주대책의 수립 및 집행은 공행정사무로 보아야 하므로 수분양권은 공법상 권리로 보는 것이 타당하므로 **공법상 당사자소송**을 제기하여야 할 것이다.

학설	권리구제
법상 취득설 (이주대책 계획수립 이전설)	① 거부시 : 거부처분 취소소송 ② 분양신청을 하더라도 거부당할 것이 명백한 특수한 경우 : 분양을 받을 권리 또는 그 법률상 지위의 확인을 구할 수 있다.(확인소송의 보충성 필요)
이주대책 수립시절	① 거부시 : 거부처분 취소소송 ② 사업시행자가 미리 수분양권을 부정하거나, 분양절차가 종료되어 분양신청을 하더라도 거부당할 것이 명백할 경우, 확인소송이 권리구제에 유효 적절한 수단이 되는 경우 : 당사자소송으로 수분양권 또는 법률상 지위의 확인을 구할 수 있다.
확인·결정시절	① 거부시 : 거부처분취소소송 ② 이주대책대상자 선정신청 및 이에 따른 확인·결정 등 절차를 밟지 아니하여 수분양권을 아직 취득하지도 못한 상태에서 곧바로 분양의무의 주체를 상대방으로 하여 민사소송이나 공법상 당사자소송으로 이주대책상의 수분양권의 확인 등을 구하는 것은 허용될 수 없다.

07 확인·결정행위의 법적성질과 권리구제

1) 학설

- ① 확인결정행위를 수분양권 취득을 위한 요건이 되는 행정작용인 처분으로 보아, 확인결정이라는 처분에 의해 비로소 수분양권이라는 권리가 발생하는 **〈형성처분〉**으로 보는 견해,
- ② 토지보상법 제78조 규정에 충족되거나 이주대책계획이 수립되면 이주자는 수분양권을 가지므로, 확인결정은 이주대책 수립·실시절차를 이행하기 위해 행하는 **〈확인·이행처분〉**으로 보는 견해가 있다.

2) 판례

- ① 대법원 다수의견은 확인·결정시 수분양권이 발생한다는 입장이므로, 확인결정행위는 **〈형성적 행정처분〉**으로 본다.
- ② 반대의견 및 반대보충의견은 확인결정 이전에 이미 취득하고 있는 것이라는 입장이므로 **〈확인·이행처분〉**으로 본다.

3) 검토

- ① 어느 견해에 따르더라도 이주대상자 확인·결정행위는 행정쟁송법상 처분이므로 **항고소송의 대상**이 된다.
- ② 수분양권은 법상 요건이 충족된 상태에서 **이주대책계획수립시에 발생**하므로, 확인·결정행위는 **확인·이행처분**으로 봄이 타당하다.
- ③ 따라서 이주자의 이주대책대상자 선정신청에 대하여 사업시행자가 거부한 경우에는 이주자는 사업시행자를 상대로 항고소송을 제기할 수 있다.

대법원 1994. 5. 24. 선고 92다35783

[다수의견]

이주자에게 사업시행자가 수립한 이주대책상의 택지분양권이나 아파트 입주권 등을 받을 수 있는 구체적인 권리(수분양권)가 직접 발생하는 것이라고는 도저히 볼 수 없으며, 사업시행자가 이주대책에 관한 구체적인 계획을 수립하여 이를 해당자에게 통지 내지 공고한 후, 이주자가 수분양권을 취득하기를 희망하여 이주대책에 정한 절차에 따라 사업시행자에게 이주대책대상자 선정신청을 하고 사업시행자가 이를 받아들여 이주대책대상자로 확인·결정하여야만 비로소 구체적인 수분양권이 발생하게 된다.

[반대의견]

이주자가 분양신청을 하여 사업시행자로부터 분양처분을 받은 경우 이러한 사업시행자의 분양처분의 성질은 이주자에게 수분양권을 비로소 부여하는 처분이 아니라, 이미 이주자가 취득하고 있는 수분양권에 대하여 그의 의무를 이행한 일련의 이행처분에 불과하고, 이는 이주자가 이미 취득하고 있는 수분양권을 구체화 시켜주는 과정에 불과하다. 이를 실체적 권리로 인정해야 구체적 이주대책 이행을 신청하고 그 이행이 없을 때 부작위위법확인소송을 제기하여 그 권리구제를 받을 수 있고, 그 권리를 포기한 것으로 볼 수 없는 한 언제나 신청이 가능하고 구체적 이주대책이 종료한 경우에도 추가 이주대책을 요구할 수 있게 된다.

[반대의견에 대한 보충의견]

사업시행자가 실제로 이주대책을 수립하기 이전에는 이주자의 수분양권은 아직 추상적인 권리나 법률상의 지위 내지 이익에 불과한 것이어서 이 단계에 있어서는 확인의 이익이 인정되지 아니하여 그 권리나 지위의 확인을 구할 수 없다고 할 것이나, 사업시행자가 이주대책을 수립 실시하지 아니하는 경우에는 사업시행자에게 이를 청구하여 거부되거나 방치되면 부작위위법확인을 소구할 수는 있다고 볼 것이다. 그러나 이주대책을 수립한 이후에는 이주자의 추상적인 수분양권이 그 이주대책이 정하는 바에 따라 구체적 권리로 바뀌게 되므로, 구체적 이주대책에서 제외된 이주자는 위와 같은 수분양권에 터잡은 분양신청(이른바 실체적 신청권의 행사)을 하여 거부당한 경우에는 이를 실체적 신청권을 침해하는 거부처분으로 보아 그 취소를 구하는 항고소송을 제기할 수 있을 것이고, 신청기간을 도과한 경우, 사업시행자가 미리 수분양권을 부정하거나 이주대책에 따른 분양절차가 종료되어 분양신청을 하더라도 거부당할 것이 명백한 경우, 또는 분양신청을 묵살당한 경우, 기타 확인판결을 얻음으로써 분쟁이 해결되고 권리구제가 가능하여 그 확인소송이 권리구제에 유효 적절한 수단이 될 수 있는 특별한 사정이 있는 경우에는, 당사자소송으로 수분양권 또는 그 법률상의 지위의 확인을 구할 수 있다고 보아야 한다.

CASE 1

공공사업으로 인한 소음·진동·먼지 등에 의한 간접 침해의 구제수단을 설명하시오. (20점) [14회, 문3]

CASE 2

丙은 이 사건 공익사업구역 밖에서 음식점을 경영하고 있었는데, 이 사건 공익사업으로 인하여 자신의 음식점의 주 출입로가 단절되어 일정 기간 휴업을 할 수 밖에 없게 되었다. 이때, 丙은 토지보상법령상 보상을 받을 수 있는가? (10점) [29회, 문1]

01 간접손실 및 간접손실보상의 개념

1) 간접손실의 개념 및 구별개념

- ① 공익사업으로 인하여 사업시행지 밖의 재산권자에게 가해지는 손실 중 공익사업으로 인하여 필연적으로 발생하는 손실이 간접손실이다.
- ② 사업시행지 내 토지소유자가 입은 부대적 손실과 구별된다.

2) 간접손실의 유형

- ① 일반적으로 물리적·기술적 손실과 사회적·경제적 손실로 구분한다.
- ② 또한 공익사업의 시행시 발생하는 피해와 사업이 완료된 후 발생하는 피해로 구분할 수 있다.
- ③ 사업시행시 발생하는 피해는 사업 과정 중의 소음·진동·먼지 등으로 인한 피해이고,
- ④ 사업 완료 후 발생하는 손실은 토지와 건물의 경우 지가하락, 지반변동, 주거 및 생활의 불편, 영업 등의 영위 곤란, 전파수신장애, 지하수고갈, 소음·진동 등이 있다.

02 간접손실보상의 필요성

- ① 토지 등이 비록 공익사업에 직접 편입되지 않았으나 그로 인해 손실이 발생하였다면 마땅히 보상되어야 한다.
- ② 공익사업지구 밖에 거주하던 자는 당해 사업이 시행되지 않았더라면 그 지역에서 아무런 변동 없이 생활을 영위할 수 있었다.
- ③ 따라서 공익사업으로 인해 손실이 발생하였음에도 불구하고 보상하지 않게 되면 이들에게 희생만 강요하는 것이 되고, 사업지 내 토지 등의 소유자와 비교하더라도 불공평하게 된다. 따라서 **형평의 관념**에서라도 간접손실보상이 필요하다.

03 간접손실보상의 법적 성격과 논거

1) 간접손실보상의 법적성질

- ① 공익사업으로 인한 발생한 불가피한 손해배상의 성격으로 보는 견해
- ② 간접손실보상도 공익사업을 위한 특별한 희생이라는 점에서 손실보상으로 보는 견해
- ③ 손해배상도 손실보상도 아닌 제3의 유형으로서 일종의 결과책임으로서의 보상이라는 견해
- ④ 손실보상인지 손해배상인지 구별은 의미가 없고, 피해를 어떻게 처리할 것인가가 중요하다고 보는 구별불요설 등이 있다.

2) 간접손실보상의 성격

- ① 간접보상은 공익사업에 의해서 간접적으로 침해가 발생한다는 점에서 직접침해에 의한 보상과는 구별된다.
- ② 또한 손실이 발생한 후에 보상하므로 사후보상의 성격을 갖는다.
- ③ 간접보상은 재산권에 대한 보상과 생활권에 대한 보상의 성격이 모두 있다.

04 간접손실이 헌법 제23조 제3항에 포함되는지 여부

1) 문제점

간접손실이 헌법 제23조 제3항에 포함되는 손실이라면 헌법 제23조 제3항의 정당보상이 주어져야 하므로, 이하 견해대립을 검토한다.

2) 학설

- ① 헌법 제23조 제3항은 공용침해로 인하여 재산권자에게 직접적으로 발생한 손실만을 보상하는 것으로 규정하고 있다고 보는 부정설,
- ② 간접손실도 적법한 공용침해에 의해 필연적으로 발생한 손실이므로 헌법 제23조 제3항의 손실보상에도 포함시키는 것이 타당하다는 긍정설이 있다.

3) 판례

판례는 간접손실을 헌법 제23조 제3항에서 규정한 손실보상의 대상이 된다고 본다.

4) 검토

간접손실도 적법한 공용침해로 인하여 예견되는 통상의 손실이고, 헌법 제23조 제3항을 손실보상에 관한 일반적 규정으로 보는 것이 타당하므로, 간접손실을 헌법 제23조 제3항의 손실에 포함시키는 것이 타당하다.

05 간접손실보상의 법률적 근거

토지보상법 제79조 및 동법 시행규칙 제59조부터 제65조에서 규정한다.

06 간접손실보상의 요건

1) 일반적 요건

(1) 간접손실의 존재

- ① 공공사업의 시행으로 사업시행지 이외의 토지소유자(제3자)가 입은 손실이어야 하고,
- ② 그 손실이 공공사업의 시행으로 인하여 발생하리라는 것이 예견되어야 하고,
- ③ 그 손실의 범위가 구체적으로 특정될 수 있어야 한다.

대법원 2002. 11. 26. 선고 2001다44352

관계 법령이 요구하는 허가나 신고없이 김양식장을 배후지로 하여 김종묘생산어업에 종사하던 자들의 간접손실에 대하여 그 손실의 예견가능성이 없고, 그 손실의 범위도 구체적으로 특정하기 어려워 공공용지의취득및손실보상에 관한특례법시행규칙상의 손실보상에 관한 규정을 유추적용할 수 없다고 한 사례

(2) 특별한 희생의 발생

- ① 사회적 제약을 넘는 특별한 희생이 발생하여야 한다.
- ② 특별한 희생의 발생여부는 형식설과 실질설을 모두 고려하여 판단하여야 한다.

(3) 보상규정의 존재

- ① 간접손실보상을 위해서 원칙적으로 간접손실보상에 관한 법령상 규정이 존재해야 한다.
- ② 토지보상법 제79조 제1항은 간접손실인 공사비용의 보상을 규정하고 있다. 또한 토지보상법 제79조 제2항은 <공익사업이 시행되는 지역 밖에 있는 토지등이 공익사업의 시행으로 인하여 본래의 기능을 다할 수 없게 되는 경우에는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 그 손실을 보상하여야 한다.> 고 규정하고 있다.
- ③ 즉 간접손실보상의 원칙을 규정하고 보상의 기준, 내용, 절차 등을 국토교통부령에 위임하고 있다. 이에 따라 동법 시행규칙은 제59조부터 제65조에서 간접보상을 유형화하여 열거·규정하고 있다.

2) 보상규정 존재와 관련한 요건

(1) 토지보상법 제79조 제4항을 일반근거규정으로 볼 수 있는지

- ① 토지보상법 제79조 제4항은 법에 규정된 사항 외의 간접손실보상에 관하여는 국토교통부령으로 정하는 기준에 따른다고 규정한다.
- ② 이에 대해 동규정을 간접손실보상에 대한 일반근거조항으로 보는 견해와, 법률에 규정되지 못한 사항에 대한 개괄수권조항으로 보는 견해가 대립한다.
- ③ 생각건대, 동규정은 위임규정인 바 일반근거조항으로 보는 것은 조문을 지나치게 확장 해석하는 것이므로 개괄수권조항설이 타당하다. 따라서 사안은 직접적인 보상 규정이 존재하지 않으므로 보상규정 흠결 시 보상청구가능성을 검토한다.

(2) 보상규정 흠결시 보상청구가능성

CASE

X군에 거주하는 어업인들을 조합원으로 하는 A수산업협동조합은 조합원들이 포획*채취한 수산물의 판매를 위탁받아 판매하는 B수산물위탁판매장을 운영하여 왔다. 한편, B위탁판매장 운영에 대해서는 관계 법령에 따라 관할 지역에 대한 독점적 지위가 부여되어 있었으며, A조합은 B위탁판매장 판매액 중 일정비율의 수수료를 지급받아 왔다. 그런데, 한국농어촌공사는「공유수면 관리 및 매립에 관한 법률」에 따라 X군 일대에 대한 공유수면매립면허를 받아 공유수면매립사업을 시행하였고, 해당 매립사업의 시행으로 인하여 사업대상지역에서 어업활동을하던 A조합의 조합원들은 더 이상 조업을 할 수 없게 되었다.

A조합은 위 공유수면매립사업지역 밖에서 운영하던 B위탁판매장에서의 위탁판매사업의 대부분을 중단하였고, 결국에는 B위탁판매장을 폐쇄하기에 이르렀다. 이에 따라 A조합은 공유수면매립사업으로 인한 위탁판매수수료 수입의 감소에 따른 영업손실의 보상을 청구하였으나, 한국농어촌공사는 B위탁판매장이 사업시행지 밖에서 운영되던 시설이었고 「공유수면 관리 및 매립에 관한 법률」상 직접적인 보상 규정이 없음을 이유로 보상의 대상이 아니라고 주장한다. 한국농어촌공사의 주장은 타당한가? [30회, 문3]

가. 학설

- ① 토지보상법 시행규칙 제59조 이하의 간접보상규정을 제한적 열거규정으로 보고, 동 규정에서 규정되지 않은 간접손실은 보상의 대상이 되지 않는다고 보는 <보상부정설>,
- ② 공공사업의 시행결과 발생한 간접손실에 대하여 헌법 제23조 제3항 및 토지보상법상의 간접손실보상에 관한 규정을 유추적용하여 보상을 청구할 수 있다고 보는 <유추적용설>,
- ③ 간접손실도 제23조 제3항의 손실보상의 범위에 포함되므로, 헌법 제23조 제3항에 근거하여 보상청구권이 인정된다고 보는 <헌법 제23조 제3항의 직접적용설>,
- ④ 간접손실도 헌법상 평등원칙 및 재산권 보장규정에 근거하여 보상해 주어야 한다고 보는 <평등원칙 및 재산권보장규정근거설>,
- ⑤ 간접손실에 대하여 명문의 보상규정이 없는 경우에는 손해배상을 청구하여야 한다는 <손해배상설> 등의 견해가 대립한다.

나. 판례의 입장

판례는 (구)토지수용법하에서 간접손실을 헌법 제23조 제3항에 규정한 손실보상의 대상이 된다고 보고, 공공용지의 취득 및 보상에 관한 특례법 시행규칙상의 각 간접손실보상규정을 유추적용하여 그에 관한 보상을 인정하는 것이 타당하다고 보았다.

대법원 1999. 10. 8. 선고 99다27231

간접손실에 대하여도 일정한 조건하에서 이를 보상하도록 규정하고 있는 점에 비추어, 공공사업의 시행으로 인하여 그러한 손실이 발생하리라는 것을 쉽게 예견할 수 있고 그 손실의 범위도 구체적으로 이를 특정할 수 있는 경우라면 그 손실의 보상에 관하여 공공용지의취득및손실보상에관한특례법시행규칙의 관련 규정 등을 유추적용할 수 있다고 해석함이 상당하다.

다. 검토

특별한 희생에 대하여 손실보상을 하는 것은 당연한 바, 간접손실보상도 헌법 제23조 제3항의 손실보상에 포함된다고 보아 헌법 제23조 제3항의 **직접효력**을 인정하여 직접 헌법 제23조 제3항에 근거하여 손실보상을 청구할 수 있다고 보는 것이 타당하다.

07 토지보상법상 간접손실의 보상내용

1) 공익사업시행지구 밖의 대지 등에 대한 보상 (칙 제59조)

공익사업시행지구 밖의 대지·건축물·분묘 또는 농지가 공익사업의 시행으로 인하여 산지나 하천 등에 둘러싸여 교통이 두절되거나 경작이 불가능하게 된 경우에는 그 소유자의 청구에 의하여 이를 공익사업시행지구에 편입되는 것으로 보아 보상하여야 한다.

2) 공익사업시행지구 밖의 건축물에 대한 보상 (칙 제60조)

소유농지의 대부분이 공익사업시행지구에 편입됨으로써 건축물만이 공익사업시행지구밖에 남게 되는 경우로서 그 건축물의 매매가 불가능하고 이주가 부득이한 경우에는 그 소유자의 청구에 의하여 이를 공익사업시행지구에 편입되는 것으로 보아 보상하여야 한다.

3) 소수잔존자에 대한 보상 (칙 제61조)

공익사업의 시행으로 인하여 1개 마을의 주거용 건축물이 대부분 공익사업시행지구에 편입됨으로써 잔여 주거용 건축물 거주자의 생활환경이 현저히 불편하게 되어 이주가 부득이한 경우에는 당해 건축물 소유자의 청구에 의하여 그 소유자의 토지 등을 공익사업시행지구에 편입되는 것으로 보아 보상하여야 한다.

4) 공익사업시행지구 밖의 공작물 등에 대한 보상 (칙 제62조)

공익사업시행지구밖에 있는 공작물 등이 공익사업의 시행으로 인하여 그 본래의 기능을 다할 수 없게 되는 경우에는 그 소유자의 청구에 의하여 이를 공익사업시행지구에 편입되는 것으로 보아 보상하여야 한다.

5) 공익사업시행지구 밖의 어업피해에 대한 보상 (칙 제63조)

공익사업의 시행으로 인하여 해당 공익사업시행지구 인근에 있는 어업에 피해가 발생한 경우 사업시행자는 실제 피해액을 확인할 수 있는 때에 그 피해에 대하여 보상하여야 한다.

6) 공익사업시행지구 밖의 영업손실보상 (칙 제64조)

(1) 요건

공익사업시행지구 밖에서 영업손실의 보상대상이 되는 영업을 하고 있는 자가 공익사업의 시행으로 인하여 ① **배후지의 3분의 2 이상이 상실**되어 그 장소에서 영업을 계속할 수 없는 경우 또는 ② **진출입로의 단절**, **그 밖의 부득이한 사유**로 인하여 일정한 기간 동안 휴업하는 것이 불가피한 경우의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 영업자의 청구에 의하여 당해 영업을 공익사업시행지구에 편입되는 것으로 보아 보상하여야 한다.

(2) 제1호의 의미

- ① <배후지의 3분의2 이상이 상실되어 그 장소에서 영업을 계속할 수 없는 경우>에 대하여 <영업을 할 수 없는 사정>에 대한 예시규정으로 보아야 하는지 문제된다.
- ② 간접손실보상은 공공필요를 위한 희생이라는 점에 보상원인이 있기 때문에 당해 공익사업으로 인해 현실적으로 영업을 할 수 없는 그 밖의 사정을 포함하는 예시규정으로 보아야 할 것이다.
- ③ 즉 배후지가 3분의2 이상 상실되었더라도 나머지 배후지만으로 여전히 손익분기점을 상회하여 당해 영업을 계속할 수 있다면 이 요건에 해당하지 않는 것으로 보아야 하고, 반대로 3분의2 미만이 상실되었더라도 손익분기점을 하회하여 더 이상 영업을 할 수 없는 상황이라면 영업손실보상청구가 가능하다고 할 것이다.
- ④ 공익사업 시행으로 진출입로가 단절되더라도 이에 대체하는 시설을 설치함으로써 계속하여 영업을 행할 수 있는 경우에는 보상대상에서 제외된다.

(3) 제2호의 의미

<그 밖의 부득이한 사유>라는 것은 공익사업의 시행 또는 시행 당시 발생한 사유로 휴업이 불가피한 경우만을 의미하는 것이 아니라 공익사업의 시행 결과, 즉 그 공익사업의 시행으로 설치되는 시설의 형태·구조·사용 등에 기인하여 휴업이 불가피한 경우도 포함된다고 해석함이 타당하다.(판례)

(4) 영업손실 보상금의 환수

사업시행자는 영업자가 보상을 받은 이후에 그 영업장소에서 영업이익을 보상받은 기간 이내에 동일한 영업을 하는 경우에는 실제 휴업기간에 대한 보상금을 제외한 영업손실에 대한 보상금을 환수하여야 한다.

7) 공익사업시행지구 밖의 농업손실보상 (칙 제65조)

경작하고 있는 농지의 3분의 2 이상에 해당하는 면적이 공익사업시행지구에 편입됨으로 인하여 당해 지역에서 영농을 계속할 수 없게 된 농민에 대하여는 공익사업시행지구 밖에서 그가 경작하고 있는 농지에 대하여도 영농손실액을 보상하여야 한다.

08 간접손실보상의 한계

- ① 현재 대규모 공익사업의 주변 지역에서는 피해의 양상이 다양하게 나타나고 있다.
- ② 따라서 사업계획단계에서 간접손실의 발생을 미연에 방지하기 위한 조치의 강구가 요구된다. 수인 범위를 넘는 손실의 발생이 예측되는 경우 계획 및 공법 변경의 검토나 손실 발생이 명백한 경우 사전 보상조치의 강구가 필요하다.

09 공사비보상

1) 공사비보상의 대상과 범위

- ① 사업시행자는 공익사업의 시행으로 인하여 취득하거나 사용하는 토지(잔여지를 포함한다) 외의 토지에
통로·도랑·담장 등의 신설이나 그 밖의 공사가 필요할 때에는 그 비용의 전부 또는 일부를 보상하여야 한다.
- ② 다만, 그 토지에 대한 공사의 비용이 그 토지의 가격보다 큰 경우에는 사업시행자는 그 토지를 매수할 수 있다
(제79조 제1항).

2) 비용보상의 청구기한

사업이 완료된 날 또는 제24조의2에 따른 사업완료의 고시가 있는 날부터 1년 내 청구해야 한다.

3) 손실보상의 협의와 재결 (토지보상법 제80조)

제79조 제1항 및 제2항에 따른 비용 또는 손실이나 토지의 취득에 대한 보상은 사업시행자와 손실을 입은 자가
협의하여 결정한다. 협의 불성립시 사업시행자나 손실을 입은 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 관할 토지수용
위원회에 재결을 신청할 수 있다.

CASE

X는 도시 및 주거환경정비법(이하 '도시정비법'이라 함)에 따른 재개발정비사업조합이고, 甲은 X의 조합원으로서, 해당 정비사업구역 내에 있는 A토지와 B토지의 소유자이다. A토지와 B토지는 연접하고 있고 그 지목이 모두 대(垔)에 해당하지만, A토지는 사도법에 따른 사도가 아닌데도 불특정 다수인의 통행에 장기간 제공되어 왔고, B토지는 甲이 소유한 건축물의 부지로서 그 건축물의 일부에 임차인 乙이 거주하고 있다. X는 도시정비법 제72조 제1항에 따라 분양신청기간을 공고하였으나 甲은 그 기간내에 분양신청을 하지 않았다. 이에 따라 X는 甲을 분양대상자에서 제외하고 관리처분계획을 수립하여 인가를 받았고, 그에 불복하는 행정심판이나 행정소송은 없었다. X는 도시정비법 제73조 제1항에 따른 甲과의 보상협정이 이루어지지 않자 A토지와 B토지에 관하여 관할 토지수용위원회에 수용재결을 신청하였고, 관할 토지수용위원회는 A토지와 B토지를 수용한다는 내용의 수용재결을 하였다. 다음 물음에 답하십시오. (40점)

물음 3) 주거이전비에 관하여 甲은 토지보상법 시행규칙 제54조 제1항에 따른 요건을 갖추고 있고, 乙은 같은 조 제2항에 따른 요건을 갖추고 있다. 관할토지수용위원회는 수용재결을 하면서 甲의 주거이전비에 관하여는 재결을 하였으나 乙의 주거이전비에 관하여는 재결을 하지 않았다. 甲은 주거이전비의 증액을 청구하고자 하고, 乙은 주거이전비의 지급을 청구하고자 한다. 甲과 乙의 권리구제에 적합한 소송을 설명하십시오. [33회, 문1]

01 의의 및 취지

- ① 주거이전비는 공익사업지구에 편입되는 주거용 건축물에 실제 거주하고 있는 소유자 및 세입자에 대하여 가구원수에 따라 지급하는 보상이다.
- ② 주거이전에 필요한 비용과 가재도구 등 동산의 운반에 필요한 비용의 보상으로 실비변상적 보상의 성격을 가진다.
- ③ 판례는 공익사업지구 안에 거주하는 세입자들의 조기이주를 장려하여 사업추진을 원활하게 하려는 **정책적인 목적**과 주거이전으로 인해 특별한 어려움을 겪게 될 세입자들을 대상으로 하는 사회보장적인 차원의 **생활보상의 성격**도 가진다고 본다.

02 소유자에 대한 보상

1) 보상평가기준

- ① 공익사업시행지구에 편입되는 주거용 건축물의 소유자에 대하여는 당해 건축물에 대한 보상을 하는 때에 가구원수에 따라 **2개월분의 주거이전비**를 보상하여야 한다.
- ② 다만, 건축물의 소유자가 해당 건축물 또는 공익사업시행지구 내 타인의 건축물에 실제 거주하고 있지 아니하거나 해당 건축물이 무허가건축물등인 경우에는 그러하지 아니하다(칙 제54조 제1항).

2) 요건의 의미

(1) 주거용 건축물, 무허가건축물

- ① <주거용 건축물>에서 <주거용>의 실제 의미는 실제 그 건축물의 공부상 용도와 관계없이 실제 주거용으로 사용되는지 여부에 따라 결정해야 한다.
- ② 불법으로 주거용으로 용도변경한 건축물 소유자는 보상대상자에서 제외된다.
- ③ 89. 1. 24 당시 무허가건축물 등에 대하여는 이를 적법한 건물로 봄으로(칙 부칙 제5조), 주거이전비 보상 대상에 해당한다.

(2) 보상의 시기

보상시기는 주거용 건축물에 대한 보상을 하는 때이다.

(3) 실제 거주요건

사업인정고시 당시 또는 공익사업을 위한 관계 법령에 의한 고시 당시 실제 거주하고 있었더라도 **주거용 건축물에 대한 보상을 하는 때**, 즉 이전 당시 실제 거주하고 있지 않았다면 주거이전비의 보상대상이 아니다.

03 세입자에 대한 보상

1) 보상기준

- ① 공익사업의 시행으로 인하여 이주하게 되는 주거용 건축물의 세입자로서 사업인정고시일등 당시 또는 공익사업을 위한 관계법령에 의한 고시 등이 있는 당시 당해 공익사업시행지구 안에서 **3개월 이상 거주한 자**에 대하여는 가구원수에 따라 **4개월분의 주거이전비**를 보상하여야 한다.
- ② 다만, **무허가건축물등에 입주한 세입자**로서 사업인정고시일등 당시 또는 공익사업을 위한 관계법령에 의한 고시 등이 있는 당시 그 공익사업지구 안에서 **1년 이상 거주한 세입자**에 대하여는 본문에 따라 주거이전비를 보상하여야 한다(칙 제54조 제2항).

2) 요건의 의미

(1) 사업인정고시일등 당시 관계법령에 의한 고시 등이 있는 당시

토지수용절차에 토지보상법을 준용하는 관계 법령 중에 주민공람공고 등 없이 바로 사업인정고시를 하는 법률이 있는 반면, 사업인정고시 이전에 주민 등에 대한 공람공고를 예정한 법률도 있기 때문에 그러한 경우를 모두 포섭하기 위한 것으로 보인다.

(2) 계속 거주요건 : 불필요

- ① 세입자에 대하여 주거이전비 산정통보일이나 수용재결일까지 계속 거주해야 한다는 주장이 있다.
- ② 그러나 '사업인정고시일 등 당시 또는 공익사업을 위한 관계 법령에 의한 고시 등이 있는 당시 당해 공익사업시행지구 안에서 3월 이상 거주한 자'에 해당하는 세입자는 이후의 사업시행자의 주거이전비 산정통보일 또는 수용개시일까지 **계속 거주할 것을 요함이 없이** 위 사업인정고시일 등에 바로 규칙 제54조 제2항의 주거이전비와 규칙 제55조 제2항의 이사비 청구권을 취득하므로(대법원 2006. 4. 27. 선고 2006두2435 판결), 위 주장은 타당하지 않다.

(3) 무허가건축물 등이 아닐 것

- ① 89.1.25 이후 건축된 무허가건축물 등에 입주한 세입자가 아니어야 한다. 그러나 무허가건축물 등이라 하더라도 사업인정고시일등 당시 관계법령에 의한 고시등이 있는 당시 그 공익사업지구 안에서 1년 이상 거주한 세입자에 대하여는 주거이전비를 보상하여야 한다(칙 제54조 제2항 단서).
- ② 물론 이 경우에는 계속 거주요건은 필요 없고, 지급기준일에 바로 주거이전비청구권을 취득한다고 볼 것이다.

04 주거이전비에 대한 쟁송

1) 주거이전비 보상청구권의 법적성질

주거이전비는 세입자들의 조기이주를 장려하여 사업추진을 원활하게 하려는 정책적 목적과 주거이전으로 인하여 특별한 어려움을 겪게 될 세입자들을 대상으로 하는 사회보장적 차원에서 지급되는 금원의 성격을 가지므로, 주거이전비 보상청구권은 **공법상 권리**이다(대판 2008. 5. 29. 2007다8129).

2) 불복방법

(1) 판례의 태도

- ① 주거이전비 보상청구권은 그 요건을 충족하는 경우에 (수용재결 없이도) 당연히 발생하는 것이므로, 주거이전비 보상청구소송은 행정소송법 제3조 제2호에 규정된 **당사자소송**에 의하여야 할 것이다.
(대법원 2007다8129 판결)
- ② 다만, 세입자의 주거이전비 보상에 관하여 재결이 이루어진 다음 세입자가 보상금의 증감 부분을 다투는 경우에는 공익사업법 제85조 제2항에 규정된 행정소송에 따라, 보상금의 증감 이외의 부분을 다투는 경우에는 같은 조 제1항에 규정된 행정소송에 따라 권리구제를 받을 수 있다고 봄이 상당하다.
(대법원 2007다8129 판결)
- ③ 이러한 법리는 주거용 건축물의 소유자가 사업시행자를 상대로 이주정착금, 주거이전비 및 이사비의 보상을 구하는 경우에도 그대로 적용된다(대법원 2018두55326).

(2) 주거이전비에 대한 수용재결을 거치지 않은 경우

주거이전비 보상청구권이 공법상 권리이므로, 주거이전비 보상을 둘러싼 쟁송은 민사소송이 아니라 <당사자소송>에 의하여야 한다.

(3) 주거이전비에 대한 수용재결을 거친 경우

주거이전비는 토지수용위원회의 재결사항에 해당하므로, 만약, 주거이전비에 대해 수용재결절차를 거쳤다면, 토지보상법 제83조의 이의신청 및 제85조 제2항 보상금증감청구소송이 가능하다.

3) 세대주가 아닌 가구원이 직접 주거이전비를 청구할 수 있는지 여부

대법원은 시행규칙의 내용, 형식, 구체적 산정방식 등에 비추어 소유자와 세입자가 지급청구권을 가지는 것으로 보아야 하고 가구원은 사업시행자를 상대로 직접 주거이전비의 지급을 구할 수 **없다**고 하였다.

05 주거이전비와 부동산 인도의무

1) 문제점

피수용자는 주거이전비, 이사비, 이주정착금을 지급받지 않음을 이유로 부동산 인도의무 이행을 거절할 수 있는지, 그리고 사업시행자는 주거이전비 등을 지급하기 위해 어떤 절차를 거쳐야 하는지 문제된다.

2) 판례

- ① 만일 사업시행자와 현금청산대상자나 세입자 사이에 주거이전비 등에 관한 **협약이 성립된다면** 사업시행자의 주거이전비 등 지급의무와 현금청산대상자나 세입자의 부동산 인도의무는 **동시이행의 관계**에 있게 되고, **재결절차 등에 의할 때에는 주거이전비 등의 지급절차가 부동산 인도에 선행**되어야 할 것이다.
- ② 사업시행자는 **협약이나 재결절차를 거칠 필요 없이** 현금청산대상자나 세입자에게 주거이전비 등을 **직접 지급**하거나 현금청산대상자나 세입자가 지급을 받지 않거나 받을 수 없을 때에는 민법 제487조에 따라 **변제공탁**을 할 수도 있다고 판시한 바 있다(대법원 2021. 8. 26. 선고 2019다235153 판결, 2022. 6. 30. 선고 2021다310088 판결 등 참조).

CASE

공공사업시행시 잔여지 및 잔여건물 보상에 관하여 설명하시오. [13회, 문4]

01 잔여 건축물의 손실에 대한 보상

1) 의의 (토지보상법 제75조의2)

- ① 사업시행자는 동일한 소유자에게 속하는 일단의 건축물의 일부가 취득되거나 사용됨으로 인하여 잔여 건축물의 **가격이 감소하거나 그 밖의 손실**이 있을 때에는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 그 손실을 보상하여야 한다.
- ② 다만, 잔여 건축물의 가격 감소분과 보수비(건축물의 나머지 부분을 종래의 목적대로 사용할 수 있도록 그 유용성을 동일하게 유지하는 데에 일반적으로 필요하다고 볼 수 있는 공사에 사용되는 비용을 말한다. 다만, 「건축법」 등 관계 법령에 따라 요구되는 시설 개선에 필요한 비용은 포함하지 아니한다)를 합한 금액이 잔여 건축물의 가격보다 큰 경우에는 사업시행자는 그 잔여 건축물을 **매수**할 수 있다.

2) 보상청구 기간

잔여 건축물의 손실에 대해서는 사업이 완료된 날 또는 제24조의2에 따른 사업완료의 고시가 있는 날(이하 “사업완료일”이라 한다)부터 **1년**이 지난 후에는 청구할 수 없다(제75조의2 제4항에서 제73조 제2항을 준용).

3) 잔여 건축물 매수의 효과

사업인정고시가 된 후 사업시행자가 잔여 건축물을 매수하는 경우 그 잔여 건축물에 대해서는 사업인정 및 사업인정고시가 된 것으로 본다(제75조의2 제4항에서 제73조 제3항을 준용).

4) 보상방법 등

손실보상은 사업시행자와 손실을 입은 자가 협의하여 결정하며, 협의가 성립되지 아니하면 사업시행자나 손실을 입은 자는 관할 토지수용위원회에 재결을 신청할 수 있다.

5) 보상평가기준

동일한 건축물소유자에 속하는 일단의 건축물의 일부가 취득 또는 사용됨으로 인하여 잔여 건축물의 가격이 감소된 경우의 잔여 건축물의 손실은 공익사업시행지구에 편입되기 전의 잔여 건축물의 가격(해당 건축물이 공익사업시행 지구에 편입됨으로 인하여 잔여 건축물의 가격이 변동된 경우에는 변동되기 전의 가격을 말한다)에서 공익사업시행 지구에 편입된 후의 잔여 건축물의 가격을 뺀 금액으로 평가한다(칙 제35조 제1항).

02 잔여건축물의 보수가 필요한 경우의 보수비

동일한 건축물소유자에 속하는 일단의 건축물의 일부가 취득 또는 사용됨으로 인하여 잔여 건축물에 보수가 필요한 경우의 **보수비**는 건축물의 잔여부분을 종래의 목적대로 사용할 수 있도록 그 **유용성을 동일하게 유지하는데 통상 필요하다고 볼 수 있는 공사에 사용되는 비용**(「건축법」 등 관계법령에 의하여 요구되는 시설의 개선에 필요한 비용은 포함하지 아니한다)으로 평가한다(칙 제35조 제2항).

01 개설

- ① 개간비 보상은 토지 등이 개간됨으로써 경제적 가치가 증가하게 되고, 개간된 토지가 공익사업에 편입되어 보상 받는 경우 국가나 지방자치단체는 자기의 노력과 상관없이 개간비 상당액의 부당이득을 갖게 되는 결과가 되어 바람직하지 않으므로 그 이익을 당초 개간한 자에게 되돌려 주도록 하는 제도이다.
- ② 개간비보상은 잔여지 공사비보상 등과 함께 <실비변상적 성격>을 갖는다.

02 개간비 보상

1) 보상대상이 되는 개간의 요건(칙 제27조)

(1) 국유지 또는 공유지의 개간

- ① 당해 토지가 국유지 또는 공유지이어야 한다.
- ② 따라서 개간지라 하더라도 공공단체나 사인이 소유한 토지에 대하여는 개간비 보상을 하지 아니한다.

(2) 적법한 개간

- ① 1995년 1월 7일 (구)공특법시행규칙 개정일부터는 불법개간에 대하여는 그 개간비를 보상하지 않으며, 관계 법령에 의하여 적법하게 개간한 경우에만 보상한다.
- ② 다만, 1995년 1월 7일 당시 공익사업시행지구 편입된 무허가개간토지에 대하여는 예외적으로 개간비를 보상하도록 하고 있다(칙 부칙 제6조).

(3) 계속 점유

- ① 개간한 자가 개간당시부터 보상당시까지 계속하여 적법하게 당해 토지를 점유하고 있어야 한다.
- ② 개간한 자가 사망한 경우에는 그 상속인이 개간한 자가 사망한 때부터 계속하여 적법하게 당해 토지를 점유하고 있는 경우를 포함한다.
- ③ 따라서 보상 당시 사실상 점유하고 있지 아니한 때에는 원칙적으로 보상대상이 되지 않는다.

2) 개간비 평가 기준

- ① 개간비는 지장물과는 별도로 개간에 소요된 비용으로 평가한다.
- ② 그러나 보상액은 개간 후의 토지가격에서 개간 전의 토지가격을 뺀 금액을 초과하지 못한다(칙 제27조 제1항).
- ③ 개간비를 평가함에 있어서는 개간 전과 개간 후의 토지의 지세·지질·비옥도·이용상황 및 개간의 난이도 등을 종합적으로 고려하여야 한다(칙 제27조 제2항).

03 개간지에 대한 보상

- ① 개간비를 보상하는 경우 취득하는 토지의 보상액은 개간 후의 토지가격에서 개간비를 뺀 금액으로 한다(칙 제27조 제3항).
- ② 이는 이중보상을 방지하기 위한 규정이다.

01 소유권 외의 권리의 내용

- ① 소유권 외의 권리란 사용·수익권인 용익물권, 즉 지상권·지역권·전세권과 채권인 사용대차 또는 임대차에 관한 권리, 그리고 담보물권인 저당권 그 밖에 소유권 외의 권리를 말한다.
- ② 여기서 <권리>는 지하 및 공중공간에 설정되는 구분지상권 등 소유권을 제외한 모든 경제적 가치가 있는 권리를 포함한다.

02 소유권 외 권리의 평가

- ① 취득하는 토지에 설정된 소유권 외의 권리에 대하여는 당해 권리의 종류, 존속기간 및 기대이익 등을 종합적으로 고려하여 평가한다(칙 제28조 제1항).
- ② 토지에 관한 소유권 외의 권리에 대하여는 **거래사례비교법에 의하여 평가함을 원칙**으로 하되, 일반적으로 양도성이 없는 경우에는 당해 권리의 유무에 따른 토지의 가격차액 또는 권리설정계약을 기준으로 평가한다(동조 제2항).

03 소유권 외의 권리의 목적이 되고 있는 토지의 평가

1) 소유권 외의 권리가 설정된 토지

- ① 소유권 외의 권리가 설정된 토지란 용익물권, 즉 지상권·지역권·전세권과 채권인 임차권 그리고 담보물권인 저당권 등의 권리가 설정된 토지를 말한다.
- ② 이때 소유권 이외의 권리에는 사용대차의 경우를 포함하되, 점유는 이 경우의 권리로 보지 아니한다.

2) 소유권 이외의 권리가 설정된 토지의 평가

토지의 평가금액에서 토지에 관한 소유권 외의 권리의 가액을 뺀 금액으로 평가한다(칙 제29조).

01 일반 토지의 사용료 평가**1) 의의**

- ① 공익사업시행을 원인으로 타인의 토지를 사용하게 되는 경우 당해 토지의 소유권을 완전히 취득하는 정도에는 이르지 않으나, 결국 소유권의 행사에 제한을 주게 되므로 이에 대한 보상으로 사용료를 지급하여야 한다.
- ② 이 경우 토지사용료의 보상범위는 지표상의 토지사용만이 대상이 되는 것이 아니라, 토지의 입체적 소유권 개념에 기초하여 토지의 지상 및 지하부분의 사용을 포함하게 된다.

2) 보상기준

- ① 협의 또는 재결에 의하여 사용하는 토지에 대하여는 그 토지와 인근 유사토지의 지료·임대료·사용방법·사용기간 및 그 토지의 가격 등을 고려하여 평가한 적정가격으로 보상하여야 한다(제71조 제1항).
- ② 사용하는 토지와 그 지하 및 지상의 공간 사용에 대한 구체적인 보상액 산정 및 평가방법은 투자비용, 예상수익 및 거래가격 등을 고려하여 국토교통부령으로 정한다(제71조 제2항).
- ③ 토지의 사용료는 임대사례비교법으로 평가한다. 다만 적정한 임대사례가 없거나 대상 토지의 특성으로 보아 〈임대사례비교법〉으로 평가하는 것이 적정하지 아니한 경우에는 적산법으로 평가할 수 있다(칙 제30조).

CASE

실농보상을 약술하시오. [1회, 문4]

01 의의 및 취지

농업손실이란 공익사업 시행으로 인하여 당해 토지가 공익사업시행지구내 편입되어 영농을 계속할 수 없게 됨에 따라 발생하는 손실로서, 농업손실보상이란 농민에게 영농손실액을 보상하는 것을 말한다.

02 농업손실보상의 성격

1) 일실손실보상

전업에 소요되는 기간을 고려한 합리적인 장래 기대이익의 상실에 대한 보상으로 <일실손실보상>의 성격을 갖는다.

2) 간접보상이자 생활보상

판례는 영농손실보상은 편입토지 및 지장물에 관한 손실보상과는 별개로 이루어지는 보상으로 원칙적으로 농민이 기존 농업을 폐지한 후 새로운 직업활동을 개시하기까지의 준비기간동안의 농민의 생계를 지원하는 <간접보상>이자 <생활보상>의 성격을 가진다고 판시한 바 있다.(2022두34913)

03 보상대상

1) 물적 대상

(1) 보상대상 농지

- ① 지목에도 불구하고 「농지법」 제2조 제1호 가목 및 같은 법 시행령 제2조 제3항 제2호 가목에 해당하는 토지를 말한다(토지보상법 시행규칙 제48조 제1항).
- ② <농지>란 전·답, 과수원, 그 밖에 **법적 지목을 불문하고 실제로 농작물 경작지 또는 다년생식물 재배지로 이용되는 토지**(「초지법」에 따라 조성된 초지 등 대통령령으로 정하는 토지는 제외한다)를 말한다.

(2) 보상대상이 아닌 농지

다음 어느 하나에 해당하는 토지는 보상대상인 농지로 보지 아니한다.

- ① **사업인정고시일등 이후부터** 농지로 이용되고 있는 토지,
- ② 토지이용계획·주위환경 등으로 보아 **일시적**으로 농지로 이용되고 있는 토지,
- ③ 타인소유의 토지를 **불법으로 점유**하여 경작하고 있는 토지,
- ④ **농민이 아닌 자**가 경작하고 있는 토지,
- ⑤ 토지의 취득에 대한 보상 이후에 사업시행자가 **2년 이상 계속하여 경작하도록 허용**하는 토지(칙 제48조 제3항).

2) 인적 대상

- ① **자경농지**의 경우 **농지 소유자**에게 지급한다.

- ② 자경농지가 아닌 농지에 대하여는 농지소유자가 해당 지역에 거주하는 농민인 경우 농지소유자와 실제 경작자의 협의 내용에 따라 보상하는 것이 원칙이나, 협의 불성립시 도별 연간 농가평균 단위경작면적당 농작물총수입으로 영농손실액이 결정된 경우는 각각 영농손실액의 50%에 해당하는 금액을 보상하고, 실제소득을 입증하여 실제소득의 2년분의 영농손실액으로 결정된 경우 농지 소유자에게는 도별 연간 농가평균 단위경작면적당 농작물 총수입의 50%의 금액을 보상하고, 실제 경작자에게는 실제소득의 2년분의 영농손실액 중 농지 소유자에게 지급한 금액을 제외한 나머지에 해당하는 금액을 보상한다.
- ③ 농지 소유자가 해당 지역에 거주하는 농민이 아닌 경우는 **실제 경작자에게** 보상한다(토지보상법 시행규칙 제48조 제4항).

3) 관련 판례

사업시행자가 보상금 지급이나 토지소유자 등의 승낙 없이 공사에 착수하여 영농을 계속할 수 없게 한 경우 농업 손실보상과 **별도로 손해배상책임**이 있다(대판 2013. 11. 14. 2011다27103).

04 보상평가기준

1) 원칙적인 산정방법

공익사업시행지구 편입되는 농지면적에 도별 연간 농가평균 단위경작면적당 농작물총수입의 직전 3년간 평균의 2년분을 곱하여 산정한 금액을 영농손실액으로 보상한다(칙 제48조 제1항).

2) 예외적 산정방법

농작물실제소득인정기준에서 정하는 바에 따라 실제소득을 입증하는 자가 경작하는 편입농지에 대하여는 그 면적에 단위경작면적당 실제소득의 2년분을 곱하여 산정한 금액을 영농손실액으로 보상한다.

05 농기구의 매각손실에 대한 보상

- ① 당해 지역에서 경작하고 있는 농지의 **3분의 2 이상**에 해당하는 면적이 공익사업시행지구 편입됨으로 인하여 농기구를 이용하여 해당 지역에서 영농을 계속할 수 없게 된 경우 해당 농기구에 대해서는 매각손실액을 평가하여 보상하여야 한다.
- ② 다만, 매각손실액의 평가가 현실적으로 곤란한 경우에는 원가법에 의하여 산정한 가격의 60퍼센트 이내에서 매각손실액을 정할 수 있다(칙 제6항).
- ③ 농업폐지의 경우뿐만 아니라 종전의 농업경영형태를 계속하기 어려운 경우도 포함된다. 따라서 소유 농지의 3분의 2 이상이 공익사업시행지구 편입되더라도 농업을 계속할 수 있는 경우에는 농기구의 매각손실액은 별도로 보상하지 않는다.

06 공익사업시행지구 밖의 농업손실에 대한 보상

경작하고 있는 농지의 3분의 2 이상에 해당하는 면적이 공익사업시행지구 편입됨으로 인하여 당해 지역에서 영농을 계속할 수 없게 된 농민에 대하여는 공익사업시행지구 밖에서 그가 경작하고 있는 농지에 대하여도 영농손실액을 보상하여야 한다(칙 제65조).

PART 03

기타 개별법

Chapter 01 부동산 가격공시에 관한 법률

Chapter 02 감정평가법

Chapter 03 도정법

제1절 표준지공시지가

01 의의 및 취지

- ① 표준지공시지가란 국토교통부장관이 토지이용상황, 주변환경, 그 밖의 자연적·사회적 조건이 유사하다고 인정되는 일단의 토지 중에서 선정한 표준지의 매년 공시기준일 현재의 단위면적당 적정가격을 말한다 (부동산 공시법 제3조 제1항)
- ② 이는 적정가격을 공시하여 적절한 가격형성과 각종 조세·부담금 등의 형평성을 도모하는 데 취지가 있다.

02 법적성질

1) 문제점

표준지공시지가가 항고소송의 대상이 되는 행정소송법상의 처분인지가 문제된다.

2) 학설

(1) 행정행위설

부동산공시법이 표준지공시지가에 대하여 이의신청을 할 수 있다고 규정하고 있으며, 표준지공시지가는 개발부담금 등의 산정기준이 되므로 국민의 구체적인 권리·의무에 직접 영향을 미친다고 본다.

[행정기본법] 제36조 (처분에 대한 이의신청)

- ① 행정청의 처분(「행정심판법」 제3조에 따라 같은 법에 따른 행정심판의 대상이 되는 처분을 말한다. 이하 이 조에서 같다)에 이의가 있는 당사자는 처분을 받은 날부터 30일 이내에 해당 행정청에 이의신청을 할 수 있다.

(2) 행정규칙설

표준지공시지가는 지가 정책집행을 위해 일반적·추상적 기준을 설정하는 것으로 보는 견해이다.

(3) 행정계획설

표준지공시지가는 행정목적 실현 수단으로서 목적에 따라 가감적용이 가능하며, 당사자의 권리의무에 영향을 미치지 않는다고 본다.

(4) 법규명령의 성질을 갖는 고시설

표준지공시지가는 개별공시지가 등 행정처분의 구속력 있는 기준이 되므로 구속력은 있으나 형식은 고시로 본다.

3) 판례

판례는 표준지 공시지가결정의 처분성을 인정하는 이유에 대하여는 언급하지 않고, 공시지가에 불복하기 위해서는 공시지가 결정의 취소를 구하는 행정소송을 제기하여야 한다고 하여 **처분임을 긍정**하고 있다.(대판 96누6851)

4) 검토

표준지공시지가를 전제로 국민의 권리·의무에 영향을 미치는 **후속 처분이 예정**되어 있으므로, 이를 조기에 다투어 법률관계를 확정하고 법적 안정성을 도모할 필요가 있다. 따라서 표준지공시지가의 처분성을 인정하는 **행정행위설이 타당**하다.

03 공시절차

1) 공시절차

- ① 표준지 선정
- ② 표준지가격의 조사·평가 및 의견청취
(조사·평가의 의뢰 → 조사·평가 → 의견청취 → 조사·평가보고서의 제출 → 적정성 검토)
- ③ 중앙부동산가격공시위원회의 심의
- ④ 지가의 공시 및 열람

2) 표준지의 선정

- ① 국토교통부장관은 부동산공시법 제3조 제1항의 규정에 의하여 표준지를 선정할 때에는 토지이용상황이나 주변환경 그 밖의 자연적·사회적 조건이 일반적으로 유사하다고 인정되는 일단의 토지 중에서 당해 토지를 대표할 수 있는 필지의 토지를 선정하여야 한다.(시행령 제2조 제1항)
- ② 표준지의 선정은 표준지의 선정 및 관리지침에 따라야 한다.(시행령 제2조 제2항)

3) 표준지공시지가의 조사·평가

(1) 조사·평가의 의뢰

- ① 국토교통부장관은 표준지공시지가를 조사·평가하고자 할 때에는 업무실적, 신인도 등을 고려하여 둘 이상의 감정평가법인등에게 이를 의뢰하여야 한다.
- ② 다만, 지가변동이 작은 경우 등 대통령령으로 정하는 기준에 해당하는 표준지에 대해서는 하나의 감정평가법인등에 의뢰할 수 있다.(제3조 제5항)

[부동산공시법 시행령] 제7조 제4항

1. 최근 1년간 읍·면·동별 지가변동률이 전국 평균 지가변동률 이하인 지역
2. 개발사업이 시행되거나 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조 제15호에 따른 용도지역(이하 “용도지역”이라 한다) 또는 같은 조 제16호에 따른 용도지구(이하 “용도지구”라 한다)가 변경되는 등의 사유가 없는 지역

(2) 조사·평가

국토교통부장관이 표준지공시지가를 조사·평가하는 경우에는 인근 유사토지의 거래가격·임대료 및 해당 토지와 유사한 이용가치를 지닌다고 인정되는 토지의 조성에 필요한 비용추정액, 인근지역 및 다른 지역과의 형평성·특수성, 표준지공시지가 변동의 예측 가능성 등 제반사항을 종합적으로 참작하여야 한다.(제3조 제4항)

(3) 의견청취

a. 토지소유자의 의견청취

- ① 국토교통부장관은 표준지 소유자의 의견을 들으려는 경우에는 부동산공시가격시스템에 다음 각 호의 사항을 20일 이상 게시해야 한다.

1. 공시대상, 열람기간 및 방법
2. 의견제출기간 및 의견제출방법
3. 법 제3조제5항에 따라 감정평가법인등이 평가한 공시 예정가격

- ② 국토교통부장관은 제1항에 따른 게시사실을 표준지 소유자에게 개별 통지해야 한다.
- ③ 제1항에 따라 게시된 가격에 이의가 있는 표준지 소유자는 의견제출기간에 의견을 제출할 수 있다.

b. 시도지사, 시장·군수·구청장의 의견청취

- ① 감정평가법인등은 제1항에 따라 조사·평가보고서를 작성하는 경우에는 미리 해당 표준지를 관할하는 시도지사 및 시장·군수·구청장의 의견을 들어야 한다.(시행령 제8조 제2항)
- ② 시·도지사 및 시장·군수·구청장은 제2항에 따라 의견 제시 요청을 받을 경우에는 요청받은 날부터 20일 이내에 의견을 제시해야 한다.
- ③ 이 경우 시장·군수 또는 구청장은 법 제25조에 따른 시·군·구부동산가격공시위원회의 심의를 거쳐 의견을 제시해야 한다.(시행령 제8조 제3항)

(4) 조사·평가보고서 제출

표준지공시지가 조사·평가를 의뢰받은 감정평가법인등은 표준지공시지가 및 그 밖에 국토교통부령으로 정하는 사항을 조사·평가한 후 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 조사·평가보고서를 작성하여 국토교통부장관에게 제출해야 한다.

(5) 적정성 검토

- ① 표준지공시지가는 제출된 보고서에 따른 조사·평가액의 산술평균치를 기준으로 한다.(시행령 제8조 제4항)
- ② 국토교통부장관은 제출된 보고서에 대하여 부동산공시법 제3조에 따라 신고한 실제 매매가격 및 감정평가법 제9조에 따른 감정평가 정보체계 등을 활용하여 그 적정성 여부를 검토할 수 있다.(시행령 제8조 제5항).
- ③ 국토교통부장관은 제5항에 따른 검토 결과 부적정하다고 판단되거나 조사·평가액 중 최고평가액이 최저평가액의 1.3배를 초과하는 경우에는 해당 감정평가법인등에게 보고서를 시정하여 다시 제출하게 할 수 있다.(시행령 제8조 제6항)
- ④ 국토교통부장관은 제출된 보고서의 조사·평가가 관계 법령을 위반하여 수행되었다고 인정되는 경우에는 해당 감정평가법인등에게 그 사유를 통보하고, 다른 감정평가법인등 2인에게 대상 표준지공시지가의 조사·평가를 다시 의뢰해야 한다. 이 경우 표준지 적정가격은 다시 조사·평가한 가격의 산술평균치를 기준으로 한다.

4) 중앙부동산가격공시위원회의 심의

국토교통부장관이 지가를 공시하기 위하여는 표준지에 대하여 매년 공시기준일 현재의 적정가격을 조사·평가하고, 중앙부동산가격공시위원회의 심의를 거쳐야 한다.

5) 표준지공시지가의 공시 및 열람

(1) 공시

- ① 국토교통부장관은 표준지의 지번, 표준지의 단위면적당 가격, 표준지의 면적 및 형상, 표준지 및 주변토지의 이용상황, 그 밖에 대통령령이 정하는 사항(제5조)을 매년 1월 1일에 공시하여야 한다.
- ② 다만, 국토교통부장관이 표준지조사·평가인력 등을 감안하여 부득이하다고 인정되는 때에는 일부지역을 지정하여 당해 지역에 대하여는 따로 공시기준일을 정할 수 있다.(시행령 제3조)

(2) 표준지공시지가의 열람 등

국토교통부장관은 표준지공시지가를 공시한 때에는 그 내용을 특별시장·광역시장 또는 도지사를 거쳐 시장·군수 또는 구청장(지방자치단체인 구의 구청장에 한정한다)에게 송부하여 일반인이 열람할 수 있게 하고, 대통령령으로 정하는 바에 따라 이를 도서·도표 등으로 작성하여 관계 행정기관 등에 공급하여야 한다.

04 효력 (부동산공시법 제9조)

- ① 표준지공시지가는 토지시장의 지가정보를 제공하고
- ② 일반적인 토지거래의 지표가 되며,
- ③ 국가·지방자치단체 등의 기관이 그 업무와 관련하여 지가를 산정하거나
- ④ 감정평가법인등이 개별적으로 토지를 감정평가하는 경우에 그 기준이 된다.

05 적용

- ① 감정평가법인등이 개별적으로 토지를 감정평가하는 경우에 그 기준이 되고(감정평가법 제3조 제1항)
- ② 개별공시지가 산정의 기준이 되며(부동산공시법 제10조 제4항)
- ③ 국가 등이 행정 목적을 위하여 적용하는 경우의 기준이 된다.

1) 이의신청

(1) 의의 및 취지 (부동산공시법 제7조)

- ① 이의신청이란 표준지공시지가에 **의의가 있는 자**가 공시일로부터 30일 이내에 국토교통부장관에게 이의를 신청하는 것을 말한다.
- ② 이는 공시지가의 객관성을 확보하여 공신력을 높이는 데 취지가 있다.

(2) 이의신청의 성격

a. 문제점

- ① 부동산공시법 제7조는 이의신청을 규정하고 그 결정에 의의가 있을 경우 행정심판을 청구할 수 있는지에 대해 별도 규정이 없어 이의신청의 성격이 문제된다.
- ② 행정심판법 제51조는 행정심판 재청구를 금지하고 있어, 이의신청의 법적성질에 따라 행정심판 청구가능 여부가 달라진다는데 논의의 실익이 있다.

b. 구별기준

① 심판기관기준설

행정심판은 행정심판위원회, 이의신청은 처분청에 제기한다고 보아 심판기관을 기준으로 구분하는 견해이다.

② 불복절차기준설

준사법적 절차가 보장되는 것만을 행정심판으로 보고, 그렇지 않은 것은 이의신청으로 보는 견해이다.

③ 판례

국가유공자법상의 이의신청에 대하여 <이의신청 담당기관인 처분청에서의 동일한 절차라는 점을 염두에 두고 행정심판이 아닌 이의신청>으로 보아 **불복절차기준설**을 취하고 있는 것으로 보인다.

④ 검토

헌법 제107조 제3항이 행정심판절차는 **사법절차가 준용**되어야 한다고 규정하고 있는 점을 비추어 **불복절차**를 기준으로 양자를 구별하는 것이 타당하다.

c. 이의신청의 성격

- ① 이에 따를 때, 부동산공시법에서는 이의신청절차를 준사법적 절차로 하는 어떠한 규정도 두고 있지 않으므로 부동산공시법상 이의신청은 **행정심판이 아니라고 보는 것이 타당하다**.
- ② 판례도 [부동산공시법]에 행정심판의 제기를 배제하는 명시적인 규정이 없고, 부동산공시법에 따른 이의신청과 행정심판은 그 절차 및 담당기관에 차이가 있는 점을 고려하여, 행정심판이 아닌 이의신청으로 보았다.

(3) 제기요건

- ① 부동산공시법 제7조 제1항에서는 '의의가 있는 자'라고 규정하고 있고, 시행령 제12조는 '이의신청을 하려는 자'라 규정한다. 토지소유자 외에 **제3자라도 법률상 이해관계가 인정되면** 이의신청을 할 수 있다.
이의신청의 상대방은 국토교통부장관이다.
- ② '공시일로부터 30일 이내'에 신청해야 한다. 이 기간에 대하여 헌법재판소는 조속하고 일률적인 확정을 위한 합리적 필요에 기인한 것으로 헌법에 위배되는 것은 아니라고 하였다.

- ③ 이의신청의 관할은 국토교통부장관이다.
- ④ 이의신청의 형식 및 내용은 사유를 적은 이의신청서와 이의신청의 사유를 증명하는 서류로 한다.

(4) 심리 등

국토교통부장관은 이의신청기간이 만료된 날부터 30일 이내에 이의신청을 심사하여 그 결과를 신청인에게 서면으로 통지하여야 한다. 이 경우 국토교통부장관은 이의신청의 내용이 타당하다고 인정될 때에는 당해 표준지공시지가를 조정하여 다시 공시하여야 한다.(부동산공시법 제7조 제2항)

(5) 이의신청 후 제소기간(행정기본법 제36조 제4항)

- ① 만약 부동산공시법 제7조의 이의신청이 특별행정심판이고 그 제기기간이 도과되었을 경우, 행정심판 재청구금지(행정심판법 제51조) 규정에 따라 행정심판의 청구가 불가능하게 된다.
- ② 그러나 부동산공시법상 이의신청을 강학상 이의신청으로 보는 것이 타당하므로, 이의신청에 대해 불복하고자 하는 자는 **그 결과를 통지받은 날부터 90일 이내에** 행정심판 또는 행정소송을 제기할 수 있다.

2) 항고소송

(1) 대상적격의 문제

표준지공시지가의 법적성질을 행정행위로 본다면 처분성이 인정된다.

(2) 원고적격의 문제

- ① 표준지공시지가의 소유자에게는 항고소송의 원고적격이 당연히 인정된다. 다만 인근주민에게도 원고적격이 인정되는지가 문제된다.
- ② 부동산공시법 시행령 제12조에서 <이의신청을 하려는 자>라고 표현하고 있어 **이의신청인을 토지소유자로 한정하지 않고 있다.**
- ③ 따라서 부동산공시법의 입법취지, 표준지공시지가의 영향범위 등을 고려할 때 **인근주민에게도** 표준지공시지가에 대해서 다룰 **법률상 이익이 있어 원고적격이 인정된다고** 봄이 타당하다.

(3) 제소기간의 문제

- ① 행정소송법 제20조에서는 처분이 있음을 안 날로부터 90일, 이른 날로부터 1년의 제소기간을 규정하고 있다.
- ② 다만 표준지공시지가처럼 처분 등이 공고 또는 고시로 이루어지는 경우, <처분이 있음을 안 날>의 해석이 문제된다.
- ③ 판례는 통상 고시 또는 공고에 의하여 행정처분을 하는 경우에는 그 처분의 효력이 **불특정 다수인에게 일률적으로 적용되는 것이므로**, 그 행정처분에 이해관계를 갖는 자가 고시 또는 공고가 있었다는 사실을 **현실적으로 알았는지 여부에 관계없이** 고시가 효력을 발생하는 날 행정처분이 있음을 알았다고 보아야 한다고 판시하였다.
- ④ 생각건대 표준지공시지가는 불특정 다수인에게 일률적으로 적용되는 것이므로, 판례와 같이 고시 또는 공고의 효력발생일에 그 처분이 있음을 알았던 것으로 보아야 하며, 따라서 표준지공시지가의 **공시일(효력발생일)로부터 90일 이내에**, 공시일로부터 1년 이내에 행정소송을 제기할 수 있다고 봄이 타당하다.

대법원 2007. 6. 14. 선고 2004두619

통상 고시 또는 공고에 의하여 행정처분을 하는 경우에는 그 처분의 상대방이 불특정 다수인이고 그 처분의 효력이 불특정 다수인에게 일률적으로 적용되는 것이므로, 그 행정처분에 이해관계를 갖는 자가 고시 또는 공고가 있었다는 사실을 현실적으로 알았는지 여부에 관계없이 고시가 효력을 발생하는 날 행정처분이 있음을 알았다고 보아야 한다.

CASE

공익사업을 위한 토지등의 취득 및 보상에 관한 법률상 보상금 증액청구소송을 하면서 해당 재결에 대한 선행처분으로서 수용대상 토지가격 산정의 기초가 된 표준지공시지가 결정이 위법함을 독립한 사유로 다룰 수 있는가에 관하여 논하시오. (10점) [24회 문4]

1) 하자승계를 긍정한 판례

(1) 표준지공시지가와 수용재결(보증소)(예외적으로 인정)

대판 2008.8.21. 2007두13845

표준지공시지가결정은 이를 기초로 한 수용재결 등과는 별개의 독립된 처분으로서 서로 독립하여 별개의 법률효과를 목적으로 하지만, 표준지공시지가는 이를 인근 토지의 소유자나 기타 이해관계인에게 개별적으로 고지하도록 되어 있는 것이 아니어서 인근 토지의 소유자 등이 표준지공시지가결정 내용을 알고 있었다고 전제하기가 곤란할 뿐만 아니라, (중략) 위법한 표준지공시지가결정에 대하여 그 정해진 시정절차를 통하여 시정하도록 요구하지 않았다는 이유로 위법한 표준지공시지가를 기초로 한 수용재결 등 후행 행정처분에서 표준지 공시지가결정의 위법을 주장할 수 없도록 하는 것은 수인한도를 넘는 불이익을 강요하는 것으로서 국민의 재산권과 재판받을 권리를 보장한 헌법의 이념에도 부합하는 것이 아니다.

따라서 표준지공시지가결정이 위법한 경우에는 그 자체를 행정소송의 대상이 되는 행정처분으로 보아 그 위법 여부를 다룰 수 있음은 물론, 수용보상금의 증액을 구하는 소송에서도 선행처분으로서 그 수용대상 토지가격산정의 기초가 된 비교표준지공시지가결정의 위법을 독립한 사유로 주장할 수 있다.

2) 하자승계를 부정한 판례

(1) 표준지공시지가와 개별공시지가

대판 1996.9.20. 95누11931

표준지로 선정된 토지의 공시지가에 대하여 불복하기 위하여는 (구)지가공시 및 토지 등의 평가에 관한 법률 제8조 제1항 소정의 이의절차를 거쳐 처분청을 상대로 그 공시지가결정의 취소를 구하는 행정소송을 제기하여야 하고, 그러한 절차를 밟지 아니한 채 개별토지가격결정의 효력을 다투는 소송에서 그 개별토지가격 산정의 기초가 된 표준지공시지가의 위법성을 다룰 수는 없다.

(2) 표준지공시지가와 조세부과처분

대판 1997.2.28. 96누10225

표준지로 선정된 토지의 공시지가에 불복하기 위하여는 (구)지가공시 및 토지 등의 평가에 관한 법률 제8조 제1항 소정의 이의절차를 거쳐 처분청인 건설부장관을 상대로 그 공시지가 결정의 취소를 구하는 행정소송을 제기하여야 하는 것이지 그러한 절차를 밟지 아니한 채 그 표준지에 대한 조세부과처분의 취소를 구하는 소송에서 그 공시지가의 위법성을 다툴 수는 없다.

(개별토지가격에 대한 불복방법과는 달리 표준지의 공시지가에 대한 불복방법을 위와 같이 제한하고 있는 것은 표준지의 공시지가와 개별토지가격은 그 목적*대상*결정기관*결정절차*금액 등 여러 가지면에서 서로 다른 성질의 것이라는 점을 고려한 것이므로, 이러한 차이점에 근거하여 표준지의 공시지가에 대한 불복방법을 개별토지가격에 대한 불복방법과 달리 인정한다고 하여 그것이 헌법상 평등의 원칙, 재판권 보장의 원칙에 위반된다고 볼 수는 없다고 할 것이다. 1997.9.26.선고96누7649)

01 의의 및 취지

- ① 개별공시지가란 시군구청장이 표준지공시지가를 기준으로 산정한 개별토지의 단위면적당 가격을 말한다.
(부동산공시법 제10조 제1항)
- ② 이는 세금 및 각종 부담금 등의 산정을 위하여 결정·공시된다.

02 법적성질

1) 논의의 실익

개별공시지가가 항고소송의 대상이 되는 행정소송법상의 처분인지가 문제된다.

2) 학설

(1) 행정행위설

부동산공시법이 개별공시지가에 대하여 **이의신청**을 할 수 있다고 규정하고 있으며, 개별공시지가는 조세 등의 산정기준이 되므로 **국민의 구체적인 권리·의무에 직접 영향**을 미친다고 본다.

(2) 행정규칙설

개별공시지가는 과세처분 등 정책집행을 위해 일반적·추상적 기준을 설정하는 것으로 본다.

(3) 행정계획설

개별공시지가는 대내적으로 행정청에 대해서만 법적 의무를 부과하는 구속적 행정계획으로 본다.

(4) 사실행위설

개별공시지가는 토지가격의 지침으로 정보제공이라는 사실적 효과를 갖는다고 본다.

3) 판례

대법원은 개별토지가격 결정은 관계법령에 의한 토지초과이득세, 택지초과소유부담금 또는 개발부담금 산정의 기준이 되어 국민의 권리, 의무 내지 **법률상 이익에 직접 관계**되므로 **행정처분**이라고 본다.(대법원 1993. 1. 15. 선고 92누12407 판결)

4) 검토

개별공시지가는 이후 **과세처분 등의 직접적 기준**이 되어 국민의 권리·의무에 직접 영향을 미치므로, 이를 조기에 다투어 법률관계를 확정하고 법적 안정성을 도모할 필요가 있다. 따라서 개별공시지가의 처분성을 인정하는 행정행위설이 타당하다.

03 개별공시지가의 공시절차

1) 공시절차 개요

- ① 개별공시지가의 산정
- ② 개별공시지가의 검증과 의견청취
- ③ 시·군·구 부동산가격공시위원회의 심의
- ④ 개별공시지가의 결정·공시

2) 개별공시지가의 산정

- ① 시장·군수 또는 구청장이 개별공시지를 결정·공시하는 경우에는 해당 토지와 유사한 이용가치를 지닌다고 인정되는 하나 또는 둘 이상의 표준지의 공시지를 기준으로 **토지가격비준표를 사용하여 지가를 산정**하되, 해당 토지의 가격과 표준지공시지가의 균형을 유지하도록 하여야 한다.(제10조 제4항)
- ② 표준지로 선정된 토지에 대하여는 해당 토지의 표준지공시지가를 개별공시지기로 본다.(제10조 제2항)

3) 개별공시지가의 검증과 의견청취

CASE

甲은 A시장이 자신의 소유 토지에 대한 개별공시지를 결정함에 있어서 부동산 가격공시에 관한 법률에 의하여 국토교통부장관이 작성한 토지가격비준표를 고려하지 않았다고 주장한다. 이에, A시장은 토지가격비준표를 고려하지 않은 것은 사실이나, 같은 법에 따른 산정지가검증이 적정하게 행해졌으므로, 甲 소유의 토지에 대한 개별공시지가결정은 적법하다고 주장한다. A시장 주장의 타당성에 대해 검토하시오. [19회 문2]

(1) 개별공시지가의 검증 의뢰

- ① 시장·군수 또는 구청장은 개별공시지를 결정·공시하기 위하여 개별토지의 가격을 산정할 때에는 그 타당성에 대하여 감정평가법인등의 검증을 받고 토지소유자, 그 밖의 이해관계인의 의견을 들어야 한다.(제10조 제5항)
- ② 시장·군수 또는 구청장이 검증을 받으려는 때에는 해당 지역의 표준지의 공시지를 조사·평가한 감정평가법인등 또는 대통령령이 정하는 감정평가실적 등이 우수한 감정평가법인등에게 의뢰하여야 한다.(제10조 제6항)

(2) 감정평가법인등의 검증

시장·군수 또는 구청장으로부터 검증의뢰를 받은 감정평가법인등은

- ① 비교표준지의 선정의 적절성에 관한 사항
- ② 개별토지 가격 산정의 적정성에 관한 사항
- ③ 산정한 개별토지가격과 표준지공시지가의 균형 유지에 관한 사항
- ④ 산정한 개별토지가격과 인근토지의 지가와 균형 유지에 관한 사항
- ⑤ 표준주택가격, 개별주택가격, 비주거용 표준부동산 가격 및 비주거용 개별부동산가격 산정시 고려된 토지 특성과 일치하는지 여부
- ⑥ 개별토지가격 산정시 적용된 용도지역, 토지이용상황 등 주요 특성이 공부와 일치하는지 여부
- ⑦ 그 밖에 시장·군수 또는 구청장이 검토를 의뢰한 사항을 검토·확인하고 의견을 제시해야 한다.(시행령 제18조 제2항)

(3) 검증의 생략

- ① 시장·군수 또는 구청장은 감정평가법인등의 검증이 필요 없다고 인정되는 때에는 지가의 변동상황 등 대통령령이 정하는 바에 따라 감정평가법인등의 검증을 생략할 수 있다.(제10조 제5항 단서)
- ② 시장·군수 또는 구청장은 감정평가법인등의 검증을 생략할 때에는 개별토지의 지가변동률과 해당 토지가 있는 읍·면·동의 연평균 지가변동률 간의 차이가 작은 순으로 대상토지를 선정해야 한다.
- ③ 다만, 개발사업이 시행되거나 용도지역·용도지구가 변경되는 등의 사유가 있는 토지는 검증 생략 대상 토지로 선정해서는 안된다.(시행령 제18조 제3항)

4) 토지소유자 등의 의견청취

시장·군수 또는 구청장은 부동산공시법 제10조 제5항에 따라 개별토지의 가격산정에 관하여 토지소유자 및 그 밖의 이해관계인의 의견을 들으려는 경우에는 개별토지가격 열람부를 갖추어 놓고 해당 시·군 또는 구의 게시판 또는 인터넷 홈페이지에 다음 각 호의 사항(열람기간 및 열람장소, 의견제출기간 및 의견제출방법)을 20일 이상 게시하여 개별토지소유자등이 개별토지가격을 열람할 수 있도록 하여야 한다.(동법 시행령 제19조)

5) 시·군·구 부동산가격공시위원회의 심의

시·군·구청장은 개별공시지가를 공시하기 전에 시장·군수 또는 구청장 소속하의 부동산가격공시위원회의 심의를 거쳐야 한다.(제25조 제1항 제1호)

6) 개별공시지가의 결정·공시

- ① 시장·군수 또는 구청장은 매년 공시지가의 공시기준일 현재 관할 구역 안의 개별공시지가를 결정·공시하고, 이를 관계 행정기관 등에 제공하여야 한다.(동법 제10조 제1항)
- ② 또한 시장·군수 또는 구청장은 개별공시지가를 공시할 때에는 조사기준일, 공시필지의 수 및 개별공시지가의 열람방법 등 개별공시지가의 결정에 관한 사항, 이의신청의 기간절차 및 방법의 사항을 해당 시·군 또는 구의 게시판 또는 인터넷 홈페이지에 게시하여야 한다.(동법 시행령 제21조)

04 정정

CASE

부동산 가격공시에 관한 법령상 개별공시지가의 정정사유에 관하여 설명하시오. (5점) [31회 문2]

1) 정정 사유

- ① 시장·군수 또는 구청장은 개별공시지가에 틀린 계산, 오기, 표준지 선정의 착오 그 밖에 대통령령이 정하는 명백한 오류가 있음을 발견한 때에는 지체 없이 이를 정정하여야 한다.(법 제12조)
- ② <그 밖에 대통령령이 정하는 명백한 오류>라 함은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.
(시행령 제23조 제1항)

1. 공시절차를 완전하게 이행하지 아니한 경우
2. 용도지역·용도지구 등 토지가격에 영향을 미치는 주요요인의 조사를 잘못된 경우
3. 토지가격비준표의 적용에 오류가 있는 경우를 말한다.

2) 정정절차

- ① 시장·군수 또는 구청장은 법 제12조에 따라 개별공시지가의 오류를 정정하려는 경우에는 시·군·구부동산 가격공시위원회의 **심의를 거쳐** 정정사항을 결정·공시하여야 한다.
- ② 다만, 틀린 계산 또는 오기의 경우에는 시·군·구부동산가격공시위원회의 심의를 거치지 아니할 수 있다.
(시행령 제23조 제2항)

3) 정정의 효력

대법원은 경정결정되어 공시된 이상 당초에 결정·공시된 개별공시지가는 그 효력을 상실하고 경정결정된 새로운 공시지가가 공시기준일에 **소급하여 그 효력을 발생**한다고 한다.(대법원 1999. 10. 26. 98두2669 판결)

4) 입법적 평가

(1) 신청에 의한 정정 규정이 없는 것

- ① 행정청은 처분에 오기, 오산 또는 그 밖에 이에 준하는 명백한 잘못이 있을 때에는 직권으로 또는 **〈신청에 따라〉** 지체 없이 정정하고 그 사실을 당사자에게 통지하여야 한다.(행정절차법 제25조)

[행정절차법] 제25조 (처분의 정정)

행정청은 처분에 오기, 오산 또는 그 밖에 이에 준하는 명백한 잘못이 있을 때에는 직권으로 또는 신청에 따라 지체 없이 정정하고 그 사실을 당사자에게 통지하여야 한다.

- ② 그런데 개별공시지가 정정 규정에는 **〈신청에 의한 정정규정〉**이 없다.
- ③ 그러나, 행정절차법에서 신청에 따른 정정을 인정하므로, 개별공시지가 정정에서도 국민의 권익구제를 위하여 인정함이 **타당**하다.

(2) 소송단계에 이르지 않고 권리구제를 위한 것

- ① 개별공시지가의 정정사유에 개별공시지가의 공시절차를 완전하게 이행하지 아니한 경우도 포함하고 있다.
- ② 이는 절차가 완전하지 못한 개별공시지가의 위법성을 소송에 이르지 않고 정정할 수 있도록 규정한 것으로 이해된다.

5) 정정신청에 대한 행정청의 거부행위에 대한 불복가능성

- ① 거부행위가 행정쟁송법상 처분이기 위해서 판례의 요건인 공권력행사의 거부일 것, 그 거부가 신청인의 권리·의무에 영향을 미칠 것, 법규상·조리상 신청권이 있을 것의 요건과 관계된다.
- ② 특히 신청권 존부와 관련해서 **판례는 신청권을 부정**하였고, 국민의 정정신청은 행정청의 직권 발동을 촉구하는 것에 지나지 않는다고 하여 이른바 관념의 통지에 불과할 뿐 항고소송의 대상이 되는 처분이라고 판시하였다.
- ③ 그러나 행정절차법 제25조에 따를 때 신청권이 인정될 수 있어 **판례 태도는 비판의 여지**가 있다.

6) 토지특성조사 착오가 명백한 경우만 정정결정을 할 수 있는지

(1) 관련 판례

대법원은 토지특성조사의 착오 또는 위산, 오기는 지가산정에 명백한 잘못이 있는 경우의 예시로서, 이러한 사유가 있으면 경정 결정할 수 있는 것으로 보아야 하고, 그 착오가 명백하여야 비로소 경정 결정할 수 있다고 해석할 것은 아니라고 판시한 바 있다.

(2) 검토

- ① 부동산공시법 시행령 제23조 제1항은 명백한 오류의 예시규정이다.
- ② 여기서 제시된 사유가 명백한 경우에 한하여만 정정할 수 있다고 보는 것은 법규정에 대한 해석의 오류라고 볼 수 있다.
- ③ 따라서 판례처럼 이 규정에 예시된 사유가 발생한 경우에는 명백한 오류인지를 불문하고 정정할 수 있다고 보는 것이 타당하다.

05 불복

1) 이의신청

(1) 의의 및 취지 (부동산공시법 제11조)

- ① 이의신청이란 개별공시지가에 이의가 있는 자가 공시일로부터 30일 이내에 시장·군수·구청장에게 이의를 신청하는 것을 말한다.
- ② 이는 공시지가의 객관성을 확보하여 공신력을 높이는 데 취지가 있다.

(2) 성격

a. 문제점

- ① 부동산공시법상 이의신청이 강학상 이의신청인지 특별법상 행정심판인지 문제된다.
- ② 행정심판법 제51조는 행정심판 재청구를 금지하고 있어, 이의신청의 법적 성질에 따라 행정심판 청구가능 여부가 달라진다는데 논의의 실익이 있다.

b. 구별기준

- ① 심판기관기준설
행정심판은 행정심판위원회, 이의신청은 처분청에 제기한다고 보아 심판기관을 기준으로 구분하는 견해이다.
- ② 불복절차기준설
준사법적 절차가 보장되는 것만을 행정심판으로 보고, 그렇지 않은 것은 이의신청으로 보는 견해이다.
- ③ 판례
국가유공자법상의 이의신청에 대하여 <이의신청 담당기관인 처분청에서의 동일한 절차라는 점을 염두에 두고 행정심판이 아닌 이의신청>으로 보아 불복절차기준설을 취하고 있는 것으로 보인다.
- ④ 검토
헌법 제107조 제3항이 행정심판절차는 사법절차가 준용되어야 한다고 규정하고 있는 점을 비추어 불복절차를 기준으로 양자를 구별하는 것이 타당하다.

c. 이의신청의 성격

- ① 이에 따라 때, 부동산공시법에서는 이의신청절차를 준사법적 절차로 하는 어떠한 규정도 두고 있지 않으므로 부동산공시법상 이의신청은 행정심판이 아니라고 보는 것이 타당하다.
- ② 판례도 [부동산공시법]에 행정심판의 제기를 배제하는 명시적인 규정이 없고, 부동산공시법에 따른 이의신청과 행정심판은 그 절차 및 담당기관에 차이가 있는 점을 고려하여, 행정심판이 아닌 이의신청으로 보았다.

대법원 2010. 1. 28. 선고 2008두19987 [개별공시지가결정처분취소]

부동산 가격공시 및 감정평가에 관한 법률 제12조, 행정소송법 제20조 제1항, 행정심판법 제3조 제1항의 규정 내용 및 취지와 아울러 부동산 가격공시 및 감정평가에 관한 법률에 행정심판의 제기를 배제하는 명시적인 규정이 없고 부동산 가격공시 및 감정평가에 관한 법률에 따른 이의신청과 행정심판은 그 절차 및 담당 기관에 차이가 있는 점을 종합하면, 부동산 가격공시 및 감정평가에 관한 법률이 이의신청에 관하여 규정하고 있다고 하여 이를 행정심판법 제3조 제1항에서 행정심판의 제기를 배제하는 ‘다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우’에 해당한다고 볼 수 없으므로, 개별공시지가에 대하여 이의가 있는 자는 곧바로 행정소송을 제기하거나 부동산 가격공시 및 감정평가에 관한 법률에 따른 이의신청과 행정심판법에 따른 행정심판청구 중 어느 하나만을 거쳐 행정소송을 제기할 수 있을 뿐 아니라, 이의신청을 하여 그 결과 통지를 받은 후 다시 행정심판을 거쳐 행정소송을 제기할 수도 있다고 보아야 하고, 이 경우 행정소송의 제소기간은 그 행정심판 재결서 정본을 송달받은 날부터 기산한다.

(3) 제기요건

- ① 부동산공시법 제11조 제1항에서는 <의의가 있는 자>라고 규정하고 있고, 시행령 제22조 제1항은 ‘이의신청을 하려는 자’라 규정한다.
- ② <결정·공시일로부터 30일 이내>에 서면으로 신청해야 한다. 이의신청의 형식 및 내용은 사유를 적은 이의신청서와 이의신청의 사유를 증명하는 서류로 한다.

(4) 심리 등

- ① 시장·군수 또는 구청장은 이의신청기간이 만료된 날부터 30일 이내에 이의신청을 심사하여 그 결과를 신청인에게 서면으로 통지하여야 한다.
- ② 시장·군수 또는 구청장은 이의신청의 내용이 타당하다고 인정될 때에는 해당 개별공시지가를 조정하여 다시 결정·공시하여야 한다.(부동산공시법 제11조 제2항)

(5) 이의신청 후 제소기간(행정기본법 제36조 제4항)

- ① 만약 부동산공시법 제11조의 이의신청이 특별행정심판이고 그 제기기간이 도과되었을 경우, 행정심판 재청구금지(행정심판법 제51조) 규정에 따라 행정심판의 청구가 불가능하게 된다.
- ② 그러나 부동산공시법상 이의신청을 강학상 이의신청으로 보는 것이 타당하므로, 이의신청에 대해 불복하고자 하는 자는 그 결과를 통지받은 날부터 **90일 이내**에 행정심판 또는 행정소송을 제기할 수 있다.

2) 항고소송

(1) 대상적격의 문제

개별공시지가의 법적성질을 행정행위로 본다면 처분성이 인정된다.

(2) 원고적격의 문제

- ① 개별공시지가의 소유자에게는 항고소송의 원고적격이 당연히 인정된다. 다만 인근주민에게도 원고적격이 인정되는지가 문제된다.
- ② 부동산공시법 시행령 제22조에서 <이의신청을 하려는 자>라고 표현하고 있어 이의신청인을 **토지소유자로 한정하지 않고 있다.**
- ③ 생각건대, 부동산가격공시법이 이의신청을 할 수 있는 자를 토지소유자에 한정하지 않고 있으므로, 개별공시지가의 결정·공시로 인해 법률상 이익이 침해된다면 원고적격이 인정된다고 볼 것이다.

(3) 개별공시지가의 취소소송 제소기간

CASE

A시장은 2020. 5. 20. 甲의 토지의 개별공시지가를 1㎡당 839만원으로 결정·공시하고, 甲에게 개별 통지하였다. 甲은 토지가격비준표에 제시된 토지특성에 기초한 가격배율을 무시하고 乙이 감정평가방식에 따라 독자적으로 지가를 산정하여 제시한 검증의견을 그대로 반영하여 개별공시지가를 결정한 것은 위법하다고 보아, 「부동산 가격 공시에 관한 법률」 제11조에 따라 2020. 6. 15. 이의신청을 제기하였고, 2020. 7. 10. 이의를 기각하는 내용의 이의신청결과가 甲에게 통지되었다.

甲은 2020. 9. 10. 개별공시지가결정에 대해 취소소송을 제기하였다. 甲이 제기한 취소소송은 제소기간을 준수하였는가? (10점) [32회 문2 변형]

a. 문제점

- ① 행정소송법 제20조 제1, 2항에 따르면, 취소소송은 처분등이 있음을 안 날로부터 90일(불변기간) 이내, 있는 날로부터 1년 이내에 제기하여야 한다.
- ② 개별공시지가는 토지소유자에 대한 개별적 통지가 강제되지 않기에, 제소기간 또한 통지여부에 따라 나누어 검토하여야 한다. 개별통지를 받았다면, 그때부터 90일 이내에 취소소송을 제기하여야 하나, 개별통지를 하지 않은 경우 처분이 있음을 안 날을 언제로 보아야 할지 문제된다.

b. 판례

개별토지가격결정 처분의 효력은 각각의 토지 또는 소유자에 대하여 발생하는 것이므로, 개별토지가격결정의 공고는 공고일로부터 그 효력을 발생하지만 처분상대방인 토지소유자 및 이해관계인이 **공고일에 그 처분이 있음을 알았다고까지 의제할 수 없어**, 결국 행정심판의 청구기간은 처분 상대방이 실제로 처분이 있음을 안 날로부터 기산하여야 할 것이나, 특별히 위 처분을 알았다고 볼 만한 사정이 없는 한 개별토지가격결정에 대한 행정심판 청구는 처분이 있는 날로부터 180일 이내에 제기하면 된다고 판시하였다.[대판 1993.12.24. 92누 17204]

대법원 1993. 12. 24. 선고 92누17204 [개별토지가격결정처분취소]

개별토지가격결정에 있어서는 그 처분의 고지방법에 있어 개별토지가격합동조사지침(국무총리훈령 제248호)의 규정에 의하여 행정편의상 일단의 각 개별토지에 대한 가격결정을 일괄하여 읍·면·동의 게시판에 공고하는 것일 뿐 그 처분의 효력은 각각의 토지 또는 각각의 소유자에 대하여 각별로 효력을 발생하는 것이므로 개별토지가격결정의 공고는 공고일로부터 그 효력을 발생하지만 처분 상대방인 토지소유자 및 이해관계인이 공고일에 개별토지가격결정 처분이 있음을 알았다고까지 의제할 수는 없어 결국 개별토지가격결정에 대한 재조사 또는 행정심판의 청구기간은 처분 상대방이 실제로 처분이 있음을 안 날로부터 기산하여야 할 것이나, 시장, 군수 또는 구청장이 개별토지가격결정을 처분 상대방에 대하여 별도의 고지절차를 취하지 않는 이상 토지소유자 및 이해관계인이 위 처분이 있음을 알았다고 볼 경우는 그리 흔치 않을 것이므로, 특별히 위 처분을 알았다고 볼만한 사정이 없는 한 개별토지가격결정에 대한 재조사청구 또는 행정심판청구는 행정심판법 제18조 제3항 소정의 처분이 있는 날로부터 180일 이내에 이를 제기하면 된다.

대법원 1995. 8. 25. 선고 94누13121 [개별공시지가결정처분취소등]

개별토지가격결정에 대한 재조사 또는 행정심판의 청구기간은 그 처분의 상대방이 실제로 그 처분이 있음을 안 날로부터 기산하여야 하므로, 개별토지가격합동조사지침(국무총리훈령 제241호, 제248호) 제12조의2 제1항 소정의 "개별토지가격이 결정된 날로부터"는 위와 같은 의미로 해석하여야 하고, 시장, 군수 또는 구청장이 상대방에 대하여 별도의 고지절차를 취하지 않는 경우에는 원칙적으로 특별히 그 처분을 알았다고 볼만한 사정이 없는 한 개별토지가격결정에 대한 재조사청구 또는 행정심판청구는 행정심판법 제18조 제3항 소정의 처분이 있는 날로부터 180일 이내에 이를 제기하면 되나, 나아가 개별토지가격결정의 경우에 있어서와 같이 그 처분의 통지가 없는 경우에는 그 개별토지가격결정의 대상토지 소유자가 심판청구기간 내에 심판청구가 가능하였다는 특별한 사정이 없는 한 행정심판법 제18조 제3항 단서 소정의 정당한 사유가 있는 때에 해당한다.

c. 검토

- ① 생각건대, 개별공시지가는 표준지공시지가와 달리 불특정 다수인에 대해서가 아니라 개별 토지에 대해서 효력이 발생하는 것이므로, 개별공시지가의 공고 또는 고시일에 처분의 상대방이 처분이 있음을 알았다고까지는 볼 수 없을 것이다.
- ② 따라서 개별공시지가결정을 **현실적으로 안 날로부터 90일**, 공고 또는 고시일로부터 1년 이내에 행정소송을 제기할 수 있다고 봄이 타당하다.

CASE

甲이 개별공시지가결정에 대해 다투지 않은 채 제소기간이 도과하였고, 이후 甲의 토지에 대해 수용재결이 있었다. 甲이 보상금의 증액을 구하는 소송에서 개별공시지가결정의 위법을 주장하는 경우, 甲의 주장은 인용될 수 있는가? (20점) [32회 문2]

1) 하자승계를 인정한 판례

① (개별통지가 없는) 개별공시지가와 과세처분

대판 1994.1.25. 93누8542

개별공시지가는 이를 토지소유자나 이해관계인에게 개별적으로 고지하도록 되어 있는 것이 아니어서 토지소유자 등이 개별공시지가 결정 내용을 알고 있었다고 전제하기도 곤란할 뿐만 아니라 결정된 개별공시지가가 자신에게 유리하게 작용될 것인지 또는 불이익하게 작용될 것인지 여부를 쉽사리 예견할 수 있는 것도 아니며 (중략) 선행처분과 후행처분이 서로 독립하여 별개의 효과를 목적으로 하는 경우에도 선행처분의 불가쟁력이나 구속력이 그로 인하여 불이익을 입게 되는 자에게 수인한도를 넘는 가혹함을 가져오며, 그 결과가 당사자에게 예측가능한 것이 아닌 경우에는 국민의 재판받을 권리를 보장하고 있는 헌법의 이념에 비추어 선행처분의 후행처분에 대한 구속력은 인정될 수 없다.

2) 하자승계를 부정한 판례

① 표준지공시지가와 개별공시지가

대판 1996.9.20. 95누11931

표준지로 선정된 토지의 공시지가에 대하여 불복하기 위하여는 (구)지가공시 및 토지 등의 평가에 관한 법률 제8조 제1항 소정의 이의절차를 거쳐 처분청을 상대로 그 공시지가결정의 취소를 구하는 행정소송을 제기하여야 하고, 그러한 절차를 밟지 아니한 채 개별토지가격결정의 효력을 다투는 소송에서 그 개별토지가격 산정의 기초가 된 표준지공시지가의 위법성을 다툴 수는 없다.

② (재조사청구에 따른 조정결정을 통지받은) 개별공시지가와 과세처분 사이

대법원 1998. 3. 13. 선고 96누6059

개별토지가격 결정에 대한 재조사 청구에 따른 감액조정에 대하여 더 이상 불복하지 아니한 경우, 이를 기초로 한 양도소득세 부과처분 취소소송에서 다시 개별토지가격 결정의 위법을 당해 과세처분의 위법사유로 주장할 수 없다고 한 사례

07 개발부담금 처분의 하자치유

1) 문제점

개별공시지가는 개발부담금, 과세처분의 산정기준이 되므로, 개별공시지가결정이 위법하다면, 이에 기초한 개발부담금, 과세처분 또한 위법하게 될 수 있다.

2) 판례

이와 관련하여, 대법원은 “선행처분인 개별공시지가결정이 위법하여 그에 기초한 개발부담금 부과처분도 위법하게 된 경우 그 하자의 치유를 인정하면 개발부담금 납부의무자로서는 위법한 처분에 대한 가산금 납부의무를 부담하게 되는 등 불이익이 있을 수 있으므로, 그 후 적법한 절차를 거쳐 공시된 개별공시지가결정이 종전의 위법한 공시지가 결정과 그 내용이 동일하다는 사정만으로는 위법한 개별공시지가결정에 기초한 개발부담금 부과처분이 적법하게 된다고 볼 수 없다.”고 판시한 바 있다.(대법원 2001. 6. 26. 선고 99두11592 판결)

3) 검토

- ① 하자의 치유는 국민의 권리와 이익을 침해하지 않는 범위 내에서만 허용된다.
- ② 개발부담금 납부의무자로서는 위법한 처분에 대한 가산금 납부의무를 부담하게 되는 등 불이익이 있을 수 있으므로, 허용되지 않는다고 봄이 타당하다.

※ 공시지가와 시가의 관계

1. 개설

- ① 시가란 시장에서 자유롭게 거래가 이루어지는 경우에 통상 성립한다고 인정되는 가액이다.
- ② 시가와 현저히 차이가 나는 공시지가 결정이 위법한지와 관련하여 공시지가와 시가의 관계가 문제된다.

2. 학설

1) 시가설

공시지가는 각종 세금이나 부담금의 산정기준이 되는 토지가격으로 현실시장 가격을 반영한 가격이어야 한다고 한다.

2) 정책가격설

부동산공시법 제1조에서 나타나는 바와 같이, 공시지가 공시를 통하여 부동산의 적정한 가격형성을 도모하는 기능이 있으므로, 이는 투기억제 또는 지가안정이라는 정책적 목적을 위하여 결정·공시되는 가격이라고 한다.

3. 판례

개별토지가격의 적정성 여부는 규정된 절차와 방법에 의하여 이루어진 것인지 여부에 따라 결정될 성질의 것이지, 당해 토지의 시가와 직접적 관련이 있는 것은 아니므로 단지 개별지가가 시가를 초과한다는 사유만으로는 그 가격 결정이 위법하다고 단정할 것은 아니라고 판시하여 공시지가를 정책적으로 결정한 가격으로 보고 있다.

4. 검토

- ① 공시지가는 통상적 시장에서 형성되는 시가를 반영하는 것이 바람직하나, 공시지가 제도의 취지상 공시지와 시가가 현저한 차이가 난다는 사유만으로 그 위법을 인정할 수는 없다.
- ② 단지 공시지가의 산정절차나 비교표준지 선정 등에 위법이 있을 때 이러한 위법을 이유로 다룰 수 있을 것이다.

CASE

B토지소유자는 토지가격비준표와 달리 결정된 개별공시지가결정은 위법하다고 주장한다. 이 주장은 타당한가?
(20점) [29회 3번]

01 의의 및 취지 (법 제3조 제8항)

- ① 토지가격비준표란 표준지와 개별토지의 지가형성요인에 관한 표준적인 비교표이다.
- ② 이는 표준지를 기준으로 개별토지의 대량평가를 위하여 작성된 객관적인 지가산정표이다.
- ③ 개별토지의 대량 지가 산정시 결여되기 쉬운 지가산정의 객관성과 합리성을 일정 수준 이상으로 끌어올릴 수 있고, 신속히 지가를 산정할 수 있는 장점을 지닌다.

02 법적 성질

1) 문제점

- ① **법령보충적행정규칙**이란 고시, 훈령 등 형식은 행정규칙이나 그 내용은 당해 행정입법의 근거가 되는 법령의 규정과 결합하여 법규적 성질을 갖는 규범을 말한다.
- ② 토지가격비준표는 행정규칙의 형식이나, 부동산공시법 제3조 제8항 등에 근거가 되는 법령의 규정이 있어 그 법적성질이 문제된다.

2) 학설

(1) 법규명령설 (실질설)

법규명령설은 실질을 중시하는 견해로서 상위법령을 보충·구체화 하는 기능이 있는 훈령·고시 등의 대외적 구속력을 긍정하여 법규명령으로 보는 견해이다.

(2) 행정규칙설 (형식설)

법규명령 형식은 대통령령·총리령·부령으로 한정되어 있으므로 이러한 형식에 의하지 않은 훈령 등은 행정규칙이라고 보는 견해로서 형식을 중시한다.

(3) 수권여부기준설

상위법령의 수권 유무에 따라 구분하는 견해로서, 위임 있다면 법규명령으로 보고 위임이 없는 경우에는 행정규칙으로 본다.

(4) 규범구체화 행정규칙설

대외적으로는 법적 구속력을 인정하나, 내부적으로는 상위법령을 구체화하는 규범구체화 행정규칙으로 보는 견해이다.

3) 판례

〈대법원〉은 토지가격비준표는 **법령 보충적인 구실**을 하는 **법규적 성질**을 가지고 있는 것으로 보아야 한다고 판시하여 법규성이 있다고 보았다.(대판 1998.5.26. 96누17103)

※ 보충자료

그러나 대법원은 보상액 산정과 관련하여 토지가격비준표는 개별토지가격을 산정하기 위한 자료로 제공되는 것으로, 토지수용에 따른 보상액 산정의 기준이 되는 것은 아니고 단지 참작 자료에 불과할 뿐이라고 판시한 바 있다.

[대법원 1999. 1. 29. 선고 98두4641]

4) 검토

- ① 상위법령의 위임이 있는 경우에는 그와 결합하여 법령을 보충하므로 법규성을 인정하는 것이 행정현실상 타당하다고 판단된다.
- ② 따라서 토지가격비준표는 부동산공시법과 결합하여 상위법령을 보충·구체화 하는 기능이 있으므로 법규명령으로 봄이 타당하다.

※ 보충자료 - 표준지 조사평가기준

- ① 의의 : 국토교통부 훈령 형식으로 제정되었으며, 「부동산공시법」 시행령 제6조 제3항에 위임 규정이 있다.
- ② 법적성질 : 법령보충적행정규칙으로서 법규명령의 성질을 가진다.

03 하자와 권리구제

1) 문제점

- ① 개별공시지가는 표준지공시지가에 토지가격비준표상의 가격배율을 곱하여 산정된다.
- ② 따라서 토지가격비준표의 작성과 활용에 하자가 있을 경우, 개별공시지가에 대한 취소소송이나 손해배상청구소송을 제기할 수 있는지가 문제된다.

2) 작성상의 하자

- ① 토지가격비준표는 그 작성 자체가 국민의 권리·의무에 직접 영향을 미친다고 보이지는 않으므로, 작성상 하자가 있더라도 쟁송의 제기는 불가능하다 할 것이다.
- ② 판례는 비준표상의 **토지의 특성 및 평가요소 등이 추가 또는 제외됨**으로 인하여 가격상승 또는 가격하락이 있게 되었다는 것만으로는 개별토지가격결정이 부당하다고 하여 이를 **다룰 수 없다**고 하였다.

대법원 1993. 6. 11. 선고 92누16706

당해 토지의 전년도 개별토지가격에 비하여 토지가격비준표상 새로운 평가요소가 추가되거나 기존의 평가요소가 제외됨으로써 가격상승 또는 가격하락이 있게 되었다는 것만으로는 개별토지가격결정이 부당하다고 하여 이를 다룰 수는 없다.

3) 활용상의 하자

① 일부항목만 적용하면 위법

토지가격비준표상의 가격배율은 비교표준지와 당해 토지의 특성을 비교하여 추출하고, 이를 개별토지의 가격을 산정할 때 모두 반영하여야 한다고 하고, 따라서 그 비교된 토지특성 중 임의로 일부 항목에 관한 가격배율만을 적용하여 산정한 지가를 기초로 하여 결정·공고된 개별토지가격결정은 위법하다고 하였다. (대법원 1995. 3. 15. 94누12937)

② 토지가격비준표 적용하지 않고 결정한 개공은 위법

토지이용상황이 특수필지에 해당된다고 하더라도 표준지 공시지가에 토지가격비준표에 의한 가격조정율을 적용하는 방식에 따르지 아니한 개별토지가격결정은 개별토지가격 산정방식에 어긋나는 것으로서 위법하다. (대법원 1998. 7. 10. 선고 97누1051)

③ 주용도에 대한 조정율 적용해야 함

비준표를 활용함에 있어 여러 용도로 복합되어 사용되고 있는 토지의 경우에는 복합되어 있는 용도 중 그 점유 면적이 많거나 또는 이용가치면에서 높은 가치인 용도를 주용도로 보아 그에 따른 조정율을 적용한다. (대법원 1993. 10. 12. 선고 93누9149)

④ 토지가격비준표를 사용하여 산정한 지가와 달리 결정되어도 위법하지 않음

부동산 가격공시 및 감정평가에 관한 법률 제11조, 부동산 가격공시 및 감정평가에 관한 법률 시행령 제17조 제2항의 취지와 문언에 비추어 보면, 시장 등은 표준지공시지가에 토지가격비준표를 사용하여 산정된 지가와 감정평가업자의 **검증의견 및 토지소유자 등의 의견을 종합하여** 당해 토지에 대하여 표준지공시지가와 균형을 유지한 **개별공시지가를 결정할 수 있고**, 그와 같이 결정된 개별공시지가가 표준지공시지가와 균형을 유지하지 못할 정도로 현저히 불합리하다는 등의 특별한 사정이 없는 한, 결과적으로 토지가격비준표를 사용하여 산정한 지가와 달리 결정되었거나 감정평가사의 검증의견에 따라 결정되었다는 이유만으로 그 개별공시지가 결정이 위법하다고 볼 수는 없다.(대법원 2013. 11. 14. 선고 2012두15364)

CASE

부동산 가격공시에 관한 법령상 중앙부동산가격공시위원회에 관하여 설명하시오. (10점) [29회 문4]

01 의의 및 근거

표준지, 개별공시지가 및 공동주택 공시에 관한 사항을 심의·의결하기 위한 위원회로 부동산가격공시법 제24, 25조 등에 근거를 둔다.

02 종류

- ① 국토교통부장관 소속의 중앙부동산가격공시위원회와
- ② 시장·군수 또는 구청장 소속의 시·군·구 부동산가격공시위원회가 있다.

03 심의사항**1) 중앙부동산가격공시위원회**

표준지, 표준주택, 비주거용 표준부동산에 대한 선정 및 관리지침, 공동주택, 비주거용 집합부동산에 대한 조사 및 산정지침, 위 부동산들의 공시가격 및 이의신청에 관한 사항 등을 심의한다.

2) 시·군·구 부동산가격공시위원회

개별공시지가, 개별주택가격, 비주거용 개별부동산가격에 대한 결정, 이의신청에 관한 사항 및 시장, 군수 등이 심의에 부치는 사항을 심의한다.

04 위원의 구성 및 의결 방법**1) 중앙부동산가격공시위원회**

- ① 위원장을 포함한 20명 이내의 위원으로 구성하며, 성별을 고려하여야 한다.
- ② 위원장은 국토교통부 제1차관이 된다. 위원회는 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고 출석의원 과반수의 찬성으로 의결한다.

2) 시군구 부동산가격공시위원회

위원장을 포함한 10명 이상 15명 이하의 위원으로 구성하며 성별을 고려하여야 한다. 위원장은 부시장, 부군수, 부구청장이 된다.

01 의미

관계 공무원 또는 부동산가격공시업무를 의뢰받은 자(이하 “관계공무원등”이라 한다)는 표준지가격의 조사·평가 또는 개별토지가격의 산정을 위하여 필요한 때에는 타인의 토지에 출입할 수 있다.(법 제13조 제1항)

02 출입절차 및 제한 등

- ① 시장·군수 또는 구청장의 허가(부동산가격공시업무를 의뢰받은 자에 한정한다)를 받아 출입할 날의 3일 전에 그 점유자에게 일시와 장소를 통지하여야 한다. 다만, 점유자를 알 수 없거나 부득이한 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.(부동산공시법 제13조 제2항)
- ② 일출 전·일몰 후에는 그 토지의 점유자의 승인 없이 택지 또는 담장이나 울타리로 둘러싸인 타인의 토지에 출입할 수 없다.(동조 제3항)
- ③ 출입을 하고자 하는 자는 그 권한을 표시하는 증표와 허가증을 지니고 이를 관계인에게 내보여야 한다.(동조 제4항)

03 토지보상법상 타인토지출입과의 비교**CASE**

토지보상법상 타인토지출입과 부동산공시법상 타인토지출입을 비교하시오.

1) 공통점**(1) 법적성질**

- ① 타인토지의 출입행위는 행정작용을 적정하게 실행하기 위해 필요한 자료 및 정보 등을 수집하기 위한 권력적 사실행위로서 행정조사가 할 것이다.
- ② 또한 사업의 준비 성격측면에서, 타인토지출입을 공용제한으로 이해하는 견해와 공용사용으로 이해하는 견해로 나누어지고 있다.

(2) 출입 제한 및 증표 등 제시

일출 전·일몰 후에는 그 토지의 점유자의 승인없이 택지 또는 담장이나 울타리로 둘러싸인 타인의 토지에 출입할 수 없고, 출입을 하고자 하는 자는 그 권한을 표시하는 증표와 허가증을 지니고 이를 관계인에게 내보여야 한다.

2) 차이점**(1) 입법취지**

- ① 토지보상법상 타인토지 출입은 공익 목적의 공익사업의 준비를 위함이며,
- ② 부동산공시법상 타인토지출입은 공시지가의 조사·평가를 위한 목적에 있다.

(2) 보상규정

- ① 토지보상법상 타인토지출입으로 인한 손실에 대하여는 보상규정을 두고 있으나,
- ② 부동산공시법은 보상규정이 없어 논란이 있다.

(3) 토지점유자의 인용의무

- ① 토지보상법은 인용의무를 규정하고, 위반시 벌칙규정을 두고 있다.
- ② 부동산공시법은 인용의무에 대한 규정이 없다. 부동산공시법상 타인토지출입은 토지보상법과 같은 장해물제거행위 등의 행위가 필요 없으므로, 토지점유자로서는 출입자의 행위를 방해할 이유가 없기 때문에 규정을 두지 않은 것으로 해석된다.

(4) 부동산공시법상 타인토지 출입시 손실보상 가능여부

a. 문제점

타인토지출입으로 특별한 희생이 발생한 경우 손실보상이 이루어져야 하나, 보상규정이 없어 손실보상이 가능한지 문제된다.

b. 보상규정 흡결시 보상청구 가능성

(손실보상 파트 참조 요망)

01 의의 및 취지

- ① 주택가격공시제도는 과세 등 공공 또는 행정목적을 위하여 국토교통부장관이 주택가격을 조사·평가하여 공시하는 제도를 말한다.
- ② 주택가격공시제도는 부동산시장의 안정과 투명성 확보, 그리고 부동산 보유 세제의 형평성 제고를 위해 도입된 제도이다.

02 표준주택가격 공시제도**1) 의의**

표준주택가격이란 국토교통부장관이 용도지역, 건물구조 등이 일반적으로 유사하다고 인정되는 일단의 단독주택 중에서 선정한 표준주택에 대한 매년 공시기준일 현재의 적정가격을 말한다.(법 제16조 제1항)

2) 법적성질

- ① 표준주택가격은 국가, 지방자치단체 등이 그 업무와 관련하여 개별주택가격을 산정하는 경우에 그 기준이 된다.
- ② 그 법적성질은 표준지공시지가와 유사하게 국민의 권리의무에 직접 영향이 있다고 볼 수 있어 처분으로 봄이 타당하다.

3) 공시절차

- ① 국토교통부장관은 일단의 단독주택 중에서 일단의 주택을 대표할 수 있는 표준주택을 선정하여야 하고, 한국부동산원에게 의뢰를 한다.
- ② 의뢰를 받은 한국부동산원은 공시기준일 현재의 적정가격을 조사*산정하고, 중앙부동산가격공시위원회의 심의를 거쳐 표준주택가격을 공시한다.
- ③ 표준주택가격을 공시할 때는 지번, 가격, 대지면적 및 형상, 용도, 연면적, 구조, 사용승인일(임시사용승인일을 포함한다), 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 공시하여야 한다.

4) 효력 및 불복

- ① 표준주택가격은 국가 등 기관이 그 업무와 관련하여 개별주택가격을 산정하는 경우 기준이 된다.(법 제19조 제1항)
- ② 불복은 표준지공시지가 이의신청을 준용하도록 규정하고 있다.(법 제16조 제7항)
- ③ 표준주택가격의 처분성을 인정하면 항고소송을 제기할 수 있다.

03 개별주택가격 공시제도

1) 의의 (법 제17조 제1항)

개별주택가격이란 시장·군수·구청장이 시·군·구 부동산가격공시위원회의 심의를 거쳐 결정·공시한 매년 공시기준일 현재의 가격을 말한다.

2) 법적성질

- ① 개별주택가격은 개별공시지가와 같이 과세의 기준이 된다는 점에서 개별공시지가의 법적성질과 동일하다고 볼 수 있다.
- ② 따라서 국민의 권리, 의무에 직접 영향을 미치는 <처분>에 해당한다.

3) 공시절차

- ① 시장·군수·구청장은 주택가격비준표를 사용하여 가격을 산정하되,
- ② 표준주택가격과의 균형 등 그 타당성에 대하여 한국부동산원의 검증을 받고,
- ③ 토지소유자, 그 밖의 이해관계인의 의견을 들은 후 시·군·구부동산가격공시위원회의 심의를 거쳐 매년 표준주택가격의 공시기준일 현재 관할 구역 안의 개별주택가격을 결정·공시하고, 이를 관계 행정기관 등에 제공한다.

4) 개별주택가격을 공시하지 아니하는 단독주택

- ① 표준주택으로 선정된 단독주택,
- ② 국세 또는 지방세의 부과대상이 아닌 단독주택,
- ③ 그 밖에 국토교통부장관이 정하는 단독주택은 개별주택가격을 결정, 공시하지 아니할 수 있다.

5) 효력 및 불복

- ① 개별주택가격은 주택시장의 가격정보를 제공하고, 국가 등의 기관이 과세 등 업무와 관련하여 주택가격을 산정하는 경우 기준으로 활용될 수 있다.(법 제19조 제2항)
- ② 불복은 개별공시지가 이의신청을 준용(법 제17조 제8항)하고, 개별주택가격의 처분성을 인정하는 한 항고소송을 제기할 수 있다.

04 공동주택가격 공시제도

1) 의의 (법 제18조 제1항)

공동주택가격이란 국토교통부장관이 조사·산정하여 중앙부동산가격공시위원회의 심의를 거쳐 공시한 공동주택에 대한 매년 공시기준일 현재의 적정가격을 말한다.

2) 법적성질

- ① 개별공시지가 및 개별주택가격과 같이 과세의 기준이 된다는 점에서 법적성질이 동일하다고 볼 수 있다.
- ② 따라서 공동주택가격은 국민의 권리·의무에 직접 영향이 있다고 보여지므로 처분이라 봄이 타당하다.

3) 공시절차

- ① 국토교통부장관은 공동주택에 대해 매년 공시기준일 현재 적정가격을 조사·산정한다. 이를 위해 한국부동산원에게 의뢰한다.
- ② 조사·산정시 공동주택소유자와 그 밖의 이해관계인의 의견을 들은 후 중앙부동산가격공시위원회의 심의를 거쳐 공시한다.

4) 효력 및 불복

- ① 공동주택가격은 주택시장의 가격정보를 제공하고, 국가 등 기관이 과세 등 업무와 관련하여 주택가격을 산정하는 경우 기준으로 활용될 수 있다.(법 제19조 제2항)
- ② 불복은 표준지공시지가의 이의신청을 준용하고(법 제18조 제8항), 처분으로 보는 한 항고소송을 제기할 수 있다.

05 비주거용 표준부동산 가격공시제도 (시행중X)

1) 의의 (법 제20조 제1항)

비주거용 표준부동산가격이란 국토교통부장관이 용도지역, 건물구조 등이 일반적으로 유사하다고 인정되는 일단의 비주거용 일반부동산 중에서 선정한 비주거용 표준부동산에 대하여 조사·산정한 매년 공시기준일 현재의 적정가격을 말한다.

2) 법적성질

- ① 비주거용 표준부동산가격은 국가, 지방자치단체 등이 그 업무와 관련하여 비주거용 개별부동산가격을 산정하는 경우에 그 기준이 된다.
- ② 그 법적성질은 개별공시지가와 유사하게 국민의 권리의무에 직접 영향이 있다고 볼 수 있어 처분으로 봄이 타당하다.

3) 공시절차

- ① 국토교통부장관은 일단의 비주거용 부동산 중에서 대표할 수 있는 비주거용 표준부동산을 선정하여야 하고, 감정평가법인등 또는 대통령령으로 정하는 부동산 가격의 조사·산정에 관한 전문성이 있는 자에게 의뢰한다.
- ② 의뢰받은 자는 공시기준일 현재의 적정가격을 조사·산정하고, 중앙부동산가격공시위원회의 심의를 거쳐 비주거용 표준부동산가격을 공시한다.

- ③ 비주거용 표준부동산가격을 공시할 때는 지번, 가격, 대지면적 및 형상, 용도, 연면적, 구조, 사용승인일 (임시사용승인일을 포함한다), 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 공시하여야 한다.

4) 효력 및 불복

- ① 비주거용 표준부동산가격은 국가 등 기관이 그 업무와 관련하여 비주거용 개별부동산가격을 산정하는 경우 기준이 된다.(법 제23조 제1항)
- ② 불복은 표준지공시지가 이의신청을 준용하도록 규정하고 있다. 비주거용 표준부동산가격의 처분성을 인정하면 항고소송을 제기할 수 있다.

06 비주거용 개별부동산 가격공시제도 (시행중X)

1) 의의 (법 제21조 제1항)

비주거용 개별부동산가격이란 시장·군수·구청장이 시·군·구 부동산가격공시위원회의 심의를 거쳐 결정·공시한 관할 구역 안의 비주거용 개별부동산에 대한 매년 공시기준일 현재의 가격을 말한다.

2) 법적성질

- ① 비주거용 개별부동산가격은 개별공시지가와 같이 과세의 기준이 된다는 점에서 개별공시지가의 법적성질과 동일하다고 볼 수 있다.
- ② 따라서 국민의 권리, 의무에 직접 영향을 미치는 처분에 해당한다.

3) 공시절차

- ① 시장·군수·구청장은 비주거용 표준부동산가격과의 균형 등 그 타당성에 대하여 비주거용 표준부동산가격의 조사·산정을 의뢰받은 자 등 대통령령으로 정하는 자의 검증을 받고,
- ② 비주거용 일반부동산의 소유자와 그 밖의 이해관계인의 의견을 들은 후 시·군·구 부동산가격공시위원회의 심의를 거쳐 매년 공시기준일 현재 관할 구역 안의 비주거용 개별부동산가격을 결정·공시한다.

4) 효력 및 불복

- ① 비주거용 개별부동산가격은 비주거용 부동산시장의 가격정보를 제공하고, 국가 등의 기관이 과세 등 업무와 관련하여 비주거용 부동산의 가격을 산정하는 경우 기준으로 활용될 수 있다.(법 제23조 제2항)
- ② 불복은 개별공시지가 이의신청을 준용(법 제21조 제8항)하고, 비주거용 개별부동산가격의 처분성을 인정하는 한 항고소송을 제기할 수 있다.

07 비주거용 집합부동산 가격공시제도 (시행중X)

1) 의의

비주거용 집합부동산가격이란 국토교통부장관이 조사·산정하여 중앙부동산가격공시위원회의 심의를 거쳐 공시한 비주거용 집합부동산가격에 대한 매년 공시기준일 현재의 적정가격을 말한다.(법 제22조 제1항)

2) 법적성질

- ① 개별공시지가 및 개별주택가격과 같이 과세의 기준이 된다는 점에서 법적성질이 동일하다고 볼 수 있다.
- ② 따라서 비주거용 집합부동산가격은 국민의 권리·의무에 직접 영향이 있다고 보여지므로 처분이라 봄이 타당하다.

3) 공시절차

- ① 국토교통부장관은 비주거용 집합부동산가격에 대하여 매년 공시기준일 현재 적정가격을 조사·산정한다.
- ② 이를 위해 부동산원 또는 대통령령으로 정하는 부동산 가격의 조사·산정에 관한 전문성이 있는 자에게 의뢰한다.
- ③ 비주거용 집합부동산 소유자와 그 밖의 이해관계인의 의견을 들은 후 중앙부동산가격공시위원회의 심의를 거쳐 공시한다.

4) 효력 및 불복

- ① 비주거용 집합부동산가격은 비주거용 부동산시장의 가격정보를 제공하고, 국가 등 기관이 과세 등 업무와 관련하여 비주거용 부동산가격을 산정하는 경우 기준으로 활용될 수 있다.(법 제23조 제2항)
- ② 불복은 표준지공시지가의 이의신청을 준용하고(법 제22조 제9항), 처분으로 보는 한 항고소송을 제기할 수 있다.

08 결론

- ① 토지와 주택에 대한 세 부담의 형평성 문제를 해결하고, 부동산가격의 평가체계를 일원화하기 위한 제도로써 주택가격공시제도는 의의가 있다.
- ② 이 취지를 살리기 위하여 지속적인 법제도의 정비가 이루어져야 할 것이다. 최근에는 비주거용 가격공시제도가 시행될 예정이어서 제도적 정비에 만전을 기해야 할 것이다.

제1절

감정평가사의 법적지위

CASE

감정평가사의 의무와 책임을 설명하여라. [2회 문2]

01 개설

- ① 감정평가사는 타인의 의뢰를 받아 토지 등을 감정평가하는 것을 그 직무로 한다(감정평가법 4조 제1항).
- ② 감정평가는 사회성·공공성이 크므로 감정평가법은 일정한 자격과 요건을 갖춘 감정평가법인등만이 감정평가를 할 수 있도록 하고, 이에 수반되는 권리·의무·책임을 규정하고 있다.

02 권리 및 의무

1) 권리

감정평가사는 일정한 요건을 갖추어 등록(감정평가법 제17조)을 하고, 사무소 개설(동법 제21조)을 하거나 감정평가법인 설립인가(동법 제29조)를 받거나 그에 소속되어 감정평가할 권리를 가진다. 그 외에도 명칭사용권(동법 제22조), 보수청구권(동법 제23조), 이의신청권(동법 제42조), 청문권(동법 제45조) 등의 권리를 가진다.

2) 의무

등록 및 갱신등록 의무(감정평가법 제17조), 성실의무 등(동법 제25조), 비밀엄수의무(동법 제26조), 명의대여 등의 금지의무(동법 제27조), 감정평가서 교부 및 보존의무(동법 제6조) 등이 있다.

대법원 2021. 10. 28. 선고 2020두41689 [법인에게 적용되는 성실의무의 내용]

감정평가법인인 경우에 실질적인 감정평가업무는 소속감정평가사에 의하여 이루어질 수밖에 없으므로, 감정평가법인이 감정평가의 주체로서 부담하는 성실의무란, 소속감정평가사에 대한 관리·감독의무를 포함하여 감정평가서 심사 등을 통해 감정평가 과정을 면밀히 살펴 공정한 감정평가결과가 도출될 수 있도록 노력할 의무를 의미한다고 판시했다.

대법원 2013. 10. 24. 선고 2013두727 [자격증 등을 부당하게 행사한다는 것의 의미]

자격증 등을 부당하게 행사한다는 것은 감정평가사 자격증 등을 본래의 용도 외에 부당하게 행사하는 것을 의미하고, 감정평가사가 감정평가법인에 적을 두기는 하였으나 당해 법인의 업무를 수행하거나 운영 등에 관여할 의사가 없고 실제로도 업무 등을 전혀 수행하지 않았거나 당해 소속 감정평가사로서 업무를 실질적으로 수행한 것으로 평가하기 어려울 정도라면 자격증 등의 부당행사에 해당한다고 판시했다.

※ 보충자료 - 감정평가법 제25조의 성실의무

1. 품위유지 및 신의성실의무

감정평가법인등은 제10조에 따른 업무를 하는 경우 품위를 유지하여야 하고, 신의와 성실로써 공정하게 감정평가를 하여야 하며, 고의 또는 중대한 과실로 잘못된 평가를 하여서는 아니 된다.

2. 불공정한 감정평가 금지

감정평가법인등은 자기 또는 친족 소유, 그 밖에 불공정한 감정평가를 할 우려가 있다고 인정되는 토지 등에 대해서는 이를 감정평가하여서는 아니 된다.

3. 토지등의 매매업 금지

감정평가법인등은 토지등의 매매업을 직접 하여서는 아니 된다.

4. 금품수수 금지

감정평가법인등이나 그 사무직원은 제23조에 따른 수수료와 실비 외에는 어떠한 명목으로도 그 업무와 관련된 대가를 받아서는 아니 되며, 감정평가 수주의 대가로 금품 또는 재산상의 이익을 제공하거나 제공하기로 약속하여서는 아니 된다.

5. 중복소속 금지

감정평가사는 둘 이상의 감정평가법인 또는 감정평가사사무소에 소속될 수 없으며, 소속된 감정평가법인 이외의 다른 감정평가법인의 주식을 소유할 수 없다.

6. 감정평가 유도, 요구에 따른 평가 금지

감정평가법인등이나 사무직원은 특정한 금액으로 감정평가를 유도 또는 요구하는 경우, 이에 따라서는 아니된다.

3) 책임

(1) 행정상 책임

① 자격의 취소 (감정평가법 제13조 제1항)

국토교통부장관은 감정평가사가 부정한 방법으로 감정평가사의 자격을 받은 경우 및 자격의 취소징계를 받은 경우에는 그 자격을 취소하여야 한다.

② 징계 (동법 제39조)

국토교통부장관은 감정평가사가 감정평가법에 따른 징계사유가 발생했을 때 자격의 취소, 등록의 취소, 2년 이하의 업무정지, 견책의 징계를 할 수 있다.

③ 과태료 (동법 제52조)

국토교통부장관은 감정평가법에 따른 과태료 부과 사유가 발생했을 때, 500만원 이하의 과태료를 부과한다.

(2) 형사상 책임

① 행정형벌 (동법 제49조 및 50조)

감정평가법상 위반 사유가 발생하면 동법 제49조 및 제50조에 따라 징역 또는 벌금에 처하게 된다.

② 공무원 의제처벌(동법 제48조)

표준지의 적정가격의 조사·평가 업무 등을 수행하는 감정평가사(제1호), 감정평가관리·징계위원회의 위원 중 공무원이 아닌 위원(제2호), 위탁업무에 종사하는 협회의 임직원(제3호)에 해당하는 사람은 「형법」 제129조부터 제132조까지의 규정을 적용할 때에는 공무원으로 본다.

(3) 민사상 책임 (손해배상책임)

감정평가법인등이 감정평가를 하면서 고의 또는 과실로 감정평가 당시의 적정가격과 현저한 차이가 있게 감정평가를 하거나 감정평가 서류에 거짓을 기록함으로써 감정평가 의뢰인이나 선의의 제3자에게 손해를 발생하게 하였을 때에는 감정평가법인등은 그 손해를 배상할 책임이 있다.

※ 보충자료 - 감정평가의 법률관계

감정평가의 사회성, 공공성에 비추어 공법적 성질도 내포하고 있으나, 감정평가 의뢰는 당사자가 상호 대등한 지위에서 이루어지는 것으로 사법상 관계의 성질을 가진다. 사법상 관계로 보는 경우 일정한 사무처리를 위한 통일적 노무의 제공을 목적으로 하는 위임계약에 해당한다. 다만, 공적 업무를 위탁받은 경우는 공법상 관계가 된다.

03 감정평가법 제28조와 민법 제750조의 관계(제28조의 법적 성질)

1) 문제점

감정평가법 제28조의 규정이 민법 제750조의 손해배상책임을 배제하는 **특칙**인지가 문제된다.

[감정평가법] 제28조 (손해배상책임)

- ① 감정평가법인등이 감정평가를 하면서 고의 또는 과실로 감정평가 당시의 적정가격과 현저한 차이가 있게 감정평가를 하거나 감정평가 서류에 거짓을 기록함으로써 감정평가 의뢰인이나 선의의 제3자에게 손해를 발생하게 하였을 때에는 감정평가법인등은 그 손해를 배상할 책임이 있다.
- ② 감정평가법인등은 제1항에 따른 손해배상책임을 보장하기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 보험에 가입하거나 제33조에 따른 한국감정평가사협회가 운영하는 공제사업에 가입하는 등 필요한 조치를 하여야 한다.

[민법] 제750조 (불법행위의 내용)

고의 또는 과실로 인한 위법행위로 타인에게 손해를 가한 자는 그 손해를 배상할 책임이 있다.

2) 학설

(1) 특칙이라는 견해 (면책설)

- ① 감정평가수수료에 비해 손해배상책임이 지나치게 크므로 손해배상의 범위를 한정할 필요가 있다는 점,
- ② 부동산은 그 특성상 적정가격을 파악하는 것은 매우 어렵기 때문에 감정평가법인등을 보호할 필요가 있다는 점을 볼 때 민법상 손해배상책임은 배제된다고 본다.

(2) 특칙이 아니라는 견해 (보험관계설)

감정평가법 제28조 제1항의 손해배상규정은 제2항의 손해배상보장규정인 보험이나 공제사업과 관련하여 규정된 것으로 보험금이나 공제금의 지급대상이 되는 손해배상책임의 범위를 한정한 것일 뿐이고 민법상 손해배상책임은 배제되지 않는다고 본다.

3) 판례

판례는 감정평가법인등의 부실감정으로 인하여 손해를 입게 된 감정평가의뢰인이나 선의의 제3자는 감정평가법상 손해배상책임과 민법상의 불법행위로 인한 손해배상책임을 **함께 물을 수 있다**고 판시한 바 있다.

(대법원 97다36293)

4) 검토

감정평가에 의한 적정가격의 산정이 어려움에도 손해배상책임을 널리 인정하면 평가제도가 위태로울 수 있으므로 <특칙>으로 봄이 합당하다.

04 손해배상책임의 요건

CASE

감정평가 및 감정평가사에 관한 법률상 감정평가법인등의 손해배상책임의 성립요건에 관하여 설명하시오. [33회 문4]

1) 감정평가를 하면서

- ① 감정평가는 가치판단작용을 말하며, 단순한 사실조사의 잘못은 그 배상책임이 없다.
- ② 다만, 판례는 임대차 사실관계 조사상 과실을 이유로 배상책임을 인정한바 있다.(2003다24840)

2) 고의 또는 과실이 있을 것

- ① 고의란 부당한 감정평가로 인한 손해의 발생을 인식하는 것을 말하고,
- ② 과실이란 손해의 발생을 부주의로 인식하지 못하는 것을 말한다(주의의무위반).
- ③ 판례는 감정평가규칙의 기준을 무시하고 자의적인 방법에 의해 토지를 감정평가한 것은 고의·중과실에 의한 부당한 감정평가로 볼 수 있다고 판시했다(96다52427).

3) 부당한 감정평가를 하였을 것

(1) 적정가격과 현저한 차이가 있을 것

판례는 현저한 차이를 인정함에 있어 1.3배가 유일한 판단기준이 될 수 없고, 부당감정에 이르게 된 감정평가 법인등의 귀책사유를 고려하여 사회통념에 따라 탄력적으로 판단해야 한다고 판시했다.(96다52427)

(2) 거짓의 기재

감정평가서에 물건의 내용, 산출근거, 가격에 변화를 일으키는 요인, 평가액 등을 사실과 다르게 거짓으로 기재하는 것을 말한다.

4) 의뢰인 또는 선의의 제3자에게 손해가 발생하였을 것

- ① 선의의 제3자란 감정내용이 허위 또는 적정가격과 현저한 차이가 있음을 인식하지 못한 것뿐만 아니라, 감정평가서를 감정의뢰 목적 이외에 사용하거나 감정의뢰인 이외의 타인이 사용할 수 없음이 명시되어 있는 경우 그 사용사실까지 인식하지 못한 제3자를 의미한다(대법원 99다28661).
- ② 손해란 재산권적 법익에 대한 불이익을 말한다.

5) 상당 인과관계가 있을 것

- ① 부당한 감정평가와 손해발생 사이에 상당인과관계가 있어야 한다.
- ② 인과관계란 특정 행위가 없었다면 그 결과가 발생하지 않았다고 볼 수 있는 관계를 말하며 가해행위의 태양, 침해의 정도 등 제반 사정을 종합하여 판단한다.

6) 위법성 요건이 필요한지 여부

- ① 감정평가법 제28조 제1항의 손해배상책임의 요건에 위법성이 명시되어 있지 않아 위법성 요건이 별도로 필요한지가 문제된다.
- ② 이에 대해서는 (a) 별도로 필요하다는 견해, (b) 고의·과실 속에 포함되어 있다는 견해, (c) 부당한 감정평가의 개념에 속에 포함되어 있다는 견해 등이 있다.
- ③ 생각건대, 감정평가법 제28조는 민법 제750조의 특칙으로 봄이 타당하다는 점에서 명시적 규정이 없는 위법성의 요건은 별도로 필요하지 않고, 부당한 감정평가의 개념 속에 위법성 요건이 포함되어 있는 것으로 보는 것이 타당하다.

05 손해배상책임의 내용

1) 손해배상의 범위

손해배상의 범위는 위법행위가 없었더라면 존재하였을 재산 상태와 위법행위가 가해진 현재의 재산 상태의 차이를 말한다.

대법원 1998. 9. 22. 선고 97다36293

불법행위로 인한 재산상 손해는 위법한 가해행위로 인하여 발생한 재산상 불이익, 즉 위법행위가 없었더라면 존재하였을 재산 상태와 위법행위가 가해진 현재의 재산 상태와의 차이이므로, 낙찰자가 감정평가업자의 불법행위로 인하여 입은 손해도 감정평가업자의 위법한 감정이 없었더라면 존재하였을 재산 상태와 위법한 감정으로 인한 재산 상태와의 차이가 된다.

2) 손해배상책임의 보장 (동법 제28조 제2항)

감정평가법인등은 손해배상책임을 보장하기 위해 보험에 가입하거나 감정평가사협회가 운영하는 공제사업에 가입하는 등 필요한 조치를 해야 한다.

01 자격등록의 의의 및 취지 (감정평가법 제17조)

- ① 자격등록이란 감정평가사 자격이 있는 자가 업무를 하기 위해 국토교통부장관에게 등록신청을 하고, 국토교통부장관이 이를 유효한 것으로 받아들이는 것을 말한다.
- ② 이는 감정평가사의 효율적 관리 및 감정평가사 자격에 대한 신뢰성 제고에 취지가 있다.

02 법적 성질

1) 등록신청

등록신청은 사인인 감정평가사가 행정청인 국토교통부장관에게 감정평가업을 영위하겠다는 등록을 신청하는 것이므로 사인의 공법행위로서 수리를 요하는 신고에 해당한다.

2) 자격등록의 법적 성질

(1) 강학상 수리 여부

- ① 강학상 허가로 보는 견해와 강학상 수리로 보는 견해가 있다.
- ② 허가는 실질적 심사를 하는 것이 원칙이나, 수리는 형식적 심사를 하되 필요 시에는 실질적 심사까지 할 수 있고, 신고요건이 허가요건보다 완화되어 있다는 점에서 양자가 구별된다.
- ③ 생각건대, 국토교통부장관은 감정평가사 자격등록 신청에 대하여 감정평가법 제18조 제1항에서 정한 등록거부사유가 없는 이상 등록을 해야 하고, 법규정 외의 사유를 들어 등록을 거부할 수 없으므로, 허가보다는 완화된 요건으로 보아 강학상 수리로 봄이 타당하다.

(2) 기속행위

- ① 강학상 수리는 법이 정한 특별한 사정이 없는 한 소정의 요건을 갖춘 신고는 반드시 수리하여야 하므로 **기속행위**의 성질을 가진다.
- ② 따라서 국토교통부장관은 등록거부사유가 없는 것으로 확인되면 등록신청을 수리해야 한다.
(강학상 수리 → 기속행위)

03 등록거부사유 (동법 제18조 제1항)**[감정평가법] 제18조 (등록 및 갱신등록의 거부)**

- ① 국토교통부장관은 제17조에 따른 등록 또는 갱신등록을 신청한 사람이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 등록을 거부하여야 한다.
 - 1. 제12조 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우
 - 2. 제17조제1항에 따른 실무수습 또는 교육연수를 받지 아니한 경우
 - 3. 제39조에 따라 등록이 취소된 후 3년이 지나지 아니한 경우
 - 4. 제39조에 따라 업무가 정지된 감정평가사로서 그 업무정지 기간이 지나지 아니한 경우
 - 5. 미성년자 또는 피성년후견인 · 피한정후견인

04 등록의 효과 및 등록증 발급

- ① 국토교통부장관이 등록을 하면 신청인은 감정평가업무를 수행할 수 있는 지위를 얻게 된다.
- ② 등록증 발급은 신청인이 감정평가업무를 수행할 수 있는 자임을 공적으로 증명하는 공증에 해당한다.

05 등록거부에 대한 권리구제

1) 국토교통부장관의 거부 등

- ① 국토교통부장관은 등록거부사유에 해당하는 경우 등록 또는 갱신등록을 거부하여야 한다.
- ② 위 사유를 확인하기 위하여 관계 기관에 관련 자료를 요청할 수 있으며, 이 경우 관계 기관은 특별한 사정이 없으면 그 자료를 제공하여야 한다.

2) 등록거부에 대한 권리구제

- ① 자격등록거부는 행정쟁송법상 처분에 해당한다. 따라서 행정쟁송을 통하여 권리구제를 도모할 수 있다.
- ② 또한 위법한 등록거부로 인하여 손해가 발생한 경우에는 국가배상을 청구할 수도 있을 것이다.

06 갱신등록과 관련한 논의

- ① 갱신등록은 등록에 기한이 있을 때, 종전 등록의 법적 효과를 유지시키는 행정청의 행위이다.
- ② 감정평가법상 갱신등록은 5년마다 행하는데, 주기적으로 검증된 감정평가사로 하여금 감정평가업무를 수행하게 하여 감정평가의 신뢰를 제고할 목적으로 도입되었다.
- ③ 다만, 갱신등록을 거부할 때, 취소소송을 제기하면서 집행정지가 가능할 것인지, 사전통지를 해야 하는 것인지 등의 관련 논점이 있다.

I

사무소 개설

CASE

감정평가 및 감정평가사에 관한 법률 제21조에 따른 ‘사무소 개설 등’에 관하여 설명하십시오. [34회 문4]

01 의의 (감정평가법 제21조 제1항)

사무소 개설이란 감정평가법 제17조에 따라 등록을 한 감정평가사가 감정평가업을 하려는 경우 사무소를 개설하는 것을 말한다.

02 사무소 개설이 금지된 자 (동법 제21조 제2항)

다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 제1항에 따른 개설을 할 수 없다.

- ① 제18조 제1항(등록거부사유) 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람
- ② 제32조 제1항(제1호, 제7호 및 제15호는 제외한다)에 따라 설립인가가 취소되거나 업무가 정지된 감정평가법인의 설립인가가 취소된 후 1년이 지나지 아니하였거나 업무정지 기간이 지나지 아니한 경우 그 감정평가법인의 사원 또는 이사였던 사람

1호 : 감정평가법인이 설립인가의 취소를 신청한 경우

7호 : 감정평가법인등이 제21조제3항이나 제29조제4항에 따른 감정평가사의 수에 미달한 날부터 3개월 이내에 감정평가사를 보충하지 아니한 경우

15호 : 제31조제2항에 따라 기간 내에 미달한 금액을 보전하거나 증자하지 아니한 경우

- ③ 제32조제1항(제1호 및 제7호는 제외한다)에 따라 업무가 정지된 감정평가사로서 업무정지 기간이 지나지 아니한 사람

03 합동사무소의 개설

- ① 감정평가사는 그 업무를 효율적으로 수행하고 공신력을 높이기 위하여 합동사무소를 설치할 수 있다.
- ② 이 경우 합동사무소는 대통령령으로 정하는 수(2명) 이상의 감정평가사를 두어야 한다.(제21조 제3항)

04 복수개설 금지

감정평가사는 감정평가업을 하기 위하여 1개의 사무소만을 설치할 수 있다.(제21조 제4항)

05 소속 감정평가사

- ① 감정평가사사무소에는 소속 감정평가사를 둘 수 있다.
- ② 이 경우 소속 감정평가사는 제18조 제1항 각 호(등록거부사유)의 어느 하나에 해당하는 사람이 아니어야 하며,
- ③ 감정평가사사무소를 개설한 감정평가사는 소속 감정평가사가 아닌 사람에게 제10조에 따른 업무를 하게 하여서는 아니 된다.

II 감정평가법인

CASE

A 등은 감정평가법인을 설립하여 국토교통부장관의 설립인가를 받았다. 설립인가 자체의 하자는 없지만, 감정평가법인의 사원에 관한 「감정평가및 감정평가사에 관한 법률」의 요건을 충족하지 못하여 설립행위에 문제가 있음을 확인한 경쟁업체의 감정평가사 甲은 소송을 통하여 이를 다투고자 한다. 이러한 감정평가법인의 설립행위와 인가행위의 관계를 설명하고, 甲은 어떠한 소송에서 어떠한 하자를 다툴 수 있는지 검토하시오. [36회 문4]

01 개설

- ① 감정평가사는 제10조에 따른 업무를 조직적으로 수행하기 위하여 감정평가법인을 설립할 수 있다 (감정평가법 제29조 제1항).
- ② 감정평가법인을 설립하려는 경우에는 사원이 될 사람 또는 감정평가사인 발기인이 공동으로 정관을 작성하여 국토교통부장관의 인가를 받아야 한다.

02 인가와 기본행위(설립행위)

1) 인가의 개념

인가란 행정청이 제3자의 법률행위를 동의로써 보충하여 그 행위의 효력을 완성시키는 행정행위를 말한다.

2) 인가와 기본행위(설립행위)의 관계

- ① 인가는 기본행위의 효력을 완성시키는 **보충적 행위**이므로 인가의 효력은 기본행위의 유무 및 하자에 의해 영향을 받는다.
- ② 따라서 기본행위가 소멸되면 인가는 별도의 무효선언이나 처분청의 직권취소 없이도 실효된다.
- ③ 다만, 기본행위에 취소원인이 있는 경우에는 기본행위가 취소되지 않은 한 인가의 효력에는 영향이 없다.

03 기본행위의 하자를 이유로 인가를 다툼 협의의 소익이 있는지

1) 문제점

기본행위에 하자가 있다면 인가행위를 다투기보다는 기본행위를 다투는 것이 보다 실효적인 권리구제수단으로 볼 수 있기 때문에, 기본행위의 하자를 이유로 인가를 다툼 협의의 소익이 있는지 문제된다.

2) 학설

- ① 동일사안을 이중으로 심리해야 하는 법원의 부담을 덜고, 기본행위에 대한 분쟁은 기본행위를 관할하는 법원으로 집중시키기 위해 부정하는 견해(다수설)
- ② 반면, 일회적 분쟁해결을 위해 협의의 소익을 인정해야 한다는 견해도 있다.

3) 판례

판례는 인가처분에 하자가 없다면 기본행위의 무효를 내세워 행정청의 인가처분의 취소 또는 무효확인을 구할 법률상 이익이 있다고 할 수 없다고 하여 소극적인 입장이다.(대법원 1994. 10. 14. 선고 93누22753 판결)

4) 검토

취소소송을 담당하는 법원이 인가처분취소소송에서 민사소송 등의 사항인 기본행위 하자를 심리하기는 어렵다고 보아야 하므로, 부정하는 견해가 타당하다.

04 인가행위에 하자가 있는 경우

기본행위가 적법 유효하고 보충행위인 인가행위 자체에만 하자가 있다면 그 인가처분의 무효나 취소를 주장할 수 있다. 인가처분이 무효이거나 취소된 경우에는 그 기본행위는 무인가행위가 된다.

Ⅲ 사무직원 고용 신고

01 사무직원 고용 신고

- ① 감정평가법인등은 그 직무의 수행을 보조하기 위하여 사무직원을 둘 수 있다(감정평가법 제24조 제1항).
- ② 감정평가법인등은 소속 감정평가사 또는 사무직원을 고용하거나 고용관계가 종료된 때에는 국토교통부장관에게 신고하여야 한다(동법 제21조의2).

02 고용 신고의 법적 성질

국토교통부장관은 신고서를 제출받은 경우 동법 제24조 제3항에 따라 사무직원이 결격사유에 해당하는지 여부를 확인해야 하므로 수리를 요하는 신고에 해당한다.

01 징계

1) 의의, 취지, 법적 성질

- ① 감정평가사가 감정평가법 제39조의 사유에 해당하는 경우 국토교통부장관이 감정평가관리·징계위원회의 의결에 따라 해당 감정평가사를 제재하는 것을 말한다.
- ② 이는 감정평가사의 관리, 감독에 취지가 있다.
- ③ 징계는 감정평가사의 권익을 제한하는 침익적 처분이다.

2) 종류

- ① 자격의 취소, ② 등록의 취소, ③ 2년 이하의 업무정지, ④ 견책이 있다.

02 감정평가관리·징계위원회

1) 감정평가관리·징계위원회 도입배경 및 취지

감정평가관리·징계위원회는 기존에 감정평가사협회에서 운영하였으나, 감정평가사에 대한 징계의 공정성을 확보하고 감정평가사 적격성 기준이 강화됨에 따라 엄정한 절차에 따라 징계가 이루어지도록 하기 위해 징계위원회를 감정평가법에 직접 규정하기에 이르렀고 징계의 내용도 한층 강화되었다.

2) 감정평가관리·징계위원회의 법적 성격

- ① 감정평가관리·징계위원회는 다수의 위원으로 구성되어서 감정평가사의 징계에 관한 사항을 의결하는 <합의제 행정기관>이다.
- ② 징계위원회는 감정평가사를 징계하기 위해 반드시 설치해야 하는 <필수기관>이다.
- ③ 징계권자는 국토교통부장관이지만 징계내용에 관한 의결은 위원회에 맡겨져 있다. 따라서 위원회는 의결권을 가진 <의결기관>에 해당한다.

3) 구성

- ① 징계위원회는 위원장 1명 및 부위원장 1명을 포함한 13명의 위원으로 구성되며, 성별을 고려하여야 한다. (시행령 제37조 제1항)
- ② 위원장은 국토교통부장관이 위촉하거나 지명한다.

4) 위원의 임기 및 제척, 기피

- ① 위원의 임기는 2년으로 하되 한 차례만 연임할 수 있다.(시행령 제37조 제4항)
- ② 감정평가관리·징계위원회 위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 위원회의 심의·의결에서 제척된다(시행령 제38조 제1항).

- ① 위원 또는 그 배우자나 배우자였던 사람이 해당 안건의 당사자가 되거나 그 안건의 당사자와 공동권리자 또는 공동의무자인 경우
- ② 위원이 해당 안건의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우
- ③ 위원이 해당 안건에 대하여 증언, 진술, 자문, 연구, 용역 또는 감정을 한 경우
- ④ 위원이나 위원이 속한 법인·단체 등이 해당 안건의 당사자의 대리인이거나 대리인이었던 경우
- ⑤ 위원이 해당 안건의 당사자와 같은 감정평가법인 또는 감정평가사사무소에 소속된 경우

③ 위원이 상기 제척 사유에 해당하는 경우에는 스스로 해당 안건의 심의·의결에서 회피하여야 한다.
(시행령 제38조 제3항)

03 징계의 절차

CASE

甲은 감정평가사 자격을 취득한 후, 2015. 9. 2.부터 2017. 8. 3.까지 '乙감정평가법인'의 소속 감정평가사였다. 또한 甲은 2015. 7. 7.부터 2017. 4. 30.까지 '수협'에서 상근계약직으로 근무하였다. 관할 행정청인 국토교통부장관 A는 甲이 위와 같이 수협에 근무하면서 일정기간 동안 동시에 乙감정평가법인에 등록하여 소속을 유지하는 방법으로 감정평가사 자격증을 대여하거나 부당하게 행사했다고 봄이 상당하여, [감정평가법] 제27조가 규정하는 명의대여 등의 금지 또는 자격증 부당행사 금지에 위반하였다는 것을 이유로 징계처분을 내리고자 한다. 국토교통부장관 A가 甲에 대하여 위와 같은 사유로 감정평가법령상의 징계를 하고자 하는 경우, 징계절차에 관하여 설명하시오. [29회 문2]

징계의결 요구 ➡ 징계위원회 의결 ➡ 국토교통부장관의 징계 처분 ➡ 징계사실을 당사자와 협회에 통보
➡ 징계의 공고

1) 징계의결 요구

- ① 국토교통부장관은 감정평가사에게 징계사유가 있다고 인정되면, 그 증명서류를 갖추어 감정평가관리·징계 위원회에 징계의결을 요구해야 한다.(동법 시행령 제34조 제1항)
- ② 감정평가사협회는 감정평가사에게 징계사유가 있다고 인정하는 경우, 그 증거서류를 첨부하여 국토교통부장관에게 징계를 요청할 수 있다.(제39조 제3항).
- ③ 징계의결의 요구는 위반사유가 발생한 날부터 5년이 지나면 할 수 없다.(제39조 제7항)

2) 의결

- ① 감정평가관리·징계위원회는 징계의결의 요구를 받으면 지체 없이 징계요구 내용과 징계심의기일을 해당 감정평가사에게 통지해야 한다.(동법 시행령 제34조 제2항)
- ② 징계위원회는 징계의결의 요구를 받은 날부터 60일 이내 징계에 관한 의결을 하여야 한다. 다만, 부득이한 사유가 있는 때에는 위원회의 의결로 30일의 범위에서 그 기간을 한 차례만 연장할 수 있다.(동법 시행령 제35조)
- ③ 당사자는 징계위원회에 출석하여 구술 또는 서면으로 자기에게 유리한 사실을 진술하거나 필요한 증거를 제출할 수 있다.(동법 시행령 제41조)
- ④ 감정평가관리·징계위원회의 회의는 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.(동법 시행령 제42조)

3) 징계

국토교통부장관은 감정평가관리·징계위원회의 의결에 따라 징계처분을 한다.

4) 징계사실의 통보

국토교통부장관은 위원회의 의결에 따라 징계를 한 때에는 지체 없이 그 구체적인 사유를 해당 감정평가사, 감정평가법인등 및 협회에 징계의 종류와 사유를 명확히 기재하여 서면으로 알려야 한다(동법 시행령 제36조).

5) 징계의 공고

(1) 공고의 방법

- ① 국토교통부장관은 감정평가사에 대한 징계를 한 때에는 지체 없이 그 구체적인 사유를 해당 감정평가사, 감정평가법인등 및 협회에 각각 알리고, 그 내용을 대통령령으로 정하는 바에 따라 관보 또는 인터넷 홈페이지 등에 게시 또는 공고하여야 한다.(제39조의2 제1항)
- ② 협회는 통보받은 내용을 협회가 운영하는 인터넷홈페이지에 3개월 이상 게재하는 방법으로 공개하여야 한다.(제39조의2 제2항)

(2) 공고의 내용 및 기간

- ① 공고의 내용에는 징계처분을 받은 감정평가사의 이름, 징계처분의 내용, 징계사유 및 징계처분의 효력발생일 등이 포함된다.
- ② 협회가 징계정보를 인터넷 홈페이지에 게재하는 기간은, 자격의 취소, 등록의 취소는 3년, 업무정지는 해당 업무정지기간(3개월 미만은 3개월), 견책은 3개월이며, 징계 정보의 범위는 신청일을 기준으로 자격의 취소, 등록의 취소는 과거 10년, 업무정지는 5년, 견책은 1년이다(동법 시행령 제36조 및 제36조의3).

04 징계의결의 하자

1) 의결에 반하는 처분

징계위원회는 의결기관이므로 징계위원회의 의결은 국토교통부장관을 구속한다. 따라서 징계위원회의 의결에 반하는 처분은 무효이다.

2) 의결을 거치지 않은 처분

국토교통부장관은 징계위원회의 의결에 구속되므로 징계위원회의 의결을 거치지 않고 처분을 한다면 권한 없는 징계처분이 되므로 무효이다.

05 징계에 대한 권리구제

- ① 국토교통부장관의 징계는 행정쟁송법상 처분에 해당하므로 행정쟁송을 통해 권리구제를 받을 수 있다.
- ② 또한 위법한 징계처분으로 손해가 발생한 경우에는 국가배상청구도 가능하다.

06 징계 공고(제39조의2)의 처분성

1) 의의

- ① 명단의 공표란 행정법상의 의무 위반 또는 의무불이행이 있는 경우에 그 위반자의 성명, 위반사실 등을 일반에게 공개하여 명예 또는 신용에 침해를 가함으로써 심리적인 압박을 가하여 행정법상의 의무이행을 확보하는 간접강제수단을 말한다.
- ② 징계 사실을 관보 또는 홈페이지 등에 게시 또는 공고하는 것은 행정상 공표에 해당한다.

2) 처분성 여부

(1) 문제점

징계의 공고가 항고소송의 대상인 처분에 해당하는지 문제된다.

(2) 학설

- ① 명단의 공표는 수인의무를 수반하지 않으므로 비권력적 사실행위라고 보는 견해이다.
(비권력적 사실행위설, 다수설)
- ② 공표행위는 일방적으로 행해지고 그로 인하여 명예, 신용 등이 침해되므로 권력적 사실행위로 보는 견해이다.
(권력적 사실행위설)
- ③ 공표에 앞서 공표결정이 통보되는 경우에는 공표결정통보는 행정처분의 성격을 갖고 공표 자체는 사실행위의 성격을 갖는 반면, 공표에 앞서 공표결정이 통보되지 않는 경우에는 공표는 권력적 사실행위라고 보는 견해가 있다.

(3) 판례

판례는 병무청장이 병역의무 기피자의 인적사항 등을 인터넷 홈페이지에 게시한 것을 항고소송의 대상인 행정처분으로 판시하였다.

(4) 검토

- ① 원칙적으로 명단을 공개하는 행위 그 자체는 순수한 사실행위일 뿐이므로 처분성이 부정된다.
- ② 그러나 예외적으로 공표의 내용이 처분의 실질을 담고 있다면 처분성을 긍정하여 행정쟁송으로 다룰 수 있게 함이 타당하다.

07 징계정보 열람 (시행령 제36조의2)

1) 의의 및 근거

감정평가를 의뢰하려는 자는 협회에 징계정보의 열람을 신청할 수 있다.

2) 열람 신청의 방법

- ① 이 경우 신청서에 신분을 확인할 수 있는 서류, 감정평가를 의뢰하려는 의사 및 징계정보가 필요한 사유를 적은 확인서를 첨부하여야 한다.
- ② 신청 방법은 직접 제출, 우편, 팩스 또는 전자우편 등으로 가능하며, 이에 소요되는 비용은 신청인이 부담한다.

3) 협회의 징계 정보의 제공

- ① 협회는 신청을 받으면, 신청일부터 10일 이내 신청인에게 징계정보를 제공하여야 한다. 이 경우 해당 감정평가사에게 그 사실을 알려야 한다.
- ② 또한, 협회는 감정평가를 의뢰하려는 자가 해당 감정평가사에 대한 징계 사실을 확인하기 위하여 징계 정보의 열람을 신청하는 경우에는 그 정보를 제공하여야 한다.

08 감정평가사 자격취소와 청문

CASE

감정평가사 甲은 A법인에 형식적으로만 적을 두었을 뿐 A법인에서 감정평가사 본연의 업무를 전혀 수행하지 않았고 그 법인의 운영에도 관여하지 않았다. 이에 대해 국토교통부장관은 감정평가관리·징계위원회의 의결에 따라 사전통지를 거쳐 감정평가사 자격취소처분을 하였다. 처분사유는 '甲이 A법인에 소속만 유지할 뿐 실질적으로 감정평가업무에 관여하지 아니하는 방법으로 감정평가사의 자격증을 대여하였다'는 것이었고, 그 법적 근거로 감정평가법 제27조 제1항, 제39조 제1항 단서 및 제2항 제1호가 제시되었다.

甲은 사전통지서에 기재된 의견제출 기한 내에 청문을 신청하였으나 국토교통부장관은 '감정평가법 제13조 제1항 제1호에 따라 감정평가사 자격취소를 하려면 청문을 실시하여야 한다는 규정이 있지만, 명의대여를 이유로 하는 감정평가사 자격취소의 경우에는 청문을 실시하여야 한다는 규정이 없을 뿐 아니라 청문을 실시할 필요도 없다'는 이유로 청문을 실시하지 않았다.

甲에 대한 감정평가사 자격취소처분이 적법한지 설명하시오. [33회 문3]

1) 문제점

감정평가법 제45조에서는 징계로서 자격취소처분을 받는 경우를 청문 사유로 규정하고 있지 않으므로, 이 경우 청문을 생략할 수 있는지 문제된다.

제45조 (청문)

국토교통부장관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 처분을 하려는 경우에는 청문을 실시하여야 한다.

1. 제13조제1항제1호에 따른 감정평가사 자격의 취소
2. 제32조제1항에 따른 감정평가법인의 설립인가 취소

2) 청문 요건 (행정절차법 제22조)

- ① 다른 법령등에서 청문을 하도록 규정하고 있는 경우,
- ② 행정청이 필요하다고 인정하는 경우,
- ③ 인허가 등의 취소, 신분·자격의 박탈, 법인이나 조합 등의 설립허가의 취소의 처분을 하는 경우 행정청은 청문을 한다.

[행정절차법]

제22조 (의견청취)

- ① 행정청이 처분을 할 때 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 청문을 한다.
 - 1. 다른 법령등에서 청문을 하도록 규정하고 있는 경우
 - 2. 행정청이 필요하다고 인정하는 경우
 - 3. 다음 각 목의 처분을 하는 경우
 - 가. 인허가 등의 취소
 - 나. 신분·자격의 박탈
 - 다. 법인이나 조합 등의 설립허가의 취소

3) 예외 사유

- ① 공공의 안전 또는 복리를 위하여 긴급히 처분을 할 필요가 있는 경우,
- ② 법령등에서 요구된 자격이 없거나 없어지게 되면 반드시 일정한 처분을 하여야 하는 경우에 그 자격이 없거나 없어지게 된 사실이 법원의 재판 등에 의하여 객관적으로 증명된 경우,
- ③ 해당 처분의 성질상 의견청취가 현저히 곤란하거나 명백히 불필요하다고 인정될 만한 상당한 이유가 있는 경우
- ④ 당사자가 의견진술의 기회를 포기한다는 뜻을 명백히 표시한 경우에는 청문을 하지 않을 수 있다.

4) 검토

- ① 행정절차법 제22조 제1항 제3호는, **자격을 박탈**하는 처분은 청문을 실시한다고 규정하고 있으며, 이러한 청문제도는 행정처분의 사유에 대하여 당사자에게 변명과 유리한 자료를 제출할 기회를 부여함으로써 위법사유의 시정가능성을 고려하고, 처분의 신중과 적정을 기하려는 데 그 취지가 있다.
- ② 따라서 행정절차법 등 관련 법령상 청문을 실시하지 않아도 되는 예외적인 경우에 해당하지 않는 한, **반드시 청문을 실시하여야 하며**, 그러한 절차를 결여한 처분은 위법한 처분으로서 취소사유에 해당한다고 봄이 타당하다.

[감정평가법]

제13조 (자격의 취소)

- ① 국토교통부장관은 감정평가사가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 자격을 취소하여야 한다.
 - 1. 부정한 방법으로 감정평가사의 자격을 받은 경우
 - 2. 제39조제2항제1호에 해당하는 징계를 받은 경우

제27조 (명의대여 등의 금지)

- ① 감정평가사 또는 감정평가법인등은 다른 사람에게 자기의 성명 또는 상호를 사용하여 제10조에 따른 업무를 수행하게 하거나 자격증·등록증 또는 인가증을 양도·대여하거나 이를 부당하게 행사하여서는 아니 된다.

제39조 (징계)

- ① 국토교통부장관은 감정평가사가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제40조에 따른 감정평가관리·징계위원회의 의결에 따라 제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 징계를 할 수 있다. 다만, 제2항제1호에 따른 징계는 제11호, 제12호에 해당하는 경우 및 제27조를 위반하여 다른 사람에게 자격증·등록증 또는 인가증을 양도 또는 대여한 경우에만 할 수 있다.

(생략)

11. 감정평가사의 직무와 관련하여 금고 이상의 형을 선고받아(집행유예를 선고받은 경우를 포함한다) 그 형이 확정된 경우
12. 이 법에 따라 업무정지 1년 이상의 징계처분을 2회 이상 받은 후 다시 제1항에 따른 징계사유가 있는 사람으로서 감정평가사의 직무를 수행하는 것이 현저히 부적당하다고 인정되는 경우

제5절

감정평가

01 감정평가

1) 의의와 기준

- ① 감정평가란 토지등의 경제적 가치를 판정하여 그 결과를 가액으로 표시하는 것으로 정의한다.(제2조 제2호).
- ② 감정평가법인등이 토지를 감정평가하는 경우에는 그 토지와 이용가치가 비슷하다고 인정되는 부동산 가격공시법에 따른 표준지공시지가를 기준으로 하여야 하되, 적절한 실거래가가 있는 경우에는 이를 기준으로 할 수 있다 (제3조 제1항).
- ③ 다만, 기업의 재무제표 작성에 필요한 감정평가와 담보권의 설정·경매 등 감정평가를 할 때에는 해당 토지의 임대료, 조성비용 등을 고려하여 감정평가를 할 수 있다.(제3조 제2항)

2) 감정평가 실무기준 (제3조 제4항 등)

- ① 국토교통부장관은 감정평가법인등이 감정평가를 할 때 필요한 세부적인 기준(감정평가 실무기준)의 제정 등에 관한 업무를 수행하기 위하여 전문성을 갖춘 민간법인 또는 단체(기준제정기관)를 지정할 수 있다.
- ② 국토교통부장관은 필요하다고 인정되는 경우 감정평가관리·징계위원회의 심의를 거쳐 기준제정기관에 실무기준의 내용을 변경하도록 요구할 수 있다. 이 경우 기준제정기관은 정당한 사유가 없으면 이에 따라야 한다.
- ③ 국가는 기준제정기관의 설립 및 운영에 필요한 비용의 일부 또는 전부를 지원할 수 있다.

02 감정평가서의 심사와 검토제도

1) 개설 (감정평가서)

- ① 감정평가법인등은 감정평가를 의뢰받은 때에는 지체 없이 감정평가를 실시한 후 감정평가 의뢰인에게 감정평가서(전자문서로 된 감정평가서를 포함)를 발급하여야 하고, 감정평가서 원본은 발급일부터 5년, 감정평가서 관련 서류는 발급일부터 2년 이상 보존하여야 한다.
- ② 감정평가법은 감정평가서의 신뢰 확보 등을 위해, 심사제도, 검토제도 및 타당성조사 제도 등을 두고 있다.

2) 감정평가서 심사

(1) 의의 및 취지 (제7조 제1항)

- ① 감정평가법인은 감정평가서를 의뢰인에게 발급하기 전에 감정평가를 한 소속 감정평가사가 작성한 감정평가서의 적정성을 **같은 법인 소속의** 다른 감정평가사에게 심사하게 하고, 그 적정성을 심사한 감정평가사로 하여금 감정평가서에 그 심사사실을 표시하고 서명과 날인을 하게 하여야 한다.
- ② 감정평가산업의 경쟁력 강화, 감정평가에 대한 신뢰 확보 및 감정평가 품질 향상 등에 취지가 있다.

(2) 감정평가서 심사의 기준과 의무

- ① 감정평가서의 적정성을 심사하는 감정평가사는 감정평가서가 감정평가법 제3조에 따른 원칙과 기준을 준수하여 작성되었는지 여부를 신의와 성실로써 공정하게 심사하여야 한다.(법 제7조 제2항)
- ② 작성된 감정평가서의 수정·보완이 필요하다고 판단하는 경우 감정평가서를 심사하는 감정평가사는 해당 감정평가서를 작성한 감정평가사에게 수정·보완 의견을 제시하고, 수정·보완을 확인한 후 감정평가서에 심사사실을 표시하고 서명과 날인을 하여야 한다.(시행령 제7조 제2항)

03 감정평가서 검토제도 (적정성검토 의뢰)

1) 의의 및 취지 (제7조 제3항)

- ① 감정평가 의뢰인 등이 발급된 감정평가서의 적정성에 대한 검토를 일정한 기준을 충족하는 감정평가법인등에게 (**해당** 감정평가서를 발급한 감정평가법인등은 **제외**한다) 의뢰하는 것을 말한다.
- ② 감정평가산업의 경쟁력 강화, 감정평가에 대한 신뢰 확보 및 감정평가 품질 향상 등에 취지가 있다.

2) 법적성격 및 효력

- ① 감정평가서 검토는 발급된 감정평가서에 대한 적정성을 검토하여 의견을 제시하는 것으로 감정평가 재평가로 보기 어렵고 감정평가와 관련된 <상담 및 자문> 등의 성격을 지닌다고 볼 수 있다.
- ② 검토결과서는 적정성에 대한 의견 제시일 뿐, 원칙적으로 법적 효력이 발생하지 않고 국가기관 등을 법적으로 구속하지는 못하지만, 행정기관이 감정평가 결과를 고려하여 관계 법령에 따른 인가·허가·등록 등의 여부를 판단하는 데 활용한다는 간접적인 효과는 있다.

3) 적정성검토 의뢰인 (시행령 제7조의2 제1항)

감정평가 의뢰인, 감정평가 의뢰인이 발급받은 감정평가서를 활용하는 거래나 계약 등의 상대방, 감정평가 결과를 고려하여 관계 법령에 따른 인가·허가·등록 등의 여부를 판단하거나 그 밖의 업무를 수행하려는 행정기관이 의뢰를 할 수 있다.

4) 적정성검토를 할 수 있는 자 (시행령 제7조의2 제2항)

소속된 감정평가사가 둘 이상인 감정평가법인등은 적정성검토를 할 수 있다.

5) 검토절차 (시행령 제7조의3)

- ① 적정성 검토를 의뢰하려는 자는 감정평가서의 사본을 첨부하여 검토를 의뢰하여야 하고,
- ② 의뢰를 받은 감정평가법인등은 지체 없이 검토업무를 수행할 감정평가사를 지정해야 한다.
- ③ 검토업무를 수행할 감정평가사는 5년 이상 감정평가 업무를 수행한 사람으로서 감정평가실적이 100건 이상이어야 한다.

6) 적정성 검토결과와 통보 (시행령 제7조의4)

- ① 검토 의뢰를 받은 감정평가법인등은 의뢰받은 감정평가서의 적정성 검토가 완료된 경우에 의뢰인에게 검토결과서를 발급해야 한다.
- ② 검토결과서에는 감정평가법인등의 사무소 또는 법인의 명칭을 적고, 적정성 검토를 한 감정평가사가 그 자격을 표시한 후 서명과 날인을 해야 한다.
- ③ 이 경우 감정평가사가 소속된 곳이 감정평가법인인 경우에는 그 대표사원 또는 대표이사도 서명이나 날인을 해야 한다.

04 타당성 조사

1) 의의 및 취지 (제8조)

- ① 국토교통부장관은 감정평가서가 발급된 후 해당 감정평가가 감정평가법 등의 절차와 방법 등에 따라 타당하게 이루어졌는지를 직권으로 또는 관계 기관 등의 요청에 따라 조사하는 것을 말한다.
- ② 이는 평가보고서의 합리성 검증 및 제고 등에 취지가 있다.

2) 실시 및 중지사유 (시행령 제8조 제1, 2항)

- ① 제47조에 따른 지도·감독을 위한 감정평가법인등의 사무소 출입·검사 결과나 그 밖의 사유에 따라 조사가 필요하다고 인정하는 경우
- ② 관계 기관 또는 제3항에 따른 이해관계인이 조사를 요청하는 경우에 실시할 수 있으며,
- ③ 법원의 판결에 따라 확정된 경우, 재판이 계속 중이거나 수사기관에서 수사 중인 경우, 관계 법령에 감정평가와 관련하여 권리구제 절차가 규정되어 있는 경우로서 권리구제 절차가 진행중이거나 권리구제 절차를 이행할 수 있는 경우, 징계처분, 제재처분, 형사처벌 등을 할 수 없어 타당성조사의 실익이 없는 경우 등에는 타당성조사를 하지 않거나 중지할 수 있다.

3) 절차 등 (시행령 제8조 제4항 내지 6항)

- ① 국토교통부장관은 타당성조사에 착수한 경우 10일내 감정평가법인등과 감정평가 의뢰인에게 타당성조사의 사유 등을 알려야 하며,
- ② 감정평가법인등과 이해관계인은 통지받고 10일내 의견을 제출할 수 있으며,
- ③ 국토교통부장관은 타당성조사를 완료한 경우 지체없이 그 결과를 통지해야 한다.

05 감정평가제도개선을 위한 표본조사

1) 표본조사의 의의 (감정평가법 제8조 제4항)

표본조사는 감정평가 제도를 개선하기 위하여 발급된 감정평가서를 조사하여 평가기준 및 방법에 대한 위반사항이나 미흡한 사항을 감정평가 제도 및 방법에 대한 개선에 활용하는 것을 말한다.

2) 표본조사 방법 (동법 시행령 제8조의2)

(1) 무작위추출방식

무작위추출방식의 표본조사는 특정분야의 감정평가서를 임의로 조사하는 것을 말한다.

(2) 우선추출방식의 표본조사

- ① 최근 3년이내에 실시한 타당성조사 결과 감정평가 원칙과 기준을 준수하지 않는 등 감정평가의 부실이 발생한 분야,
- ② 무작위추출방식의 표본조사를 실시한 결과 법 또는 다른 법률에서 정하는 방법이나 절차 등을 위반한 사례가 다수 발생한 분야,
- ③ 그 밖에 감정평가의 부실을 방지하기 위하여 협회의 요청을 받아 국토교통부장관이 필요하다고 인정하는 분야에 대한 표본조사이다.

3) 표본조사결과와 활용

국토교통부장관은 표본조사 결과 감정평가 제도의 개선이 필요하다고 인정되는 경우에는 기준제정기관에 감정평가의 방법과 절차등에 관한 개선 의견을 요청할 수 있다.

06 감정평가 정보체계의 구축·운용 (제9조)

- ① 국토교통부장관은 국가등이 의뢰하는 감정평가와 관련된 정보 및 자료를 효율적이고 체계적으로 관리하기 위하여 감정평가 정보체계를 운용할 수 있다.
- ② 감정평가법인등은 감정평가 결과를 감정평가 정보체계에 등록하여야 하되, 개인정보 보호 등 정당한 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.
- ③ 감정평가법인등은 감정평가 정보체계 등록 대상인 감정평가에 대해서는 감정평가서를 발급할 때 해당 의뢰인에게 그 등록에 대한 사실을 알려야 한다.
- ④ 그리고 국토교통부장관은 감정평가 정보체계의 운용을 위하여 필요한 경우 관계 기관에 자료제공을 요청할 수 있으며, 이 경우 해당 기관은 정당한 사유가 없는 이상 그 요청을 따라야 한다.

01 과징금

1) 제도의 도입 취지 및 근거

- ① 감정평가법인등의 업무영역이 확대되고 공공성이 강화됨에 따라 감정평가법인등이 업무정지처분을 받는 경우에 그 감정평가법인등의 감정평가를 필요로 하는 공공목적의 감정평가의 영역의 원활한 추진에 어려움을 겪게 될 수 있다.
- ② 과징금 제도는 이러한 사정을 감안하여 감정평가법 제41조 내지 제44조에 도입되게 되었다.

2) 과징금 제도

(1) 의의

과징금이란 행정법규의 위반이나 행정법상의 의무 위반으로 경제상의 이익을 얻게 되는 경우엔 당해 위반으로 인한 경제적 이익을 박탈하기 위하여 그 이익액에 따라 행정기관이 과하는 행정상 제재금이다.

(2) 변형된 과징금

- ① 영업정지처분에 갈음하여 과징금을 부과할 수 있도록 규정하고 있는 경우 영업정지에 갈음하여 부과되는 과징금을 변형된 과징금이라 한다.
- ② 변형된 과징금의 취지는 영업을 정지함으로써 시민 등이 큰 불편을 겪거나 국민경제에 적지 않은 피해를 주는 등 공익을 해할 우려가 있는 경우 그 영업정지로 인해 초래될 공익에 대한 침해 등 문제를 고려하여, 영업정지처분을 대신하여 영업을 통한 이익을 박탈하는 과징금을 부과할 수 있도록 한 것이다.

(3) 법적성질

- ① 과징금 부과는 **금전급부하명**으로서 침익적 처분이며, ② ‘~할 수 있다’고 규정하여 **재량행위**에 해당한다.

3) 과징금의 성질 및 이중부과 가능성

과징금은 행정상 제재금이고, 범죄에 대한 국가의 형벌권 실행으로서의 과벌이 아니므로, 행정법규 위반에 대하여 벌금이나 범칙금 이외 과징금을 부과하는 것은 이중처벌금지의 원칙에 반하지 않는다. 헌법재판소도 같은 입장이다. (헌법재판소 1994. 6. 30. 92헌바38결정)

헌법재판소 199(4) (6) 30. 선고 92헌바38 전원재판부[합헌]

헌법 제13조 제1항이 정한“이중처벌금지의 원칙”은 동일한 범죄행위에 대하여 국가가 형벌권을 거듭 행사할 수 없도록 함으로써 국민의 기본권 특히 신체의 자유를 보장하기 위한 것이므로, 그 “처벌”은 원칙으로 범죄에 대한 국가의 형벌권 실행으로서의 과벌을 의미하는 것이고, 국가가 행하는 일체의 제재나 불이익처분을 모두 그에 포함된다고 할 수는 없다.

무허가건축행위로 구(舊) 건축법 제54조 제1항에 의하여 형벌(刑罰)을 받은 자가 그 위법건축물에 대한 시정명령에 위반한 경우 그에 대하여 과태료를 부과할 수 있도록 한 동법 제56조의2 제1항의 규정이 이중처벌금지원칙에 위배된다고 볼 수 없다.

4) 감정평가법상 과징금의 부과 및 징수

(1) 과징금의 부과 (제41조 제1항 및 제2항)

- ① 국토교통부장관은 감정평가법인등이 업무정지사유에 해당하게 되어 업무정지처분을 하여야 하는 경우로서 그 업무정지처분이 표준지공시지가의 조사·평가 등의 업무를 정상적으로 수행하는 데에 지장을 초래하는 등 공익을 해칠 우려가 있는 경우에는 업무정지처분에 갈음하여 5,000만 원(감정평가법인의 경우는 5억 원) 이하의 과징금을 부과할 수 있다.
- ② 국토교통부장관은 과징금을 부과하는 경우 위반행위의 내용과 정도, 위반행위의 기간과 위반횟수, 위반행위로 취득한 이익의 규모를 고려하여야 한다.

(2) 과징금의 승계 (제41조 제3항)

국토교통부장관은 이 법을 위반한 감정평가법인이 합병을 하는 경우 그 감정평가법인이 행한 위반행위는 합병 후 존속하거나 합병에 의해 신설된 감정평가법인이 행한 행위로 보아 과징금을 부과·징수할 수 있다.

(3) 과징금의 징수 및 체납처분 (제44조)

- ① 국토교통부장관은 과징금납부의무자가 납부기한 내에 과징금을 납부하지 아니한 경우에는 납부기한의 다음 날부터 납부한 날의 전일까지의 기간에 대하여 대통령령이 정하는 **가산금**을 징수할 수 있다.
- ② 국토교통부장관은 과징금납부의무자가 납부기한 내에 과징금을 납부하지 아니하였을 때에는 기간을 정하여 독촉을 하고, 그 지정한 기간 내에 과징금이나 제1항에 따른 가산금을 납부하지 아니하였을 때에는 국세 체납처분의 예에 따라 징수할 수 있다.

(4) 권리구제

a. 이의신청 (제42조)

- ① 과징금 부과에 이의가 있는 자는 통보받은 날부터 30일 이내에 사유서를 갖추어 국토교통부장관에게 이의를 신청할 수 있다.
- ② 국토교통부장관은 이의신청에 대하여 30일 이내 결정을 하여야 한다.
- ③ 다만, 부득이한 사정으로 그 기간에 결정을 할 수 없을 때에는 30일의 범위에서 그 기간을 연장할 수 있다. 위 이의신청은 강학상 이의신청에 해당한다(행정심판이 아니다).

b. 행정심판 (제42조 제3항)

이의신청에 따른 결정에 이의가 있는 자는 행정심판을 청구할 수 있다.

c. 행정소송 및 부당이득반환청구소송

과징금은 금전급부하명으로서 행정소송법상 처분에 해당하므로, 행정소송을 제기할 수 있다. 또한, 법률상 원인 없이 부과된 경우 민사상 부당이득반환청구소송을 제기할 수도 있다.

02 과태료

1) 과태료 의의 (제52조)

- ① 행정법에서 일정한 의무를 이행하지 않거나 가벼운 벌칙을 위반한 사람에게 부담해서 국가에 납부하게 하는 돈으로, 판례는 행정상의 질서유지를 위한 **행정질서벌**에 해당할 뿐 형벌이라고 할 수 없어 죄형법정주의의 규율대상이 아니라고 본다.
- ② 따라서 과태료부과는 행정소송의 대상이 되는 처분으로 보기 어렵다.

2) 불복절차

과태료에 대한 불복절차는 “이의제기 - 법원의 재판 - 항고(법원 결정에 대한 불복을 항고, 단 약식재판으로 할 경우 이의신청 가능) - 재항고”로 진행된다.

3) 과태료, 과징금, 벌금 비교

구 분	과태료	과징금	벌금
개념	경미한 위반행위에 대한 금전적 제재	불법이익 환수 또는 영업정지 대체의 금전적 제재	범죄인에 대한 금전지불의무 부과 형벌
종류	행정질서벌(형벌X)	금부하명(처분)	행정형벌
부과주체	행정청	행정청	법원
불복절차	이의신청/비송사건절차법	행정소송	형사소송

03 한국감정평가사협회

1) 목적 및 설립 (제33조)

협회의 목적은 감정평가사의 품위 유지와 직무의 개선·발전을 도모하고, 회원의 관리 및 지도에 관한 사무를 하도록 하기 위함이며, 법인의 형태를 가진다.

2) 회칙(제34조)과 윤리규정 (제36조)

- ① 협회는 회칙을 정하여 국토교통부장관의 인가를 받아야 하는데, 명칭과 사무소 소재지, 회원가입 및 탈퇴에 관한 사항, 임원 구성에 관한 사항 등이 회칙에 포함되어야 한다.
- ② 협회는 회원이 직무를 수행할 때 지켜야 할 직업윤리에 관한 규정을 제정하여야 하고, 감정평가법인등의 손해배상책임을 보장하기 위해 공제사업을 운영한다.
- ③ 회원은 위 윤리규정을 준수할 의무가 있다.

3) 회원가입 의무 (제35조)

감정평가법인등과 그 소속 감정평가사는 협회에 회원으로 가입하여야 하며, 그 밖의 감정평가사는 협회의 회원으로 가입할 수 있다. 회원은 회칙을 준수하여야 한다.

4) 자문(제37조)과 회원에 대한 교육·연수 (제38조)

- ① 국가 등은 제감정평가사의 직무에 관한 사항에 대하여 협회에 업무의 자문을 요청하거나 협회의 임원·회원 또는 직원을 전문분야에 위촉하기 위하여 추천을 요청할 수 있으며, 협회는 해당 회원으로 하여금 업무를 수행하게 할 수 있고, 국가등에 대하여 필요한 경우 감정평가의 관리·감독·의뢰 등과 관련한 업무의 개선을 건의할 수 있다.
- ② 또한, 협회는 회원에 대해서 교육·연수를 실시하고 회원의 자체적인 교육·연수활동을 지도·관리한다.

5) 국토교통부장관의 업무의 위탁 (제46조)

협회 한국부동산원, 한국산업인력공단과 함께 국토교통부장관의 업무를 위탁받아 수행할 수 있는데, 감정평가사 등록 및 등록 갱신, 소속 감정평가사 또는 사무직원의 신고 업무는 협회만이 위탁받을 수 있다.

제1절 정비사업의 기초

01 정비사업의 의미 및 종류

정비사업이란 도시기능을 회복하기 위하여 정비구역에서 정비기반시설을 정비하거나 주택 등 건축물을 개량 또는 건설하는 사업을 말하며 주거환경개선사업, 재개발사업, 재건축사업이 있다.

02 정비사업의 절차



01 추진위원회

1) 추진위원회의 구성과 승인

- ① 시장·군수등, 토지주택공사등 또는 지정개발자가 아닌 자가 정비사업을 시행하려는 경우에는 토지등소유자로 구성된 조합을 설립해야 한다. 다만, 토지등소유자가 재개발사업을 시행하려는 경우에는 그러하지 아니하다 (법 제35조 제1항).
- ② 조합을 설립하려는 경우에는 정비구역 지정·고시 후 토지등소유자 과반수의 동의를 받아 조합설립을 위한 추진위원회를 구성하여 국토교통부령으로 정하는 방법과 절차에 따라 시장·군수 등의 승인을 받아야 한다 (법 제31조 제1항).

※ 보충자료 - 토지등소유자 정의 (도시정비법 제2조 제9호)

가. 주거환경개선사업 및 재개발사업의 경우에는 정비구역에 위치한 토지 또는 건축물의 소유자 또는 그 지상권자나, 재건축사업의 경우에는 정비구역에 위치한 건축물 및 그 부속토지의 소유자

2) 추진위원회 구성승인의 법적성질

판례는 추진위원회 구성승인처분은 조합의 설립을 위한 주체인 추진위원회의 구성행위를 보충하여 그 효력을 부여하는 처분이라고 판시하여 **강학상 인가**로 본다.(2011두11129)

3) 조합설립인가 후 추진위원회 구성승인처분을 다룰 수 있는지

추진위원회 구성승인처분을 다투는 소송 계속 중에 조합설립인가처분이 이루어진 경우에는, 추진위원회 구성승인처분에 위법이 존재하여 조합설립인가 신청행위가 무효라는 점 등을 들어 **직접 조합설립인가처분을 다툼으로써** 정비사업의 진행을 저지하여야 할 것이고, 이와는 별도로 **추진위원회 구성승인처분에 대하여 취소 또는 무효확인을 구할 법률상의 이익은 없다**고 보아야 한다.(2011두11129)

02 조합설립

1) 설립절차

조합설립 추진위원회가 승인되면 토지등소유자로부터 **조합설립 동의(결의)**를 받는 등 도시정비법에서 정한 요건과 절차를 갖추어 시장등에게 **조합설립인가(강학상 특허)**를 받은 후 등기함으로써 **법인**으로 성립한다.

2) 조합의 법적지위

정비사업조합은 관할 행정청의 감독 아래 정비사업을 시행하는 목적 범위 내에서 행정작용을 행하는 **행정주체**로서의 지위를 갖는다.

03 조합설립인가의 법적성질

1) 학설

- ① 조합설립행위는 기본행위로, 조합설립인가는 이를 보충하는 행위로서 **강학상 인가**로 보는 견해
- ② 조합설립행위는 조합설립인가를 받기 위한 요건으로 보고, 조합설립인가는 정비사업을 시행할 수 있는 권한을 갖는 행정주체로서의 지위를 부여하는 **강학상 특허**로 보는 견해가 있다.

2) 판례

(1) 종전 판례 (강학상 인가)

종전에는 조합설립인가는 조합설립행위를 보충하여 그 법률상 효력을 완성시키는 보충행위라고 하여 인가설을 취했다.

대법원 2000. 9. 5. 선고 99두1854

주택건설촉진법에서 규정한 바에 따른 관할시장 등의 재건축조합설립인가는 불량·노후한 주택의 소유자들이 재건축을 위하여 한 재건축조합설립행위를 보충하여 그 법률상 효력을 완성시키는 보충행위일 뿐이므로 그 기본되는 조합설립 행위에 하자가 있을 때에는 그에 대한 인가가 있다 하더라도 기본행위인 조합설립이 유효한 것으로 될 수 없고, 따라서 그 기본행위는 적법유효하나 보충행위인 인가처분에만 하자가 있는 경우에는 그 인가처분의 취소나 무효확인을 구할 수 있을 것이지만 기본행위인 조합설립에 하자가 있는 경우에는 민사쟁송으로써 따로 그 기본행위의 취소 또는 무효확인 등을 구하는 것은 별론으로 하고 기본행위의 불성립 또는 무효를 내세워 바로 그에 대한 감독청의 인가처분의 취소 또는 무효확인을 소구할 법률상 이익이 있다고 할 수 없다.

(2) 최근 판례 (설권적 처분)

최근에는 입장을 바꾸어 조합설립인가처분을 도시정비법상 재건축사업을 시행할 수 있는 권한을 갖는 행정주체로서의 지위를 부여하는 **설권적 처분**으로 보고, 조합설립행위는 인가처분을 위한 **요건** 중에 하나라고 판시했다.

대법원 2009. 9. 24. 선고 2008다60568

행정청이 도시 및 주거환경정비법 등 관련 법령에 근거하여 행하는 조합설립인가처분은 단순히 사인들의 조합설립행위에 대한 보충행위로서의 성질을 갖는 것에 그치는 것이 아니라 법령상 요건을 갖추 경우 도시 및 주거환경정비법상 주택 재건축사업을 시행할 수 있는 권한을 갖는 행정주체(공법인)로서의 지위를 부여하는 일종의 설권적 처분의 성격을 갖는다고 보아야 한다.

3) 검토

도시정비법상 조합설립인가처분은 조합이 정비사업을 시행할 수 있는 권한을 부여하여 행정주체로서의 지위를 설정하는 능력설정행위이므로 **강학상 특허**로 보는 것이 타당하다.

CASE

S시의 시장 A는 K구의 D지역을 도시정비법상 정비구역으로 지정·고시하였다. 그러자 이 지역의 주민들은 조합을 설립하여 주택재개발사업을 추진하기 위해 도정법에서 정한 절차에 따라 조합설립추진위원회를 구성하였고, 동 추진 위원회는 토지등소유자의 동의, 정관, 공사비 등 정비사업에 드는 비용과 관련된 자료 등을 첨부하여 A로부터 X조합 설립인가를 받아登記하였다. X조합은 조합총회를 개최하고 도정법상 토지등 소유자 동의를 얻어 지정개발자로서 Y를 사업시행자로 지정하였다.

D지역의 토지소유자 중 甲이 “추진위원회가 주민의 동의를 얻어 X조합을 설립하는 과정에서 ‘건설되는 건축물의 설계의 개요’ 등에 관한 항목 내용의 기재가 누락되었음에도 이를 유효한 동의로 처리하여 조합설립행위에 하자가 있다.”고 주장하며 행정소송으로 다투려고 한다. 이 경우 조합설립인가의 법적 성질을 검토한 다음, 이에 기초하여 쟁송의 형태에 대해 설명하시오. [25회 문1]

1) 조합설립인가 전에 다투는 경우

- ① 조합설립인가처분 전에는 행정주체로서의 조합이 존재하지 않으므로, 조합설립동의를 다투는 소송은 **추진위원회**를 상대로 제기해야 한다.
- ② 추진위원회는 행정주체가 아니므로 **민사소송**으로 다투어야 한다.

2) 조합설립인가 후에 다투는 경우

- ① 조합설립인가처분은 **강학상 특허**로서 조합설립동의를 조합설립인가처분을 하는 데 **필요한 요건 중 하나**에 불과하다.
- ② 조합설립동시에 하자가 있다면 그 하자는 조합설립인가처분의 위법사유가 되며, **항고소송**으로 **인가처분**을 다투어야 한다.
- ③ 따라서 조합설립인가처분이 있는 후에 조합설립동의를 하자를 이유로 민사소송을 통해 그 동意的 효력 유무를 다투는 것은 **확인 이익이 없는** 부적법한 소에 해당한다.

대법원 2009. 9. 24. 선고 2008다60568

조합설립결의는 조합설립인가처분이라는 행정처분을 하는 데 필요한 요건 중 하나에 불과한 것이어서, 조합설립결의에 하자가 있다면 그 하자를 이유로 직접 항고소송의 방법으로 조합설립인가처분의 취소 또는 무효확인을 구하여야 하고, 이와는 별도로 조합설립결의 부분만을 따로 떼어내어 그 효력 유무를 다투는 확인의 소를 제기하는 것은 원고의 권리 또는 법률상의 지위에 현존하는 불안·위험을 제거하는 데에 가장 유효·적절한 수단이라 할 수 없어 특별한 사정이 없는 한 확인의 이익은 인정되지 아니한다.

구 분	조합설립행위 법적성질	조합설립인가 법적성질	소송수단 (조합설립행위의 하자)
변경 전	기본행위	강학상 인가	민사소송으로 기본행위의 무효확인의 소 제기
변경 후	인가처분에 필요한 요건	강학상 특허	항고소송으로 조합설립인가의 취소 또는 무효확인의 소 제기

05 조합설립인가처분 취소판결 등으로 인한 법률관계

- ① 조합설립인가처분이 판결에 의하여 취소 내지 무효로 확인된 경우 조합은 조합설립인가 당시로 소급하여 공법인으로서의 법적 지위를 상실한다.
- ② 다만, 조합설립인가취소 후에도 청산사무가 종료될 때까지 청산의 목적 범위 내에서는 행정주체의 지위가 유지되며, 정관 등도 그 범위 내에서 효력을 가진다.

01 개설

사업시행자는 정비계획에 따라 토지이용계획, 정비기반시설 및 공동이용시설의 설치계획, 주민이주대책 등을 포함하는 사업시행계획을 수립하여 시장등의 인가를 받아야 한다.(도시정비법 제50조, 제52조).

02 법적성질

1) 사업시행계획

조합은 공법인으로서 행정주체의 지위를 가지므로 조합이 도시정비법에 기초하여 수립한 사업시행계획은 행정계획이며, 인가·고시를 통해 확정되면 이해관계인을 구속하는 행정계획으로서 독립된 행정처분에 해당한다.

2) 사업시행계획인가

조합이 수립한 사업시행계획을 인가하는 행정청의 행위는 사업시행계획을 동의로써 보충하여 법률상 효력을 완성시키는 강학상 인가에 해당한다.

※ 보충자료 - 토지등소유자가 사업시행계획을 수립하는 경우

1. 사업시행계획의 법적성질

- ① 도시정비사업을 직접 시행하려는 토지등소유자들은 시장·군수로부터 사업시행인가를 받기 전에는 행정주체로서의 지위를 가지지 못한다.
- ② 따라서 그가 작성한 사업시행계획은 인가처분의 요건 중 하나에 불과하고 항고소송의 대상이 되는 독립된 행정처분에 해당하지 않는다.

2. 토지등소유자가 수립한 사업시행계획에 대한 인가

1) 법적 성질

도시정비법상 정비사업을 시행할 수 있는 권한을 가지는 행정주체로서의 지위를 부여하는 일종의 설권적 처분의 성격을 가지므로 강학상 특허에 해당한다.

2) 소송 유형

- ① 사업시행계획은 사업시행인가처분을 하는 데 필요한 요건 중 하나에 불과하다.
- ② 따라서 사업시행계획에 하자가 있다면 그 하자는 사업시행계획인가처분의 위법사유가 되며, 항고소송으로 인가처분을 다투어야 한다.

03 소송 유형

1) 사업시행계획인가를 다투는 경우

- ① 기본행위인 사업시행계획에는 하자가 없는데 보충행위인 인가처분에 고유한 하자가 있는 경우에는 항고소송으로 인가처분을 다투어야 한다.
- ② 인가처분에는 고유한 하자가 없고 사업시행계획에만 하자가 있다면 기본행위인 사업시행계획을 다투어야 하며, 사업시행계획의 무효를 주장하면서 인가처분의 무효확인 또는 취소를 구할 법률상 이익은 없다.

대법원 2021. 2. 10. 선고 2020두48031

(구) 도시 및 주거환경정비법에 기초하여 주택재개발정비사업조합이 수립한 사업시행계획은 관할 행정청의 인가·고시가 이루어지면 이해관계인들에게 구속력이 발생하는 독립된 행정처분에 해당하고, 관할 행정청의 사업시행계획 인가처분은 사업시행계획의 법률상 효력을 완성시키는 보충행위에 해당한다. 따라서 기본행위인 사업시행계획에는 하자가 없는데 보충행위인 인가처분에 고유한 하자가 있다면 그 인가처분의 무효확인이나 취소를 구하여야 할 것이지만, 인가처분에는 고유한 하자가 없는데 사업시행계획에 하자가 있다면 사업시행계획의 무효확인이나 취소를 구하여야 할 것이지만 사업시행계획의 무효를 주장하면서 곧바로 그에 대한 인가처분의 무효확인이나 취소를 구하여서는 아니 된다.

사업시행계획 (기본행위)	사업시행계획인가 (보충행위)	소송내용
하자X	하자O	인가처분을 대상으로 하는 항고소송
하자O	하자X	기본행위를 대상으로 하는 항고소송

2) 조합총회결의에 대한 소송제기 가능여부

(1) 사업시행계획인가 전에 다투는 경우

조합총회결의의 효력을 다투는 소송은 그 소송결과에 따라 사업시행계획의 위법 여부에 직접 영향을 미치는 공법상 법률관계에 관한 것이므로, 조합을 피고로 하여 당사자소송으로 다투어야 한다.

(2) 사업시행계획인가 후에 다투는 경우

판례는 사업시행계획안에 대한 조합 총회결의는 그 행정처분에 이르는 절차적 요건 중 하나에 불과한 것으로서, 그 계획이 확정된 후에는 항고소송의 방법으로 계획의 취소 또는 무효확인을 구할 수 있을 뿐, 절차적 요건에 불과한 총회결의 부분만을 대상으로 그 효력 유무를 다투는 확인의 소를 제기하는 것은 허용되지 아니한다고 판시하였다. (2009마596)

다툼의 대상	다툼하는 시점	소송내용
조합총회결의의 하자	사업시행계획인가 전	조합총회결의의 무효확인을 구하는 당사자소송
	사업시행계획인가 후	사업시행계획(기본행위)을 대상으로 하는 항고소송

01 관리처분계획의 의의

포괄적 행정계획으로서 사업시행의 결과 설치되는 대지를 포함한 각종 시설물의 권리귀속에 관한 사항과 그 비용 부담에 관한 사항을 정하는 행정처분이다.

02 절차

1) 분양공고

사업시행자는 사업시행계획인가의 고시가 있는 날부터 90일 이내에 관련 내용을 토지등소유자에게 통지하고, 분양의 대상이 되는 대지 또는 건축물의 내역 등을 해당 지역에서 발간되는 일간신문에 공고하여야 한다.

2) 분양신청

대지 또는 건축물에 대한 분양을 받으려는 토지등소유자는 분양신청기간에 대통령령으로 정하는 방법 및 절차에 따라 사업시행자에게 대지 또는 건축물에 대한 분양신청을 하여야 한다.

3) 관리처분계획수립 및 인가

사업시행자는 분양신청기간이 종료된 때에는 분양신청의 현황을 기초로 관리처분계획을 수립하여 **총회의결**을 거친 후 시장·군수등의 **인가**를 받아야 한다.

03 법적성질

1) 관리처분계획 (행정계획)

관리처분계획은 조합원의 비용 부담에 관한 사항 등을 정하는 계획으로서 그것이 인가·고시를 통해 확정되면 이해관계인에 대한 **구속적 행정계획**으로서 독립적인 **행정처분**에 해당한다.

대법원 2009. 9. 17. 선고 2007다2428 전원합의체

재건축조합이 행정주체의 지위에서 도시정비법 제48조에 따라 수립하는 관리처분계획은 정비사업의 시행 결과 조성되는 대지 또는 건축물의 권리귀속에 관한 사항과 조합원의 비용 부담에 관한 사항 등을 정함으로써 조합원의 재산상 권리·의무 등에 구체적이고 직접적인 영향을 미치게 되므로, 이는 구속적 행정계획으로서 재건축조합이 행하는 독립된 행정처분에 해당한다.

2) 관리처분계획인가 (강학상 인가)

사업시행자가 수립한 관리처분계획을 인가하는 행정청의 행위는 관리처분계획을 동의로써 보충하여 법률상 효력을 완성시키는 **강학상 인가**에 해당한다.

대법원 2016. 12. 15. 선고 2015두51347

도시정비법에 기초하여 주택재개발정비사업조합(이하 '조합'이라 한다)이 수립한 관리처분계획은 그것이 인가·고시를 통해 확정되면 이해관계인에 대한 구속적 행정계획으로서 독립적인 행정처분에 해당한다. 이러한 관리처분계획을 인가하는 행정청의 행위는 조합의 관리처분계획에 대한 법률상의 효력을 완성시키는 보충행위이다.

04 소송 유형

1) 관리처분계획인가를 다투는 경우

- ① 기본행위인 관리처분계획에는 하자가 없는데 보충행위인 인가처분에 고유한 하자가 있는 경우에는 **항고소송**으로 인가처분을 다투어야 한다.
- ② 인가처분에는 고유한 하자가 없고 관리처분계획에만 하자가 있다면 기본행위인 관리처분계획을 다투어야 하며, 관리처분계획의 무효를 주장하면서 인가처분의 무효확인 또는 취소를 구할 법률상 이익은 없다.

대법원 2016. 12. 15. 선고 2015두51347

기본행위가 적법·유효하고 보충행위인 인가처분 자체에 흠이 있다면 그 인가처분의 무효나 취소를 주장할 수 있다. 그러나 인가처분에 흠이 없다면 기본행위에 흠이 있다고 하더라도 따로 기본행위의 흠을 다투는 것은 별론으로 하고 기본행위의 흠을 내세워 바로 그에 대한 인가처분의 무효확인 또는 취소를 구할 수는 없으므로, 그 당부에 관하여 판단할 필요 없이 해당 부분 청구를 기각하여야 한다.

관리처분계획 (기본행위)	관리처분계획인가 (보충행위)	소송내용
하자X	하자O	인가처분을 대상으로 하는 항고소송
하자O	하자X	기본행위를 대상으로 하는 항고소송

2) 조합총회결의에 대한 소송제기 가능여부

(1) 관리처분계획인가 전에 다투는 경우

관리처분계획안에 대한 조합총회결의의 효력을 다투는 소송은, 행정처분인 관리처분계획에 이르는 **절차적 요건의 존부나 효력 유무에 관한 소송**으로서 그 소송결과에 따라 관리처분계획의 위법 여부에 직접 영향을 미치는 **공법상 법률관계**에 관한 것이므로, 이는 행정소송법상의 **당사자소송**으로 다투어야 한다.

(2) 관리처분계획인가 후에 다투는 경우

관리처분계획에 대한 관할 행정청의 인가·고시까지 있게 되면 관리처분계획은 행정처분으로서 효력이 발생한다. 따라서 총회결의의 하자를 이유로 하는 경우에는 **항고소송**의 방법으로 **관리처분계획의 취소 또는 무효확인을 구해야 하고**, 별도로 행정처분에 이르는 절차적 요건에 불과한 총회결의만을 떼어내어 효력 유무를 다투는 확인의 소를 제기하는 것은 허용되지 않는다.

다툼의 대상	다툼의 시점	소송내용
조합총회결의의 하자	관리처분계획인가 전	조합총회결의의 무효확인을 구하는 당사자소송
	관리처분계획인가 후	관리처분계획(기본행위)을 대상으로 하는 항고소송

관리처분계획은 재건축조합이 조합원의 분양신청 현황을 기초로 관리처분계획안을 마련하여 그에 대한 조합 총회결의와 토지 등 소유자의 공람절차를 거친 후 관할 행정청의 인가·고시를 통해 비로소 그 효력이 발생하게 되므로, 관리처분 계획안에 대한 조합 총회결의는 관리처분계획이라는 행정처분에 이르는 절차적 요건 중 하나로, 그것이 위법하여 효력이 없다면 관리처분계획은 하자가 있는 것으로 된다.

따라서 행정주체인 재건축조합을 상대로 관리처분계획안에 대한 조합총회결의의 효력 등을 다투는 소송은 행정처분에 이르는 절차적 요건의 존부나 효력 유무에 관한 소송으로서 그 소송결과에 따라 행정처분의 위법 여부에 직접 영향을 미치는 공법상 법률관계에 관한 것이므로, 이는 행정소송법상의 당사자소송에 해당한다.

그리고 이러한 소송은, 관리처분계획이 인가·고시되기 전이라면 위법한 총회결의에 대해 무효확인 판결을 받아 이를 관할 행정청에 자료로 제출하거나 재건축조합으로 하여금 새로이 적법한 관리처분계획안을 마련하여 다시 총회결의를 거처도록 함으로써 하자 있는 관리처분계획이 인가·고시되어 행정처분으로서 효력이 발생하는 단계에까지 나아가지 못하도록 저지할 수 있고, 또 총회결의에 대한 무효확인판결에도 불구하고 관리처분계획이 인가·고시되는 경우에도 관리처분계획의 효력을 다투는 항고소송에서 총회결의의 무효확인소송의 판결과 증거들을 소송자료로 활용함으로써 신속하게 분쟁을 해결할 수 있으므로, 관리처분계획에 대한 인가·고시가 있기 전에는 허용할 필요가 있다.

그러나 나아가 관리처분계획에 대한 관할 행정청의 인가·고시까지 있게 되면 관리처분계획은 행정처분으로서 효력이 발생하게 되므로, 총회결의의 하자를 이유로 하여 행정처분의 효력을 다투는 항고소송의 방법으로 관리처분계획의 취소 또는 무효확인을 구하여야 하고, 그와 별도로 행정처분에 이르는 절차적 요건 중 하나에 불과한 총회결의의 부분만을 따로 떼어내어 효력 유무를 다투는 확인의 소를 제기하는 것은 특별한 사정이 없는 한 허용되지 않는다고 보아야 한다.

05 하자의 승계 여부

1) 사업시행계획과 관리처분계획 간의 하자의 승계 여부

판례는 사업시행계획과 관리처분계획은 서로 독립하여 별개의 법률효과를 발생시키는 것으로서 이 사건 사업시행 계획의 수립에 관한 취소사유인 하자가 이 사건 관리처분계획에 승계되지 아니하므로, 위 취소사유를 들어 이 사건 관리처분계획의 적법 여부를 다룰 수는 없다고 판시했다(대법원 2012. 8. 23. 선고 2010두13463).

2) 관리처분계획과 청산금부과처분 간의 하자의 승계 여부

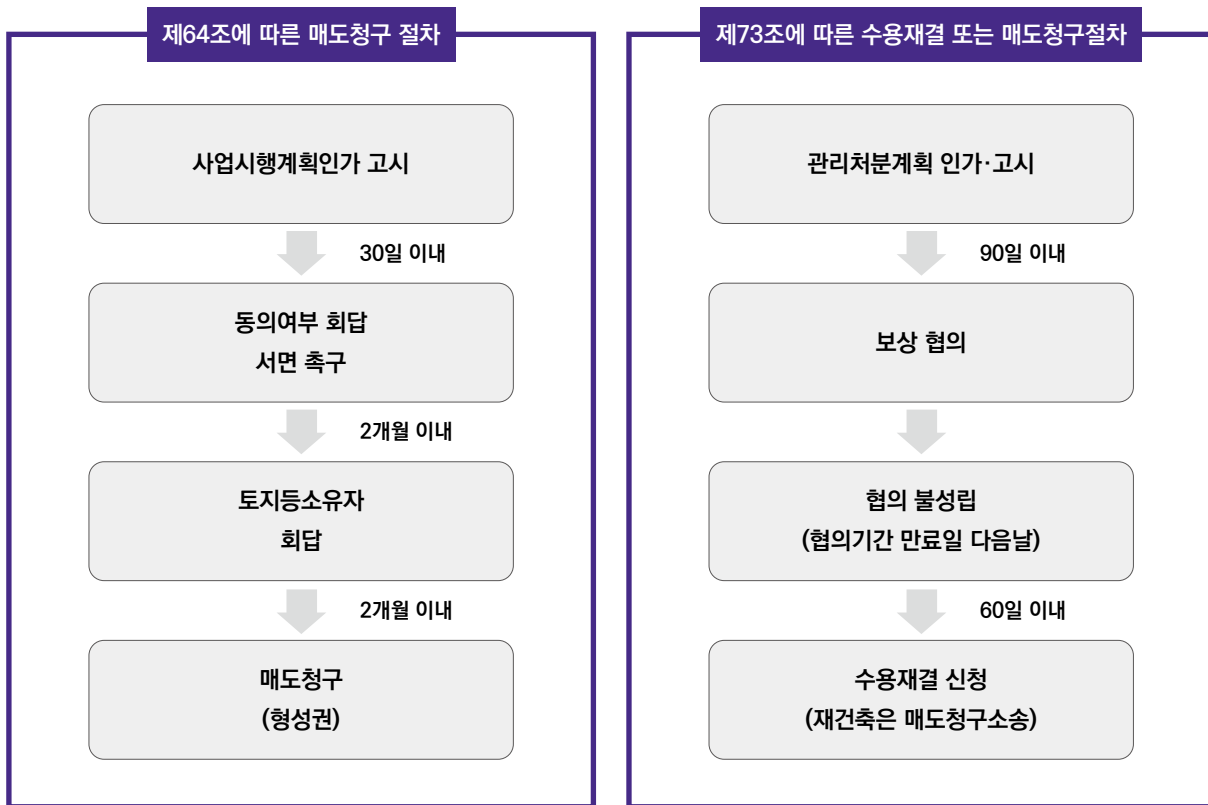
판례는 관리처분계획과 청산금부과처분은 서로 독립하여 별개의 법률효과를 발생시키는 것이므로, 관리처분계획에 불가쟁력이 생겨 그 효력을 다룰 수 없게 된 경우에는 그 관리처분계획에 위법사유가 있다 할지라도 그것이 당연 무효의 사유가 아닌 한 관리처분계획상의 하자를 이유로 후행처분인 청산금부과처분의 위법을 주장할 수는 없다고 판시했다(대법원 2007. 9. 6. 선고 2005두11951).

01 재건축사업의 매도청구 (도시정비법 제64조, 제73조)

- ① 재건축사업의 사업시행자는 도시정비법에서 정한 절차를 거쳐 조합설립 또는 사업시행자 지정에 동의하지 않은자 (제64조), 분양신청을 하지 않은 자 등(제73조)을 상대로 건축물 또는 토지의 소유권과 그 밖의 권리를 매도할 것을 청구할 수 있다.
- ② 매도청구권은 매매계약의 성립을 강제하는 **형성권**의 성질을 가진다.

02 재개발사업의 수용재결 (도시정비법 제73조)

재개발사업의 사업시행자는 도시정비법에서 정한 절차를 거쳐 분양신청을 하지 않은 자 등을 상대로 토지, 건축물 또는 그 밖의 권리에 대해 수용재결을 신청할 수 있다.



03 매도청구소송과 보상금증감청구소송의 차이점

1) 소송형태 및 관할법원

- ① 매도청구를 둘러싼 법률관계는 사법상의 법률관계로서 그 매도청구권 행사에 따른 소유권이전등기의무의 존부를 다투는 소송인 매도청구소송은 **민사소송**이다. 따라서 관할 법원은 민사법원이 된다.

대법원 2010. 4. 8. 선고 2009다93923

(구)도시 및 주거환경정비법상 주택재건축정비사업조합이 공법인이라는 사정만으로 조합 설립에 동의하지 않은 자의 토지 및 건축물에 대한 주택재건축정비사업조합의 매도청구권을 둘러싼 법률관계가 공법상의 법률관계에 해당한다거나 그 매도청구권 행사에 따른 소유권이전등기절차 이행을 구하는 소송이 당연히 공법상 당사자소송에 해당한다고 볼 수는 없고, 위 법률의 규정들이 주택재건축정비사업조합과 조합 설립에 동의하지 않은 자와의 사이에 매도청구를 둘러싼 법률관계를 특별히 공법상의 법률관계로 설정하고 있다고 볼 수도 없으므로, 주택재건축정비사업조합과 조합 설립에 동의하지 않은 자 사이의 매도청구를 둘러싼 법률관계는 사법상의 법률관계로서 그 매도청구권 행사에 따른 소유권이전등기 의무의 존부를 다투는 소송은 민사소송에 의하여야 할 것이다.

- ② 반면, 토지보상법 제85조 제2항에 따라 제기하는 보상금증감청구소송은 **공법상 당사자소송**이며, 사업시행자와 피수용자가 각각 피고 또는 원고가 되어 보상금을 다투는 소송이므로 **형식적 당사자소송**에 해당한다. 따라서 행정법원이 관할 법원이 된다.

대법원 1991. 11. 26. 선고 91누285

토지수용법 제75조의2 제2항의 규정은 그 제1항에 의하여 이의재결에 대하여 불복하는 행정소송을 제기하는 경우, 이것이 보상금의 증감에 관한 소송인 때에는 이의재결에서 정한 보상금이 증액 변경될 것을 전제로 하여 기업자를 상대로 보상금의 지급을 구하는 공법상의 당사자소송을 규정한 것으로 볼 것이다.

2) 절차 및 제소기간

(1) 매도청구

- ① 도시정비법 제64조에 따라 사업시행계획인가의 고시가 있는 날부터 30일 이내에 조합설립 또는 사업시행자 지정에 관한 동의 여부를 회답할 것을 촉구하고, 촉구를 받은 토지등소유자는 2개월 이내에 회답해야 한다.
- ② 2개월 이내 회답하지 않은 경우 부동의한 것으로 본다. 2개월의 회답기간이 만료된 때부터 2개월 이내에 부동의자를 상대로 매도를 청구할 수 있다.
- ③ 그리고 도시정비법 제73조에 따라 관리처분계획인가가 고시된 다음 날부터 90일 이내에 분양신청을 하지 않은 자 등과 손실보상에 관한 협의를 해야하고 협의가 성립되지 않으면 협의 기간 만료일 다음 날부터 60일 이내에 매도청구소송을 제기해야 한다.

(2) 보상금증감청구소송

보상금증감청구소송은 수용재결 재결서 정본 송달일로부터 90일 이내에, 이의신청을 거쳤을 때에는 이의신청에 대한 재결서를 받은 날부터 60일 이내에 제기해야 한다.(도시정비법 제65조, 토지보상법 제85조)

3) 당사자

- ① 매도청구소송의 원고는 사업시행자가 되고, 피고는 부동의자, 분양신청을 하지 않은 자 등이 된다.
- ② 반면, 보상금증액청구소송에서는 원고는 피수용자, 피고는 사업시행자가 되며, 보상금감액청구소송에서는 원고는 사업시행자, 피고는 피수용자가 된다.

4) 감정평가의 기준시점 (가격시점)

- ① 매도청구 소송감정의 기준시점은 **형성권인** 매도청구의 의사가 상대방에게 도달한 때인 **매매계약체결 의제일**이다.
- ② 반면, 수용재결의 보상금을 다투는 소송감정의 가격시점은 **수용재결일**이다(토지보상법 제67조 제1항).

5) 감정평가 시 개발이익 반영 여부

- ① 매도청구에 따른 감정평가는 재건축사업이 시행된다는 것을 전제로 하여 시장에서 형성, 반영되고 있는 **개발이익을 반영해야 한다**. 다만, 기준시점에 현실화, 구체화되지 않은 개발이익이나 조합원의 비용부담을 전제로 한 개발이익은 배제해야 한다.
- ② 반면, 수용재결에 따른 보상평가는 해당 사업으로 인한 **개발이익은 반영하지 않는다**(토지보상법 제67조 제2항).

대법원 2009. 3. 26. 선고 2008다21549,21556,21563

사업시행자가 주택재건축사업에 참가하지 않은 자에 대하여 도정법 제39조에 의한 매도청구권을 행사하면, 그 매도청구권 행사의 의사표시가 도달함과 동시에 주택재건축사업에 참가하지 않은 자의 토지나 건축물에 관하여 시가에 의한 매매계약이 성립되는 것인바, 이때의 시가란 매도청구권이 행사된 당시의 토지나 건축물의 객관적 거래가격으로서, 노후되어 철거될 상태를 전제로 하거나 주택재건축사업이 시행되지 않은 현재의 현황을 전제로 한 거래가격이 아니라 그 토지나 건축물에 관하여 주택재건축사업이 시행된다는 것을 전제로 하여 토지나 건축물을 평가한 가격, 즉 재건축으로 인하여 발생할 것으로 예상되는 개발이익이 포함된 가격을 말한다.

6) 사실상 사도의 평가기준

- ① 매도청구권 행사에 따른 평가는 시가평가이며 판례는 ‘토지의 현황이 도로일지라도 재건축사업이 시행될 것을 전제로 할 경우의 **인근 대지 시가와 동일하게 평가하되**, 각 토지의 형태, 주요 간선도로와의 접근성, 획지조건 등 개별요인을 고려하여 감액 평가하는 방법으로 산정하는 것이 타당하다’고 판시하고 있다.
- ② 반면에, 수용재결에 따른 보상평가는 토지보상법 시행규칙 제26조 제1항 2호에 의거 **인근토지에 대한 평가액의 1/3 이내**로 평가하여야 한다.

대법원 2014. 12. 11. 선고 2014다41698

도시 및 주거환경정비법에 의한 주택재건축사업의 시행자가 같은 법 제39조 제2호에 따라 乙 등이 소유한 토지에 대하여 매도청구권을 행사하였는데, 토지 현황이 인근 주민의 통행에 제공된 도로 등인 사안에서, 토지의 현황이 도로일지라도 주택재건축사업이 추진되면 공동주택의 일부가 되는 이상 시가는 재건축사업이 시행될 것을 전제로 할 경우의 인근 대지 시가와 동일하게 평가하되, 각 토지의 형태, 주요 간선도로와의 접근성, 획지조건 등 개별요인을 고려하여 감액 평가하는 방법으로 산정하는 것이 타당한데도, 현황이 도로라는 사정만으로 인근 대지 가액의 1/3로 감액한 평가액을 기준으로 시가를 산정한 원심판결에 법리오해의 잘못이 있다고 한 사례.

CASE

X는 도시정비법에 따른 재개발정비사업조합이고, 甲은 X의 조합원으로서, 해당 정비사업구역 내에 있는 A토지와 B토지의 소유자이다.

X는 도시정비법 제72조 제1항에 따라 분양신청기간을 공고하였으나 甲은 그 기간내에 분양신청을 하지 않았다. 이에 따라 X는 甲을 분양대상자에서 제외하고 관리처분계획을 수립하여 인가를 받았고, 그에 불복하는 행정심판이나 행정소송은 없었다. X는 도시정비법 제73조 제1항에 따른 甲과의 보상협정이 이루어지지 않자 A토지와 B토지에 관하여 관할 토지수용위원회에 수용재결을 신청하였고, 관할 토지수용위원회는 A토지와 B토지를 수용한다는 내용의 수용재결을 하였다.

甲이 수용재결에 대한 취소소송을 제기하면서, 'X가 도시정비법 제72조 제1항에 따라 분양신청기간과 그 기간 내에 분양신청을 할 수 있다는 취지를 명백히 표시하여 통지하여야 하는데도 이러한 절차를 제대로 거치지 않았다'고 주장할 경우에, 甲의 주장이 사실이라면 법원은 그것을 이유로 수용재결을 취소할 수 있는지 설명하시오. (단, 사실심 변론 종결 전에 도시정비법에 따른 이전고시가 효력을 발생한 경우와 그렇지 않은 경우를 구분하여 설명할 것) [33회 문1]

01 분양신청기간의 통지 등 절차를 이행하지 않은 채 한 수용재결의 위법성 여부

판례는 분양신청기간의 통지 등 절차는 재개발구역 내의 토지 등의 소유자에게 분양신청의 기회를 보장해 주기 위한 것으로서 토지수용을 하기 위하여 반드시 거쳐야 할 필요적 절차이고, 또한 그 통지를 함에 있어서는 분양신청기간과 그 기간 내에 분양신청을 할 수 있다는 취지를 명백히 표시하여야 하므로, 이러한 통지 등의 절차를 제대로 거치지 않고 이루어진 수용재결은 위법하다고 판시했다.(대법원 2007. 3. 29. 선고 2004두6235 판결)

02 이전고시의 법적 성질

도시 및 주거환경정비법에 따른 이전고시는 준공인가의 고시로 사업시행이 완료된 이후에 관리처분계획에서 정한 바에 따라 종전의 토지 또는 건축물에 대하여 정비사업으로 조성된 대지 또는 건축물의 위치 및 범위 등을 정하여 **소유권을 분양받을 자에게 이전**하고 가격의 차액에 상당하는 금액을 청산하거나 대지 또는 건축물을 정하지 않고 금전적으로 청산하는 **공법상 처분**이다.(대법원 2016. 12. 29. 선고 2013다73551 판결)

03 이전고시의 효력발생 후 관리처분계획 등을 다룰 수 있는지 여부

1) 관련 판례

- ① 대지 또는 건축물의 소유권 이전에 관한 고시의 효력이 발생하면 조합원 등이 관리처분계획에 따라 분양받을 대지 또는 건축물에 관한 권리의 귀속이 확정되고 조합원 등은 이를 토대로 다시 새로운 법률관계를 형성하게 되는데, 이전고시의 효력 발생으로 **대다수 조합원 등에 대하여 권리귀속 관계가 획일적·일률적으로 처리되는 이상 그 후 일부 내용만을 분리하여 변경할 수 없고**, 그렇다고 하여 전체 이전고시를 모두 무효화시켜 처음부터 다시 관리처분계획을 수립하여 이전고시 절차를 거치도록 하는 것도 정비사업의 공익적·단체법적 성격에 배치되어 허용될 수 없다.

- ② 위와 같은 정비사업의 공익적·단체법적 성격과 이전고시에 따라 이미 형성된 법률관계를 유지하여 법적 안정성을 보호할 필요성이 현저한 점 등을 고려할 때, 이전고시의 효력이 발생한 이후에는 조합원 등이 해당 정비사업을 위하여 이루어진 수용재결이나 이의재결의 취소 또는 무효확인을 구할 법률상 이익이 없다고 해석함이 타당하다 (대법원 2017. 3. 16. 선고 2013두11536 판결).

2) 검토

(1) 이전고시 효력이 발생하기 전

이전고시 효력이 발생하기 전이라면 관리처분계획의 하자로 인하여 자신의 권리를 침해당한 조합원 등으로서는 그 관리처분계획이나 수용재결에 대해서 다툴 수 있다.

(2) 이전고시 효력이 발생한 후

- ① 이전고시 효력발생 후에 관리처분계획이 무효로 확인되어 새로운 관리처분계획이 의결된다면, 이전고시 효력 발생 후 형성된 새로운 법률관계에 터잡은 다수의 이해관계인들에게는 예측하지 못한 피해가 초래하게 된다.
- ② 따라서 이전고시의 효력이 발생한 후에는 관리처분계획, 해당 정비사업과 관련된 수용재결이나 이의재결에 대해 다툴 수 없다.